

الصفحة	السؤال
ص: ٥	س ١: عرف حق الملكية مبيناً عناصره وخصائصه؟
ص: ٨	س ٢: اكتب في نطاق حق الملكية وحمائته؟
ص: ١٠	س ٣: اكتب في القيود القانونية علي الملكية المقررة للمصلحة العامة؟
ص: ١١	س ٤: اكتب في نظرية مزار الجوار غير المألوفة؟
ص: ١٤	س ٥: اكتب في حق المرور المرور القانوني من حيث الشروط والاحكام؟
ص: ١٦	س ٦: تكلم عن قيود المطالبات؟
ص: ١٨	س ٧: وضع شروط صحة الشرط المانع من التصرف مبيناً اثاره؟
ص: ٢٢	س ٨: وضع كيفية الانتفاع بالمال الشائع؟
ص: ٢٤	س ٩: اكتب في التصرف في المال الشائع؟
ص: ٢٨	س ١٠: تكلم عن القسمة الرضائية موضحاً انواعها وشروط نقض القسمة للغبن؟
ص: ٣٧	س ١١: وضع الحالات التي واجهها المشرع للتحايل علي قواعد الميراث في شكل تصرفات صورية؟
ص: ٣٩	س ١٢: عرف الالتصاق مبيناً شروطه؟
ص: ٤١	س ١٣: اكتب في الالتصاق الصناعي موضحاً فروضه وحكم كل فرض؟

ص: ٤٢	س ١٤: عرف الشفعة مبيناً طبيعتها ثم اذكر حالاتها وكيفية فض التزامم عند تعدد الشفعاء؟
ص: ٤٩	س ١٥: لا شفعة الا في البيوع. وضح ذلك مبيناً البيوع التي لا يجوز فيها الشفعة؟
ص: ٥٨	س ١٦: وضح الاثار المترتبة علي الحكم بثبوت الشفعة؟
ص: ٦١	س ١٧: وضح الفرق بين الاستيلاء والحيازة موضحاً اهمية الحيازة في الحياة القانونية؟
ص: ٦٥	س ١٨: اكتب في الركن المعنوي للحيازة مبيناً عيوبها؟
ص: ٦٨	س ١٩: اكتب في انتقال الحيازة وزوالها وحمايتها؟
ص: ٧١	س ٢٠: وضح شروط التقادم الطويل؟
ص: ٧٣	س ٢١: وضح شروط التقادم القصير؟
ص: ٧٥	س ٢٢: وضح الاثار المترتبة علي التقادم المكسب؟
ص: ٧٨	س ٢٣: وضح شروط كسب ملكية المنقول بالحيازة الفورية؟
ص: ٨٠	س ٢٤: وضح حكم المنقولات المسروقة او الضائعة؟
ص: ٨١	س ٢٥: وضح شروط كسب الحائز ملكية الثمار؟
ص: ٨٢	س ٢٦: وضح حق الحائز في استرداد المصروفات ومسئوليته عن هلاك الشيء ؟

الحقوق العينية الأصلية

— الحق العيني —

أولاً : تعريف الحق العيني :

🕒 **تعريف الحق العيني** ← " سلطة مباشرة لشخص على شيء معين تخوله استعماله واستغلاله والتصرف فيه تحت حماية القانون " .

🕒 **ويمتاز الحق العيني** ← بأنه يمنح سلطات مباشرة لصاحب الحق على محل الحق أي علاقة قانونية قائمة مباشرة بين الشخص ومحل الحق فلا حاجة للشخص لإستئذان أحد أو لوساطة أحد لمباشرة سلطاته

🕒 كما ان محل الحق من الاشياء دائماً ، سواء أكانت جمادات أو كائنات حيه ، عقارات أو منقولات ، مثلية أو قيمة ، قابلة للاستهلاك أو غير قابلة للاستهلاك .

ثانياً : الحق العيني والحق الشخصي :

🕒 **تعريف الحق العيني** ← سلطة مباشرة لشخص على شيء معين اما الحق الشخصي فهو رابطة مديونية بين الدائن والمدين ، حيث للدائن حق فى ذمة مدينه ، يلتزم المدين بمقتضاه بأداء عمل أو الامتناع عن عمل أو بتسليم واعطاء شيء .

🕒 يبدو واضحاً الفرق بين الحق العيني والشخصي من حيث محل الحق ووسيله اقتضاء الحق ومباشرة فالحق العيني يرد على شيء معين ، ويمنح صاحبه سلطة مباشرة على محل الحق حيث يمكن ممارسه كل سلطاته على الشيء مباشرة اما الحق الشخصي فمحلّه علاقه مديونية بين الدائن والمدين .

🕒 ايضاً فإن الحقوق العينية هي محدده على سبيل الحصر وبنصوص قانونية اما الحق الشخصي فينشأ بإتفاق الدائن والمدين .

🕒 ايضاً فإن الحقوق العينية يمكن اكتسابها بالتقادم أي بمرور فترة زمنية معينة على وضع اليد على الشيء بنيه اكتساب الحق العيني عليه أو بدون حاجة لفترة زمنية (كالاستيلاء) اما الحقوق الشخصية فلا دور للحيازة أي التقادم فى اكتسابها .

🕒 كذلك فالحق العيني خاصة حق الملكية ، يمتاز بالديمومه أي الأبدية ، فلا تسقط ملكية شخص وتنتهى بعد فترة معينة (طالت أو قصرت) مالم يتصرف فى حقه أو يهمل فيه ويحوزه شخص آخر ، اما الحق الشخصي فلا يتصور ان يظل الشخص مديناً للأبد بل هو امر مؤقت بطبيعته .

ثالثاً : أنواع الحقوق العينية :

🕒 تنقسم الحقوق العينية الى **حقوق عينية أصلية** و **حقوق عينية تبعية**

🕒 **الحق الأول :-** تنشأ مقصورة فى ذاتها ولذاتها لما تحققه من الحصول على منافع الاشياء .

🕒 **الحق الثانى :-** الحقوق العينية التبعية فهي تتفق مع الاصلية فى انها ترد على (عين) معينة وتمنح صاحبها سلطة مباشرة له على الشيء ، وتخوله حق التقدم وحق التتبع للمال فى اي يد كانت والاحتجاج بالحق على الكافة مادام مستوفياً للشروط .

لكن الحقوق العينية التبعية لا تنشأ لذاتها بل تنشأ تبعاً لوجود حق آخر هو المديونية فهي تبعية وليست أصلية حيث تأتي لضمان الوفاء بهذا الحق وتتبعه وجوداً وعدمه .

❖ **الحق الاول** ← فقد نظمة المشرع فى سته صور او حقوق عينية اصلية وهى

(حق الملكية ، **حق الانتفاع ،** **حق الاستعمال ،** **حق السكنى ،** **حق الحكر ،** **حق الارتفاق**)

❖ تمنح كل من هذه الحقوق لصاحبها سلطات على الشيء ولكن حق الملكية هو الوحيد من بين تلك الحقوق الذى يمنح صاحبه كل السلطات على محله من الاستعمال والاستغلال والتصرف اما الحقوق الخمسة الاخرى فتمنح صاحبها واحد او اثنين من السلطات الثلاث السابقة لذلك يعد حق الملكية هو الاكبر والافضل سلطة ومجالاً ، والجامع المانع اما الحقوق الاخرى فأقل منه ومشتقة منه ، وتسمى اصطلاحاً "الحقوق المتفرعة عن الملكية" .

❖ **الحق الثانى** ← فقد نظم المشرع المصرى اربعة حقوق عينية تبعية

(**حق الرهن الرسمى ،** **حق الرهن الحيازى ،** **حق الاختصاص ،** **حق الامتياز**) .

رابعا : هل وردت الحقوق العينية على سبيل الحصر :

❖ **الرأى الراجح يميل** ← الى اعتبار الحقوق العينية وردت على سبيل الحصر فلا يجوز للارادة انشاء حقوق عينية اخرى حيث يتعلق الأمر بالنظام العام .

خامسا : الاشياء والاموال :

❖ **المقصود بالشيء** ← كل ما عدا الانسان من حيوانات وجمادات وعقارات ومنقولات .

❖ **المقصود بالاموال** ← الحق ذو القيمة المالية ايا كان نوعه او محله .

سادسا : نطاق الحق العينى (الملكية الفردية) :

❖ الحقوق العينية الاصلية سته حقوق على سبيل الحصر ، اما الحقوق العينية التبعية والتي تنشأ تبعاً لوجود حق مالى (دين) وضماناً للوفاء به ، وهى اربعة حقوق على سبيل الحصر .

❖ من ضمن الحقوق العينية الاصلية فإن دراستنا تنصب حول الملكية الفردية ، اى ملكية الاشخاص الخاصة .

❖ ملكية الدولة العامة منها او الخاصة فليس هنا مجال دراستها .

❖ قد ورد بعد التنظيم للأموال العامة خاصة من حظر تملكها بالتفادم أو الحجز عليها أو التصرف عليها والأموال العامة هي العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون .

سابعا : اسباب انساب الحقوق العينية الاصلية :

❖ **عرف القانون المدنى سبعة مصادر لاكتساب الحق العينى الاصلى** ← منها يكسب الحق ابتداء وبواقعه مادية

مقتترنة بنية تملك منقول لا مالك له وهو الاستيلاء ومنها ما يكسب الحق بسبب واقعة الوفاة وهو الميراث والوصية ، ومنها ما يكسب الحق بالاتفاق اى بعمل الارادة وهو العقد ، ومنها واقعة مادية للارادة فيها دور كالاتصاق والحياسة ، او وجود الشخص فى مركز قانونى يسمح له بالمطالبة بالاولوية والافضلية وهى الشفعة .

❖ **الشريعة الاسلامية فتقر بعض تلك الاسباب** (كالعقد - والميراث - الوصية - واحراز المباحات) (الاستيلاء) - والشفعة) ولا تعرف البعض الاخر كالاتصاق .

حق الملكية

القواعد العامة لحق الملكية

حق الملكية - الخصائص والنطاق

تعريف حق الملكية وخصائصه

س ١: عرف حق الملكية مبيناً عناصره وخصائصه؟

أولاً: تعريف حق الملكية وعناصره:

تعريف حق الملكية: "الحق الذي يمنح صاحبه، وفي حدود القانون سلطة استعمال واستغلال والتصرف في الشيء محل الحق".

وبالتالي فهناك أربعة عناصر رئيسية في التعريف.

١- فمالك: قد يكون شخص طبيعي (إنسان) وقد يكون شخص معنوي:

يضع المشرع المصري قيوداً على تملك الأجانب للعقارات في مصر، طبيعيين أو معنويين، كما أن ملكية الأشخاص المصريين أيضاً منظمة بضوابط لمنع تكتل الملكيات في يد أشخاص معدودين.

٢- محل حق الملكية (الأشياء والأموال):

القاعدة أن: كل الأشياء تصلح أن يرد عليها حق الملكية الفردية، عقارات كانت أو منقولات، والأشياء محل التملك دائماً ما تكون لها قيمة، أي تقوم بالنقود، أما ما كانت معدومة القيمة فلا يقبل عليها أحد. لكن بعض الأشياء لا تجرى عليها أحكام حق الملكية، أما لأنها مباحة للكافة أو مشتركة بينهم كمياه الأنهار والمحيطات والهواء والشمس، وأما لأن القانون حظر على الأفراد جميعهم أو بعضهم حيازتها أو تملكها كالمخدرات والأسلحة والذخائر، أو مملوكة للدولة ملكية خاصة كالمناجم والمحاجر.

٣- سلطان المالك:

يجمع المالك في يده كل السلطات القانونية المتصور ورودها على الأشياء في حق واحد فالمالك له، سلطة استعمال الشيء في الغرض المخصص له وسلطة استغلاله والحصول على غلاته وثماره، وسلطة التصرف فيه.

٤- حدود حق الملكية، حق الملكية بين الإطلاق والقيود:

استقرت الجماعات الإنسانية في مراحلها الأولى على فكرة الملكية الجماعية، وسرعان ما تطورت الأفكار التقليدية نحو طغيان الملكية الفردية على حساب الملكية الجماعية، خاصة بعد الثورة الصناعية وانتشار الآلات وزيادة الإنتاج.

جاء إعلان حقوق الإنسان الأول الصادر سنة ١٧٨٩ في أعقاب نجاح الثورة الفرنسية مؤكداً على أن (حق الملكية حق مقدس لا يجوز المساس به).

على أثر طغيان المذهب الرأسمالي اتحد العمال وأسسوا الفكر الاشتراكي تمهيداً للفكر الشيوعي، حيث باتت كل الملكية من وسائل الإنتاج أو مواد خام أو أراضٍ أو عقارات ملك الدولة.

بالرغم من انهيار الثورة الشيوعية وانحسار المد الاشتراكي عالمياً منذ نهاية الثمانينات من القرن الماضي وطغيان الفكر الرأسمالي على الفلسفة الاقتصادية للدول عموماً، إلا أن المشرعين مازالوا على ولائهم لوجوب تقييد حق الملكية في الإطار الاجتماعي فيحظر على الملاك بعض الأنشطة الزراعية كزراعة المخدرات والدخان، وتضع قيوداً على الأنشطة المضرة بالبيئة.

على الجملة فقد بات حق الملكية مقيدا للصالح العام للمجتمع ولبعض المصالح الخاصة الجديرة بالرعاية ، فيما صار يطلق عليه **الوظيفة الاجتماعية لحق الملكية** .

ثانيا : خصائص حق الملكية :

أ- حق الملكية حق جامع (سلطان المالك) :

أ- سلطة الاستعمال :

- تمنح سلطة استعمال الشيء لمالكه ، وتكون بإستعماله فيما اعد له بحسب طبيعته ، فإستعمال الارض يكون بزراعتها والمنزل بسكناه والسيارة بركوبها .
- يتمتع المالك نفسه بسلطه الاستعمال فإن تنازل عنها لشخص آخر انتقلنا الى سلطة استغلال الشيء .
- والاصل ان استعمال الشيء المملوك لا يؤدي لزواله او هلاكه ماديا او التصرف فيه فلا تختلط سلطة الاستعمال بالتصرف .
- الا ان هذا لا يمنع من وجود بعض الحالات للخلط بين الاستعمال والتصرف في عمل واحد ، فإستعمال المأكولات بصفة عامة يؤدي لهلاكها ، كما ان استعمال النقود يكون بالتصرف فيها اي بإنفاقها .
- الملاحظ ان استعمال الشخص بنفسه لممتلكاته قد يعطل مؤقتا استغلاله لها .
- لكن ممارسة المالك لأي من سلطتي الاستعمال او الاستغلال لا يعطل ممارسته كأصل عام لسلطة التصرف في المملوك بعوض كالبيع ، او بدون عوض كالهبة .
- سلطة الاستعمال ليست مطلقة للمالك ، بل تخضع لضوابط قانونية فقد يفرض عليه القانون عدم استعمال الارض الزراعية (مثلا) في بعض الأنشطة كالبناء عليها او تجريفها او تبويرها او زراعتها بالنباتات المخدرة .

ب- سلطة الاستغلال :

- استغلال الشيء المملوك يكون بتمكين الغير من الانتفاع به والحصول على ثماره منه ، **يفرق الفقه في هذا الصدد بين الثمار والمنتجات** .
- المقصود بالثمار** ← ما ينتج دوريا دون الانتقاص من اصل الحق ، وهي اما طبيعية او مستحدثة او مدنية .
- المقصود بالثمار الطبيعية** ← التي تنتج في مواعيد دورية ثابتة دون تدخل من الانسان ، كالعشب او الكأ في المراعى والحشائش المختلفة في الغابات الطبيعية .
- المقصود بالثمار المستحدثة** ← التي يتدخل الانسان في زراعتها وتعهدها بالرعاية حتى موسم الجنى والحصاد ، كزراعة المحاصيل الموسمية المختلفة أو اشجار الفاكهة .
- المقصود بالثمار المدنية** ← ما يغله الشيء من دخل ثابت نتيجة استغلاله كأجرة المنزل او المحل او الشقة .
- على خلاف الثمار فالمنتجات هي ما ينتج في مواعيد غير دورية مع الانتقاص من اصل الحق** كالمناجم والمحاجز وآبار النفط واشجار الغابات المعدة للقطع .
- يغلب على العلاقة بين مالك المنتجات والطرف الثاني احكام عقد البيع حيث يقوم المشتري بالتعاقد على الكمية المطلوبة مقابل ثمن نقدي ، اما الايجار فلا يرد الا على الاشياء غير القابلة للاستهلاك .
- والمالك له الحق في الحصول على ثمار الشيء ومنتجاته ، اما غير المالك فيكون له الحصول على ايهما بحسب سنده فالمنتفع يحصل على ثمار الشيء فقط .
- الاستغلال يمتد لجميع ما يشمله حق الملكية من عناصره الجوهرية وملحقاته بما فيها الثمار والمنتجات كما يشمل العلو والعمق فالمالك له ثمار الارض سواء كانت ثمار طبيعية او صناعية او مدنية ، وللمالك ان يستغل العلو فيؤجره مثلا لمن يبني فيه .

ج- سلطة التصرف :

السلطة الثالثة للمالك على ملكه هي اخراجه من ذمته نهائيا ، فى مقابل عوض فيكون البيع او المقايضة او بدون مقابل فتكون الوصية او الهبة ، فيحق اذا للمالك التصرف فيما يملك بأى من صور التصرف مادام كامل الاهلية غير محجور عليه لأى من موانع الاهلية .

التصرف فى الشيء يكون اما بتصرف قانونى واما بتصرف مادى :

✗ **التصرف القانونى** ← يعنى ابرام اى من التصرفات القانونية التى تؤدى لخروج ملكية الشيء نهائيا من ذمة المتصرف ، بعقد معاوضة كالبيع او بتصرف بإرادة منفردة حال كالوعد بجائزة او مضاف لما بعد الوفاة كالوصية .

✗ **التصرفات المادية** ← تتعلق بإهلاك الشيء بما يقتضيه طبيعته الشيء وحسن التصرف فيه ، كطهى الاطعمة وتناول الفاكهة وذبح بعض الحيوانات كالأضاحى .

✗ قد يختلط التصرف القانونى بالمادى وبلاستعمال كما فى النقود ، حيث يكون اتفاقها بمثابة التصرف فيها .
✗ **الاصل ان :-** يتمتع المالك بكامل السلطات على ما يملك من الاستعمال والاستغلال والتصرف ، ولكنه قد يلجأ لتجزئة السلطات على الشيء فيتنازل عن سلطتى الاستعمال والاستغلال لشخص آخر ، ويحتفظ هو بسلطته التصرف ، ويسمى المالك حينئذ بمالك الرقبة اما صاحب سلطتى الاستعمال والاستغلال فيسمى بصاحب حق الانتفاع .

٢- حق الملكية حق مانع :

✗ يعنى ذلك ان حق الملكية يخص المالك وحده حيث يتمتع على غيره مشاركة المالك فى اى من السلطات الثلاث على الشيء ، وينعكس ذلك ايجابيا على حدود الملكية على عناصر الشيء الجوهرية وملحقاته وثماره ، حيث الاصل ان كل ما على الارض من مباني غراس (نباتات) او منشآت تعد ملكا لصاحب الارض .
✗ يترتب على ذلك ان الشيء الواحد لا يمكن ان يكون مملوكا لشخصين فى وقت واحد ، ولكن لا يعنى ذلك بالضرورة ان تكون ملكية كل الاشياء مفرزة دائما ، بل يمكن ان يتعدد ملاك الشيء الواحد فيما يعرف بالملكية الشائعة ، او بواقعة مادية كالميراث .

✗ اذا كان المالك يستأثر وحده بمنافع ومزايا ملكه ، لا يشاركه فيه غيره ، فعلى الجميع التزام عام سلبى باحترام حق المالك والامتناع عن اى تعرض غير قانونى له ، الا ان ذلك لا يمنع من حق المالك فى اشراك الغير فى الانتفاع ببعض مزايا ملكه وسلطانه ، كتحويل الغير حق الانتفاع على ملكه او حق استعمال او حق سكنى .

٣- الملكية حق مؤبد :

✗ يعنى تأييد الملكية انه الحق العيني الوحيد الذى لا يسقط ابدا بعدم الاستعمال فكل الحقوق المتفرعة عنه تسقط بمجرد عدم استعمالها فترة معينة عادة ما تكون خمسة عشر سنة .

✗ فمجرد عدم استعمال حق الملكية ، لا يسقط حق المالك على ملكه ، فيحق له فى اى وقت يشاء ، ان ينتفع بملكه مره ثانية ، او يمكن الغير من استعماله .

✗ **هذا لا يمنع من اكتساب الملكية انتقالا من الغير بالحيازة** اى بالتقادم الطويل المكسب للملكية ، فلو فرض ان اهمل هذا المالك فى رعاية منزله القديم وتركه مهجورا فوضع شخص آخر يده عليه بنيه تملكه واستمر وضع اليد مدة خمس عشرة سنة ، فى هدوء وعلافيه ووضوح فيحق للحائز كسب الملكية بالتقادم المكسب **الهلاك القانونى** فيسرى على العقارات او المنقولات حيث تنزع الملكية للمنفعة العامة ، فتزول الملكية وتنتقل للدولة مقابل التعويضات المنصوص عليها .

وهناك ثلاثة نتائج لدوام حق الملكية :

- ✗ **الاولى** ← هى ان الملكية بطبيعتها غير مؤقتة .
- ✗ **الثانية** ← ان الملكية لا تزول بعدم الاستعمال .
- ✗ **الثالثة** ← محل الخلاف فتتعلق بمدى جواز ان تقترن الملكية بأجل فاسخ (الملكية المؤقتة) .

س ٢: اكتب فى نطاق حق الملكية وحمايته؟

— نطاق حق الملكية وحمايته —

يمتد نطاق حق الملكية الى كل ما يعد من عناصر الشئ الجوهريه فيشمل حق الملكية الفضاء الذى يعلو المكان والعمق اللازم للتمتع بمزايا الارض او المبنى كما يمتد النطاق لثمار الشئ وملحقاته وتوابعه

اولا : عناصر الشئ الجوهريه :

المقصود بعناصر الشئ الجوهريه ← التى تكون ماهيته ووجوده ولا يمكن الاستغناء عنها ، والا فينفى الشئ او يتلف او يتحول لشئ آخر ، فأساس المنزل والارض المقامة عليه والجدران والحوائط والاسقف وشبكة الكهرباء الداخلية والمياه والصرف والاسلام والمصعد فى المباني المرتفعة كلها من عناصره الجوهريه اما المزرعة فيعد من عناصرها الجوهريه التى لا يمكن الاستغناء عنها مصادر الرى والمياه والات الرى واشجار الزراعة وحظائر الماشية ومخازن السماد والحبوب وادوات الزراعة المختلفة .
فإن امكن الاستغناء عن العنصر فى الشئ دون تلف او هلاك او تغير فلا يعد عنصر جوهري .

ثانيا : ملكية الارض تشمل العلو والعمق :

اعتبر القانون ان الارض هى الاساس لما يقام عليها او تحتها ، ومالك الارض هو مالك ما فوقها وما تحتها كأصل عام .

١- ملكية العلو :

تمتد ملكية العلو فى الارض للطبقات الهوائية العليا ، الى الحد الذى يمكن ان يصل اليه الانتفاع المرخص للارض فإذا صرح للمالك ببناء برج شاهق او ناطحه سحب على ارضه فله الحق فى الارتفاع بمبناه الى الحد المسموح به والعلو بما يساوى مساحة ارضه .

ويحد حق العلو قيدين:-

القيد الاول ← خاص بعدم التعسف فى استعمال الحق ،
القيد الثانى ← خاص بالقوانين المنظمة لخطوط الهاتف والكهرباء والطيران ومراعاة المسافات القانونية للزراعة او البناء بين الجيران .

القيد الخاص بعدم التعسف فى استعمال الحق ← يقيد الجميع طبقا للمادة الخامسة من القانون المدنى ، فلا يجوز للمالك (مثلا) الارتفاع بسور حديقته بقصد الاضرار بالجار ومنع الهواء والضوء عنه او زرع اعمدة شاهقة الارتفاع على الحد الفاصل بين ملكه والمطار المجاور لاعاقبة حركة صعود وهبوط الطائرات واجبار ادارة الطيران على شراء ارضه بالسعر الذى يحدده .
ومن المشاكل التى بدأت تطفو على السطح فى الآونة الاخيرة ،

انشاء ابراج ومحطات تقوية التليفون المحمول فوق اسطح المنازل وعادة ما تدفع شركات المحمول مبالغ كبيرة لملاك المباني لوضع وتركيب المحطات ويعترض السكان فى المبنى والجيران الملاصقين لما يثار من شكوك حول تسبب هذه المحطات فى امراض سرطانية للأطفال والكبار والتسبب فى العقم .

نقطة : فهل يعد المالك متعسفا فى استعماله لحقه فى هذه الحالة ؟

يصعب القول بإنطباع احد معايير التعسف هنا ، حيث لا يوجد قصد الاضرار بالغير ، ولا تفاهة المصلحة وجسامة الضرر . علما بأن لم يثبت اى مخالفة قانونية لاشتراطات السلامة والبيئة .
لكن تبقى مسئولية الجهات التى منحت التراخيص والشركات المعنية ، ان ثبت وجود الاضرار ، وغالبا لن يثبت .

القيد الثانى خاص باحترام القوانين المنظمة لاقامة اعمده وابراج وخطوط الكهرباء متنوعه القدرة ومراعاة قواعد

الزراعة والبناء بين الجيران

حيث ان حق المالك هنا ليس مطلقا فالقانون يمنح وزارة الكهرباء والادارة المحلية الحق فى اقامة اعمدة وابراج الكهرباء ومد الشبكات لتوصيل التيار الكهربائى لأى مكان ، حتى ولو امتد فى ارض احد او فوق الملك الخاص لأحد الافراد ولا يجوز له الاعتراض او المنع بل كل ما يحق له المطالبة بالتعويضات .

بخصوص الزراعة ← فتنظم قوانين الزراعة واللوائح والتعليمات والمسافات الواجب تركها لزراعة نباتات واشجار بجانب مزرعة الجار حتى لا تمتد اغصان الاشجار فى المزارع المجاورة وتسبب تلف وبوار الزراعات الاخرى للملاك المجاورين .

كذلك فعند الارتفاع بالبناء للحد المرخص به يجب ترك المسافات القانونية بجانب الجار لفتح مطلات (شبابيك - شرفات) او للخروج ببرز في المبنى وهى لا تقل عن متر فى المطلات المواجهة ، وعن خمسين سنتيمتر فى المطلات المنحرفة .

٢- ملكية العمق :

تمتد ملكية الارض للعمق اللازم للتمتع والاستفادة من الارض بحسب الغرض المخصصة له ، فالارض الزراعية يمتد العمق فيها للحد اللازم لنمو النباتات والاشجار بل ويصل للاعماق اللازمة لاستخراج المياه الجوفية لغرض الزراعة او الشرب او للاستثمار (كمصنع لتعبئة المياه الطبيعية والمعدنية) كما يمتد ليشمل انايب المياه المدفونه للرى او للصرف الزراعى .

بالنسبة للابراج الشاهقة فالعمق يمتد للطبقات التحتية من الارض للحد اللازم لوضع الاساسات الحاملة للمبنى ، او لاقامة بدروم او مخبئ او خزان لمياه الشرب او الصرف .

يرد على حق العمق قيود قانونية خاصة بالمعادن والآثار والكنوز وانايب نقل الغاز الطبيعى والبتترول والصرف الزراعى :

المعادن والآثار الكامنة فى باطن الارض ليست ملكا لصاحب الارض بل ان القانون الخاص بالمناجم والمحاجر يخص بالملكية الدولة فقط ، وهى ملكية خاصة فى المعادن ، وعامة فى الآثار ، ويحق للدولة نزع ملكية الارض ان اكتشف فيها ثروات طبيعية او اثار مقابل تعويض لصاحب الارض ، اذ تعتبر المناجم والمحاجر من الثروات القومية الهامة ومصادر دخل سيادية للدولة وتخرج عن نطاق الملكية الفردية .

الكنز فله حكم خاص وهو لمالكه الذى خبأه ان استطاع الاثبات ، والا فلصاحب الارض التى وجد فيها الكنز ، او لمالك الرقبة ان توزعت الملكية بين مالك رقبة وصاحب منفعة .

يحق للجهات المختصة مد شبكات الصرف الزراعى وانايب نقل الغاز والبتترول فى اى منطقته ، دون حق الاعتراض عليها من ملاك الاراضى وينحصر حقهم فى طلب التعويضات ان ثبت وجود اضرار .

ثالثا : جواز فصل ملكية الارض عما فوقها او تحتها

الاصل ← فى القانون ان ملكية الارض تشمل ملكية ما فوقها وما تحتها ، فهى قرينة قانونية لصالح مالك الارض

ولكن هذه القرينة القانونية ليست قاطعة ، حيث اجازت المادة (٣/٨٠٣) مدنى ان تنفصل ملكية الارض عن ملكية العلو او العمق ، بمقتضى الاتفاق او القانون .

قد يتفق مالك الارض مع الغير على منح هذا الاخير الحق فى اقامة مبانى على ارض الاول او تحتها ، على ان يملكها البانى ، لفترة طالت ام قصرت وينظم الاتفاق مصير هذه المنشآت النهائى بعد انتهاء المدة المتفق عليها .

كما ان القانون قد يرخص لبعض الاشخاص بالبناء او القراس على ارض الغير كما ينظم مصير وايلولة هذه المنشآت ولكن ملكية العلو او العمق لا تقوم قرينة على ملكية السطح (الارض) .

رابعا : ملكية الشئ تشمل ملحقاته وثماره ومنتجاته :

تشمل ملكية الشئ ايضا ما يعد من ملحقاته وثماره ومنتجاته ، فهى حق للمالك وحده .

" يشمل التسليم ملحقات الشئ المبيع وكل ما اعد بصفه دائمة لاستعمال هذا الشئ " .

بشأن ثمار الشئ ومنتجاته فهى ملك لصاحبه ، " فالمالك الشئ الحق فى كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ، مالم يوجد نص او اتفاق يخالف ذلك " .

خامسا : حماية حق الملكية

" الملكية الخاصة مصونة لا تنزع الا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل وفقا للقانون " .

فلا يجوز ان يحرم احد من ملكه تعنتا وتعسفا من الافراد او الجهات التابعة للدولة او الدولة ذاتها ، وان استوجب الامر ذلك فيكون لغرض المصلحة العامة الاولى بالرعاية ، او فى الاحوال التى يقررها القانون لمصلحة اعلى من مصلحة المالك .

يحمى حق الملكية **دعوى الاستحقاق** ← الدعوى التى يرفعها المالك للمطالبة بملكه ممن غصبه او وضع يده عليه دون سند قانونى .

توجد دعويان اخريان من دعاوى الملكية هما **دعوى منع التعرض** فى الملكية و**دعوى وقف الاعمال الجديدة** فى الملكية

دعوى الاستحقاق هى دعوى استرداد يرفعها المالك على الغير الذى وضع يده على عقاره ، فإن لم يكن لديه سند ملكية فإنه يلجأ الى دعوى استرداد الحيازة متى توافرت شروطها .

القيود القانونية والاتفاقية على حق الملكية

— القيود القانونية على الملكية —

تنقسم القيود القانونية الى قيود مقررة للصالح العام وقيود اخرى مقيدة للمصالح الخاصة .

س ٣: اكتب فى القيود القانونية على الملكية المقررة للمصلحة العامة؟

" القيود القانونية المقررة للمصلحة العامة "

" القيود الواردة على حق التملك والحد الاقصى للملكية "

اولا : حظر تملك الاجانب العقارات فى مصر :

تبني المشرع المصرى سياسة واضحة مع نجاح ثورة يوليو سنة ١٩٥٢ نحو منع تملك الاجانب للعقارات بصفة عامة والملكية الزراعية بصفة خاصة فى مصر .

بالنسبة للعقارات المبنية جاء القانون رقم (٨١ لسنة ١٩٧٦) بحظر صريح فى تملك الاجانب .

ثانيا : النوسع فى الاستثناءات الخاصة بتملك الاجانب :

بدأ المشرع يتوسع فى الاستثناءات الخاصة بتملك العقارات فى مصر تشجيعا لجذب الاستثمارات العربية والاجنبية حيث سمح القانون رقم (٥٥ لسنة ١٩٨٨) للعرب والاجانب بتملك الاراضى الصحراوية لاستصلاحها واستزراعها ومشروعات تربية الاسماك وذلك بقرار من رئيس الجمهورية وبعد موافقة مجلس الوزراء .

كما سمح بتملك الاجانب لبعض الشركات والبنوك المباشرة فى اطار برنامج الخصخصة .

كما نظم القانون خاصة القانون رقم ٢٣٠ لسنة ١٩٩٦ بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والاراضى الفضاء ، ونص على انه يجوز لغير المصرى سواء أكان شخصا طبيعيا او اعتباريا ، تملك

العقارات مبنية كانت او ارض فضاء بالشروط الآتية :

- ١- ان يكون التملك لعقارين على الاكثر فى جميع انحاء الجمهورية بقصد السكنى الخاصة له ولاسرته .
- ٢- الا تزيد مساحة كل عقار على اربعة الاف متر مربع ، اما العقارات اللازمة لمزاولة النشاط الخاص فلم يقيده المشرع بحد اقصى .

٣- الا يكون العقار من العقارات المعتبرة اثرا فى تطبيق احكام قانون حماية الآثار .

ثالثا : الحد الاقصى لملكية الاراضى الزراعية فى مصر :

وضع القانون حدودا قصوى على تملك المصريين للاراضى الزراعية لمنع تركزها فى يد بعض الاشخاص فقط ، وبات الحد الاقصى لملكية الفرد فى الاراضى الزراعية ، هو خمسون فدانا للفرد ومائة فدان للأسرة .

اذا فأى تعاقد يتم بعد العمل بأحكام هذا القانون ويؤدى لزيادة ملكية الفرد او الأسرة على الحدود المنصوص عليها يعد باطلا مطلقا ولا اثر له بين اطرافه او بالنسبة للغير ، ولا يجوز تسجيله .

بالنسبة للاراضى الصحراوية فالقانون رقم (١٤٣ لسنة ١٩٨١) فى شأن تملك الاراضى الصحراوية يجعل الحد الاقصى للملكية بجانب الارض الزراعية هو ٢٠٠ فدانا للفرد وثلاثمائة فدان للأسرة .

بالنسبة للأشخاص المعنوية فهناك حدودا قصوى اخرى لملكياتهم ، فالجمعيات التعاونية (عشرة آلاف فدان - بحد اقصى ثلاثون فدان لكل عضو) وشركات الاشخاص والتوصية بالاسهم (عشرة الاف فدان - بحد اقصى مائة وخمسون فدان لكل عضو) ، وشركات المساهمة (خمسون الف فدان) .

لم تعد لهذه القيود قيمة قانونية بعدما اطلقت الدولة للأفراد (وطنيين واجانب) وللشركات الحرية فى تملك الاراضى الصحراوية دون قيود ، مالم تتعارض مع الاعتبارات العسكرية والامن القومى .

"جواز نزع الملكية والاستيلاء المؤقت للمنفعة العامة"

أولاً : جواز نزع الملكية للمنفعة العامة :

المبدأ المقرر دائماً انه حين تعارض المصلحة العامة مع المصالح الخاصة تقدم المصلحة العامة دائماً ، حيث الامر يخص مصلحة المجتمع ككل مع العمل على عدم اهدار المصلحة الخاصة ، وهذا هو الشأن في نزع الملكية للمنفعة العامة ، حيث اجاز القانون لرئيس الجمهورية اصدار قرار لنزع ملكية اى شخص للمنفعة العامة مقابل التعويضات .

ويعد من اعمال المنفعة العامة انشاء الطرق والشوارع والياديين او توسعتها او تعديلها او تمديدتها او انشاء احياء جديدة ، ومشروعات المياة والصرف الصحى والطاقة وانشاء الكبارى ، وينشر القرار المقرر للمنفعة العامة مع صورة من مذكرة بيان المشروع المطلوب تنفيذه فى الجريدة الرسمية .

ثانياً : الاستيلاء المؤقت :

اجاز القانون رقم (١٩٩٠) بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة للجهة طالبة نزع الملكية الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات التى تقرر لزومها للمنفعة العامة وذلك بقرار من رئيس الجمهورية او من يفوضه ينشر فى الجريدة الرسمية ويتم تقدير التعويض عن عدم الانتفاع .

لوزير المختص بناء على طلب الجهة المختصة فى حالة حصول غرق او قطع جسر او تفشى وباء وسائر الاحوال الطارئة او المستعجلة ان يأمر بالاستيلاء مؤقتاً على العقارات اللازمة لاجراء اعمال الترميم او الوقاية او غيرها ، ويجب على جهة الادارة اعادة العقار فى نهاية مدة الاستيلاء (ثلاث سنوات او انتهاء الغرض ايهما اقرب) بالحالة التى كان عليها وقت الاستيلاء مع تعويض كل تلف او نقص فى قيمته .

ملحوظة

يلاحظ ان الاستيلاء يكون مؤقتاً ، ولفترة محددة لدواعى الضرورة التى لا تحتمل التأخير كالكوارث العامة من الزلازل والبراكين والسيول والفيضانات وتفشى الاوبئة وغيرها ، وتعود العقارات بعدها لأصحابها مع التعويضات .

ثالثاً : نحدد القيود الاخرى المقررة للمصلحة العامة :

بجانب القيود السابقة توجد قيود قانونية اخرى مقررة على الملكيات العقارية تحقيقاً للمنفعة والصالح العام ، ومنها القيود المتعلقة بخطط التنظيم والتخطيط العمرانى ، والبناء والهدم والزام طالبي البناء بتوفير اماكن لإيواء السيارات .

"القيود القانونية المقررة للمصلحة الخاصة (الترامات الجوار)"

"اضرار الجوار غير المألوفة"

س ٤ : اكتب فى نظرية مضار الجوار غير المألوفة ؟

مفهوم الجوار فى نظرية اضرار الجوار غير المألوفة

أولاً : مفهوم الجوار من حيث الاشخاص :

صفة الجار تتوافر فى كل من توافر له عنصر الاستقرار ، بغض النظر عما اذا كان يستند فى ذلك الى حق عينى او حق شخصى (مستأجر مثلاً) او حتى حائز عرضى .

ويرى الفقه امكانية رجوع الجار المضروب على المتسبب فى الاضرار والمضايقات مباشرة بغض النظر عن كونه مالكا او مستأجراً .

وقد قضى بمسؤولية الحلوانى والخباز والقصاب عن الاصوات الفجرية والشديدة والمستمرة الناجمة عن ممارسة المهنة نفسها والتى ادت الى منع نيام الجيران .

لا يشترط تلاصق العقارات ، لمساءلة الجار المتسبب فى الضرر بل يكفى ان يكون الجار متأذى من الضرر فالدخان المتصاعد من مصنع قد يصيب حتى بأكمله بالاضرار .

ايضا فإن التجاور قد يمتد للدول ولو لم تتلاصق حدودها وهذا ما حدث بالنسبة لانفجار المفاعل النووى السوفيتى فى تشيرنوبيل ، وليس بخلاف ما سببه لاوروبا كلها تقريبا من كوارث ، وكل ذلك غالبا ما ينظم عن طريق معاهدات دولية ولا تترك للقوانين الداخلية .

ثانيا : مفهوم الجوار من حيث الاموال :

- ظلّت التشريعات المدنية لفترة ليست ببعيدة تنظر الى العقارات على انها رمز الثروة ومقياس الجاه والثناء وكانت تفرد لحمايتها الكثير من احكامها .
- وقد انتقد اغلب الفقه "بحق" صياغة النص فى هذه الجزئية وفضل مد نطاق النظرية للعقارات والمنقولات واورد مصطلح "الاشياء" بدلا من العقارات ، كما ان توسيع مفهوم الجوار لاضفاء الحماية على المضرور ايا كان سبب الضرر يحقق الغرض من النص .
- يمتد حكم هذه النظرية للاموال العامة فى رأى اغلب الفقه والقضاء وقد قضى بمسئولية الدولة عن الضجيج والصخب الذى يحدثه سير القطارات .
- كما حكم القضاء المصرى ، بمسئولية الحكومة عن اقامتها محطة مجارى فى حى مخصص للسكنى حتى ولو لم تخالف القوانين واللوائح لأنه بعد التقدم الحديث فى الآلات والمعدات فقد تضاعف الضجيج المنبعث منها على وجه غير الموقف .

مضمون الالتزام بعدم الاضرار بالجار

- الجار لا يسئل عما يحدثه لجاره من اضرار اذا كانت فى النطاق المألوف والمعتاد الذى لا يمكن تجنبه .

اولا : تقدير فكرة عدم عادية الضرر :

- المقصود بالضرر غير العادى** ← ذلك الضرر الذى لم تجر العادة على تحمله دون شكوى وهو يكون غير مألوف اذا كان يمنع الجار من تحصيل المنافع الرئيسية لملكه ، والغالب ان يكون هذا الضرر فاحشا .
- ويذهب الاتجاه الغالب فى الفقه والقضاء الى ان فكرة التسامح بين الجيران هى اساس عادية او عدم عادية الضرر ، فالجيرة عادة تسبب مضايقات واضرار لا يمكن تلافيها الا بالتضييق على الناس فى استعمال حقوقهم وحررياتهم مما يوقعهم فى الحرج ويشل ايديهم عن استعمالها ، لذلك جرى العرف بين الجيران على تحمل قدر من هذه المضايقات والاضرار بل والتسامح بشأنها بحيث يمكن وصف هذا القدر بالضرر المألوف ولا مسئولية عنها .

ثانيا : وسائل تقدير عدم عادية الضرر

- ١- العرف :**
اول معيار يجب الاعتماد به لتقدير عادية السلوك ام العكس ، والعرف هنا بمعنى ما اعتاد الناس على تحمله دون الشكوى وتعارفوا على ذلك ويستمد ذلك من ظروف المكان التى تلعب دورا كبيرا فى تحديد صفة الاضرار .
إقامة السرايدات للعزاء واستعمال الميكرفونات تشكل ضررا مألوفاً لأن العادة جرت بين الجيران على التسامح بشأنها نظرا لظروف الوفاة .

- ٢- طبيعة الاشياء :**
قد اورد المشرع هذا المعيار تحت تسمية "العقارات" .
إذا كان العقار محلا عاما او فندقا او مقها ، تحمل من الجلبة والضوضاء مالا يتحمل المكان الهادئ ايضا فإن ما يعتبر ضررا مألوفاً بالنسبة لمصنع تدور فيه الآلات ويحتشد فيه العمال ويشتد الصخب ، قد يعتبر ضررا غير مألوف بالنسبة الى مدرسة او مستشفى .

- ٣- موقع العقار بالنسبة للآخر :**
مكان وجود عقار الجار المتضرر من عقار الجار مصدر الضرر غير العادى ، فصاحب السفلى يجب بطبيعته موقعه من العلو ان يتحمل من العلو مالا يتحمله العلو من السفلى .
الجار الملاصق يجب عليه تحمل قدرا من المضايقات لا ينبغى على الجار البعيد تحملها كالضوضاء البسيطة او دبيب الاقدام فى العلو .

- ٤- الغرض الذى خصص له العقار :**
الغاية التى اعد العقار من اجلها ، ولكن يثار هنا تساؤل ، هل هذا الظرف يعد معيارا شخصيا او موضوعيا فالمستقر عليه ان كل الاعتبارات التى اوردها النص هى موضوعية .
العقار المخصص ليكون مصحة او مستشفى او مكان للاستشفاء او مكتب وما شاكل وشابه ذلك قد يكون الضرر المألوف بالنسبة لغيره ضررا غير مألوف بالنسبة له ، فإن كان منزلا للسكنى فيعتبر ضررا غير مألوف إقامة مصنع او ورشة بجانبه .

وهناك تسائل آخر هو هل يجب الاعتماد بالظروف الشخصية للجار ام ان الظروف كلها موضوعية ؟

- الاعتبارات الشخصية لشخص الجار** فأغلب الفقه لا يجبذ هذه الفكرة ويرى ان فى ذلك منافاة للعدالة ، لأن الامر سيختلف حسب ظروف كل جار وبالتالي فقد يعد الضرر مألوفاً عند غالبية السكان ولا يعد ذات الضرر مألوفاً عند احدهم لظروفه الخاصة كمرضه او حالته النفسية او كونه منشغلا بأعمال تقتضى الهدوء التام فينزعج لاية حركة ولو كانت مألوفة او غير ذلك .

❖ **معيار الضرر غير المألوف معيار مرن** ← وليس قاعدة جامدة فيتكيف مع الظروف المختلفة ويواجه الحاجات المتغيرة ، والعبرة بحالة الشخص المعتاد وهو شخص من أواسط الناس يزعجه ما يزعج الناس عادة ويتحمل ما جرى العرف بتحملة فيما بين الجيران.

ثالثاً : خصائص الضرر غير العادي :

١- جسامة الضرر :

❖ الجيرة تفرض بعض المضايقات التي لا مفر من التسامح بشأنها والا غلت ايدي الناس عن اموالهم مما يوقعهم في الحرج الشديد ، اما اذا تعدى الامر هذا القدر فإن القضاء قد عوض المضرور .
❖ وفي هذا الصدد قضى " بأنه لا يحق للجار مطالبة جاره بالتعويض عما يلحق زراعته من ضرر بسبب ظل اشجاره الا اذا اثبت ان صاحب الاشجار قد تعمد بغرسه الاضرار او اهمل في اتباع الاصول الزراعية .
❖ على العكس من ذلك فلا يلزم الجار بتحمل الاضرار اذا تجاوزت الحد المألوف بين الجيران ، فالروائح الكريهة والدخان الكثيف والاصوات المزعجة في سكون الليل او الاصوات المخترقة لحاجز الصوت من الطائرات او غير ذلك من الاضرار التي لا يطبق اواسط الناس تحملها يجب منعها او التعويض عنها .
❖ تقدير مدى الخطورة والجسامة من مسائل الواقع التي يختص قاضي الموضوع بتقديرها ولا تراقبه محكمة النقض الا في حدود سلطتها في مراقبة القاضي في تقديره للوقائع .

٢- ان يكون المضرور جارا :

❖ اي ان ينطبق عليه وصف الجار ولكن لا يشترط التلاصق فالمفهوم القانوني لشخص الجار هنا لا يرتبط بالمكان بقدر ارتباطه بالاضرار فما دام ان الضرر يصل اليه وتوافرت الشروط الاخرى فهو يعد جارا ، وتطبيقا لذلك قضى بمسئولية صاحب مصنع للفحم الحجري والذي يرسل الغبار والادخنة السوداء على مدينة (كان) بفرنسا واعتبر جميع السكان جيرانا للمصنع .

نظرية سبب الوجود

❖ تنطلق هذه الفكرة من وجود نشاط قديم في المكان ويأتى شخص جديد ويجاور صاحب النشاط ثم يتضرر الجار الطارئ مدعيا عدم عادية الاضرار ومطالباً بوقف النشاط او التعويض .

❖ **فهل هو محقا في دعواه أم يجب احترام الاوضاع الظاهرة المستقرة ؟**

اولا : فكرة الوجود المسبق الفردي :

❖ تمثل فكرة احترام الوضع الظاهر والقديم احد بنود دعامة استقرار المعاملات خاصة اذا كان هذا الوضع من شأنه ان يخلق اعتقاد عام باحترامه وبإلزاميته ، فإذا استقر الشخص في مكان وجعله مسكناً يأوي اليه او محلاً يكسب منه رزقه ومعيشتة او غير ذلك من الاغراض فإن العدل والمنطق يأبى حرمانه من حق التمتع العادي والهادئ لما بدأه من نشاط .
❖ من هذا المنطلق رأى بعض الفقه الفرنسي الاحتماء خلف هذه الفكرة السليمة والمقبولة للقول بضرورة الاعتداد بفكرة الاسبقية الفردية .
❖ لم يقف الامر على صعيد المبادئ النظرية ، بل تعدى ذلك الى التطبيق العملي .

❖ في الحقيقة فإننا لا نستطيع ان نجرد هذا الرأي من كل حجة منطقية فهو لا يعدمها ولكن الاسترسال في هذا الصدد يوقعنا في الحرج ، لأن ذلك يعطى الجار السابق حق فرض ارادته بدون ان يستطيع احد ان يطالبه بشئ .

ثانيا : فكرة سبق الوجود الجماعي :

❖ حاول الفقه الحديث صياغة هذه الفكرة صياغة جديدة ، وقالوا ان الاسبقية التي يعتد بها هي الاسبقية الجماعية لا الفردية ، فمادام الامر قد اتخذ طابع الجماعية فإنه يجب الاعتداد به ، وبناء على ذلك اذا اتخذ الطابع العام لمنطقة ما صيغة معينة ، سواء أكانت صناعية او تجارية او سكنية فإن ما يستجد من جيران على هذا التجمع ويتضرر من ذلك كبناء سكني في حي صناعي فلا يحق له المطالبة بالتعويض عن هذا الضرر لأنه الطارئ عليهم .
❖ هذه الفكرة بالصياغة الجديدة تنال تأييد اغلب الفقه والقضاء فإذا اتى شخص واقام منزلاً في قطعه ارض صناعية او تجارية ، فليس له ان يتضرر مما قد يصيبه من ضرر .

المسئولية عن الاضرار غير المألوفة

اولا : نطاق المسئولية :

❖ يذهب الرأي الغالب الى ان القاضي من حقه ازالة مصدر الضرر او الحكم بالتعويض النقدي ، فهو يقدر ذلك ويوازن بين المنافع والمضار ، ولا يختلف الامر في شئ عن القواعد العامة ، فمسئولية المالك تكون بإلزامه بتعويض ما اصاب الجار من الضرر ويجوز الحكم بإزالة الشئ الذي يخشى منه حصول ضرر في المستقبل عن الضرورة القصوى .

قد قضى بأنه " ليس للمالك الذى فى ملكه نخيل للغير وحصل له ضرر من وجود هذا النخيل فى ملكه بسبب تردد صاحبه عليه ودخوله فى ملكه لتفقدته مرارا ان يمنعه مهما بلغ الضرر ، بل كل ما له فى مثل هذه الحالة ان يطلب تعويضا اذا اساء مالك النخيل استعمال حقه ، كما انه ليس له ان يطلب ازالة بعض هذا النخيل لمجرد احتمال سقوطه او تمكن اللصوص بواسطته من الدخول لمنزله فإذا طلب ذلك كانت دعواه مرفوضة . الامر لا يثير خلافا اذا ما كان النشاط مخالف للقانون في إزالة المخالفة واجب .

ثانيا : ترخيص الادارة بالنشاط واثره فى المسؤولية وفى تحديد المحكمة المختصة :

لا يحول ترخيص الادارة بممارسة النشاط دون تقرير مسؤولية الجار المتسبب فى الاضرار غير العادية عن تعويض هذه الاضرار ، فالترخيص الادارى يتطلب فقط لنفى المسؤولية الجنائية اما المدنية فلا نص على الاعفاء منها .

هذا ما اضطرر عليه القضاء ، حيث قضى بمسؤولية شركة الطيران عن الاصوات والضجيج التى تحدثه آلاتها ومحركات طائراتها اثناء الهبوط والاقلاع متى كانت تجاوز من حيث شدتها واستمراريتها الاضرار العادية الواجب تحملها حتى ولو راعت القوانين واللوائح المعمول بها .

حول تحديد الجهة القضائية المختصة هنا بنظر الدعوى وهل هى جهة القضاء العادى ام القضاء الادارى .

الرأى الراجح

يرى عدم تأثير الترخيص الادارى على اختصاص القضاء العادى بهذه المنازعات .

كما لا يؤثر هذا الترخيص الادارى على سلطة المحكمة فإذا ثبت ان الاضرار غير المألوفة ناتجة عن نشاط مصرح به من جانب الادارة فيستطيع القاضى ان يأمر بوقف هذا النشاط اذا لم يجد وسيلة غير ذلك لمنع الضرر او لتخفيفه او يحكم بالتعويض التقضى فله مطلق الحرية فى ان يأمر بالتنفيذ العيى او بمقابل .

س هـ : اكتب فى حق المرور المرور القانونى من حيث الشروط والاحكام ؟

حق المرور القانونى

مالك الارض المحبوسة على الطريق العام ، او التى لا يصلها بهذا الطريق ممر كاف اذا كان لا يتيسر له الوصول الى ذلك الطريق الا بنفقة باهظة او مشقة كبيرة ، له الحق فى المرور فى الاراضى المجاورة بالقدر اللازم لاستغلال ارضه واستعمالها على الوجه المألوف .

على انه اذا كان الحبس عن الطريق العام ناشئا عن تجزئة عقار تمت بناء على تصرف قانونى ، وكان من المستطاع ايجاد ممر كاف فى اجزاء هذا العقد ، فلا تجوز المطالبة بحق المرور الا فى هذه الاجزاء .

اولا : شروط قيام حق المرور (الانحباس) :

قيام حق المرور رهن بوجود حالة انحباس عن الطريق العام ، ويعنى ذلك توافر احدى الحالتين : " الانحباس الكلى ، او الانحباس الجزئى " .

١ - الانحباس الكلى :

يعنى عدم وجود اى ممر اطلاقا يربط الارض بالطريق العام ، فالارض معزولة نهائيا ومحاطة من الجوانب الاربعة بأراضى اخرى او جبال او موانع ايا كانت طبيعتها لا تسمح لاحد بالوصول اليها الا بالمرور عبر اراضى الجيران .

٢ - حالة الانحباس الجزئى :

هنا يوجد ممر فعلا يربط الارض بالطريق العام ، ولكن هذا الممر غير كاف **ويعد الممر غير كاف** اذا كان لا يوفر للمالك الوصول للارض بشكل ميسر ، بل يكلفه نفقة باهظة او مشقة كبيرة ، كأن يكون بين منطقة جبلية وعرة مليئة بالحفر والمنخفضات والانهيارات الصخرية ، او يستلزم الالتفاف والسير مسافات طويلة على الاقدام ، وهو امر يستقل قاضى الموضوع بتقديره متى اقام قضاءه على اسباب سائغة .

لكن لا تتوافر حالة الانحباس الجزئى اذا كان الممر غير ممدد او ترابى او غير مريح للمالك ، اذا كان يكفى لاستغلال الارض .

قد يكون الممر فى احد اوجه الاستغلال ثم يصبح غير كاف وتتوافر حالة الانحباس الجزئى اذا تغير وجه استغلال الارض بشكل مشروع ، فالممر الضيق الذى لا يجاوز عرضه متر قد يشكل ممرا كافيا لممر الانسان بقدميه ودوابه لخدمه الارض الزراعية ، وهذا حال كثيرا من الاراضى الزراعية فى مصر ، فإن تغير وجه استغلال الارض (حيث حصل المالك على ترخيص بمشروع زراعى صناعى كمصنع لتعبئة الفاكهة والخضروات او مزرعة دواجن للتسمين او لانتاج البيض ، فهنا تظهر حالة الانحباس الجزئى ، بعد ان كانت غير متوافره .

إن كان للارض حق ارتفاق بالممر على ارض احد الجيران ← سواء نشأ هذا الحق بالتقادم او بالاتفاق مع الجار ، فلا تتوافر حالة الانحباس ، مادام الممر كافيا لحسن استغلال ارضه ، ولكن هل يعود الانحباس قائما اذا ما اهمل المالك فى استعمال حق ارتفاقه وتركه ليسقط بالتقادم لى يطالب بحق المرور القانونى يرى بعض الفقه عدم جواز مطالبة مالك هذه الارض بحق المرور القانونى بعدما اهمل فى حق ارتفاقه بالمرور حتى سقط بالتقادم او تنازل اختياريا عنه . ولكن يرى جانب آخر من الفقه ، ومعهم محكمة النقض الفرنسية قيام حق المالك للارض فى المطالبة بحق المرور القانونى نظرا لوجود حالة انحباس . إن كان مالك الارض يمارس فعلا نشاطه عليها ويقوم باستغلالها تسامحا من الجيران حيث يسمحون له وديا بالمرور بأراضيهم للوصول لارضه .

فهل توجد حالة انحباس تسمح له بالمطالبة بحق المرور القانونى ام لا ؟

المسألة خلافية فى الفقه ولكن **الرأى الراجح** يميل لعدم الاعتداد بالتسامح ، فقد يزول وينتهى فى اى لحظة ، فهو عرضه للتقلبات بحسب قوة العلاقة بين الجيران او ضعفها ، ويحق لمالك الارض المطالبة بحق المرور القانونى لى لا يتوقف استغلاله لارضه على محض مشيئة وتفضل الجار .

ثانيا : احكام حق المرور :

١ - تعيين موضع المرور وعرض الممر :

إذا تقرر حق المرور فلا يترك الامر لمحض ارادة صاحب الارض المحبوسة الذى قد يغلو فى استعمال حقه للاساءة للجيران بعد ان رفضوا مروره بأراضيهم من قبل بل يخضع ذلك لتقدير وسلطة المحكمة المختصة الذى تعين وحدها موضع المرور .

قد وضع القانون قيودا عاما على سلطة المحكمة حين تعيينها موضع الممر فى اى من العقارات المتجاورة ، على ان "ولا يستعمل هذا الحق الا فى العقار الذى يكون الممر فيه اخف ضررا وفى موضع منه يتحقق فيه ذلك" .

فيجب اختيار العقار الذى يتحمل بأخف الاضرار وهو عادة الاقرب للطريق العام ، ولكن ليس ذلك بشرط فقد يكون هذا العقار مبنيا ومن شأن تقرير حق المرور فيه اتلاف جزء كبير من المبنى ، ولكن الآخر والابعد قليلا عن الطريق العام ارضا زراعية والاضرار فيها اقل فيقع الاختيار عليها ، فإذا حدث ذلك وتم تعيين العقار المقرر المرور فيه فيجب اختيار موضع المرور الذى يحقق اخف الاضرار ايضا فى هذا العقار

بالنسبة لعرض الممر ← فذلك تقدره المحكمة المختصة بحسب نوع الاستغلال المعد لها الارض المحبوسة فعرض الممر يرتبط بكفايته للاستغلال من عدمه ويمكن طلب توسعته فيما بعد ان تغير وجه الاستغلال فطرات حالة الانحباس الجزئى كتغيير استغلال الارض الزراعية الى نشاط صناعى او تجارى يستلزم دخول وخروج مركبات نقل كبيرة او متوسطة ، فيمكن التعديل فى عرض الممر ضيقا واتساعا بحسب الغرض .

الاصل ان ← يكون الممر على سطح الارض ، ولكن لا يمنع هذا من امكانية ان تقرر المحكمة انشاء ممر او نفق فى باطن الارض اذا أمكن ذلك وتحقق الغرض او عمل كوبرى (جسر) فوق مجرى مائى خاص .

اثر التقادم فى تعيين موضع الممر :

إذا اختار صاحب الارض المحبوسة مكانا او موضعا معيننا فى ارض الجار وبدأ يمارس حقه فى المرور من هذا الموضع وتركه مالك الارض المجاورة ، بعد ان تقرر له مبدأ حق المرور ، وظل على هذا الوضع مدة خمس عشرة سنة فيكتسب الحائز حق المرور فى هذا الموضع المحدد فى حيازته الطويلة ، وبعد اكتمال مدة التقادم لا يجوز للجار ان يعترض على مكان المرور .

قيد خاص بتعيين موضع المرور في حالة الانحباس الناشئة عن تجزئة العقار :

إذا كانت حالة الانحباس ناشئة عن تجزئة وقسمة للعقار بناء على تصرف قانوني بين الملاك المشتاعين ، ونتج عن القسمة ان صارت بعض قطع العقار المقسوم في حالة انحباس كلى او جزئى عن الطريق العام ، فليس من العدل فى شئى ان يتحمل الجيران اخطاء او تعنت الملاك المتقاسمين مع بعضهم البعض بل اوجب القانون

ايجاد ممر كاف لاستغلال كل القطع المقسومة فى العقار المجزئ ذاته وليس العقار او العقارات المجاورة .

حيث نص القانون على انه " اذا كان الحبس عن الطريق العام ناشئا عن تجزئة عقار تمت بناء على تصرف قانوني ، وكان من المستطاع ايجاد ممر كاف من اجزاء هذا العقار ، فلا يجوز المطالبة بحق المرور الا فى هذه الاجزاء " .

ويشترط لينطبق هذا القيد شرطين رئيسيين :

١- الاول : ان تقع تجزئة للعقار بناء على تصرف قانوني :

التصرف القانوني يكون عقد قسمة بين ملاك على الشيوع او عقد بيع لعقار مجزءا على قطع متساوية مختلفة او هبة او وصية فالتجزئة تمت بناء على عمل ارادى .

٢- الثانى : انه يمكن ايجاد ممر كاف فى اجزاء هذا العقار :

حيث يستطيع القاضى ايجاد ممر كافى فى اجزاء هذا العقار ، فالامر معلق على الاستطاعة والقدرة على انفاذ هذا الممر ، فإن تعذر او استحال ذلك انتقل القاضى للعقار او العقارات المتجاورة .

٢- التعويض :

لا يتقرر حق المرور لمالك الارض المحبوسة على العقار او العقارات المجاورة بدون مقابل ، بل يجب تعويض مالك العقار المجاور عن الضرر او الاضرار التى ستلحق بعقاره ، وتقرر المحكمة المختصة والتى قضت بقيام حق المرور ، ومكانه وعرضه (مساحته) مقدار التعويض الواجب دفعه للآخرين .

كما يحدد القاضى طريقة دفع التعويض ، وهل دفعة واحدة ام على اقساط ، ومقدارها ومواعيدها او فى شكل مبلغ سنوى (دورى) طالما ظل حق المرور قائما .

س ٦: تكلم عن قيود المطلات ؟

قيود المطلات

اولا : تعريف المظل والمظور :

المظور ← " التى تعلو قاعدتها عن قمة الانسان المعتادة ، ولا يقصد بها الانفاذ الهواء والنور ، دون ان يستطاع الاطلاع منها على العقار المجاور " .

المطل بمفهوم المخالفة ← " هو ما تكون قاعدته فى مستوى قمة الانسان المعتادة ، ويقصد بها نفاذ الهواء والنور والاطلال على العقار المجاور " .

ثانيا : حكم المطلات :

قسم المشرع المطلات الى نوعين :

١- المطلات المواجهة :

فالمطل المواجه هو الذى يسمح بالاطلال مباشرة على ملك الجار ، دون التلفت يمينا او يسارا ، فمن ينظر منه يرى مباشرة ملك جاره وحرمة منزله واهله او املاكه ، وهو بذلك اكثر مضايقة للجار المواجه اذ هو جارح لملكه ، فهو يسمح لمالك المطل برؤيه ملك الجار تماما .

لذلك رأى المشرع ضرورة ترك مسافة لا تقل عن ١٠م ← لكى يسمح لأى جار بفتح أى مطل مواجهه لجاره يحق للجار طلب غلق المطل ولو لم يتوافر أى ضرر فى حقه ، ولا يحتاج لاقامة الدليل على الضرر لقبول دعواه بغلق المطل المخالف ، فالمشرع قد افترض وقوع الضرر هنا بقرينة لا تقبل اثبات العكس ؟

لكن ترك مسافة متر بين الملكين تسمح للجار المالك للبناء بأن يفتح المطل الذى يريده بالمساحة (العرض والارتفاع) الذى يرغب فيه ، بل وان يعد المطل فى الجدار الواحد فى الغرفة الواحدة فى الطوابق المتكررة ، فذلك حقه القانوني .

يرتفع قيد المسافة اذا كان المطل مواجهة لطريق او ترعة عامة ، فلا يكلف البانى بترك متر من ملكه لفتح مطل مواجه لطريق او ترعة عامة ، وان كان يلزم بمراعاة قواعد البناء والتخطيط العمراني للمدن او القرى .

التقادم المكسب للارتفاع بالمطل :

- ان قام البانى بفتح مطل مواجه على ملك الجار دون ترك مسافة متر ١٠٠ اسم وتوافرت فى شأنه شروط الحيازة او التقادم المكسب واستمر ذلك مدة خمس عشرة سنة ، فيستطيع البانى ان يتمسك باكتساب حق ارتفاع بالتقادم الطويل المكسب فى مواجهة الجار .
- وان اراد الجار البناء على ملكه فعليه ان يحترم الحق المكتسب بالتقادم ولا يسد مطل جاره وان يترك مسافة من ملكه هو لا تقل عن متر ، وذلك على طول الجدار المفتوح فيه المطل وليس فى مواجهة المطل المفتوح فقط .
- فإن اراد الجار فتح مطلات فى حائطه فهل يجب عليه ان يرتد مترا اخر فى ملكه بجانب ما تركه سابقا (متر ايضا) مراعاة للارتفاع المكتسب بالمطل ام يكتفى بما تركه سابقا ويفتح هو الآخر فيه مطلات ؟
- المسألة ليست محل اتفاق الفقه ، فبينما يرى البعض ضرورة تركه .
- يرى البعض الاخر بحق امكانيه فتحه مطلات هو الاخر فى المتر المتروك فهو ملكه لم ينزع منه ، فالجار اكتسب حق ارتفاع بالمطل وليس ملكية هذه المساحة ، فما تزال فى ملك البانى ، وفتحه مطلات فى ملكه لا يعطل حق الجار فى الارتفاع بالمطل .

٢- المطل المنحرف :

- يكون المطل منحرفا اذا كان صاحبه لا يستطيع الاطلاع مباشرة على ملك الجار ، بل يلزمه لرؤيه ملك جاره ان يتلفت يمينا او يسارا وبذلك فالمطل المنحرف اقل مضايقة للجار ،
- لذا رأى المشرع الاكتفاء بترك مسافة خمسين سنتيمترا على الأقل لفتح هذا المطل ، وذلك ايا كان نوع المطل المنحرف (شباك - بلكونه - خارجه - مشريه) .
- فاذا كان المطل المنحرف يعد فى ذات الوقت مطل مواجه لطريق عام فيحق للبانى ان يفتحه دون ترك اى مسافة بجانب الجار .

ثالثا : حكم المناور :

- المشرع عني بتعريف المناور وانه الفتحة فى الجدار التى تعلو قاعدتها عن قامة الانسان المعتاده ، ولا يقصد بها الا مرور الهواء ونفاذ النور دون ان يستطيع الاطلاع منها على العقار المجاور .
- فالغرض من المنور فقط هو مرور الهواء ونفاذ النور وهما ملك للناس كافة على السواء .
- فإن قام الجار البانى بفتح منور على ملك جارة دون ترك اى مسافة ملك له بجوار حائطه فقد استعمل رخصه قانونية لا تعد فيها على ملك الجار ولا يتوافر بشأنه احكام الحيازة ، اى التقادم المكسب ، وبالتالي يحق للجار الآخر ان يبني على نهاية ملكه فى اى وقت ويسد هذا المنور ، دون حق اعتراض من صاحب المنور .

ضوابط البناء فى قانون البناء الموحد :

- اضاف قانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ضوابط اخرى للبناء والبروزات والخارج بالمبنى ، حيث تنقيد الخوارج والبوارز بالمبنى بعرض الشارع المطل عليه المبنى ، فلا تتجاوز ١٠% من عرضه ، وكذلك لا يتجاوز ارتفاع المبنى مره ونصف من عرض الشارع ، ويجب ترك مسافة فى البلكونات او الخوارج لا تقل عن متر من ناحية مبنى الجار من كل النواحي دون بروز .

— القيود الاتفاقية على حق الملكية (الشرط المانع فى التصرف) —

- قد تظهر امام الارادة القانونية من المبررات الجدية ما يدفعها لتقييد تصرفها فيما تملكه ، فيتفق الافراد ذوى الاهلية القانونية على نقل ملكية مال مضمين عقد البيع شرطا يقضى بعدم قدرة المشتري على التصرف فى المال الذى اشتراه ، لفترة طالت ام قصرت ويقبل المشتري بهذا الشرط الذى يغفل يده عن التصرف فى ملكه للاعتبارات الجدية المشروعة التى يهدف اليها المشتري .
- لكن تقييد سلطة الافراد فى التصرف فى ملكياتهم يتعارض حتما مع خصائص حق الملكية .
- لذلك لم يكن الشرط المانع من التصرف محل ترحيب الفقه والقضاء فى بدايه الامر ، وابطله القضاء الفرنسى .
- ومع تطور الفكر القانونى وزيادة الحاجة لهذه الاتفاقات او الشروط لما تحققه من اغراض مشروعة بدأ القضاء يقر بصحتها .
- قد جاء القانون المدنى المصرى مستجيبا لهذه البواعث المشروعة ومقررا صحة الشرط المانع من التصرف .

س٧: وضع شروط صحة الشرط المانع من التصرف مبيئاً اثاره؟

اولا : شروط صحة الشرط المانع من التصرف :

- ١- اذا تضمن العقد أو الوصية شرطا يقضى بمنع التصرف فى مال فلا يصح هذا الشرط مالم يكن مبنيا على باعث مشروع ، ومقصورا على مدة معقولة .
- ٢- ويكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو للمتصرف اليه أو للغير .
- ٣- والمدة المعقولة يجوز ان تستغرق مدى حياه المتصرف أو المتصرف اليه أو للغير .

مجال الشرط المانع من التصرف :

فمجال الشرط مقيدة بنوعين من التصرفات (العقد والوصية) :

- 🔹 **العقد** ← تلاقى ارادتين على احدث آثار قانونية ولم يقيده القانون هنا بنوع معين من العقود ، ولكن الواقع عملا هو وجود الشرط المانع من التصرف فى العقود التبرعية كعقد الهبة مع اشتراط عدم تصرف الموهوب له فى محل الهبة ، أو فى عقد البيع اذا كان الثمن مؤجلا .
- 🔹 كما اجاز القانون ان يرد الشرط المانع فى
- 🔹 **الوصية** ← تصرف بإرادة منفردة مضافا لما بعد الوفاة ، وهى لا تنفذ فى حق الموصى له الا اذا قبلها بكل شروطها .

- 🔹 ولكن لا يصح ان يقيد المالك نفسه وإرادته المنفردة من التصرف فى امواله فذلك يؤدي حتما للاضرار بالدائنين واخراج امواله من الضمان العام بمحض ارادته فمن آثار وجود هذا الشرط عدم جواز الحجز على المال الممنوع من التصرف فيه ولا التنفيذ عليه .
- 🔹 ودائما ما يكون المال الممنوع من التصرف فيه عقارا ، فهذا الشرط لم يحقق فائدة عملية اذا ورد على مال منقول .

الشرط الاول : الباعث مشروع :

- 🔹 **الباعث المشروع** ← تحقيقه لمصالح معتد بها قانونا ، وهذه المصالح قد تكون مصلحة للمشتري ، أو للمشتري عليه .
- 🔹 البيع بشرط دفع الثمن فى شكل مرتب دورى ، أو على اقساط طويلة الاجل يحقق فيه الشرط المانع
- 🔹 **مصلحة للبائع** المشتري حتى يضمن وفاء المشتري بما تعهد به وتأكيد لما له من حق الامتياز وتجنباً لاجراءات التتبع فى مواجهة الغير .
- 🔹 قد يحقق الشرط **مصلحة (مادية وأدبية) للمشتري عليه** ، كهبة المنزل أو شقة للبنت للزواج فيها ، على الا يجوز لها التصرف فيها طوال حياتها خشية والدها تعرضها للطلاق أو المشاكل فى زواجها فيبقى لها منزل أو مكان تستتر به .

- 🔹 كما قد تكون **المصلحة خاصة بالغير** ، كالبيع بشرط دفع الثمن (أو الهبة أو الوصية) فى شكل مرتب دورى لإبن أو حفيد البائع حتى ينهى تعليمه أو يلتحق بعمل .
- 🔹 ان كان الباعث على الشرط غير مشروع فيبطل الشرط ولا يعتد به ويظل العقد صحيحا خاليا من المنع فى التصرف .

الشرط الثانى : ان تكون مدة المنع من التصرف معقولة :

- 🔹 حيث ان المنع المؤبد للمالك من التصرف فى ملكه غير مقبول .

ولكن متى تكون المدة معقولة أو ما هو معيار معقولية المدة ؟

- 🔹 لم يضع المشرع معيارا محددا لذلك ، بل تركها لتقدير المحكمة المختصة فى كل حالة على حده بحسب المصلحة المبتغاه ، وبوجه عام فقد تكون المدة عشر سنوات أو اكثر أو اقل ، وفى عقد البيع مع دفع الثمن فى شكل مرتب دورى محدد حتى يتم السداد كاملا ، أو فى حالة الرهن ، فتكون المدة معقولة اذا تطابقت مع عدد الاقساط والمبلغ الاجمالى

ثانيا : آثار الشرط المانع من التصرف

١- بطلان التصرفات الممنوعة :

أهم الآثار المترتبة على الشرط المانع من التصرف هو **بطلان كل تصرف مخالف للشرط المانع** من التصرف وهذا يعني بطلان التصرف الممنوع الشخص من اتيانه ، خاصة التصرفات الناقلة للملكية كالبيع والهبة والمقايضة والتقديم كحصة عينية في شركة ، او غير الناقلة للملكية كتقرير حق الانتفاع او حق ارتفاق . لا يقتصر البطلان على التصرفات المنصوص عليها او التي تفوت المصلحة مباشرة ، بل والتي تؤدي الى ذلك بشكل غير مباشر ، فإذا كان التصرف الممنوع فيه المشتري عليه هو البيع مثلا ، فيمتد اثر المنع للرهن الرسمي والحيازي للمال الممنوع فيه التصرف .

٢- طبيعة البطلان للتصرف الممنوع :

إذا كان التصرف في المال على خلاف الشرط المانع من التصرف يقع التصرف المبرم في منطقة البطلان ، فإن التساؤل يثار حول طبيعة البطلان هذا ، **وهل هو البطلان المطلق ام البطلان النسبي ؟** اجابت المذكرة الايضاحية على ذلك بأنه " اذا خولف الشرط المانع من التصرف كان **التصرف باطلا بطلانا مطلقا لعدم قابلية المال للتصرف** " .

لكن تطبيق احكام البطلان المطلق لا تتفق مع الاحكام المقررة على مخالفة الشرط المانع ، فطلب البطلان يقتصر على من تقرر الشرط لمصلحته ، ولا تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ، فيحق له ان يتمسك بإبطال التصرف كما يحق له اجازة التصرف لتعلق ذلك بمصالح خاصة ، ولا يتعلق الامر بحماية النظام العام .

الرأي الراجح

الرأي الراجح فقها وقضاء ، بحق ، يقوم على اعتبار البطلان المترتب على مخالفة الشرط المانع هو بطلان من نوع خاص ، يتفق مع الغاية القانونية من تقرير هذا النظام ، وهي حماية مصلحة خاصة جديرة بالرعاية ، وقد قضى بأن البطلان ، لمخالفة شرط المنع من التصرف ليس بطلانا مطلقا بل هو **بطلان يتفق مع الغاية من تقرير المنع** وهي حماية مصلحة خاصة مشروعة لاحد الاشخاص . ومن ثم يتحتم ضرورة قصر المطالبة بهذه الحماية أو التنازل عنها علي صاحب المصلحة وحده ويمتنع على المحكمة الحكم به من تلقاء نفسها .

٣- عدم جواز الحجز على اموال الممنوع فيه من التصرف :

ايضا لا يجوز الحجز على المال الممنوع من التصرف فيه ، فالحجز تمهيدا لتوقيع البيع الجبري بالمزاد العلني يفوت المصلحة ايضا من وراء المنع .

٤- الاحتجاج بالشرط المانع على الغير :

يشترط للاحتجاج بالشرط المانع من التصرف على الغير ، اذا كان الممنوع من التصرف فيه من العقارات ، **ان يسجل الشرط المانع** طبقا لاجراءات الشهر العقاري . بالنسبة للمنقولات فيفقد هذا الشرط فاعليته اذا انتقلت حيازة المنقول للغير حسن النية ، حيث يستطيع الغير التمسك بقاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز وتخلص له ملكية وحيازة المال خاليا من اثر الشرط المانع .

- ❶ كما يمتنع على المشتري عليه القيام بالاعمال المادية التي تعدم المال وتفتوت المصلحة كهدم المنزل تمهيدا لبيع الارض المقام عليها .
- ❷ لكن يجوز للمشتري عليه ابرام التصرفات القانونية غير الناقلة للملكية ولا المفوتة للمصلحة المشروعة كأعمال الادارة (الايجار) وايضا يجوز له القيام بالاعمال المادية التي تؤدي للحفاظ على المال وتنميته كترميم المنزل واصلاحه بل والبناء فوقه ان كانت اساساته تسمح بذلك وزراعه الارض وتنميتها .



أولاً: اجب عن الاسئلة الآتية

س ١ : اكتب في نطاق حق الملكية ؟

س ٢ : وضع الحكم القانوني للمطلات والمناور ؟

س ٣ : تكلم بالتفصيل عن حق المرور القانوني؟

س ٤ : عرف حق الملكية مبيناً عناصره وخصائصه ؟

س ٥ : وضع الفرق بين الحق العيني والحق الشخصي ؟

س ٦ : ما هي القيود التي تحدد حق العلو وحق العمق ؟

س ٧ : ما هي حدود المسؤولية عن الأضرار غير المألوفة للجار ؟

س ٨ : ما هي القيود القانونية علي الملكية المقررة للمصلحة العامة ؟

س ٩ : اكتب بالتفصيل في الشرط المانع من التصرف وما هو نوع البطلان المرتبت علي مخالفة هذا الشرط ؟

2026

ثانياً: بين مدي صحة او خطأ العبارات الآتية:

العلامة	السؤال	م
	الملكية حق اجتماعي قبل ان تكون حق فردي	-١
	المنتجات هي ما ينتج في مواعيد غير دورية مع الانتقاص من اصل الحق	-٢
	حق الملكية حق مؤبد ويمنع بالتالي اكتساب الملكية من الغير بالتقادم	-٣
	ملكية العلو والعمق قرينة علي ملكية الارض	-٤
	القيود القانونية محددة علي سبيل الحصر بخلاف الارتفاقات	-٥
	القيود القانونية والارتفاقات مصدرها النص القانوني	-٦
	يجوز نزع الملكية للمنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية او من يفوضه	-٧
	فكرة التسامح بين الجيران هي اساس عادية او عدم عادية الضرر	-٨
	معيار الضرر غير المألوف معيار موضوعي والعبرة بحالة الشخص المعتاد	-٩
	يشترط في الضرر غير العادي ان يكون جسما وان يقع علي جار وان يكون هناك تلاصق	-١٠
	ترخيص الادارة ممارسة نشاط معين يحول دون مسئولية المالك عما ينتج عن الاستغلال من ضرر غير مألوف	-١١
	وضع القانون قيودا عاما علي سلطة المحكمة حين تعيينها موضع المرور القانوني	-١٢
	اذا كان حالة الانحباس عن الطريق العام ناشئة عن تجزئة عقار بناء علي تصرف قانوني فيجوز المطالبة بحق المرور في العقار المجزء او العقارات المجاورة	-١٣
	مجال الشرط المانع من التصرف مقيد بنوعين من التصرفات هم العقد والوصية	-١٤

الملكية الشائعة

🔴 **الملكية الشائعة** ← تعني اشتراك أكثر من شخص في ملكية مال (عقار او منقول) بنسبة او حصة حسابية شائعة .

🔴 **الملكية الشائعة غير الملكية الجماعية وغير توزيع سلطات المالك على أكثر من شخص .**

🔴 **الملكية الجماعية** ← تعني ملكية مجموعة من الاشخاص (في شكل قبيله - عشيرة - اسره) لمال ملكية جماعية لهم على السواء ، اما رئيس الجماعة فله تنظيم الانتفاع بالمال باعتباره ممثلا للجماعة .

🔴 **توزيع سلطات الملكية بين أكثر من شخص** ← كأن يحتفظ المالك بملكه الرقبة ويمنح شخص آخر سلطة الاستعمال والاستغلال ، اما الشيوع فيكون كل شريك مالكا لكل السلطات على كل ذرة من اجزاء الشيء الشائع وذلك بقدر حصته في المال فله سلطة الاستعمال والاستغلال والتصرف في كل جزء من الاجزاء ، وللآخرين مثله تماما في حدود حصصهم وانصبتهم .

🔴 ينشأ الشيوع **بالاتفاق** كأن يشترك أكثر من شخص في شراء عقار بنسب حسابيه على الشيوع بينهم ، كما قد ينشأ عن **واقعة الحيازة او الاستيلاء او الالتصاق** ولكن اغلب حالات الشيوع تنشأ من **واقعة الوفاة**

— الاحكام العامة في الشيوع —

س ٨: وضع كيفية الانتفاع بالمال الشائع؟

" الانتفاع باطل الشائع "

🔴 **يعنى ادارة المال الشائع** ← مباشرة سلطتي الاستعمال والاستغلال على المال اى استعماله فيما اعد له او استغلاله بالحصول على ثماره وغلاته ، وهذا الانتفاع قد لا يثير مشكلة اذا ما اتفق جميع الشركاء عليه ، او وكلوا احدهم لادارته .

🔴 إن لم يتفقوا على اى من هذه الحلول لم يبق الا معرفة مدى سلطة الاغلبية في مباشرة اعمال الادارة العادية وغير العادية .

نساوى حصص الشركاء مالم يقر دليل على غير ذلك :

🔴 " اذا ملك اثنين او اكثر شيئا غير مفرزة حصة كل منهم فيه ، فهم شركاء على الشيوع ، وتحسب الحصص متساوية اذا لم يقر دليل على غير ذلك " .

🔴 إذا ادعى احدهم ان حصته تزيد عن حصة الآخرين فعليه اقامة الدليل على ما يدعيه ، فإن نجح فى مسعاه تحسب الحصص طبقا لما بينت .

اولا : ادارة المال بالاجماع :

١- الانتفاع بالمال باجماع الشركاء :

🔴 اذا ما اجمع الشركاء على الانتفاع بالمال ، بأى من اوجه الانتفاع ، فقرارهم صحيح وسارى عليهم فبالاجماع يستطيع الشركاء تقرير القيام بأعمال الادارة العادية (كزراعة الارض بإحدى لمزروعات الموسمية) كتبوير الارض لتحويلها الى ارض فضاء او البناء عليها .

🔴 كما ان لهم القيام برهن المال الشائع رهنا حيازيا او رهنا رسميا ، واذا كان من بين الشركاء قاصرا او عديم الاهلية تولى النائب القانونى عنه ادارة المال مع الشركاء الآخرين مراعاة لمصلحة من يمثله .

٢- تولى احد الشركاء ادارة المال الشائع :

🔴 اذا تولى احد الشركاء ادارة المال الشائع ، دون اعتراض من الشركاء الآخرين فيعد الشريك اصيلا عن نفسه فى حدود حصته من المال ، ووكيلا عن الباقيين فيما يخصهم من باقى المال .

🔴 ويحدث هذا الفرض كثيرا اذا غالبا ما يكون احد الشركاء اقدر على ادارة المال

🔴 **مثال ذلك** ← مزرعة ورثها اربعة اخوة اقدمهم يقيم بالقرية ويمتهن الزراعة والآخرين ليسوا بذات الظروف فيتولى هذا الشريك ادارة المال دون اعتراض من الآخرين فيعد اصيلا عن نفسه ووكيلا عنهم .

٣- تعيين مدير للمال الشائع :

يجوز للشركاء جميعا ان يعينوا مديرا يتولى ادارة المال نائبا عنهم جميعا سواء كان من بينهم او من الغير ، فإن تعذر الاتفاق اى (الاجماع) على تعيين مدير المال ، فيمكن لإغلبيه الشركاء (الاجلبيه المطلقة، اى النصف + واحد) ان تعيين مديرا للمال وقرارها ملزم للاقلية فى هذا الشأن .

ثانيا : ادارة المال بالاغلبيه :

وقد فرق المشرع فى تعامله مع الاجلبيه بحسب موضوع القرار وهل يتعلق بأعمال الادارة العادية ام غير العادية .

١- اساس الاجلبيه هو الانصبه وليس الرؤوس :

اعتد القانون بالاغلبيه المحسوبة على اساس قيمة الانصبه وليس عدد الرؤوس
مثال ذلك ← إذا اشترك خمسة اشخاص فى مال شائع وكان لأحدهم ثلثي المال ، وللاربعة الاخرين الثلث ، فالاول يملك الاجلبيه ويستطيع اتخاذ (وحده) قرارات تخص المال الشائع .

٢- سلطة الاجلبيه المطلقة فى ادارة المال الشائع :

الاجلبيه المطلقة تعنى النصف + واحد اى اكثر من النصف ولو بقليل محسوبة على عدد الانصبه .
 ولهذه الاجلبيه او من يحوزها ان يباشر اعمال الادارة العادية للمال كزراعته واستعماله فى الغرض المخصص له او تأجيريه .

فوق ذلك من حق الاجلبيه ان تضع نظاما معينيا لادارة المال والانتفاع به ، وللاجلبيه ايضا ان تختار مديرا .

٣- سلطة الاجلبيه غير العادية (4/3) الحصص :

إذا ما تعلق الامر بقرارات اشد خطورة تتعلق بالانتفاع بالمال الشائع .

مثال ذلك ← لو تعلق الامر بهدم العقار القديم لاعادة بناؤه بشكل اوسع واكبر ، او تحويل الارض الفضاء لمبانى او البناء عليها ، او تعليه البناء ، فإن الاجلبيه المطلوبة تتجاوز الاجلبيه المطلقة حيث الامر يغير من شكل ومصير المال ، لذا قرر القانون ضرورة توافر اغلبيه من يحوزون ثلاثة ارباع الحصص فى المال الشائع لاتخاذ قرارات من هذا القبيل .

على انه لا يعنى الغاء سلطة الاقلية فما يزال هناك ربع الحصص ، لذا يجب اعلانهم اولا بقرار الاجلبيه **وللاقلية الحق فى الاعتراض** على هذا القرار ولها فى سبيل ذلك اللجوء للمحكمة المختصة خلال شهرين من وقت اعلانهم بقرار الاجلبيه فإن فاتت المدة صار قرار الاجلبيه غير العادية نهائيا وملزم للجميع ، وللمحكمة ان رأت برغم اعتراض الاقلية الموافقة على اقرار الاجلبيه فلها ان تقرر اتخاذ التدابير المناسبة للحفاظ على حقوق الاقلية ، ومنها تقديم الاجلبيه كفالة مالية تضمن الوفاء بما قد يستحق من تعويضات

ثالثا : حق الشريك منفردا فى الانتفاع بالمال الشائع :

لكل شريك منفردا حق الانتفاع بالمال الشائع كله او بعضه فيما لا يعطل حقوق الشركاء الباقين ودون حاجة لاذن سابق منهم ، وذلك كأن يمر فى الشارع او الممر المشترك للوصول لمنزله او ارضه او يأخذ من المسقى او المروى المشترك ما يكفى لرى ارضه .

كما يحق للشريك منفردا ان يباشر الاعمال المادية اللازمة لحفظ المال الشائع وصيانته كترميم جدار آيل للسقوط ، بشرط الا يضر بالمال فإن وقع ضرر بالمال الشائع فعليه وحده نفقات الاصلاح .

ايضا من حقه مباشرة الاعمال القانونية اللازمة للحفاظ على المال كرفع دعوى على حائز المال دون سند قانونى لقطع التقادم قبل ان يكتمل فى حقهم جميعا ورفع دعاوى الحيازة ضد من اغتصب حيازة المال الشائع .

لشريك القيام بهذه الاعمال المادية او القانونية دون الحصول على موافقة بقية الشركاء ، فهى اعمال تتعلق بالحفاظ على المال لمصلحتهم جميعا ويتحمل الجميع النفقات كل بقدر حصته .

"التصرف في اموال الشائع"

اولا : التصرف بالاجماع في اموال الشائع :

- ❖ اذا انعقد اجماع الشركاء على احد اوجه التصرف في المال **فيصح تصرفهم وينفذ في حق الجميع** ايا كانت نتيجة القسمة بينهم ، وفي الحقيقة انهم لا يحتاجون لقسمة المال الشائع اذا ما كان التصرف ناقلا للملكية .
- ❖ ونعني بسلطه التصرف هنا التصرفات الناقلة للملكية او غير الناقلة لها ، كالمقررة لبعض الحقوق الاخرى دون نقل الملكية (الايجار والرهن يُعدان من قبيل الانتفاع بالمال) فيدخل اذا في التصرف الهبة والمقايضة والتقدم بحصة عينية في شركة .
- ❖ إذا كان من بين الشركاء قاصر او عديم الاهلية ، فلا بد من اعمال قواعد الولاية على المال ، حيث يحق للولي فقط التصرف في هذا المال .

ثانيا : تصرف الاغلبيه في اموال الشائع :

- ❖ تملك الاغلبيه تقرير التصرف في المال الشائع كله ولكن بشرط ان تكون اغلبيه من يحوزون **ثلاثه ارباع** المال الشائع ، فهي اغلبيه غير عادية ، وذلك مع حفظ حق الاقلية في الاعتراض .
- ❖ قد نص القانون " للشركاء الذين يملكون على الاقل ثلاثة ارباع المال الشائع ، ان يقرروا التصرف فيه اذا استندوا في ذلك الى اسباب قوية على ان يعلنوا قراراتهم الى باقى الشركاء ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع الى المحكمة خلال شهرين من وقت الاعلان ، وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء ، ان تقدر تبعا للظروف ما اذا كان التصرف واجبا .

❖ قانون قيد حق الاغلبيه في التصرف في المال الشائع اجمالا بشرطين :

الاول : الاستناد لاسباب قوية :

- ❖ اي مبررات جدية وقوية تحتم اقدامهم على التصرف في المال الشائع كله كعدم قابلية المال للقسمة العينية (كحيوان او شقة او سيارة) او قابليتها للقسمة ولكن بخسارة كبيرة على الجميع كقطعة ارض بناء صغيرة المساحة والتصرف فيها مجزأة تضيع الفائدة منها .

الثاني : وهو شرط شكلي ان يعلنوا قرارهم للاقلية :

- ❖ حتى يسمحوا للاقلية بدراسة الامر وتقليبه على كل الوجوه ، فإن اقتنعوا بالقرار اقروه وحصلوا على نصيبهم المادي ، والا فلهم الحق في اللجوء للمحكمة للاعتراض على قرار الاغلبيه بالتصرف بشرط ان يتم الاعتراض في خلال شهرين من وقت الاعلان .

ثالثا : تصرف الاقلية او الشريك منفردا في اموال الشائع :

١- تصرف الشريك منفردا (او الاقلية) في اموال الشائع كله او فيما جاوز حصصهم :

- ❖ قد يلجأ الشريك للتصرف في المال الشائع كله دون تفويض مسبق من باقى الشركاء فهو ليس وكيلا عنهم .
- ❖ **حكم هذا التصرف انه يعد تصرفا في ملك الغير** وبالتالي لا ينفذ في حق الشركاء الآخرين الا اذا اقروه ، فهو باطل في حقهم ويحق لهم عدم الاعتداد بالتصرف وتعاملهم على المال على اعتبار انهم شركاء ولهم حصص ثابتة فيه واستبعاد اي طرف اجني حين النظر في اي استغلال او قرار يتعلق بالانتفاع بالمال او التصرف فيه .
- ❖ بشأن مصير التصرف ، ففي العلاقة بين الشريك والمتصرف اليه (المشتري مثلا) فيظل الامر متوقفا على رأى الشركاء فإن اقروه صار نافذا في حق الجميع ، وان رفضوه وتعذر على الشريك تنفيذ التزاماته فمن حق المشتري اللجوء للفسخ لاخلال البائع بالتزاماته .

٢- تصرف الشريك في حدود حصته الشائعة :

- ❖ اذا انصب تصرف الشريك على حدود حصته الشائعة (كلها او بعضها) **فالتصرف صحيح** بين الطرفين نافذا في حق الشركاء الآخرين .

❁ لكن هل يشترط ان يتصرف الشريك فى حصته الشائعة لاحد الشركاء الآخرين فى ذات المال ، ام يستطيع ان

يتصرف لأجنبى عن الشركاء ؟

❁ الحقيقة انه لا قيد قانونى على حق الشريك فى التصرف لشريك آخر او لاجنبى عن الشركاء فهذا حقه واختياره طبقا لمصلحة .

❁ تصرفه فى حصته لاجنبى فهو وان كان صحيحا بين طرفيه نافذا فى حق الجميع ، الا انه يفتح للشركاء الآخرين فى المال مجتمعين او منفردين **الحق فى الاخذ بالشفعة** ، اذا كان المبيع عقارا ، او يفتح لهم **الحق فى الاسترداد** اذا كان المبيع حصة شائعة فى منقول او المجموع من المال .

٣- نصرف الشريك منفردا فى جزء مفرز من اموال الشائع :

❁ لا تتحقق قسمة وافراز المال الشائع الا بإجماع الشركاء (بالتراضى) او بحكم قضائى (بالتقاضى) اما الافراز والتقسيم بالإرادة المنفردة او حتى بالاغلبية فلا ينتج عنها اى اثر قانونى وتظل حالة الشيوع قائمة قانونا .

❁ لذلك فإن افراز الشريك حصته فى المال الشائع ، لا اثر له وكذلك بيعه او تصرفه عموما فى هذا الجزء المفرز ، **ويأخذ حكم بيع ملك الغير** فلا ينفذ فى حق بقيه الشركاء الا بإقرارهم له ، حتى ولو كان فى حدود حصته فى المال او اقل منها ، لأنه لم تحدث قسمة ويحق للشركاء عدم الاعتراف بالتصرف والتعامل على اعتبار استمرار حالة الشيوع وتجاهل الاجنبى ، ولا يحق لهذا المشتري ان يطلب تسليم المبيع مفرزا اليه قبل القسمة .

❁ **لكن هل يفتح هذا التصرف فى جزء مفرز باب الاخذ بالشفعة للشركاء الآخرين اذا كان التصرف تم لاجنبى عنهم**

وذلك على غرار التصرف فى الحصة الشائعة ؟

❁ الحقيقة ان هذا الفرض مختلف ، لأن تصرف الشريك فى حصته شائعة صحيح ونافذ فى حق الجميع وفتح باب الشفعة هنا للشركاء الآخرين له ما يبرره حتى يتجنبوا وجود اجنبى عنهم فى المال مع ما يحمله ذلك من مضايقات وربما منازعات .

❁ اما التصرف فى حصة مفرزة فهو غير نافذ فى حق الشركاء الآخرين ويكفيهم القانون عناء اى اجراء لانه فى حكم بيع ملك الغير ولهم تجاهل التصرف وتجاهل الاجنبى وممارسة حقوقهم على الجزء المفرز محل التصرف فلا حاجة بهم للشفعة لتجنب دخول اجنبى فى الشيوع .

❁ وهذا هو ما اخذت به محكمة النقض المصرية فى اول الامر وهو المتفق مع صحيح القانون .

❁ ولكن محكمة النقض عدلت عن رأيها السابق واقربت بحق بقية الشركاء فى رفع دعوى الشفعة .

❁ **اما من جانب حكم التصرف فى العلاقة بين الشريك والمتصرف اليه** ← قد نص القانون المدني على انه " واذا

كان التصرف منصبا على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة فى نصيب المتصرف ، انتقل حق المتصرف اليه من وقت التصرف الى الجزء الذى آل الى المتصرف بطريق القسمة ، وللمتصرف اليه اذا كان يجهل ان المتصرف لا يملك العين المتصرف فيها مفرزة الحق فى ابطال التصرف

بيان ذلك :

أ- **اذا كان المتصرف اليه يعلم بعدم ملكية المال ملكية مفرزة** ← فليس امامه الا انتظار نتيجة القسمة فإن وقع

فى نصيب المتصرف الجزء المتصرف فيه صح التصرف ونفذ واذا وقع فى نصيب المتصرف جزء آخر (من ذات الطبيعة للمال محل التصرف كما اذا تصرف فى قطعة ارض زراعية مفرزة ، ووقع فى نصيبه قطعة ارض زراعية اخرى) انتقل حق المتصرف اليه الى الجزء الذى وقع فى نصيب المتصرف من ذات طبيعة الشيء .

❁ اما ان وقع فى نصيبه مالا نقديا او مالا مختلفا فى الطبيعة عن المال المتصرف اليه (كما لو كان تصرف فى قطعة ارض زراعية ووقع فى نصيبه سيارة او شقة) فلا يبقى امام المتصرف اليه الا طلب الفسخ لاخلال المتعاقد معه بالتزامه

ب- **فإن كان المتصرف اليه يجهل ان المال محل التصرف ليس مفرزا** ← فله الحق فى طلب ابطال العقد للغلط

فى صفة جوهرية فى الشيء محل التعاقد وفى المتعاقد ذاته .

رابعاً : استرداد الحصة الشائعة

على غرار حق الشفعة بالنسبة لبيع العقار وضع المشرع نظاماً لاسترداد الحصة الشائعة فى المنقول .

١- شروط الاسترداد :

الشرط الاول : ان يتم بيع حصة شائعة فى منقول او فى المجموع من المال :

الامر يخص تصرف واحد ناقل للملكية وهو البيع ، اى نقل الملكية مقابل ثمن نقدي فلا بد ان يستجمع التصرف اركان عقد البيع وشروطه ، اما البيع الباطل نسبياً فهو موجود ومنتج لآثاره الى ان يتقرر بطلانه ويتوقف مصير دعوى الاسترداد على مصير البيع ذاته ، فإن التصرف الناقل للملكية غير البيع كالهبة والمقايضة والصلح وغيرها فلا يفتح باب الاسترداد .

كما يجب ان يرد البيع على الحصة شائعة ، وليس مفزعة ، فإذا انقضت حالة الشيوع بالقسمة ، فلا مجال للاسترداد اخيراً فالامر يتعلق بالمنقولات او بالمجموع من المال ، وتستبعد العقارات من هذا النظام ويطبق بشأنها نظام الشفعة ، اما المنقولات بطبيعتها والعقار بالتخصيص اذا ما فصل عن العقار الاصلى بإرادة مالكه وكذلك المجموع من المال والذي يضم عناصر مادية ومعنوية كالمحل التجارى والتركة واموال الشركة بعد حلها ، فهى المعنية بنظام الاسترداد حتى ولو اشتمل هذا المجموع من المال على عقار .

الشرط الثانى : ان تباع الحصة الشائعة لاجنبى عن الشركاء :

اى ان الشريك على الشيوع فى المنقول او المجموع من المال قد باع حصته شائعة وبالتالي فالتصرف صحيح بين طرفيه ونافذ فى حق الشركاء الآخرين .

كما يشترط هنا ان يتم التصرف لاجنبى عن الشركاء اى شخص ليس شريكاً فى المال محل الاسترداد .

ان تعدد الشركاء واختار الشريك البائع احدهم وتصرف له بالبيع فى حصته مثلاً فلا يحق للآخرين اللجوء للاسترداد .

الشرط الثالث : ان يتم البيع بطريق الممارسة :

يعنى ذلك عدم اللجوء للمزاد العلنى ، فإن تم البيع بالمزاد العلنى طبقاً للقانون فلا يفتح باب الاسترداد ، حيث كان يحق للشريك المسترد دخول المزاد والتزايد على الحصة اما وقد فوت فرصته فى ذلك فلا حق له فى الاسترداد .

٢- اجراءات الاسترداد :

إذا اجتمعت الشروط الثلاثة السابقة انفتح امام الشريك باب الاسترداد ، وثبت له هذا الحق لمدة ثلاثين يوماً يبدأ حسابها من تاريخ علمه اليقيني بالبيع لاجنبى او من تاريخ اعلانه به ويثبت هذا الحق لكل شريك فإن استقر رأيه على الاسترداد فعليه ان يوجه اعلاناً بذلك للطرفين يوضح فيه جدياً استقراره على اخذ الحصة الشائعة المبيعة بالاسترداد بالسعر المعلن به او المباع به ، ويتم الاسترداد بهذا الاعلان دون حاجة لدعوى او حكماً قضائياً ، فإن لم يتم الاسترداد رضاءاً فله ان يرفع دعوى الاسترداد فى اى وقت الى ان تتم القسمة .

لكن لا يتسلم الحصة المباعة فعلاً الا من تاريخ تعويضه المشتري عن كل ما انفق على الحصة المستردة ، والتعويض لا يقتصر على الثمن المدفوع فحسب بل يشمل ايضاً النفقات التى انفقها المشتري عليها حتى ما قبل الاعلان بالاسترداد

"القسمة الرضائية والقسمة القضائية"

اولا : نعرىف القسمة وانواعها :

١- تعرىف :

🕒 **القسمة** ← افراز وتجنيب نصيب كل شريك فى المال الشائع ، يحصل عليه ويتنازل عن الانصبة الاخرى للشركاء الآخرين "

٢- انواع القسمة :

أ- قسمة التجميع وقسمة التفريق :

🕒 **قسمة التجميع** تعتمد على تجميع نصيب كل شريك فى مال محدد ، وعدم تفريقه بين اجزاء المال الشائع وهذا يفترض تعدد الاموال الشائعة كالتركة التى تتكون من مزرعة ومصنع وفيلا واموال سائلة ، فإذا كان الشركاء ثلاثة اخوة فيمكن ان يمنح احدهم الفيلا ، والاخر المزرعة ، والثالث المصنع وتقسم الاموال السائلة على الثلاثة .

🕒 **قسمة التفريق** ، فيعطى كل شريك ما يعادل حصته فى كل جزء من الاموال الشائعة ففى المثال السابق يقسم المصنع على ثلاثة انصبه ، يعطى كل منهم نصيب ، وكذلك الفيلا والمزرعة ، وهذه القسمة لا يلجأ اليها اذا كانت تسبب خسارة للشركاء حيث بعض الاموال تقل قيمتها كثيرا بقسمتها عينا وبعض الاموال لا تقبل القسمة العينية اصلا .

ب- القسمة العينية وقسمة التصفيه :

🕒 تعتمد القسمة العينية على حصول كل شريك على جزء عيني من المال الشائع متى امكن ذلك اما قسمة التصفيه فتعتمد على بيع المال الشائع ، واقتسام ثمن البيع على الشركاء بنسبة حصصهم .

ج- قسمة المهايأة والقسمة النهائية :

🕒 طريقة لتنظيم الانتفاع بالمال الشائع مؤقتا ، ولا تستمر اكثر من خمس سنوات مالم تتجدد وقد تكون مهايأة زمانية او مكانية ، ولا تنهى حالة الشيوخ ، اما القسمة النهائية وايا كان نوعها فهى تنهى حالة الشيوخ ، ويحصل كل شريك على نصيبه محدد ومفرضا من المال .

د- القسمة الرضائية والقسمة القضائية :

🕒 تتم القسمة الرضائية بالتراضى بين الشركاء فيتفقون جميعا عليها ، لا يعارض منهم احد وغالبا مالا تكون عادلة تماما ، والغبن فيها مقبول ، مالم يجاوز الخمس .

🕒 القسمة القضائية فتتم بحكم قضائى ينهى حالة الشيوخ ويحصل كل شريك على حقه تماما لا اكثر .

ثانيا : حىف طلب القسمة :

🕒 **الاصل** ← انه يحق لكل شريك فى الشيوخ طلب قسمة المال الشائع قسمة نهائية وتحديد وافراز نصيبه وانصبة غيره من الشركاء وذلك فى اى وقت .

🕒 **الاستثناء** ← يمتنع على الشريك طلب القسمة اذا كان مجبرا على الشيوخ بنص قانونى او بالاتفاق

🕒 قد يجبر الافراد على البقاء فى الشيوخ رغما عنهم اذا ما قرر القانون وجود شيوخ اجبارى كما فى الاجزاء الشائعة فى ملكية الشقق والطبقات (السلام ، المصاعد ، الاسطح ، مدخل العمارة ..) وقد يتفق الشركاء على استمرار الشيوخ بينهم مدة خمس سنوات او مدة دورة معينة يحصل كل شريك خلالها على ريع المال الشائع كله ويتركه لفترة مماثلة لشريكه الآخر ، فإذا وجد الاتفاق تعيين احترامه من الجميع .

🕒 لا يجوز بمقتضى الاتفاق ان تمنع القسمة الى اجل يجاوز خمس سنين ، فإذا كان الاجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق فى حق الشريك وفى حق من يخلفه

س ١٠ :تكلم عن القسمة الرضائية موضحاً أنواعها وشروط نقض القسمة للغبن؟

ثالثاً : القسمة الرضائية :

🔴 **القسمة الرضائية** ← التي انعقد عليها اجماع الشركاء ، وهى اما قسمة مهاياها واما قسمة نهائية :

١ - قسمة المنافع (قسمة المهاياة) :

🔴 قسمة المهاياة لا تنهى حالة الشيوع بل هى طريقة لتنظيم الانتفاع بالمال الشائع "فهى قسمة منفعة وليس قسمة ملك " وتتم بالتراضى وإجماع الشركاء عليها وهى اما قسمة مهاياة مكانية او زمانية

أ - المهاياة المكانية :

🔴 تتم بإتفاق الشركاء على ان يختص كل منهم بجزء مفرز من المال الشائع يعادل نصيبه تقريبا ، ينتفع به وحده طوال مدة الاتفاق متنازلا فى الوقت ذاته عن الانتفاع بالاجزاء الاخرى لصالح شركائه الآخرين .
🔴 يصح اتفاق الشركاء على هذه المهاياة بشرط الا تتجاوز خمس سنوات ، فإذا انقضت فيمكن تجديدها لمدة او لمدة مماثلة ، وان تجاوز الاتفاق مدة الخمس سنوات نقص الى هذه المدة وصح الاتفاق .

تحول المهاياة المكانية الى قسمة نهائية بقوة القانون :

🔴 ان استمر الوضع كذلك مدة خمسة عشرة سنة ، انقلبت قسمة المهاياة المكانية **من قسمة مؤقتة الى قسمة نهائية** بقوة القانون ، فتلك خير قسمة توصل اليها الشركاء وارتضوها بينهم ضمنا ، واستمروا عليها تلك المدة الطويلة .
🔴 بل وقد اقام المشرع ، قرينة مقتضاها انه اذا حاز الشريك على الشيوع جزءا مفرزا من المال الشائع مدة خمسة عشرة سنة ، افترض ان حيازته لهذا الجزء تستند لقسمة المهاياة المكانية بكل احكامها السابقة .
🔴 يترتب على اعتبار هذه القسمة نهائية بقوة القانون وليست قسمة اتفاقية انه لا يجوز نقضها للغبن ، واذا كان بين الشركاء شخص لم تتوافر فيه الاهلية او كان بينهم غائب فإن هذا لا يمنع تحول قسمة المهاياة الى قسمة نهائية ، والاعتبارات العملية جعلت القضاء يتجه الى ضرورة تسجيلها .

ب - المهاياة الزمانية :

🔴 تكون المهاياة الزمانية بعمل دورة زمنية للمال بعدد الشركاء فيه ، يحوز كل شريك المال كاملا للانتفاع به المدة الزمانية المتفق عليه (اسبوع ، شهر ، سنة) ثم يسلمه لشريكه الآخر كاملا لينتفع به مدة مماثلة ، وهكذا حتى يستفيد كل الشركاء بمدد مماثلة من المال تتناسب مع حصصهم فيه ، وبعد انتهاء الدورة يمكن بدء دوره مهاياة جديدة .
🔴 قد نص القانون على انه " تكون قسمة المهاياة ايضا بأن يتفق الشركاء على ان يتناوبوا الانتفاع بجميع المال المشترك كل منهم لمدة تتناسب مع حصته ، وتخضع قسمة المهاياة من حيث جواز الاحتجاج بها على الغير ومن حيث اهلية المتقاسمين وحقوقهم والتزاماتهم وطرق الاثبات لاحكام عقد الايجار .

٢ - القسمة النهائية :

🔴 " للشركاء اذا انعقد اجماعهم ان يقتسموا المال الشائع بالطريقة التي يرونها ، فإذا كان من بينهم ناقص الاهلية وجبت مراعاة الاجراءات التي يفرضها القانون " .
🔴 بالتالى فلا تصح القسمة الرضائية بالاغلبية ، ولكن يظل اتفاق الاغلبية ملزم لهم ، بشرط الا يضر بحقوق الشركاء الآخرين . ويكون للشركاء الآخرين ان يقرروا الاتفاق فينفذ فى حقهم متى شاؤوا ، وتنتهى حالة الشيوع ان اقروه جميعا ، ولكن بشرط ان يعينوا فى اتفاقهم هذه انصبه الشركاء الآخرين ، فإن لم يتم هذا التعيين (عمدا او سهوا او غلطا) فإن القسمة هذه تقع باطلا بطلانا مطلقا .

🔴 **ولكن هل يشترط لتحقيق القسمة الرضائية الاتفاق الصريح الواضح لجميع الشركاء ام يمكن ام يكون الاتفاق ضمنيا**
🔴 اجازت المحاكم الاتفاق الضمنى على القسمة الرضائية واقترته وقضت بترتيب آثاره بين المتقاسمين ومن ذلك ان يتصرف احد الشركاء المشتاعين فى جزء مفرز من المال الشائع يعادل حصته ، ثم يتبعه فى ذلك سائر الشركاء ، فيتصرف كل منهم فى جزء مفرز يعادل نصيبه ، فإن تصرفهم هذا يدل على رضائهم بهذه القسمة الفعلية التي تمت بفعل جميع الشركاء .

لكن اذا اتفق بالاجماع على القسمة الرضائية فلا محل بعد ذلك للرجوع عنها ، فالقسمة الرضائية يحتج بها بين الشركاء بمجرد الاتفاق عليها ولكن لا يحتج بها على الغير الا بتسجيلها . وتثبت القسمة الرضائية بكل طريق الاثبات ، وغالبا ما يفرغ اتفاق الاطراف فى اطار مكتوب يوقع عليه الجميع .

إن كان من بين الشركاء ناقص الاهلية وخاضع لنظام الوصاية فيجب مراعاة حقوقه ، فيجب على الوصى استئذان المحكمة المختصة قبل القسمة .

هذا اذا كان القاصر خاضع لنظام الوصاية فإن كان خاضعا لنظام الولاية فلا يحتاج الولى (الاب او الجد الصحيح) لاستئذان المحكمة لإجراء القسمة الرضائية لأموال القاصر .

٣- نقض القسمة الرضائية للغبن :

تعد القسمة الرضائية عقدا بالمعنى القانونى يخضع للقواعد العامة فى العقود من ناحية الانعقاد والآثار ، خاصة من ضرورة توافر اركان العقد من الرضاء والمحل والسبب ومن شروط صحة العقد من الاهلية وخلو الارادة من العيوب .

بخصوص الغبن فلم يرد المشرع اخضاعه للقواعد العامة بل وضع للغبن فى القسمة الرضائية حكما خاصا ، مراعاة منه لما يكتنف القسمة هذه من موائمات وتراضى يتم بين الشركاء .

فيشترط لنقض القسمة الرضائية للغبن الفاحش شرطين :

الشرط الموضوعى : ان يزيد الغبن عن خمس نصيب المتقاسم :

نقص نصيب احد المتقاسمين حتى الخمس مقبولا فى النص القانونى ، فإن كان نصيب كل متقاسم فى المال مبلغ مليون جنيه مثلا وحصل احدهم على نصيب ٨٠٠ ألف واحداهم على مليون و ٢٠٠ ألف ، فهذا ما يزال مقبولا قانونا لأننا فى حدود الخمس لم نتجاوزه ، والنص يشترط ان يزيد الغبن على الخمس فإن كان نصيبه اقل من ٨٠٠ ألف فقد تحقق الشرط الاول .

ويحسب الغبن على اساس قيمة المال المقسوم وقت اجراء القسمة وليس بعدها فالعبرة بالقيمة الحقيقية للمال فى تلك اللحظة فإن زاد نصيب احد المتقاسمين بعد القسمة ولو بيوم واحد على اثر زيادة الاسعار ، او ادخال المنطقة الواقعة بها نصيبه فى التخطيط العمرانى مما رفع قيمتها فكل ذلك لا اثر له من ناحية الغبن .

الشرط الشكلى : ان ترفع الدعوى خلال السنة الثانية للقسمة :

وهى مدة قصيرة وضعها المشرع لسرعة حسم المنازعات التى يمكن ان تثار بمناسبة الاتفاق على القسمة ولاستقرار الاوضاع بين المتقاسمين .

وتحسب مدة السنة من تاريخ اجراء القسمة ، وهذه مدة سقوط وليس تقادم فلا يرد عليها لا الوقف ولا الانقطاع . وقد اجاز القانون للمتقاسم الآخر ان يتوقى نقض القسمة اذا هو اكمل للمتقاسم المغبون نقدا او عينا ، مقدار ما نقص من حصته ، فتقف الدعوى .

فإذا فاتت مدة السنة فيعد المتقاسم المغبون قد تنازل ضمنا عن حقه فى نقض القسمة للغبن الذى يجاوز الخمس ، كما يملك ان يتنازل صراحة عن هذا الحق فيستقر الوضع النهائى للقسمة الرضائية .

ولكن ان تمسك بحقه واجابته المحكمة لطلبه عادت حالة الشيوخ قائمة كما كانت ويعود له ولغيره الحق فى طلب القسمة القضائية .

رابعا : القسمة القضائية

اذا اختلف الشركاء ولم يستطعوا الوصول الى قسمة رضائية بإجماعهم فننتقل للقسمة القضائية .

ويطلب القسمة القضائية ايا من الشركاء وايا كان نصيبه فى المال ، صغيرا او كبيرا ، وتختص بنظر دعوى قسمة المال الشائع المحكمة الجزئية الواقع فى نطاق دائرتها المال ، كما تختص ايضا بالفصل فى المنازعات التى تتعلق بتكوين الحصص وكل المنازعات الاخرى المتعلقة بالقسمة والمال المقسوم والتى تدخل فى اختصاصها .

وبعد طلب الخصوم اجراء القسمة القضائية تبدأ المحكمة بنظر الدعوى ، وغالبا ما تنتدب احد خبراءها لتعيين الوضع على الطبيعة وتقييم المال واقتراح مشروعات القسمة .

وبعد اختيار مشروع القسمة (عينية او تصفيه) توزع الانصبة على الشركاء .

وان تعذر قسمة المال قسمة عينية ، فيمكن للمحكمة ان تقرر اجراء قسمة التصفية بالتزايد عليه ، ويمكن ان يقتصر المزداد على الشركاء اذا ما طلبوا جميعا ذلك والا فيباع بالمزاد العلنى .

حكم القسمة ملزما للشركاء المتقاسمين الذين كانوا طرفا فى دعوى القسمة بما فصل فيه ، فإن بات نهائيا فقد حاز حجية الامر المقضى .

حماية حقوق الدائنين :

حرصا من المشرع على حماية حقوق دائني بعض الشركاء المتقاسمين او كل الشركاء ، وحتى لا تحدث موائمات واتفاقات سرية ضارة بمصالحهم فقد اجاز القانون لهم ان يعارضوا اجراء القسمة دون تدخلهم ، وتوجه المعارضة لكل الشركاء .

في جميع الاحوال يجب ادخال كل الدائنين المقيدة حقوقهم على المال قبل اجراء القسمة عارضوا ام لم يعارضوا
فإن تمت القسمة دون حدوث معارضة من احد الدائنين او كلهم فليس له ان يحتج بعدم نفاذ القسمة في حقه الا في حالة واحدة هي الغش ان استطاع اثباته .

احكام خاصة بتصفية الشركات وقسمتها :

فمن حق كل وارث ان يطلب من المصفي ان يسلمه نصيبه في الارث مفرزا وعلى المصفي ان يجري قسمة ودية لاعيان التركة على الا تصير نهائية الا بإقرارها من الورثة بالاجماع فإن تعذر ذلك فعلى المصفي ان يرفع دعوى قسمة (على نفقة التركة) .

فإذا كان من بين اعيان التركة اوراق عائلية واشياء تتصل بعاطفة الورثة نحو مورثهم وتعذر اجماع الورثة على قسمتها فللمحكمة ان تأمر ببيعها او بإعطائها لاحد الورثة مع استئصال قيمتها من نصيبه او دون استئصال .

تصديق المحكمة الابتدائية على حكم القسمة في حالة وجود شريك غير كامل الاهلية :

يجب الحصول على تصديق المحكمة الابتدائية التي تتبعها المحكمة الجزئية على حكم القسمة بعد ان يصبح نهائيا اذا كان من بين الشركاء غائب او كان بينهم من لم تتوافر فيه الاهلية وكان ينوب عنه في القسمة الوصي او القيم وذلك وفقا للقانون .
فإن كان الولي هو من ينوب عنه فلا حاجة للتصديق .

آثار القسمة

اولا : الاثر الرجعي للقسمة (الافراز) :

تعتمد فكرة الاثر الرجعي للقسمة على طبيعة القسمة ذاتها وهل هي كاشفة عن الحق او منشئة له ؟
فقد اعتنق الفكر القانوني في بداية الامر الطبيعة المنشئة للقسمة فهي ناقلة للحق وليست كاشفة له ويترتب على ذلك بقاء التصرفات التي أبرمها كل شريك متقاسم على الجزء الذي كان يحوزه .
ولتلافي هذه النتائج الضارة بدأ الفكر القانوني يتجه صوب فكره الاثر الرجعي للقسمة ، بما تتضمنه من آثار كاشفة وليست منشئة للحق ، وضمن القانون الفرنسي هذه الفكرة ثم القانون المدني الاهلي المصري ثم القانون الحالي حيث نص على انه "يعتبر المتقاسم مالكا للحصة التي آلت اليه منذ ان تملك في الشيوع وانه لم يملك غيرها شيئا في بقية الحصة" .
والنص محل انتقاد الفقه لما يترتب من نتائج متناقضة .
وبناء عليه فالافراز الذي تحقق نتيجة القسمة والتي تمت في يناير سنة ٢٠١٠ مثلا ، يعد بمقتضاه الشريك المتقاسم مالكا لهذا النصيب منذ بدء الشيوع في يناير ٢٠٠٠ مثلا ، وانه لم يملك غيره في اي من ايام الشيوع
وبما ان القسمة كاشفة فلا تصلح كسبب صحيح يستند اليه الحائز للتمسك بالتقادم الخمسي او الحيازة في المنقول بحسن نية وبسبب صحيح سند الحائز فالسبب الصحيح يجب ان يكون تصرفا قانونيا ناقلا للملكية ، والقسمة ليست ناقلة للملكية بل كاشفة لها .

تسجيل القسمة للاحتجاج بها على الغير :

برغم اثرها الكاشف الا ان المشرع نص على وجوب تسجيلها وذلك للاحتجاج بها على الغير ، حيث نص على " سريان هذا الحكم (الخاص بالتسجيل) على القسمة ولو كان محلها اموالا موروثة ، اما بالنسبة للشركاء المتقاسمين انفسهم فإنه يحتج عليهم بالقسمة منذ تاريخ الاتفاق عليها ، ولو لم تسجل .

ثانياً : ضمان التعرض والاستحقاق

ليس معنى حدوث القسمة وافراز نصيب كل متقاسم هو انتهاء العلاقة نهائياً بين المتقاسمين بزوال الشيوع ، فالقانون اقام علاقة بينهم لصالحهم جميعاً ، حيث قد يقع تعرض (قانوني) لاحد المتقاسمين وينجح المتعرض فى دعواه ويأخذ النصيب من يد المتقاسم ، فهنا يضمن المتقاسمون الآخرون تعويض ما استحق من تحت يد احد المتقاسمين لتتساوى الانصبة النهائية ، وكذلك لا يحق لاي متقاسم ان يتعرض للآخر فى نصيبه سواء أكان تعرض مادي او قانوني .

إذا كانت احدى الاعيان المقسومة ليست ملكاً (للمورث مثلاً) بل كانت يده عليها عارضه ، كما فى عارية الاستعمال او عقد الامانة ، وقام الورثة بإدخالها ضمن التركة وقسموها عن جهل منهم بعدم تملك مورثهم لها ، ولما ادعى مالکها الحقيقى بها وحصل على حكم بإستردادها من تحت يد من وقعت فى نصيبه فقد بات المتقاسم هذا بلا نصيب بغير خطأ منه ، بل بسبب سابق على اجراء القسمة ، وهنا وجب الضمان على بقية المتقاسمين ، كل منهم يلزم بتعويض هذا المتقاسم بنسبه حصته .

يقدر الشئ او النصيب المستحق من تحت يد المتقاسم بقيمته وقت القسمة ، ويسقط حق المتقاسم فى ضمان الاستحقاق بالتقادم الطويل (١٥ عاماً) من وقت الاستحقاق .

غير ان ضمان التعرض والاستحقاق يرتفع فى حالتين :

١. **الاولى : اذا ما اتفق على ذلك** ← حيث الامر يتعلق بمصالح خاصة ولا يمس النظام العام فى شئ ، ويشترط فى الاتفاق المعفى من الضمان ان يكون صريحاً وليس ضمناً ، حيث قد يتوقع الشركاء ان يدعى شخصاً بعينه بحق على المال المقسوم ، فيطلبه احد المتقاسمين ويتفق مع الآخرين على عدم ضمانهم اذا نجح المدعى فيما يدعيه .

٢. **الثانية : اذا استحق النصيب بخطأ المتقاسم نفسه** ← فإذا ثبت ان التعرض والاستحقاق وان كان بسبب سابق على القسمة الا انه كان بخطأ من المتقاسم نفسه فلا يلومن الا نفسه ولا يحق له مطالبة الآخرين بضمن التعرض والاستحقاق فلو كان المتقاسم قد باع هذا النصيب مفرزاً قبل القسمة وقبض الثمن وانفقه ، ووقع هذا الجزء المباع فى نصيبه بعد القسمة وطالب به المشتري وحصل عليه ، فلا يحق للمتقاسم الرجوع على الآخرين بالضمان .

ثالثاً : امتياز المتقاسم

نص المشرع على امتياز لمتقاسم المنقول او العقار بما قد يستحق له من تعويضات نتيجة ضمان التعرض والاستحقاق او نتيجة فروق الانصبة .

فلمتقاسم المنقول او العقار الاولوية فى الحصول على حقه من التعويضات المستحقة له فى ذمة المتقاسم معه ، والذي وقع المنقول او العقار فى نصيبه ويشترط القانون ان يقيد هذا الحق اذا كان المال المقسوم عقاراً ، وتكون مرتبته فى التقدم على غيره من الدائنين الممتازين من تاريخ هذا القيد ، اما المنقول فلا يقيد الحق عليه ويأخذ ذات مرتبة حق البائع وبذلك يخرج المتقاسم بما له من حقوق وتعويضات عن مزاحمة دائنى المتقاسم الآخر من دائنين ممتازين او عاديين فيضمن حصوله على مستحقاته من المال المقسوم ذاته .

الوصية بالقسمة

يحدث كثيراً ان يرغب احد الاشخاص فى ان يوزع ما قد يتركه من اموال بعد وفاته بين ورثته بطريقة تضمن تجنيب الورثة المنازعات ، فيقوم بقسمة هذه الاموال بين ورثته المحتملين مضمناً ذلك فى شكل وصية تنفذ بعد وفاته تكون ملزمة لهم جميعاً .

اولاً : شروط الوصية بالقسمة :

الاول : توافر اهلية الايصاء لدى المورث :

حيث يجب توافر هذه الاهلية للمورث لحظة الايصاء ، من الرشد وخلوه من عوارض الاهلية اما الموصى لهم (الورثة) فلا يشترط فيهم الاهلية فهى تسرى فى حق الراشد والقاصر وغيرهما .

الثانى : اثبات الوصية بالقسمة :

حيث يجب اثباتها اما بورقة رسمية او ورقة عرفية مصدق على توقيع المورث فيها ، او ورقة مكتوبة جميعها بخط المورث وعليها امضاؤه .

ثانيا : نطاق الوصية بالقسمة :

❖ **من ناحية الاموال** ← يجوز ان تشمل الوصية بالقسمة كل اموال المورث حتى وفاته ، او ان يقصرها على بعض تلك الاموال ، وهنا ينحصر اثرها على ما ورد فيها من اموال اما ما لم يرد به بيان فيخضع لقواعد الميراث والشيوع .

❖ **من ناحية الاشخاص** ← يمكن ان تشمل الوصية بالقسمة كل الورثة ، فتحدد لكل منهم نصيبه فيها وما يختص به من اعيان تقابلها ، فإن مات اى من هؤلاء الورثة المحتملين ممن شملتهم الوصية بالقسمة ولم يتم تغيير الوصية ، فإن الحصة المفروزة والتي وقعت فى نصيب من مات تؤول شائعة الى باقى الورثة طبقا لقواعد الميراث .

❖ إن اقتصرت الوصية على تحديد لكل وارث نصيبه مفروزا فى التركة ، دون مجاوزة لقواعد الميراث الشرعية فيها وان ثبت مجاوزة النصيب عما يستحقه الوارث شرعا فإن الزيادة تعد فى حكم الوصية ، وهى لا تنفذ الا فى حدود ثلث التركة فقط ، فإن جاوزت الزيادة ثلث التركة فلا تنفذ فى حق الورثة الآخرين إلا بموافقتهم عليها .

ثالثا : آثار الوصية بالقسمة :

❖ قبل وفاة المورث يجوز له الرجوع فيها متى شاء ، كليا او جزئيا او يعدلها وقد يستفاد الرجوع من تصرفه فى ممتلكاته اثناء حياته كلها .

❖ فإن مات المورث مصرا على وصيته ، فقد باتت لازمة لجميع الورثة ، لا يتعدونها فى التقسيم ، مالم يتجاوز حصص بعضهم فى زيادتها ثلث التركة ، ولا ترد هذه الوصية بردها من الورثة ، ولا حاجة لقبوله او رفضه ، اما الوصية فهى لكيفية التقسيم فقط ، وهى ملزمة فى هذا الشأن .

❖ تطبق احكام القسمة من ناحية الاثر الرجعى والاثار الكاشف للقسمة ، حيث تخلص الحصص المفروزة لكل وارث مطهرة من اى حقوق عينية قد رتبها عليها وارث اخر .

❖ كما تطبق احكام ضمان التعرض والاستحقاق على الورثة ايضا اذا استحق ايا من الاعيان المفروزة المسلمة لاحد الورثة بسبب قانونى سابق على وفاة مورثه وبغير خطأ من الوراث .

❖ بشأن احكام الغبن فى القسمة الرضائية والتي يجوز نقضها اذا جاوز الغبن حد الخمس ، فلا يطبق بشأن الوصية بالقسمة .

صور خاصة للملكية الشائعة (الشيوع الاجبارى - ملكية الاسرة - ملكية الطبقات)

"الشيوع الاجبارى"

❖ " ليس للشركاء فى مال شائع ان يطلبوا قسمته اذا تبين من الغرض الذى اعد له هذا المال انه يجب ان يبقى دائما على الشيوع " .

❖ ويحدث هذا كثيرا فى حالات الطرق والشوارع والمداخل والحارات الخاصة التى تخدم بعض المزارع او المنازل والتي يضيع الغرض منها بقسمتها وكذلك فى بعض المقابر المخصصة لدفن عائلة او اكثر ودور المناسبات .

❖ عن ادارة هذا المال وصيانتة ورعايته فيخضع للقواعد العامة فى الشيوع ، حيث يلتزم كل الشركاء فيه بالمساهمة فى نفقات ادارة المال الشائع وحفظه وسائر الضرائب والرسوم المفروضة عليه ، والقاعدة ان تحسب هذه النفقات على اساس الحصص فإن لم يوجد ما يثبت حصه كل شريك فيفترض التساوى بين الجميع .

❖ بالنسبة لسلطة التصرف فليس للشريك هنا ان يتصرف فى حصته قانونا بشكل يتعارض مع الغرض المخصص له المال ، فليس للشريك فى مدافن وجبانات الاسرة مثلا ان يتصرف فى حصته لاجنبى عنهم ، وليس لدائنية الحجز على هذه الحصة تمهيدا لبيعها بالمزاد العلنى .

" ملكية الاسرة "

❖ قد تتفق اسرة واحدة فيما بينهم على جعل التركة والاموال الموروثة لهم او بعضها ملكية شائعة بينهم لا يجوز قسمتها ولا التصرف فيها لاجنبى عنهم .

❖ ورأى القانون انه لا مانع من اقرار هذا الاتفاق ، فهو يحقق مصالح جديرة بالحماية ولا يخالف النظام العام فى شئ .

اولا : شروط نشأة ملكية الاسرة :

الشرط الاول : ان يكون اعضاء الاتفاق من اسرة واحدة :

❖ ولم يضع النص معيارا لتحديد افراد الاسرة .

❖ لذلك اختلف الفقه فى تحديد معنى الاسرة فمنهم من طالب بقصرها على قرابة النسب مع استبعاد الزوج او الزوجة ومنهم من وسع المفهوم اعتبارا بالمعيار المحدد فى المادة وهو وحدة العمل او وحدة المصلحة

الشرط الثاني : اتفاق اعضاء الاسرة الواحدة كتابة :

الشرط الثاني المستخلص من النص ضرورة اجماع اعضاء الاسرة الواحدة ، ولكن ليس عدم موافقة احدهم تؤدي لعدم قيام ملكية الاسرة ، بل يمكن قيامها بين من وافق منهم عليها ويستبعد من رفض الاتفاق .

لكن المهم هو الشرط الشكلي هو ضرورة كتابة الاتفاق ، فلن تقوم هذه الملكية ما لم يوجد اتفاق كتابي عليها

الشرط الثالث : ان تكون مدة الاتفاق خمس عشرة سنة :

الاتفاق على تأييد هذه الملكية او تمديدتها لاكثر من خمس عشرة سنة غير جائز قانونا ، وان حدث فيمكن اللجوء لنظرية انقاص العقد ، حيث تخفض المدة الى ١٥ سنة ويصح الاتفاق ولا يبطل مطلقا .

إذا انقضت تلك المدة فيمكن الاتفاق على التجديد مدة مماثلة .
وان لم يذكر مدة سريان الاتفاق فيعد الاتفاق صحيحا وان كان يجوز لأي فرد في الاتفاق ان يتخارج بنصيبه منها بعد ستة اشهر من اعلان ارادته لباقي الشركاء .

ثانيا : احكام ملكية الاسرة :

إذا نشأت الملكية صحيحة مستوفية لركانها وشروطها فقد قيدت سلطة الشركاء في طلب قسمة المال محل التخصيص .

فلا يحق لأي من الشركاء طلب القسمة طوال مدة الاتفاق وإي طلب للقسمة الرضائية او القضائية لن يقبل ويلزم هذا الاتفاق الفرد في الاسرة وخلفة العام .

يستثنى من ذلك ← الحالة التي اجاز فيها القانون ل احد الشركاء ان يطلب من المحكمة وقبل انقضاء مدة الاتفاق ، ان تأذن له في اخراج نصيبه من ملكية الاسرة اذا ما طرأت مبررات قوية لذلك ، كهجرته او سفره للخارج مدة طويلة .

اما بشأن التصرف فيجوز للشريك في ملكية الاسرة ان يتصرف في حصته شائعه ، بشرط ان يتصرف ل احد الشركاء فيها ، وليس لاجنبي عن الاسرة والشركاء ما لم يوافقوا جميعا على التصرف لاجنبي فإن اعترض احدهم فلا يحق له ادخال اجنبي في الاسرة وعليه التصرف لايهم او البقاء في الملكية معهم

لكن هل المقصود بالتصرف بالتصرفات العوضية ، ام العوضية والتبرعية ؟

لم يحدد النص ويظل المطلق على اطلاقه الى ان يرد ما يقيد به ، وان توفي احدهم آلت حصته شائعة لخلفه العام ويلزم بذات القواعد .

بشأن ادارة هذه الاموال وتحقيقا للمصالح المشتركة بينهم لاستمرار الملكية والروابط العائلية فقد اجاز القانون للشركاء الذين يملكون القدر الاكبر من قيمة الحصص ، ان يعينوا من بينهم مدير للمال .

للمدير ان يدخل من التغييرات ما يشاء مادام محققا للمصالح المشتركة وحسن الانتفاع بالمال ويمكن عزل المدير بذات الطريقة المعين بها .

ملكية الشقوق والطبقات

" ملكية وادارة الاجزاء المشتركة في ملكية الشقوق والطبقات "

قسم المشرع نظام ملكية الشقوق والطبقات الى ثلاثة انواع ، ملكية مفرزة و ملكية مشتركة ، و ملكية شائعة شيوعا اجباريا .

١- الملكية المفترزة في الشقوق والطبقات :

تتمثل هذه الملكية في كل شقة او كل طابق من طوابق المبنى ، حيث يملك كل شخص شقته ملكية مفرزة وخالصة بما تحويها من حوائط داخلية وتشطيبات ومنقولات ونوافذ وبلكونات وشبكات داخلية للمياه والغاز والكهرباء والصرف والتكييف والحمامات .

ملكية مفرزة يحق للمالك ان يتصرف فيها كيف يشاء ودون اذن احد مادام لا يعرض سلامه المبنى ولا السكان للخطر ، فيستطيع ان يغير شبكه المياه او الكهرباء او المياه الداخلية او الحمام او المكيفات او لون الحوائط او الديكورات بالشقة كما يلزم بالقيام بالاصلاحات الداخلية لشقته اذا ترتب عليها اضرار للمبنى او لجاره ، كتغيير شبكة السباكة والصرف في الحمام اذا تسربت المياه منها للجار الجاني او السفلى هذا عن الاعمال المادية اما الاعمال القانونية فيستطيع ابرام ما يشاء من تصرفات قانونية على شقته او طابقه فيؤجر للغير او يرهنه او يبيعه او يهبه .

٢- الملكية المشتركة بين مالكي شقتين أو طابقين :

- الاجزاء المشتركة بين الوحدتين المتلاصقتين فى الجوانب او الارتفاعات الرأسية او الاجزاء السفية ، كالحائط الفاصل بين شقتين ، والسقف .
- هذه الاجزاء مشتركة تكون مملوكة لاصحاب هاتين الشقتين وليس كل الشقق او الطوابق فى المبنى وتخضع ادارتها والانتفاع بها لقواعد الشيوخ العادى ، فيحق لكل مالك ان ينتفع بها من ناحيته كما يشاء دون اذن شريكه بشرط الا يضر بالحائط او السقف او يعطل شريكه عن استعماله والانتفاع بها مثله ، وتكون صيانتها مشتركة بينهما .
- يكون التصرف فيها تابعا للتصرف فى المكان ذاته فلا يحق رهنا او بيعها استقلالا عن الشقة .

٣- الاجزاء الشائعة اجباريا فى ملكية الشقق والطبقات :

أ- تحديد الاجزاء الشائعة :

- تشمل اجمالا (ملكية الارض وملكية اجزاء البناء المعدة للاستعمال المشترك بين الجميع) اما على سبيل التفصيل فقد ذكرت منها : (الاساسات والجدران الرئيسية والمداخل والافنية والاسطح والمصاعد والممرات والدهاليز وقواعد الارضيات وكل انواع الانابيب المشتركة) .
- هذه الاجزاء كلها تعد من الاجزاء المشتركة والشائعة شيوعا اجباريا بين ملاك المبنى ، وذلك مالم يوجد اتفاق يخالف ذلك كأن يتملك الطابق الاخير السطح كاملا ، او يتملك الدور الارضى الحديقة الامامية .

ب- عدم قابلية الاجزاء الشائعة اجباريا للقسمة :

- لا يجوز قسمة اى من هذه الاجزاء ، ولا يقبل طلب قسمتها رضائيا او قضائيا فهى شائعة شيوعا اجباريا .
- وان لم يمنع هذا من حق كل مالك فى المبنى من استعمال هذه الاجزاء دون موافقة شركائه بشرط الا يعطل استعمالهم العادى لها .
- لكن لا يجوز له احدث اى تعديلات فى هذه الاجزاء .

- استثناء من ذلك** ← يحق لأى مالك منفردا ان يجرى التعديلات فى الاجزاء المشتركة من المبنى اذا توافرت شروط اربعة فى حقه وهى : ان يكون ذلك على نفقته الخاصة ، وان يكون من شأنها ان تسهل استعمال الاجزاء المشتركة للجميع والا يغير من تخصيصها والا يلحق الضرر بالمالك الاخرين .

ج- عدم جواز التصرف فيها مستقلة :

- يحظر على كل الملاك التصرف فى الاجزاء المشتركة الشائعة اجباريا مستقلة عن الشقة او الطابق الذى تتبعه فلا يجوز مثلا للمالك ان يبيع ما يعادل حقه فى الاسطح ، او المصعد ، بل يلزم ان يكون ذلك مع التصرف فى الاصل ذاته ، فالفرع يتبع الاصل ويأخذ حكمه .
- ايضا لا يجوز ابرام التصرفات الاخرى التى تخرج هذه الاجزاء عن طبيعتها التفافا حول الحظر السابق كأن يرهنها مستقلة او يقايض عليها ، كما لا يجوز للدائنين الحجز عليها مستقلة عن الشقة .

د- نفقات صيانة الاجزاء المشتركة :

- توزيع تكاليف حفظ وصيانة وإدارة الاجزاء المشتركة على اساس تحميل كل مالك عبء فى هذه النفقات يعادل نصيبه فى المبنى .

هـ- ادارة الاجزاء المشتركة (اتحاد الشاغلين) :

- رأى القانون ان حتمية استمرار بقاء الشيوخ الاجباري للأجزاء المشتركة فى المباني والعمارات الموزعة ملكية طوابقها وشققها بين اكثر من مالك تحتم وجود نظام دائم لإدارة والحفاظ على وصيانة هذه الاجزاء ، فأنشأ بين ملاكها هيئة قانونية سماها "اتحاد ملاك الطبقات او شقق البناء الموحد" .
- ظل قيام هذا الاتحاد جوازي فى القانون المدنى حتى جاء القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ والخاص بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فجعله وجوبيا اذا جاوز عدد الطوابق والشقق فى المبنى خمسة ، على ان يكون الغرض منه ادارة الاجزاء المشتركة وحسن الانتفاع بها .
- يتمتع الاتحاد بالشخصية الاعتبارية بالرغم من عدم النص على ذلك حيث ان القانون قرر له ذمة مالية مستقلة ، ويجوز له التقاضى باسمه عن طريق من يمثله .

سلطة اتحاد الملاك :

- يضع بموافقة جميع الاعضاء نظاما لضمان حسن الانتفاع بالعقار المشترك وحسن ادارته ، كأن يضع لائحة تنظيمية يتبعها لضمان حسن انتفاع الاعضاء بالاجزاء المشتركة .

مأمور الاتحاد :

- يكون للاتحاد مأمور يتولى تنفيذ قراراته ويعين هذا المأمور بقرار يصدر من الاتحاد بأغلبية الملاك محسوبة على اساس قيمة الانصبه .
- عن سلطاته عليه اذا اقتضى الحال ان يقوم من تلقاء نفسه بما يلزم لحفظ جميع الاجزاء المشتركة وحراستها وصيانتها وله ان يطالب كل ذي شأن بتنفيذ هذه الالتزامات .
- يمثل المأمور الاتحاد امام القضاء حتى فى مخاصمة الملاك اذا اقتضى الامر وله اجره يتحدد بالقرار الصادر من الاتحاد بتعيينه او بأمر القاضى الصادر بهذا التعيين ويجوز عزل المأمور بقرار من الاتحاد تتوافر فيه الاغلبية او بأمر يصدر من رئيس المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار .
- إن هلك البناء بحريق او بسبب آخر فعلى الشركاء ان يلتزموا من حيث تجديده بما يقرره الاتحاد بالاغلبية يمكن منح احد الاعضاء قرضا من الاتحاد لتمكينه من القيام بالتزاماته ويكون القرض مضمونا بإمتياز على الجزء المفروز الذى يملكه .

تعديل اتحاد الملاك الى اتحاد الشاغلين :

- صدر القانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ بشأن البناء الموحد ، حيث ألزمت المادة ٧٢ اقامة اتحاد للشاغلين للعقارات المبنية والقي لا يقل عدد وحداتها عن خمس وحدات او المجمعات المبنية (سكنية او غير سكنية) مملوكة او بحق الانتفاع او مؤجرة لاشخاص طبيعية او اعتبارية .
- فى حالة التجمعات السكنية المتكاملة من مجاورة او اكثر يلتزم الشاغلون وملاك هذا التجمع بإنشاء شركة او اكثر للإدارة والصيانة ، لها الاختصاصات المقررة لاتحاد الشاغلين .
- يختص اتحاد الشاغلين بالحفاظ على سلامة العقار واجزائه المشتركة وملحقاته وضمان صيانتة وترميمه وتدعيمه والحفاظ على طابعة المعمارى وتوفير الخدمات المطلوبة للعقار .

" ملكية العلو والسفل "

- هذه الملكية تفترض ان لكل مالك منهما ملكية مفروزة تشمل طبقته والاجزاء الملحقة بها ولكل واحد منهما وحده دون غيره سقف طبقته والجدران المحيطة به ، ويكون للعلو على السفلى حق القرار .
- وحق القرار على السفلى حقا عينيا ، حيث انه يرد مباشرة على الشئ ويخول لصاحبه سلطه مباشرة على هذا الشئ
- فقد ألزم القانون صاحب السفلى ان يقوم بأعمال الترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو ، فإذا امتنع عن القيام بهذه الترميمات جاز للقاضى ان يأمر ببيع السفلى ، ويجوز فى كل حال لقاضى الامور المستعجلة ان يأمر بإجراء الترميمات العاجلة .



أولاً: اجب عن الامثلة الآتية

س ١ : وضع الآثار القانونية المترتبة علي القسمة ؟

س ٢ : وضع شروط أعمال نظام إسترداد الحصة الشائعة ؟

س ٣ : عرف الملكية الشائعة مبيناً كيفية إدارة المال الشائع والإنتفاع به ؟

س ٤ : عرف القسمة مبيناً الفرق بين القسمة الرضائية والقسمة القضائية ؟

س ٥ : وضع أنواع القسمة الرضائية مبيناً شروط نقض القسمة الرضائية للغبن الفاحش ؟

س ٦ : وضع النتائج المترتبة علي صدور حكم بالقسمة وهل يجوز نقص القسمة القضائية بالغبن الفاحش ؟

س ٧ : وضع كيف يمكن التصرف في المال الشائع مبيناً حكم تصرف الشريك منفرداً في جزء مفرز من المال الشائع ؟

ثانياً: بين مدي صحة او خطأ العبارات الآتية :

العلامة	السؤال	م
	لكل شريك منفرداً حق الانتفاع بالمال الشائع دون حاجة لإذن سابق من الشركاء	١-
	يعد تصرف الشريك منفرداً في المال الشائع كله تصرفاً في ملك الغير	٢-
	افراز الشريك حصته في المال الشائع دون قسمة رضائية او قضائية لا اثر له	٣-
	تملك الاغلبية في المال الشائع حق التصرف في المال الشائع كله وينفذ في حق الجميع ايا كانت نتيجة القسمة	٤-
	يمنع علي الشريك طلب القسمة اذا كان مجبراً علي الشيوع بنص قانوني او بالاتفاق	٥-
	قسمة المهايأة هي قسمة منفعة ولا تنهي حالة الشيوع	٦-
	تنقلب قسمة المهايأة المكانية من قسمة مؤقتة الي قسمة نهائية بقوة القانون اذا استمرت مدة خمسة عشرة سنة	٧-
	تقتصر دعوي النقص بسبب الغبن علي القسمة الحاصلة بالتراضي	٨-
	تصح القسمة الرضائية بأغلبية من يحوزون ثلاثة ارباع المال الشائع	٩-
	يحسب الغبن في القسمة علي اساس قيمة المال بعد اجراء القسمة	١٠-
	العبرة في تقدير قيمة المال لحساب الغبن هو بقيمته وقت اجراء القسمة	١١-
	تحسب مدة السنة لرفع دعوي الغبن في القسمة من تاريخ اجراء القسمة وهي مدة سقوط لا يرد عليها الوقف والانقطاع	١٢-
	تختص بنظر دعوي القسمة المحكمة الجزئية الواقع في نطاق دائرتها الاموال المطلوب قسمتها	١٣-
	يعتبر المتقاسم مالكا للحصة التي الت اليه منذ ان تملك في الشيوع وانه لم يملك غيرها شيئاً في بقية الحصص	١٤-

اسباب اكتساب الحقوق العينية الاصلية (حق الملكية)

العقد والوصية والميراث

العقد

- يعد العقد من اهم اسباب اكتساب الحقوق العينية الاصلية بصفة عامة وحق الملكية بصفة خاصة
- العقد** ← اتفاق ارادتين على احدث اثر قانونى معين متى كان ممكن وجائز وكان الباعث عليه مصلحة مشروعة .
- يرد العقد كسبب لاكتساب حق الملكية على كل الاموال من العقار والمنقول ولكن المشرع المدنى حرص على النص على كيفية انتقال الملكية فى العقار والمنقول .
- فقرر ان الملكية فى المنقول المعين بنوعه فقط تنتقل للمشتري بعد التعاقد فإن كان المنقول معيناً بذاته ويملكه البائع فإن ملكيته تنتقل بمجرد التعاقد وذلك كشأن التعاقد على شراء سيارة معينة .
- إن تعلق الامر بعقار فلا تنتقل الملكية الا بالتسجيل سواء بالنسبة للمتعاقدين او بالنسبة للغير .

س ١١ : وضع الحالات التي واجهها المشرع للتحايل علي قواعد الميراث في شكل تصرفات صورية؟

الوصية

- الوصية** ← تصرف فى التركة مضاف الى ما بعد الوفاة ، فهي تصرف بإرادة منفرد وان تطلب الامر موافقة الموصى له لتنفيذها بعد وفاة الموصى ، فإن رفض الموصى له تنفيذها فترد على ورثة الموصى .
- الوصية قد تكون بملكية عين معينة او بتقرير حق انتفاع عليها لمصلحة الموصى له او بغيرها ، وفى جميع الاحوال لا تجوز الوصية الا فى حدود ثلث التركة ، بعد اسقاط الديون ، فإذا زادت عن الثلث فلا تنفذ فيما زاد عن الثلث الا بإجازة الورثة ، ويجوز الوصية لوارث او لغير وارث فى القانون المصرى .
- ينظم احكام الوصية القانون رقم ٧١ لسنة ١٩٤٦ بالنسبة للمصريين كافة (مسلمين او غير مسلمين) وهو مأخوذ من الشريعة الاسلامية .
- اقر المشرع فيه الوصية الواجبة** ← وذلك اذا لم يوص الميت لفرع ولده الذى مات فى حياته او مات معه ولو حكما ، بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثا فى تركته لو كان حيا عند موته ، حيث اوجب للفرع فى التركة وصية بقدر هذا النصيب فى حدود الثلث وبشرط ان يكون غير وارث ، والا يكون الميت قد اعطاه بغير عوض عن طريق تصرف اخر قدر ما يجب له .

حماية الورثة من الوصايا المفسدة وتصرفات مورثهم :

- اجاز القانون للشخص ان يتصرف فى تركته المستقبلية استثناء من قاعدة عدم جواز ذلك بتصرفات اقرها لهم ومنها الوصية والوقف . وقد واجه المشرع حالات التحايل على قواعد الميراث فى شكل تصرفات صورية

وقد قرر فى هاتين المادتين حكم حالتين اراد فيهما حماية الورثة :

الحالة الاولى : تصرف المورث فى مرض الموت :

- كل عمل قانونى يصدر من شخص فى مرض الموت ويكون مقصودا به التبرع ، يعتبر تصرفا مضافا الى ما بعد الموت ، وتسرى عليه احكام الوصية ايا كانت التسمية التى تعطى لهذا التصرف .

شروط تصرف المورث في مرض الموت :

🕒 **الشرط الاول : التصرف صادر في مرض الموت** ← حيث يكون الانسان في اضعف حالاته النفسية والبدنية ، خاضعا لتأثير الآخرين فيه والذين يؤثرون على ارادته .

🕒 **التصرف** الصادر من المورث قد يكون بيعا او هبة او اقرارا او ابراء .

🕒 الشق الآخر في هذا الشرط ان يصدر التصرف في **مرض الموت** ، وهو المرض الشديد الذي تعقبه الوفاة حتما ، والذي لا تمر مدة سنة على الشخص بين الاصابة به والوفاة .

🕒 عبء اثبات ان التصرف صدر في مرض الموت على الورثة ، ولهم اثبات ذلك بكل طرق الاثبات .

🕒 **الشرط الثاني : ان يكون التصرف تبرعا** ← وهذا هو الشرط الثاني حيث قصد المورث التبرع بالمحل المتصرف فيه للمتصرف ، وقلما يكون تصرف المريض في مرض بعوض ، حيث لا حاجة به للنقود .

🕒 المقصود هنا ليس التصرفات التبرعية بطبيعتها فحسب بل والتصرفات العوضية التي يكون جوهرها تبرعا ، كعقد بيع مع تسجيل ثمن بخس او ابراء المشتري من الثمن بالتبرع به له ، فإن ثبت ان الثمن تبرعى هكذا خاصة في البيع ، سرت احكام الوصية لا البيع في حق المتصرف اليه مالم يكن الثمن حقيقيا والبيع حقيقى واثبت ذلك المشتري وهذا حقه .

الحالة الثانية : تصرف الشخص لأحد ورثته واحتفاظه بحيازه العين وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته :

🕒 يعتبر هذا التصرف مضافا الى ما بعد الموت وتسرى عليه احكام الوصية مالم يقيم دليل يخالف ذلك " .

🕒 **هنا ايضا لابد من توافر شرطين لانطباق حكم المادة :**

🕒 **الشرط الاول : ان يصدر التصرف لأحد ورثته** ← يجب ان يكون المتصرف اليه احد الورثة للمتصرف ، حيث تظهر هنا نية التحايل على قواعد واحكام الميراث الشرعية بغية زيادة حق المتصرف اليه في التركة .

🕒 **الشرط الثاني : ان يحتفظ المتصرف بحيازه العين وبحقه في الانتفاع بها طيلة حياته** ← حيث واقع الحال ينطبق بعكس المسجل او التصرف المتفق عليه والمدعى به ، حيث احتاط المتصرف لنفسه ، فخشى من غدر المتصرف اليه به فدون في التصرف حقه في الاحتفاظ والانتفاع بالعين المتصرف فيها طوال حياته عضد ذلك بشئ آخر ، حيث ظل حائزا للعين المتصرف فيها .

🕒 بالتالي فالمتصرف احتفظ فعلا بشئين على العين ، حيازتها الفعلية وحقه في الانتفاع بها طوال حياته بأية طريقة كانت .

🕒 ذلك ايا كان شكل التصرف المبرم بين الطرفين بيعا او هبة او غيرهما ، بشرط ان يكون استبقاء الحيازة والانتفاع في يد المتصرف بناء على سند قانوني ملزم المتصرف اليه ، كعقد ايجار او بيع اما الانتفاع الفعلى دون سند فلا يكفي لقيام القرينة القانونية .

الميراث

🕒 " تعيين الورثة وتحديد انصبتهم في الارث وانتقال اموال التركة اليهم تسرى في شأنها احكام الشريعة الاسلامية والقوانين الصادرة بشأنها " .

وجوب شهر حق الارث لنقل الملكية للمورث :

🕒 يجب شهر واقعة الارث لما لها من اهمية بالغة ، اذ هي من اكثر ولكن ليس معنى هذا ان ملكية اعيان التركة لا تنتقل للورثة الا بشهر حق الارث ، بل هي تنتقل اليهم بمجرد واقعة الوفاة للمورث ولكن الوارث اذا تصرف في عقارات التركة قبل شهر حق الارث فلا يجوز شهر تصرفه هذا .

— الالتصاق —

اولا : نعرف وشروط :

يعرف الالتصاق بأنه " اندماج شيئين متميزين عن بعضهما مملوكين لشخصين مختلفين ودون اتفاق بينهما ، بطريقة لا يمكن فصلهما الا بتلف " .
الالتصاق واقعة مادية تؤدي لاكتساب الملكية اذ ان الاندماج بين الشيئين افرز شيئا جديدا لا بد من اسناد ملكيته لاحد مالكين الشيئين .

ولكى يتحقق الالتصاق يجب توافر مجموعة من الشروط هي :

١ - وجود شيئين متميزين :

اذا يفترض الالتصاق وجود شيئين متميزين عن بعضهما البعض قبل الالتصاق لكل منهم وجوده وخصائصه ، فإن كان احد الشيئين تابعا للاصل او غير متميز عنه فلن يستدعى احكام الالتصاق وعلى ذلك فالتحسينات والتزميمات التي يجريها الحائز في ملك غيره لا تعتبر متميزة عن الاصل ، اما الثمار التي تتولد عن الشيء في مواعيد دورية فهي متولدة عن الاصل وتابعة له وكذلك تعد المنتجات جزاءا من الشيء ذاته وليست شيئا مستقلا عنه ، فهذه الملكية ليست جديدة بل تابعة للاصل ومتفرعة عنه ، اما الملكية بناء على احكام الالتصاق فهي جديدة مستقلة عن ملكية الشيء الاصلى .

٢ - ملكية الشيئين لشخصين مختلفين :

مالك الشيء الاول غير مالك الشيء الثاني ، فلو اتحد مالك الشيئين قبل الالتصاق فلا داعى لاحكام الالتصاق هنا ولا ضرورة لذلك ، فالمالك الذي يبني في ارضه يملك البناء اولا بأول بناء على ملكيته للاصل .

ان كان مختلفا فتطبق احكام الالتصاق وهذا شأن تملك صاحب الارض للزيادة عليها بسبب طمى النهر الذي تكون بطريقة تدريجية غير محسوسة ، حيث كان الطمى ملك الدولة وتملكه صاحب الارض بالالتصاق .

٣ - اندماج الشيئين بطريقة لا يمكن فصلهما الا بتلف :

حيث اتحدا الشيئين مع بعضهما ولا يمكن فصلهما مرة ثانية الا بتلفهما او تلف احدهما فلا يمكن نزع المبانى المقامة على ارض الغير الا بهدمها .

إذا امكن فصلهما دون تلف فلا مكان لأحكام الالتصاق فالكنز المدفون فى الارض او فى حائط يمكن فصله عن الارض او الحائط لذا فهو ملك من وضعه أن أثبت ذلك والا فملك صاحب الارض .

٤ - عدم وجود اتفاق بين مالكي الشيئين :

حيث الاتفاق لو وجد لكان هو الواجب التطبيق ، ايا كان مصير الملكية حيث تراضى الطرفان على ذلك ، فنطبق احكام العقد كمصدر للملكية ، فالصانع الذي يتفق مع رب العمل على صنع شيئا له بمواد يحضرها رب العمل واخرى يقدمها الصانع يملك رب العمل الشيء النهائى بناء على عقد المقاولة ، وليس بأحكام الالتصاق .

ثانيا : موقف القانون المدنى :

رأى المشرع فى القانون المدنى اذا ما تحققت تلك الشروط ضرورة اسناد ملكية الشيء كاملا لاحد المالكين ، مع تعويض الآخر .

من منهما يملك الشيء المملوك للآخر ، فقد اختار المشرع مالك الشيء الاصلى ليمتلك الشيء الاخر الذى اندمج به ، واعتبر الارض هى الاصل ما يلحق بها من بناء او غراس (نبات) يعد مندمجا بها .

بشأن المنقولات فلم يستطع ان يضع قاعدة محددة لحكم كل الحالات ، لصعوبة تحديد ما هو الشيء الاصلى وما هو الشيء التابع فترك الامر للمحكمة مرشدا اياها ببعض المعايير .

اولا : صور الانصاف :

- الضم ← حيث يضم الشيء الاول للآخر ويتحد في شيء واحد مع امكان التمييز بينهما ولكن لا يمكن فصلهما الا بتلف كالتصاق قطعه من الماس في خاتم من ذهب .
- المزج او الخلط ← هنا يختلط المنقول بالآخر بالامتزاج مع بعضهما البعض ، كإختلاط السكر او الملح بالماء
- التحويل ← حيث ينتج شيء جديد مختلف عن العناصر الداخلة في تكوينه كخلط الماء بالدقيق بالسكر والسمن وبعض الاضافات الاخرى لتكوين الحلويات .

ثانيا : حكم القانون :

- " اذا التصق منقولين لمالكين مختلفين بحيث لا يمكن فصلهما دون تلف ولم يكن هناك اتفاق بين المالكين قضت المحكمة في الامر مسترشدة بقواعد العدالة ومراعية في ذلك الضرر الذي حدث وحالة الطرفين وحسن نية كل منهما "
- فلم يضع المشرع قاعدة موحدة لاسناد ملكية الشيء الجديد لأحد المالكين ، بل ترك الامر لتقدير المحكمة المختصة بنظر النزاع وان وضع قواعد ارشادية لها هي **قواعد العدالة والضرر الواقع ، وحالة الطرفين وحسن نية كل منهما** .

- لا مانع من الاخذ بالقاعدة التي تقول ان صاحب الشيء الاكثر قيمة يمتلك الشيء الاخر الاقل قيمة ، وحسن النية يمتلك الشيء الاخر لسيئ النية ، وسيئ النية يتحمل بالتعويضات والاضرار التي سببها للطرف الاخر ، واذا كان حالة احدهما لا تسمح له بتملك الشيء الجديد فلا مانع من اسناد الملكية للطرف الآخر مع تعويض الاول .
- قد ترى المحكمة بقاء الشيء ملكا للطرفين على الشيوع ، بنسبة قيمة كلا منهما في المنقول الذي كان يملكه اذا كان ذلك يحقق العدالة بينهما .

" التصاق المنقول بالعقار بعمل الطبيعة (طمي و طرح النهر) "

اولا : انحسار الضرورات العملية للنصوص القانونية :

- قبل اتمام بناء السد العالي على نهر النيل كان النهر يغرق اجزاء من الوادي والدلتا في وقت الفيضان ، وكان يجلب معه كميات هائلة من ذرات الطمي من مباحة يرسها حول ضفافه او في مجراه .
- عاما بعد آخر كان يظهر في مجرى النهر جزرا جديدة وعلى ضفافه مساحات اراضي جديدة ملتصقة بالارض القديمة .
- ايضا توجد في مصر مجموعة من البحيرات في الشمال والوسط تتصل بها فروع النهر والرياحات او فروع الصرف الزراعي وهذه البحيرات قد يقل الماء الوارد اليها من النهر فتجف في بعض اجزائها وتظهر اراضي جديدة ملتصقة بالاراضي القديمة ، وهنا يثار التساؤل عن ملكية تلك الاراضي الجديدة .
- الحقيقة انه بعد بناء السد العالي وترويض النهر انقطع الطمي ولم يعد هناك تطبيقات عملية لاراضي طمي النهر وطرحه ، بل استقرت الاراضي على الضفتين او في المجرى (الجزر) وايه توسعه او زيادة فيها فيكون بفعل الانسان ويشكل اعتداء على النهر المحمي تشريعا من بداية دخوله مصر حتى مصبه في البحر المتوسط .
- ولم يبق الا الاراضي التي ينكشف عنها البحر ، او البحيرات الشمالية ، او بحيره قارون ، والتي يمكن ان تستدعي هذه الاحكام القانونية لحكمها .

ثانيا : الاحكام القانونية :

١ - اراضي طمي النهر :

- " الاراضي التي تتكون من طمي النهر بطريقة تدريجية غير محسوسة بحيث تغلو منسوب مياه النهر في زمن الفيضان العادي " .
- يشترط** فيها **اولا** ان تكون من طمي النهر ، وليس من حجارة وجذوع الاشجار **وثانيا** ان تتكون بطريقة تدريجية غير محسوسة فلا تظهر فجأة ، حيث كونها النهر على مدى سنوات طويلة ، اما ما قد يقوم به بعض الملاك المجاورين للنهر من ردم في مجراه او وضع عوائق من حجارة واخشاب تعوق تدفق مياهه لترسب الطمي وتظهر اراضي فلا ينطبق عليها هذا الحكم ولن تكون ملكا لهم ، بل ملكا للدولة ، كما **يشترط ثالثا** ان تغلو منسوب المياه في زمن الفيضان .

المستشار

﴿ **حكم هذه الاراضى** ﴾ " الارض التى تتكون من طمى يجلبه النهر بطريقة تدريجية غير محسوسة تكون ملكا للملاك المجاورين " اذن فإن ملكية هذه الارض تكون لمالك الارض الاصلية الملتصقة بها ويتملكها مجانا دون دفع اى قيمة لأحد ولا للدولة .

٢- طرح النهر :

﴿ **طرح النهر** ﴾ " الارض التى تظهر فجأة فى مجرى النهر (الجزائر) او على ضفتيه " سواء كانت مقطوعة من ارض اخرى او انكشفت عنها المياه فجأة بعد انحسار الفيضان .

﴿ **حكم هذه الاراضى** ﴾ انها ملك للدولة ملكية خاصة .

﴿ بما انها **ملكية خاصة للدولة ، وليست ملكية عامة** ، فيجوز لها التصرف فيها او تأجيرها ، كما يعوض اصحاب اراضي اكل النهر تعويضا نقديا بما يعادل خمسين مثالا من الضريبة العقارية المفروضة على الحياض الواقع بها أكل النهر .

٣- الاراضى التى ينكشف عنها البحر والبحيرات :

﴿ **البحر المقصود هنا** ﴾ البحر الابيض المتوسط والبحر الاحمر وخليج السويس والعقبة وبما ان الدلتا يحدها شمالا البحر المتوسط ولا توجد اراضى زراعية ملاصقة للبحر الاحمر فلن تظهر تطبيقات فى هذه المناطق ، ولكن يمكن ان تظهر تطبيقات اخرى فيما يخص الاراضى الصحراوية او الرملية .

﴿ الاراضى التى ينكشف عنها البحر ، تكون **ملكا للدولة** ، اما الاراضى التى يغمرها البحر ويستعيد صاحبها بعد طغيان البحر عليها فتظل **ملكا لصاحبها** .

﴿ **البحيرات والبرك** ﴾ فالمقصود بها بحيرات مصر (المنزلة ، البرلس ، ادكو ، البردويل ، البحيرات المرة ، قارون ، بحيرة ناصر امام السد العالى) ، فالاراضى التى تنكشف عنها هذه البحيرات تكون ملكا للدولة ملكية خاصة ، وليس ملكا لملاك الاراضى المجاورة .

س ١٣ : اكتب فى الالتصاق الصناعى موضحاً فروضه وحكم كل فرض ؟

" التصاق المنقول بالعقار بفعل الانسان (الالتصاق الصناعى) "

﴿ هنا يكون التصاق المنقول بالعقار بفعل الانسان ، حيث اقام بناء او غرس نباتات على ارض غيره ، او بمواد مملوكة لغيره ، اما بحسن نية او سوءها فما حكم هذه الفروض ؟

اولا : مالك الارض يملك ما فوقها وما تحته بالم يثبت العكس :

﴿ اقام القانون قرينة مقتضاها ان الارض هى الأساس وما فوقها وما تحته يعد ملكا لصاحب الارض اقامة على نفقته وبعمله ولا حاجة لمالك الارض للتدليل على ذلك فقد اعفاه القانون من عبء الاثبات .

﴿ لكن هذه القرينة ليست مطلقة ، فإن احتج شخص آخر بأنه يملك هذه المنشآت او الغراس (النباتات) بسند قانوني من مالك الارض فعليه عبء الاثبات .

﴿ على ذلك فكل المباني والمنشآت المقامة على الارض فى المزارع او الارض الفضاء او غيرها هى ملك لصاحب الارض ، حيث الفرع يتبع الاصل ، فخطائر الماشية وامكن تشوين المحاصيل والاسمدة ولوازم الزراعة وانايب الرى او الصرف المدفونة فى باطن الارض كلها ملك لصاحب المزرعة .

ثانيا : اقامة مالك الارض منشآت (او غراس) على ارضه مواد مملوكة للغير :

﴿ **الاصل** ﴾ ان مالك الارض يملك توابعها من بناء او غراس ، لذا فمالك الارض يملك هذه المنشآت او النباتات وليس ذلك مجانا ، بل مقابل دفع قيمتها كاملة لصاحبها ، وليس هذا فحسب بل يحكم عليه بالتعويضات فى حال ثبوت الاضرار الاضافية .

﴿ ليس معنى هذا غل يد مالك المواد عن المطالبة بها عينا وليس بقيمتها ، بل له الحق فى ذلك ، حيث يجوز له طلب نزعها على نفقة صاحب الارض ولكن بشرط ان يطلب ذلك خلال مدة عام من علمه بإندمجها فى ارض الغير .

﴿ هذه المدة مدة سقوط لامة تقادم ، فلا يرد عليها الوقف او الانقطاع .

﴿ إذا استحال نزع هذه المواد لتغير طبيعتها ، او كان نزعها يسبب لها ضرر جسيم او لم يطلب مالك المواد نزعها خلال عام ، **فيتملك صاحب الارض هذه المواد المملوكة للغير مع رد قيمتها لمالكها** السابق ، والتعويض ان كان له محل .

﴿ تقدر قيمة هذه المواد وقت اندماجها بالارض لتصبح عقارا بطبيعته .

ثالثاً : صاحب المواد هو الباني في ارض غيره :

هذا الفرض هو الاكثر وقوعاً ، حيث ان الباني في ارض غيره قد يعتقد بحسن نية ان له الحق في اقامة المنشآت ، وقد يبني في ملك غيره متعمداً ذلك مع علمه بعدم رضا الغير بما يحدثه في ملكه من منشآت فيكون سيئ النية .

١ - البناء (او الغراس) على ارض الغير بحسن نية :

يحدث ذلك في حالات عديدة منها ← ان الشخص الباني كان حائزاً للارض بسند قانوني ثم زال هذا السند بأثر رجعي لبطلانه او فسخه ، او كان يعتقد بحسن نية انه يبني في ملكه لعدم وضوح الحدود في القطع المتشابهة الابعاد والمساحة او المخططات العمرانية الجديدة ، فحسن النية معناه انه يعتقد انه له الحق في اقامة المنشآت .

بحكم هذا الفرض سجلته المادة ٩٢٥ بقوله انه :

١- اذا كان من اقام المنشآت المشار اليها في المادة السابقة يعتقد بحسن النية ان له الحق في اقامتها فلا يكون لصاحب الارض ان يطلب الازالة ، وانما يخير بين ان يدفع قيمة المواد واجرة العمل او ان يدفع مبلغاً يساوي ما زاد في ثمن الارض بسبب هذه المنشآت هذا مالم يطلب صاحب المنشآت نزاعها .

٢- الا انه اذا كانت المنشآت قد بلغت حداً من الجسامة يرهق صاحب الارض ان يؤدي ما هو مستحق عنها ، كان له ان يطلب تملك الارض لمن اقام المنشآت نظير تعويض عادل " .

فلا اثر لحسن النية او سوءها على ملكية المبنى والمنشآت المقامة على ارض الغير فهي ملك لصاحب الارض

القاعدة : تملك صاحب الارض للمنشآت بالاتصال :

اذن فإن مصير هذه المنشآت انه يملكها كقاعدة صاحب الارض مقابل دفع احد القيمتين الاتيتين

١ " قيمة المواد واجرة العمل ، او قيمة ما زاد في ثمن الارض بسبب المنشآت " .

الاستثناء على القاعدة : تملك الباني للارض :

أ- حالة ارهاق قيمة المنشآت لصاحب الارض :

اذا كان الاصل تملك صاحب الارض للمنشآت الا انه استثناءاً من ذلك الاصل اجاز القانون ان يطلب صاحب الارض هو فقط تملك الارض لصاحب المنشآت ، مقابل تعويض عادل له عن قيمة ارضه ، وذلك في حالة ما اذا كانت قيمة المنشآت تكون قد بلغت درجة حسيمة على امكانياته المادية بحيث ترهقه ان يرد قيمتها للباني .

ب- حالة التجاوز بحسن نية على قدر ضئيل من ملك الجار :

هذا الفرض يتعلق اذا كان مالك الارض وهو يقيم عليها بناء قد جار بحسن نية على جزء من الارض الملاصقة فأجاز للمحكمة اذا رأت مجازاً لذلك ان تجبر صاحب الارض على ان ينزل لجاره عن ملكه الجزء المشغول بالبناء وذلك في نظير تعويض عادل

بحسب ويشترط لتطبيق هذا الاستثناء مجموعة من الشروط هي :

⊗ الشرط الاول ← ان يكون مالك الارض يبني في ملكه اصلاً وبصفه اساسية ، اي ان البناء والمنشآت مقرر اقامتها على ارض مملوكة له اصلاً .

⊗ الشرط الثاني ← ان يجور الباني على جزء ضئيل من ملك الجار الملاصقة له ، والمقصود هنا ان يكون التجاوز قد جرى على جزء ضئيل من ملك الجار .

⊗ الشرط الثالث ← ان يتم هذا التجاوز بحسن نية من الباني : اذ لم يتعمد تجاوز المبنى حدود املاكه ، وقد يكون لضياع الحدود بين القطعتين او عدم اتضاها وهذه مسألة تقدرها المحكمة المختصة ، والاصل هو حسن النية وعلى من يدعى العكس عبء الاثبات ، فإن قام الدليل على سوء النية لوضوح المعالم تماماً ، او تنبيهه للباني لذلك قبل البناء فلا ينطبق النص .

⊗ الشرط الرابع ← ان يتم هذا التجاوز بحسن نية من الباني : اذ لم يتعمد تجاوز المبنى حدود املاكه ، وقد يكون لضياع الحدود بين القطعتين او عدم اتضاها وهذه مسألة تقدرها المحكمة المختصة ، والاصل هو حسن النية وعلى من يدعى العكس عبء الاثبات ، فإن قام الدليل على سوء النية لوضوح المعالم تماماً ، او تنبيهه للباني لذلك قبل البناء فلا ينطبق النص .

⊗ الشرط الخامس ← ان يتم هذا التجاوز بحسن نية من الباني : اذ لم يتعمد تجاوز المبنى حدود املاكه ، وقد يكون لضياع الحدود بين القطعتين او عدم اتضاها وهذه مسألة تقدرها المحكمة المختصة ، والاصل هو حسن النية وعلى من يدعى العكس عبء الاثبات ، فإن قام الدليل على سوء النية لوضوح المعالم تماماً ، او تنبيهه للباني لذلك قبل البناء فلا ينطبق النص .

⊗ الشرط السادس ← ان يتم هذا التجاوز بحسن نية من الباني : اذ لم يتعمد تجاوز المبنى حدود املاكه ، وقد يكون لضياع الحدود بين القطعتين او عدم اتضاها وهذه مسألة تقدرها المحكمة المختصة ، والاصل هو حسن النية وعلى من يدعى العكس عبء الاثبات ، فإن قام الدليل على سوء النية لوضوح المعالم تماماً ، او تنبيهه للباني لذلك قبل البناء فلا ينطبق النص .

٢- البناء (أو الغراس) على ارض الغير بسوء نية :

يكون **الباني على ارض الغير سيئ النية** عندما يعلم انه يبني على ملك الغير وان الغير لا يوافق على اقامة هذه المنشآت على املاكه ، فإن كان يعتقد في رضا صاحب الارض او كان قد حصل على موافقة مبدئية منه على البناء فلننا بصد سوء نية من الباني .

وكذلك ان كان الباني يعتقد لاسباب معقولة ان الارض ملكه ، حتى ولو طرح بشأنها نزاع امام القضاء فأقام بناء اثناء نظر الدعوى ، فنعتقد انه يظل حسن النية حتى يحسم القضاء النزاع بحكم نهائي ، فحينئذ يعد سيئ النية ان خسر الدعوى واقام البناء بعد صدور الحكم .

حكم هذا الفرض ← فورد في المادة ٩٢٤ مدني فأجاز لمالك الارض ان يطلب **ازالة المنشآت على نفقه من اقامها مع التعويض ان كان له وجه** ، وذلك في ميعاد سنة من اليوم الذي يعلم فيه بإقامه المنشآت او ان يطلب **استبقاء المنشآت مقابل دفع قيمتها مستحقة الازالة** ، او **دفع مبلغ يساوي ما زاد في ثمن الارض** بسبب هذه المنشآت ، كما اجاز لمن اقام المنشآت ان يطلب نزعها ان كان ذلك لا يلحق الارض ضررا .

يتضح مدى المعاملة المتشددة التي اولاهها المشرع للباني سيئ النية ← مراعاة لقصد السيئ وردعا لغيره لكي لا يتعدى بقصد على اراضي غيره ، وبالتالي فإن صاحب الارض يحق له ان :

أ- **يطلب ازالة المنشآت على نفقة من اقامها** ← مع التعويضات عن الاضرار ان وجدت بشرط ان يطلب ذلك خلال مدة سنة تحسب من تاريخ علمه بإقامة هذه المنشآت .

ب- **يطلب استبقاء المنشآت وتملكها بالانصاف** ← وهذا حقه ايضا ، وعليه ان يدفع تعويض للباني ، على ان قيمة التعويض يراعى فيها سوء نية الباني ، فيكون اما قيمتها مستحقة الازالة ، اى باعتبارها انقضاء ليس الا ، واما قيمة مازاد عن ثمن الارض بسبب المنشآت .

حق الباني سيئ النية في طلب نزع المنشآت

للباني سيئ النية طلب نزع ما اقامه من منشآت على ارض الغير **بشرطين اساسيين هما** : الا يلحق بالارض ضررا والا يكون صاحب الارض قد طلب استبقائها .

٣- المباني المرخص في اقامتها من صاحب الارض والمباني المؤقتة :

اذا رخص صاحب الارض بإقامة مباني على ارضه ولكن لم يتفق الطرفان على مصير هذه المباني ومن يملكها في النهاية واي التعويضات يدفعها فإن القانون قد تولى تنظيم هذه العلاقة حيث حرم مالك الارض من طلب ازلتها لأنه وافق على اقامتها من قبل ، والازالة تعد اقرب للجزاء لا يستحقه من لم يخطئ .

بالتالي اجاز للباني ان ينزع هذه المنشآت اذا اراد على ان يعيد الارض لأصلها او يتحمل بالتعويضات عن الاضرار التي تلحق بالارض .

فإن لم يطلب نزعها فيتملكها صاحب الارض وذلك مقابل دفع التعويضات المنصوص عليها للباني حسن النية على ارض الغير .

هو احدى القميتين ← قيمة المواد واجرة العمل ، او ما زاد في ثمن الارض بسبب هذه المنشآت .

امكانية تقسيط التعويضات :

كل التعويضات المنصوص عليها يمكن طلب تقسيطها على دفعات وبجوز للمحكمة ان تقبل هذا الطلب بحسب تقديرها للمسألة .

بشأن المباني المؤقتة المقامة على ملك الغير ، فالمشرع غاير وجه المعاملة فيها ، حيث ان طبيعة المباني مؤقتة وليست دائمة فهي ستنزع من مكانها ان أجلا ام عاجلا ، وبالتالي " فالمنشآت الصغيرة كالاكشاك والحوانيت والمأوى التي تقام على ارض الغير دون ان يكون مقصودا بقاؤها على الدوام تكون ملكا لمن اقامها" .

يستوى في ذلك ان يكون من اقامها حسن النية ام سيئ النية ، ولا يمنع هذا من حق مالك الارض في التعويضات ، ومن طلب ازلتها في اي وقت على نفقه من اقامها .

رابعا : الباني بني في ارض الغير مواد مملوكة لغيرهما

هناك ثلاث علاقات قانونية ← الاولى بين الباني ومالك الارض ، ثم بين الباني ومالك المواد ، ثم بين مالك الارض ومالك المواد .

أ- العلاقة بين الباني ومالك الارض :

افترض القانون ان الباني هنا حسن النية ، حيث اختلط عليه الامر كثيرا اذ قام بالبناء في ملك الغير وبمواد مملوكة لشخص ثالث ، فليس له مصلحة في ذلك فهو غالبا مقاول يحصل على اجره من اقامة المنشآت المتفق عليها .

بالتالي فإن **مالك الارض لا يحق له طلب نزعها بل يملكها تطبيقا للقاعدة العامة** على ان يدفع القيمة المحددة سلفا للباني حسن النية وهي اجرة العمل وقيمة المواد او ما زاد على ثمن الارض بسبب هذه المنشآت .

ان ثبت ان الباني سيئ النية فلمالك الارض ان يدفع له اي القميتين ، قيمة المنشآت مستحقة الازالة او مازاد في قيمة الارض بسبب المنشآت ، والاختيار لمالك الارض .

ب- العلاقة بين الباني وصاحب المواد :

يحق لمالك المواد مطالبة الباني بقيمة المواد المملوكة له والتي استعمالها في اقامة تلك المنشآت على ملك الغير ، فهو الذي حصل على هذه المواد واستعملها وبالتالي هو المسئول امام مالك المواد عن رد قيمتها له ، وتحسب قيمة المواد بحسب قيمتها وقت اقامتها .

ج- العلاقة بين صاحب المواد وصاحب الارض :

لصاحب المواد دعويان في مواجهة صاحب الارض ، الاولى دعوى غير مباشرة والثانية دعوى مباشرة .

الدعوى غير المباشرة ← تطبيقا للقواعد العامة فيجوز للدائن ولو لم يكن حقه مستحق الاداء ان يستعمل بأسم مدينة جميع حقوق هذا المدين ، الا ما كان منها متصلا بشخصه خاصة او غير قابل للحجز .

وبناء عليه فيما ان صاحب المواد دائن للباني اي ان الباني مدين له بقيمة المواد والتعويضات وان الباني دائما لصاحب الارض بقيمة المواد واجرة العمل ، فيحق لصاحب المواد مطالبة صاحب الارض بحقوق مدينة (الباني) لديه كلها ، او بعضها وهذا يفترض ان مالك الارض لم يسلم الباني هذه الحقوق .

اما الدعوى الثانية فهي الدعوى المباشرة ← وبمقتضى الدعوى المباشرة يحق لمالك المواد مطالبة مالك الارض بكل قيمة تلك المواد او بما تبقى في ذمته من قيمتهما ، اذا كان قد سبق ان دفع للباني جزءا من هذه القيمة

ويبرر اعطاء القانون لصاحب المواد هذه الدعوى المباشرة قبل صاحب الارض ان المنفعة التي قدمها صاحب المواد بمواده كانت هي السبب في حق التعويض الذي وجد في ذمه صاحب الارض للباني .

س ٤١ : عرف الشفعة مبيناً طبيعتها ثم اذكر حالاتها وكيفية فسخ التزامها عند تعدد الشفعاء ؟

الشفعة

اولا : تعريف الشفعة والحكمة منها :

١- تعريف الشفعة :

رخصة تجيز في بيع العقار الحلول محل المشتري في الاحوال وبالشروط المنصوص عليها .
بالتالى فهي تقوم على ← مكنه يستطيع بها الشفيع اخذ العقار المبيع رغما عن البائع والمشتري او ايهما وذلك باستصدار حكما قضائيا بالحلول محل المشتري اذ لم يسلم له الامر رضاء ، والشفعة تفترض وجود تصرف قانوني قد وقع فعلا الا وهو البيع وانه انصب على عقار وليس على منقول .

٢- الحكمة من تقريرها :

دفع المضار تطبيقا لمبدأ (لا ضرر ولا ضرار) فالبايع اذا عقد العزم على بيع عقاره فلا مانع لديه من البيع لأي شخص يقدم له اعلى سعر ، فلا ضرر من ان يبيع للشفيع مادام سيدفع ذات السعر ، فإن ابي رضاء ذلك فيمكن اجباره على الامر بحلول الشفيع جبرا محل المشتري .
كما ان الشفيع من حقه ان يدفع ضررا محتملا من شريك اجني او جار لا يعرف عن طباعه او خصاله شيئا وربما يعرف سوء طباعه فيرغب في دفع المضار عن نفسه فيقدم لاختد العقار المبيع بذات السعر .

والشفعة مأخوذة كنظام وسبب لكسب الملكية ، من الفقه الاسلامي فهي ثابتة فيه بالسنة والاجماع فأما السنة فقد رويت احاديث عديدة عن الرسول صلى الله عليه وسلم تثبت حق الشفعة منها (جار الدار أحق بالدار) اما الاجماع فقد اخذ بالشفعة في كل زمان ومكان من غير ان ينكر ذلك الفقهاء المسلمون وافر الشفعة الحنفية والمالكية والشافعية .

قد اقرت المحكمة العليا (الدستورية العليا) دستورية نظام الشفعة واتفاقه مع مبادئ الدستور المصري .

ثانيا : طبيعة حق الشفعة :

الشفعة ليست بحق شخصي ولا بحق عيني ، بل هي سبب لاكتساب ملكية العقار .
والشفعة كسبب لكسب الملكية في العقارات تقوم على واقعة مركبة اقترن فيها الصلة المادية بين العقار المشفوع فيه والعقار المشفوع به ، بتصرف قانوني تمثل في بيع العقار المشفوع فيه ، وبإعلان الشفيع عن رغبته في الاخذ بالشفعة بعد توافر مركز قانوني في حقه يسمح له طلب الشفعة .

الشفعة رخصه تولدت للشفيع ← وهي تخول الشفيع الحق في ان يملك العقار المشفوع فيه بإرادته المنفردة ، فالشفيع ليس له حق الملك ، بل له الحق في ان يملك بعد اعلان رغبته في الاخذ بالشفعة .
الشفعة رخصه متصلة بشخص الشفيع لا يستطيع دائنوه ان يستعملوها نيابة عنه بالدعوى غير المباشرة ، كما يجوز له ان يتنازل عنها صراحة او ضمنا ، قبل ثبوت حقه فيما او بعد ذلك .

ثالثا : تقييد المشرع للشفعة باعتبارها قيدا على حرية التصرف :

إذا كانت الشفعة مقررة لدفع ضرر محتمل قد يلحق بالشفيع من جار أو شريك اجنبي الا انها تمثل في ذات الوقت قيدا على حرية التصرف وحرية التعاقد واختيار المتعاقدين اذ يجبر البائع على التعاقد مع شفيع قد لا يرغب في التعاقد معه بل قد لا يطيق التعامل معه ، كما ان المشتري يجبر على الخروج من علاقة قانونية ارادها واستوفى شروطها فينتزع منه العقار بغير رضاه .

لذا فالشفعة هي قيد استثنائي يجب عدم التوسع فيه ، ثم انه حق ضعيف يجب تقويته بإبداء رغبة جديّة والتدليل على ذلك بإتباع إجراءات محددة وفي وقت قصير حتى لا تتخذ الشفعة زريعة لعرقلة التصرف في العقار وبناء عليه عمد المشرع لتقييد هذا الحق ، واتضح ذلك في الاحكام الآتية :

- ١- منع المشرع الشفعة في بعض البيوع ← كالبيع بين الاقارب والاصهار لدرجة معينة والزوج وكذلك بين ممتلكات وعقارات الدولة او بيع العقار لجعله محل عبادة وبيع العقار بالمزاد العلني .
- ٢- منع المشرع بعض الاشخاص من الاخذ بالشفعة ← كالوقف او القضاء واعوانهم والمحامون من التعامل في العقارات محل النزاع في دائرة عملهم .
- ٣- اذا توافر في المشتري شروط الشفعة فلا يجوز لمن هم في طبقته او ادنى منه طلب الشفعة .
- ٤- يجب ايداع كامل الثمن الحقيقي ← المباع به العقار خزينة المحكمة خلال ثلاثين يوما ، من تاريخ اعلان الرغبة في الاخذ بالشفعة والاسقط الحق في الاخذ بالشفعة .
- ٥- يسقط حق الشفيع ← اذا لم يعلن رغبته في الشفعة خلال ١٥ يوما من تاريخ اذاره رسميا لاعلان رغبته او بعد مرور اربعة اشهر على تسجيل عقد البيع او خلال ١٥ عاما من تاريخ التعاقد .
- ٦- يجوز التنازل عن الحق في الشفعة ← صراحة او ضمنا ، قبل او بعد ثبوت الحق فيها .

" الشفعاء وطبقاتهم "

" حالات الشفعة "

الحالة الاولى : شفعة مالك الرقبة في حق الانتفاع :

الحالة الاولى لما لها من اهمية في جمع شتات السلطات الموزعة على العقار بين مالك رقبة ومالك منفعة ، حيث تفترض ان سلطات المالك على العقار وهي ثلاثة من استعمال واستغلال وتصرف قد توزعت بين شخصين او اكثر لاول سلطة التصرف ويسمى مالك الرقبة ، وللثاني سلطة الاستعمال والاستغلال ويسمى صاحب حق الانتفاع .

ولصاحب حق الانتفاع وهو حق عيني ان ينتفع به شخصيا طوال المدة المتفق عليها ، كما له ان يتصرف في حقه للغير ، كما ينتهي حق الانتفاع حتما بوفاة المنتفع الاصلى .

فإن حدث وتصرف المنتفع في حق الانتفاع للغير فقد فتح المشرع لمالك الرقبة الحق في طلب الشفعة في حق الانتفاع المباع للغير ، فله الاولوية في ضم سلطات المالك على العقار حتى يحسن الانتفاع به واستغلاله .

الحالة الثانية : شفعة الشريك على الشيوع :

للشريك على الشيوع الحق في طلب الشفعة اذا بيع شيء من العقار الشائع لاجنبي . حيث يحق للشريك على الشيوع التصرف (بالبيع) في حصته (كلها او بعضها) شائعة لاجنبي عن الشركاء . للشريك في الشيوع الحق في دفع مضار الاضرار للاشتراك مع اجنبي ، كما ان جمع الملكية الشائعة في يد شخص واحد من الشركاء او تقليل عدد الشركاء في العقار يؤدي لحسن استغلال المال ، ويجنبنا مشاكل الشيوع والقسمة .

مركز

ولكن اذا كان امر طلب الشفعة في بيع حصه شائعة او بعضها لاجنبي مسلما ، فهل بيع حصته مفرزة تعادل نصيب الشريك يفتح باب الاخذ بالشفعة ايضا ؟

ان تصرف الشريك في حصته مفرزة في العقار الشائع قبل القسمة الرضائية او القضائية يعد تصرفا في ملك الغير ، وهو يأخذ حكم بيع ملك الغير في العلاقة مع الشركاء .

بناء عليه فيكفي الشركاء ان يتجاهلوا هذا البيع ولا يعتدوا به ، ولا يحق للمتصرف اليه (المشتري) ان يتدخل معهم في اي قرار بشأن المال الشائع .

بشأن حق الشفعة هل يحق لهم طلب الشفعة في الجزء المفروز المبيع ؟

هذا الحل قد يراه الشركاء في مصلحتهم أي يمكنهم حينئذ الاعتداد بالمبيع في حدود نصيب الشريك ثم طلب الشفعة .

ينبغي عن شروط الأخذ بالشفعة في هذه الحالة فهي كما يأتي :

١- ان يكون الشفيع شريكا على الشيوع وقت البيع :

أي تكون حالة الشيوع مازالت قائمة وقت البيع ومن يطلب الشفعة تثبت له صفة الشريك ، سواء طلب الشفعة جميع الشركاء على الشيوع أو بعضهم أو أحدهم ، أما ان كان الشيوع قد انتهى بالقسمة القضائية أو الرضائية وقت البيع فلا يحق للمتقاسمين طلب الشفعة بناء على هذه الحالة ، بل يمكن طلبها بناء على إحدى الحالات الأخرى ان توافرت في حقه ، وذلك كالجار المالك .

ويحتج بالقسمة الرضائية على الشركاء وان لم تسجل ، ويقع الإفراز بمقتضاها فالتسجيل شرط للاحتجاج بها على الغير وليس بين الشركاء .

ولكن هل يشترط ان يكون الشفيع شريكا في العقار الشائع ذاته ، أم يكفي ان يكون شريكا في بعض اجزائه أو ارتفاعاته (الشريك في الأجزاء المشتركة في ملكية الطبقات المفروزة ، أو الشريك في الحائط المشترك الفاصل ، أو الشريك في حق الارتفاق بالرى أو المرور) .

الحقيقة ان **الرأى الراجح** يميل بحق لاشتراط ان يكون الشفيع شريكا في العقار الشائع ذاته ، بأى نسبه كبرت أم قلت ، ولكن الاشتراك في الحائط الفاصل أو الأجزاء المشتركة في ملكية الشقق والطبقات أو حق المرور والرى وغيرها لا يفتح باب الشفعة هنا ، وان كان يفتح باب الشفعة بناء على حالة الجوار .

٢- ان يباع جزء من العقار الشائع لأجنبي :

فالمشتري أجنبي عن الشركاء وليس واحد منهم ، فإن كان واحدا منهم فلا يحق لأى من الشركاء الآخرين طلب الشفعة .

٣- ان تستمر حالة الشيوع قائمة حتى تمام الأخذ بالشفعة :

فإذا انقطعت الصلة الشائعة بين الشركاء بأن تمت القسمة رضاء أو قضاء اثناء نظر الدعوى انقضى حق الشفعة بناء على هذه الحالة فلم يعد هناك شيوع ، وان كان يمكن ان يطلب الشفعة من جديد متى توافرت في شأنه حالة أخرى كالجار الملاصق .

٤- الا يكون البيع ممن لا تجوز فيه الأخذ بالشفعة :

فالبيع للأقارب لدرجة معينة وبيع المكان لجعله محل عبادة أو للاحقه بمحل عبادة قائم والبيع بالمزاد العلنى كلها بيوع لا يجوز فيها الأخذ بالشفعة سواء ورد على حصص شائعة أو مفروزة .

الحالة الثالثة : شفعة المنتفع في ملكية الرقبة

وهذه هي الحالة الثالثة حيث يثبت حق الشفعة " لصاحب حق الانتفاع اذا بيعت كل الرقبة الملازمة لهذا الحق أو بعضها " ولكن هنا ينصب الأمر على أحقية صاحب حق الانتفاع في الأخذ بالشفعة اذا بيعت ملكية الرقبة كلها أو بعضها .

ويستند المنتفع على ذات الاعتبار التي استند عليها مالك الرقبة فيما سبق عندما شفع في حق الانتفاع ، ألا وهو ضم ماتفرق من سلطات على العقار ، لتتجمع الملكية في يد مالك واحد أو أقل عدد من الشركاء ليحسن الانتفاع بالعقار .

وتطبيقا لذلك ← اذا تفرقت السلطات على العقار بين ملك رقبة واحدة ومالك منفعة واحد وباع مالك الرقبة ملكيته لأجنبي ، حق للمنتفع ان يطالب الشفعة في ملكية الرقبة المباعة كلها الملازمة لحقه .

وينبغي هنا للممارسة المنتفع حقوق الشفيع :

١- ثبوت صفة المنتفع للشفيع واستمرارها حتى تمام الأخذ بالشفعة :

أي ان الشفيع قد ثبت له قانونا حق الانتفاع ايا كان مصدر حقه (عقد ، وصية ، تقادم ، شفعة) اما اذا كان عقد الانتفاع قد انتهت مدته ، أو كان المنتفع الاصلى قد مات فإن حق الشفعة لا يثبت .

٢- ان تباع ملكية الرقبة كلها أو بعضها لأجنبي :

فيتم البيع فعلا لملكية الرقبة ، وليس غيره من التصرفات القانونية أو الوقائع المادية (كال ميراث مثلا) . والمقصود بالأجنبي هنا أى شخص ليس له أى سلطات على ذات العقار ، فلو بيعت بعض ملكية الرقبة للشريك الآخر في ملكية الرقبة ، فلا يجوز للمنتفع طلب الشفعة .

٣- ان يجوز طلب الشفعة في البيع :

❊ فإن كان البيع بين الاقارب لدرجة معينة او تم بالمزاد العلني فلا يجوز طلب الشفعة فيه .

الحالة الرابعة : شفعة الحكر :

❊ يثبت حق الشفعة ، لمالك الرقبة في الحكر اذ بيع حق الحكر ، وللمستحكر اذا بيعت الرقبة .
❊ ولم يعد للحكر ايه فائدة في الوقت الحاضر خاصة بعد ان تحدد نطاقه بالاموال الموقوفه فقط ثم اصدر المشرع عام ١٩٨٢ القانون رقم ٤٣ بتصفية الاحكار على الارض الموقوفة .

الحالة الخامسة : شفعة الجار المالك :

❊ اورد المشرع حالة الجار المالك عندما يشفع في العقار الملاصق له في المرتبة الاخيرة من الحالات .
❊ وقد فرق القانون بين العقارات المبنية والاراضي المعدة للبناء وبين الاراضي غير المعدة للبناء .
❊ وقبل الشروع في دراسة هذه الحالات نوضح ان القانون قصر الشفعة هنا على الجار المالك ، وبما اننا في مجال العقارات فلا تنتقل الملكية الا بالتسجيل في التصرفات القانونية ، وبالتالي فالمشتري للارض بعقد غير مسجل لا يثبت له الحق في الشفعة .
❊ **المقصود بالجار المالك** ← هو الملكية التامة والذي يجمع الشفع فيهما بين حق الرقبة وحق الانتفاع كما تثبت الشفعة لصاحب حق الرقبة عندما يشفع في العقار المبيع الملاصق لملكه ، ولكن لا تثبت لصاحب حق الانتفاع .
❊ ولا يشترط ان تكون الملكية مفرزة ، بل يكفي الشفع ان يكون مالكا ولو على الشيوع حيث حقه ينصب على كل ذرة من ذرات العقار الشائع .
❊ ايضا يجب ان يكون الجار مالكا للعقار المشفوع به وقت بيع العقار الملاصق ، فإذا لم تثبت له الملكية وقتئذ فلا حق له في الشفعة .

اولا : الشفعة في المباني او الاراضي المعدة للبناء (شرط التلاصق فقط) :

❊ اثبت المشرع حق الشفعة للجار المالك في المباني او الاراضي المعدة للبناء بشرط واحد هو التلاصق ، والتلاصق يكون من اي جهة ويكفي ان يكون من جهة واحدة ولاي مسافة مهما قلت ولو لشبر واحد .
❊ تأخذ المباني والاراضي المعدة للبناء حكما واحدا ، فلا يشترط ان تكون العقارات من طبيعة واحدة بل يمكن ان يشفع مالك المباني في المباني او الاراضي المعدة للبناء المجاورة له .
❊ كما انه لا يشترط مساحة معينة او قيمة معينة في العقار المشفوع به .
❊ كما لا يشترط ان تكون التلاصق افقي بل يمكن ان يكون رأسي كما هو الشأن في ملكية الشقق والطبقات المفرزة .
❊ التلاصق يتوافر ولو وجد مسافة او فراغ او ممر او فناء او حديقة ملحقة بالمنزل .
❊ فإن فصل بين العقارات المبنية او الاراضي الفضاء ارضا مملوكة للغير او ممر او شارع عام ، فقد انقطع التلاصق بينهما .
❊ فإذا ثبت ان قطع التلاصق بين العقارين كان تحيلا لملع الجار من طلب الشفعة فيرد التحايل على صاحبه ويبقى التلاصق ، ويحدث هذا عندما يقطع البائع من الارض المبيعة شريطا ضيقا بطول حد الجار ويحتفظ بملكيته له ويخرجه من البيع حتى يفصل بين بقية عقاره المبيع وملكا الجار او يهبه للمشتري .
❊ **والمباني** ← المنشآت المستحدثة بفعل الانسان والتي تكون حيزا مغلقا ، ايا كانت المواد المستخدمة في صنعها (حديد ، اسمنت ، او طوب لبن ، او حديد وزجاج او غيرها) مادام مقصودا بها الدوام واتصلت بالارض اتصال قرار
❊ **اما الاراضي المعدة للبناء** ← التي صدرت لها قرارات تخصيص بالبناء من الجهات الرسمية المختصة ، وغالبا ما تكون داخلية في نطاق المخططات العمرانية .

ثانيا : الشفعة في الاراضي غير المعدة للبناء (الزراعية او غيرها) :

❊ اذا خرجت الارض من عداد الكردونات والمخططات العمرانية المعتمدة فتدخل في نطاق هذه الحالة التي تشمل الاراضي غير المعدة للبناء ، من الاراضي الزراعية والمستصلحة والفضاء والبور .
❊ **وقد قسمها المشرع لحالتين :**

١- التلاصق من جهة واحدة مع وجود حق ارتفاق :

❊ " اذا كان للارض المبيعة حق ارتفاق على ارض الجار ، او كان حق ارتفاق لارض الجار على الارض المبيعة" .
❊ **وهي تفترض شرطين الاول : وجود التصاق ، والثاني : وجود حق ارتفاق .**

أ- الالتصاق :

❊ اتصال ارض الجار بالارض المبيعة من ايه جهة ولاية مسافة ، وهذا يفترض تلاصق الارضين معا حتى ولو وجد بينهما ممر مشترك مملوكا للجار .
❊ قد قضي بأن المصرف الذي يفصل بين جارين لا يعتبر معه التلاصق بين الارضين غير قائم ، الا اذا كان غير مملوك للجارين ، اما اذا كان مشتركا بينهما فالتلاصق قائم .

ب- وجود ارتفاع لأحد الارضين على الارض الاخرى :

فهناك علاقة ارتباط بين الارضين تعزز وتؤكد طلب الجار المالك للشفعة وهو تحمل احد الارضين لحق ارتفاع لمصلحة الارض الاخرى وبالاخذ بالشفعة او القضاء بها يزول حق الارتفاع بإتحاد المالك ، وحق الارتفاع يكتسب الاتفاق او بالحيازة او بتخصيص المالك الاصلى او بالوصية وقد يكون بالمروى او بالمرور او بالصرف .
ومن جهة اخرى فيستوى ان تكون ارض الجار هى المحملة بحق الارتفاع لمصلحة الارض المباعة ، او العكس ان تكون الارض المباعة هى المحملة بحق ارتفاع لمصلحة ارض الجار ، اذ كثيرا بل دوما ما توجد مروى او مسقة خصوصية بجسريها لكل حوض زراعى ، تروى منها جميع الاراضى فى الحوض الزراعى الذى قد تصل مساحته لخمسين فداناً او اكثر ، وغالبا ما تكون المروى محملة على ناحية من الاراضى ، على ان يحمل الممر الملازم لها (جسر ، طريق ، مدق) على جميع الاملاك المقابلة لتوزيع الاعباء المشتركة على الملكيات المتقابلة بالتساوى .

مركز

ولكن يثار التساؤل فى حالة ما اذا كانت الارض المباعة هى المقرر الارتفاع لصالحها ، واراد المشتري التنازل عن حق الارتفاع هذا لى يفوت شروط الحالة على الجار ، وتنازل عن حق الارتفاع فعلا فى عقد البيع او فى اتفاق الحق ، فهل يسقط هذا التنازل حق الجار فى طلب الشفعة ؟

الرأى الذى نعتقد ان التنازل ان كان بغرض تفويت فرصه الجار المالك فى طلب الشفعة فلا يعتد به ، خاصة اذا كان ذلك ملازما للبيع او تاليا له مباشرة ، او بعد اعلان الرغبة فى الشفعة ورفع الدعوى .

٢- التلاصق من جهتين ووصول قيمة ارض الجار لنصف ثمن الارض المباعة على الاقل :

" اذا كانت ارض الجار ملاصقة للارض المباعة من جهتين وتساوى من القيمة نصف ثمن الارض المباعة على الاقل " فالحالة تؤكد ارتباط العقارين ببعضها مع استبعاد الملكيات الصغيرة حتى لا تتخذ ذريعة لتعطيل تداول وانتقال الملكيات الكبيرة بالبيع .

الارتباط هنا من جهتين بين الارضين ← حيث ان التلاصق بينهما من الجهة الشمالية والغربية او الشمالية والشرقية او من الجهة الجنوبية والغربية او الجنوبية والشرقية .

والتلاصق لا يشترط فيه مساحة معينة ، فيكفى لو كان لاقل مسافة ممكنه ولو بشبر واحد .

الشرط الاضافى ← فى هذه الحالة فهو ان تساوى ارض الجار نصف ثمن الارض المباعة على الاقل ويهدف المشرع لاستبعاد الملكيات الصغيره حينما ترغب فى شفعة المساحات الكبيرة .

المقصود هنا قيمة الارض وليس مساحتها فالقيمة السوقية هى المعول عليها حيث قد تكون ارض الجار خصبة وبها زراعات جيدة فيرتفع ثمنها وان صغرت مساحتها ، على عكس الارض المباعة .

الارض المباعة فيعول المشرع على الثمن المذكور فى العقد مالم يثبت الجار انه صوريا ومبالغا فيه لابعاد الشفيع عن الاخذ بالشفعة .

" طبقات الشفعاء وفض التزامهم بينهم "

اولا : طبقات الشفعاء :

قسم المشرع الشفعاء الى خمسة ← واعتد بهذا الترتيب فيما بينهم ،

الطبقة الاولى منحها لملك الرقبة ،

الطبقة الثانية للشريك على الشيوع

الطبقة الثالثة لصاحب حق الانتفاع ،

الطبقة الرابعة لملك الرقبة عندما يشفع فى حق الحكر وللمستحكر عندما يشفع فى حق ملكية الرقبة ،

الطبقة الخامسة والاخيرة فهى للجار المالك ، وهذه الطبقات الخمسة وردت على سبيل الحصر .

ثانيا : التزامهم بين الشفعاء :

اذا بيعت حصة شائعة فى عقار فطلب الشفعة جميع الشركاء المشتاعون فى العقار ، وكذلك طلب الجار او الجيران الملاصقين لهذا العقار ، فمن اولى بالاخذ بالشفعة قبل غيره او لمن تعطى الحصة الشائعة هنا اعتمد المشرع فى ذلك على فرضين قد يثار بشأنهما التزام .

الحالة الاولى : التزام بين شفعاء من طبقات مختلفة :

- اعتمد المشرع على خطته السابقة فى طبقات الشفعاء فتقدم الطبقة الاعلى على ما دونها من الطبقات الاخرى ، فالاولوية لمالك الرقبة اذا شفع فى الانتفاع ، يتلوه الشريك على الشيوخ وفى الفرض المثار سلفا فالشريك على الشيوخ يقدم على الجار المالك وعلى المستحكر .

الحالة الثانية : التزام بين الشفعاء من طبقة واحدة :

- اذا كان التزام بين شفعاء من طبقة واحدة حيث طلب الشفعة فى المبيع (حصة شائعة) اكثر من شريك على الشيوخ .
- اذا تزامم الشفعاء من طبقة واحدة فإستحقاق كل منهما للشفعة يكون على قدر نصيبه " .
- وبالتالى يقسم العقار المبيع على الشفعاء جميعا ، كل بقدر نصيبه فى العقار الشائع** ← فإذا كان احد الشفعاء يملك النصف فى العقار الشائع فله نصف العقار المباع وهكذا ولكن ليس معنى هذا ان الشفيع يقتصر فى طلبه الشفعة على ما يعادل حصته .
- فعلى كل منهم ان يطلب الشفعة فى العقار كاملا ، وان كانت المحكمة ستقضى له بقدر نصيبه .
- ولكن هذا الحل قد لا ينسجم مع حالة الشفعة من اكثر من جار مالك او كان العقار المبيع لا يقبل القسمة .
- الحقيقة ان هذا الحل لن يكون مجديا وربما من الافضل ان نرجع لما كان مستقرا عليه ، فيحق للمحكمة ان تقرر منح العقار المبيع لمن يعود على ملكيته اى عقاره منفعة اكبر من غيره ، وذلك اذا كان فى القسمة ضرر للعقار المبيع او تعذر قسمته .

استثناء : اذا كان المشتري توافرت فى شأنه شروط الشفعة :

- حالة ما اذا كان المشتري قد توافرت فى حقه شروط الشفعة ايضا ، فيفضل المشتري على غيره من الشفعاء ممن هم من ذات طبقته او طبقة ادنى منه ، فإذا كان المشتري قد توافرت فيه الشروط التى كانت تجعله شفيعا بمقتضى نص المادة السابقة فإنه يفضل على الشفعاء الذين هم من طبقته او من طبقة ادنى .
- من هم من طبقة اعلى منه فإنهم يمكن ان يحتجوا عليه بحقهم ويفضلوا عليه حينئذ .

شروط الشفعة

بيع العقار

س ١٥ : لا شفعة الا فى البيوع . وضع ذلك مبيناً البيوع التى لا يجوز فيها الشفعة ؟

اولا : لا شفعة الا فى البيوع :

١ - البيع وحده يفتح باب الشفعة :

- يعرف البيع** ← " عقد بمقتضاه يلتزم البائع بأن ينقل للمشتري ملكية شيء او حق مالى آخر فى مقابل ثمن نقدي " فأى تصرف قانونى يتوفر فى شأنه شروط وخصائص عقد البيع هو الذى يفتح باب الاخذ بالشفعة .
- ترجع الحكمة فى قصر المشرع الشفعة على البيوع فقط** ← دون غيرها من التصرفات القانونية الناقلة للملكية الى ان شخصية المتعاقدين فى البيع ليست محل اعتبار عند التعاقد ، وبناء عليه فالبايع يقبل التعاقد مع من يقدم اعلى ثمن له فى عقاره ، ويستوى عنده ان يكون المشتري (أ) او (ب) من الناس فإذا كان الشفيع سيقدم ذات الثمن فلا ضرر يلحق بالبايع حينئذ ، وبذلك نجب الشفيع ضرر قد يلحقه من وجود اجنبى كشريك فى عقاره او جاره له ، او يجمع ما تفرق من سلطات على العقار فيحسن استغلاله ويقلل المشكلات .

- ايضا لا تثبت الشفعة فى الوقائع المادية المرتبة لأثر قانونى** ← كالوفاة المرتبة للميراث ولا التصرفات الكاشفة للحق كالقسمة والصلح ، ولو وجد بدل نقدي فيهما ، وكذلك لا تثبت فى التصرفات فى التركة المضافة لما بعد الموت (الوصية) او المنجزة (الوقف) .

تجـ ولكن ان ورد البيع على حق الانتفاع ، فهل يفتح باب الاخذ بالشفعة للجار المالك ؟

- المعروف ان بيع حق الانتفاع يفتح باب الاخذ بالشفعة لمالك الرقبة وللشريك على الشيوخ فى حق الانتفاع ، ولكن ما حكم طلب الجار المالك الشفعة فى حق الانتفاع فى العقار المجاور ؟

ذهب بعض الفقه الى عدم جواز ذلك استنادا لعدم التوسع فى شفعه الجوار ، وبأنه لن يكون مالكا للعقار المبيع كاملا بل سيوجد شركاء له فيه فلن تخلص له الملكية .
ولكن محكمة النقض كان لها رأيا آخر ، اذا أجازت له الشفعة فى هذه الحالة .
إذا قرر المشرع الافضلية لمالك الرقبة على باقى الشفعاء عند مزاحمتهم له وفق ما جرى به هذا النص فقد تصور ان يزاحم الشفعاء الآخرين مالك الرقبة فى بيع حق الانتفاع فتكون الافضلية للأخير مؤكدا بذلك ان الشفعة فى حق الانتفاع مقررة لسائر الشفعاء .

٢- شروط البيع المحقق للشفعة :

يشترط فى البيع الذى يفتح باب طلب الشفعة مجموعة من الشروط وهى :

أ- الشرط الاول : ان يكون حقيقيا :

ويعنى ذلك ان يستجمع حقيقه اركان وشروط عقد البيع ، من نقل الملكية للعقار مقابل ثمن نقدي يدفعه فعلا المشتري للبائع .

البيع الصورى ← اما ان كان البيع صوريا بأن استجمع شكلا عناصر واركان عقد البيع ، ولكن كان يخفى فى الحقيقة هبة مستترة مثلا ، او كنا بصدد صورية مطلقة ، حيث لا تعاقد حقيقى مطلقا بل عقد صورى بين الطرفين قصد خروج العقار من ملكية البائع وابعاده عن دائنيه .

ب- فهل تفتح الصورية باب الاخذ بالشفعة ؟

باستدعاء الاحكام العامة للصورية هنا نجد ان من حق غير المتعاقدين ان يبني تصرفاته على ما هو ظاهر امامه ، اذ هو حسن النية فلا يعلم بحقيقة ما يجرى ويفتح له عقد البيع الصورى الحق فى الاخذ بالشفعة **البيع المستتر بالهبة** ← هنا على العكس ما سبق ، هناك بيع حقيقى ورغبة من الطرفين فى تفويت حق الشفيع فى الاخذ بالشفعة فقد ستر عقدهما الحقيقى (البيع) بعقد آخر لا يجوز فيه الشفعة كالهبة . فيجوز هنا للشفيع ان يتمسك بالعقد الحقيقى ، وله اثبات ذلك بكل طرق الاثبات .

الثمن الصورى ← ان اقتضت الصورية على الثمن فى العقد بأن كان مرتفعا جدا بقصد تعجيز الشفيع عن الاخذ بالشفعة ، فيجوز له اثبات صورية الثمن والتحايل بقصد حرمانه من الشفعة ، وله الحق فى اثبات الثمن الحقيقى ، وهو ثمن المثل بكل طرق الاثبات فهو ليس طرفا فى العقد ولا خلفا عاما لأحد الطرفين . ان كان الثمن منخفضا جدا فى العقد ولا يتناسب مع الثمن الحقيقى للمبيع ، وعادة ما يسجل الطرفان ذلك لتخفيض رسوم تسجيل تصرفهما حيث ما تزال مرتفعة فإن للشفيع اذا كان حسن النية ان يتمسك بالثمن الصورى

ب- الشرط الثانى : ان يكون البيع صحيحا تاما :

يقصد بالبيع الصحيح ← ان يكون عقد البيع مستوفيا الاركان من رضاء ومحل وسبب ، وشروط هذه الاركان بحسب كل ركن منها ، وايضا متوافر بشأنه شروط صحة العقد من تمام الاهلية دون عوارض او موانع ، وخلو الارادة من عيوبها الاربعه (غلط-اكراه-تدليس-غبن استغلالي) .
فإن تخلفت ايا من اركان العقد او احد شروط هذه الاركان ، او كان احد المتعاقدين مجنونا او معتوها او عديم الاهلية وقع البيع باطلا مطلقا .

وبناء عليه ← فلا يفتح هذا العقد الباطل مطلقا باب الاخذ بالشفعة لانه معدوم الوجود القانونى فتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ويثار الدفع به فى اى مراحل التقاضى ولو امام محكمة النقض .
اما العقد القابل للابطال ، فهو عقد موجود منتج لآثاره بين طرفيه وفى مواجهة الغير .
وبالتالى فهو يفتح باب الاخذ بالشفعة ، ويتوقف مصيره على مدى استمرار العقد وزوال ما يهدده من ابطال او التمسك بالابطال وعوده المتعاقدين للحالة التى كانوا عليها قبل العقد .

الشفعة فى بيع ملك الغير :

اذا انصب عقد البيع على ملك الغير فهل يفتح باب الشفعة للجار المالك مثلا للعقار المبيع ؟

المعروف ان بيع ملك الغير عقد صحيح منتج لآثاره بين طرفيه ، وان كان غير نافذ فى حق المالك الحقيقى ، ويتوقف مصيره على موقف المالك الحقيقى من العقد فإن اقره صار نافذا فى حقه وفى حق طرفيه .
فإن رفض المالك الحقيقى اقرار العقد فيحق للمشتري طلب ابطاله اذا كان قد وقع فى غلط من امره بإعتقاده انه سيتعامل مع المالك الحقيقى .
فإذا بيع ملك الغير فيحق للشفيع طلب الاخذ بالشفعة اذا توافرت شروطها فى حقه ، فإن اقره المالك الحقيقى وصار نافذا أكمل الشفيع الاجراءات وسار فى الدعوى حتى نهايتها المرضية له .
وان ابطل عقد البيع للغلط ، او انفسخ للاخلال ، انقضى حق الشفيع .

إذا كان البيع بين الطرفين عرفيا أي غير مسجلا طبقا لإجراءات التسجيل بالشهر العقاري فهو بالرغم من صحته وترتيبه لآثاره القانونية بين طرفيه إلا أنه لا ينقل ملكية العقار المبيع لا بالنسبة لطرفيه ولا بالنسبة للغير إلا بالتسجيل .

لكن هذا لا يمنع الشفيع عن المطالبة بحقه في الأخذ بالشفعة أما مسألة نقل الملكية للمشتري فلا تؤثر على حق الشفعة إذ تنتقل الملكية للشفيع بعد الحكم بالشفعة له وتسجيل هذا الحكم .

القول بغير ذلك يعطل حق الشفعة في أصله ، إذ يكفي الطرفان (البائع والمشتري) الاتفاق على عدم تسجيل عقدهما لكي يفوتا فرصة الشفيع في طلب الشفعة .

لذا فالرأي المستقر عليه فقها وقضاء ← هو ثبوت حق الشفيع في طلب الشفعة ولو كان المبيع غير مسجل أما بالنسبة لعقار الشفيع (المشفوع به) فإنه يشترط أن يكون مملوكا له فإن كان قد اشتراه من قبل فيشترط أن يكون عقده هو مسجلا ، حيث لا تنتقل الملكية إلا بالتسجيل له أو بالنسبة للغير .

قد تظهر فائدة التسجيل ، في تفويت حق الشفيع حيث يسقط حقه في طلب الشفعة إذا مرت أربعة أشهر على تسجيل المشتري لعقد البيع .

ج- الشرط الثالث : يجب أن يظل البيع قائما الى حين تمام الأخذ بالشفعة :

الشرط الثالث والآخر يتطلب بقاء البيع قائما حتى تمام الأخذ بالشفعة ، وذلك أن عقد البيع هو الذي يفتح باب الأخذ بالشفعة فاستمراره ضرورة لبقاء الحق قائما ويترتب على ذلك أنه إذا ما تقرر إبطال العقد ، أو وقع باطلا مطلقا فإن البيع يزول بأثر رجعي ويعتبر كأن لم يكن ويزول معه حق الشفيع .

أيضا أن وقع إخلال من أحد الطرفين بالتزاماته العقدية فللطرف الآخر أن يطلب من المحكمة فسخ التعاقد فإن تقرر فسخ عقد البيع انقضى حق الشفيع في الأخذ بالشفعة .

كذلك فإن التقايل (التفاسخ) ينهى العلاقة العقدية بين الطرفين وهو يعني رجوع المتعاقدين معا عن عقدهما .

فإن تقايل البائع والمشتري على عقدهما فهل يؤدي ذلك لانقضاء حق الشفيع في الأخذ بالشفعة .

يُفرق هنا بين التقايل الصادر قبل طلب الأخذ بالشفعة أو بعد هذا الطلب .

الفرض الأول ← يبدو من تطبيق القواعد العامة أن التقايل (قبل طلب الشفعة) ينهى التعاقد وبالتالي فلم يعد هناك عقد بيع قائما حتى تمام الأخذ بالشفعة فينقضي بناء عليه حق الشفيع في المطالبة بالشفعة .

الفرض الثاني ← فإن كان التقايل بعد طلب الأخذ بالشفعة فلا أثر له على حق الشفيع في طلبه الذي يستطيع الاستمرار فيه .

ثانيا : لا شفعة إلا في العقارات :

قصر المشرع الشفعة على العقارات دون المنقولات ← ويرجع ذلك إلى ثبوت العقارات بحيزها حيث لا يمكن

نقلها من مكان لآخر دون تلف ، وفيها يتحقق المعنى والحكمة من الشفعة من جمع ما تفرق من سلطات حق الملكية أو تجنيب الشريك أو الجار الأجنبي تطبيقا لمبدأ لا ضرر ولا ضرار ، وهذا لا ينطبق إلا على العقارات ، أما المنقولات فإنها بطبيعتها تنتقل من مكان لآخر دون تلف ولا تستقر بحيز محدد ويتم تداولها بين أشخاص المجتمع يوميا تقريبا .

والعقارات المقصوده ← في النص القانوني هي العقارات بطبيعتها والتي يجوز فيها الشفعة ، أما العقار بالتخصيص فلا ترد عليها الشفعة استقلالا حيث هي في الأصل من المنقولات وذلك ما لم يشملها بيع العقار كبيع منزل أو شقة بكل مشتملاتها خاصة من العقار بالتخصيص أو بيع مزرعة بكل ما فيها من أجهزة حرث وبذر سماء وقطعان ماشية .

المنقولات بحسب المال ← فإذا بيعت على هذا الأساس فلا يتصور فيها الشفعة ، كمبنى آيل للسقوط وبيع على اعتباره انقضاء لازالته ، وأيضا الأشجار المعدة لقطعها إذا بيعت على أنها أخشاب ، دون الأرض المزروعة فيها ، أما أن شمل البيع الأرض فيمكن وقتئذ طلب الشفعة .

المنقولات بطبيعتها ← وإن كان لا يجوز فيها الأخذ بالشفعة إذا ما بيعت ، إلا أنه يجوز طلب استردادها في حالة ما إذا كان قد تقرر عليها حق الانتفاع استقلالا ، أو كانت على الشيوع بين أكثر من مالك ، فقد أقام المشرع نظاما شبيها بالشفعة فيما يخص المنقولات والمجموع من المال وهو نظام الاسترداد .

ثالثا : البيوع العقارية التي لا يجوز فيها الاخذ بالشفعة :

فهناك ثلاث حالات لا يجوز فيها الاخذ بالشفعة :

الحالة الاولى : البيع بالمزاد العلني :

اذا ما تم البيع للعقار بالمزاد العلني وفقا للاجراءات القانونية المحددة لذلك فلا يجوز طلب الاخذ بالشفعة في هذا البيع ، ويشترط لتحقيق هذه الحالة ضرورة توافر الشروط الآتية :

١- ان يتم البيع بالمزاد :

حيث يتبع في هذا البيع التزايد بين المتقدمين حيث يسقط العطاء المقدم بتقديم عطاء اعلى منه ، وهكذا الى ان يستقر المزاد على عطاء معين لم يقدم عطاء اعلى منه ، فإذا لم يكن البيع قد تم بهذه الطريقة ، بأن كان قد تم بطريق المساومة والمفاوضة بين الاطراف ، او كان قد تم بطريق العطاءات المغلقة فإنه يفتح باب الاخذ بالشفعة .

٢- ان يكون المزاد علنيا :

ويكون المزاد علنيا عندما يكون التزايد والاشتراك فيه لاي شخص يرغب في الشراء اي عاما للجمهور ، ولا تلغى صيغة العمومية ان كان قد اشترط تقديم تأمين معين لدخول المزاد وضمان جديته .
اما ان كان المزاد مقصورا على بعض الاشخاص فقط ، كالتزايد بين الشركاء او الورثة في عقار معين دون غيرهم فهذا المزاد غير العلني يفتح باب الاخذ بالشفعة ، وكذلك اذا تم البيع بطريق المظاريف المغلقة ، فهذا البيع لا تتوافر فيه العلانية .

٣- ان يتم وفقا لاجراءات قانونية :

حيث هي الضمان الحقيقي لأن يخرج المزاد بالشكل الذي يضمن حقوق مالك الشيء والجهة المباعة لصالحه والمتزايدين فإن خولفت تلك الاجراءات او تم البيع بإجراءات اخرى اتفاقية وليست قانونية فلا يمنع ذلك من الاخذ بالشفعة ، كبيع المالك عقاره بيعا حرا بالمزاد العلني دون اتباع الاجراءات القانونية .
ويتضح من استقراء النصوص القانونية توافر هذه الشروط في بيع ممتلكات المدين وفاء لحقوق الدائنين بطريقة المزاد العلني الجبري ، او بيع العقار الشائع بطريقة التصفية وبيع الدولة لاملاكها بالمزاد العلني ، وبيع عقار المفلس وعديم الاهلية والغائب بالمزاد العلني .

الحالة الثانية : البيع لاقارب لدرجة معينة :

رأى القانون ان البيع للاقارب لدرجة معينة غالبا ما يغلب عليه الاعتبارات الشخصية بين الطرفين ، والسماح بالاخذ بالشفعة في هذا البيع يضيع الغرض من ابرامه كإيصال الارحام او مساعدة الاقارب الاولى بالمعروف او الاعتبارات العائلية الاخرى .
ولكن لم يشأ ان يطلق البيع للاقارب نسبا او مصاهرة دون ضوابط ، لذا فقد قيدها القانون بدرجة القرابة الرابعة في البيع للاقارب نسبا ، وللدرجة الثانية للاقارب مصاهرة وبين الزوجين .

على ذلك الفئات التي يمنع في حالة البيع لها الاخذ بالشفعة هي :

- ١- **بيع المالك لفروعه مهما نزلوا او لأصوله مهما علوا** ← فإذا باع الاب او الام عقاره لابنه او ابنته او لابن ابنه او لابن ابنته او لبنت ابنه او لبنت ابنته مهما نزل الفرع فإن الشفعة لا تجوز ، وكذلك الشأن بالنسبة لأصوله ان باع لابوه او جده او لجد جده وان علا ، او باع لأمه او لأم امه وان علت ، او لام ابية (جدته) فإن الشفعة لا تجوز .
- ٢- **اذا كان المشتري ابن او بنت عم البائع (درجة رابعة)** ← او عمه او عمته (الثالثة) او خاله او خالته (الثالثة) او اخيه (الشقيق او غير الشقيق) الدرجة الثانية ، فهذه البيوع لا تفتح باب الاخذ بالشفعة .
- ٣- **قرابة المصاهرة** ← ايضا لا تجوز الشفعة اذا كان المشتري صهرا للبائع للدرجة الثانية ، كأب او ام الزوج او الزوجة (درجة اولى) او اخ او اخت الزوج او الزوجة (درجة ثانية) .
- ٤- **البيع بين الزوجين** ← وكذلك اذا كان البيع قد تم بين الزوجين (من احدهما للآخر) فلا يفتح باب الاخذ بالشفعة مادام كان رباط الزوجية قائم بينهما لحظة البيع ، فإن طلقت الزوجة او تزلزلت بعد ذلك فلا يجوز ايضا الشفعة في البيع لأن العبرة بقيام علاقة الزوجية وقت البيع فقط .

الحالة الثالثة : جعل المبيع محل عبادة او الحاق به :

حيث كان غرض البيع منذ ابرامه ان يخصص العقار لاقامه محل عبادة ، او ان يلحق بمحل عبادة قائما بالفعل .
محل العبادة لم يحدده المشرع ويصلح اطلاق اللفظ على اي مكان مخصص لاقامة شعائر العبادة في الديانات السماوية الثلاثة المعترف بها (اليهودية-المسيحية-الاسلام) اي لاقامة معبد او كنيسة او مسجد ، اما غير ذلك من العبادات غير السماوية فلا يعترف بها ولا يصلح اقامة مكان للممارسة شعائرها ، ويفتح البيع باب الاخذ بالشفعة

يمكن ان يكون البيع للاحاق العقار بمحل عبادة لتوسعه او لاضافة ملاحق له لخدمة اغراض العبادة والاغراض الدينية المخول لدار العبادة تقديمها لجمهور المصلين كدار المناسبات ، صالة طعام ، مكان لصلاة النساء او مكان لقضاء الحاجة والوضوء .
إن كان البيع لغير ذلك فيفتح باب الشفعة حتى وان كانت الفكرة قد طرأت فى ذهن المشتري فيما بعد او كان قد ذكر هذا الغرض صوريا تهربا من حق الشفعة فيجوز اثبات ذلك التحايل بكل طرق الاثبات .

الحالة الرابعة : الحالات المنصوص عليها فى القوانين المختلفة :

توجد بعض النصوص المتناثرة فى القوانين المختلفة لا تجيز الاخذ بالشفعة .
ومن هذه الحالات ما ورد بشأن اموال الدولة الخاصة ، كالأراضى والعقارات الاخرى ، حيث غالبا ما تبيع الدولة هذه الممتلكات لمحدودي الدخل او لصغار المزارعين او شباب الخرجين او المقبلين على الزواج بأثمان زهيدة وعلى اجال بعيدة تحقيقا للبعد الاجتماعى .
ومن ذلك ما ورد فى قانون اصلاح الزراعى حيث لا يجوز الاخذ بالشفعة فى الملكيات الصغيرة الموزعة على مستحقيها .
وكذلك اذا كان من شأن الاخذ بالشفعة فى البيع الذى تم ان تزيد ملكية الشخص الشفيع عن الحد الاقصى المقرر قانونا للفرد فى الاراضى الزراعية ، او للأسرة .

وجود الشفيع

يتطلب الشرط الثانى الاخذ بالشفعة الا وهو وجود شفيع ضرورة توافر شرطين رئيسيين :

الشرط الاول : توافر احد حالات الشفعة :

حيث يتطلب الامر ضرورة توافر احدى الحالات الخمس التى يجوز فيها الاخذ بالشفعة ، ويشترط توافر ايا منها وقت وقوع بيع العقار لا بعد البيع ، وان تبقى هذه الحالة قائمة حتى تمام الاخذ بالشفعة ، فإن توافرت هذه الشروط والحالات فى حق احد فيحق له المطالبة بالاخذ بالشفعة ، سواء أكان من اشخاص القانون العام او اشخاص القانون الخاص ، اما الاهلية ففي حالة عدم توافرها فيحق للنائب القانونى ان يطلب الشفعة نيابة عن عديمى وناقص الاهلية ممن هم تحت ولايتهم .
قد قضى بجواز طلب السفير اخذ الارض المجاورة لدار السفارة بالشفعة تعبيرا عن رغبة حكومته فى ذلك .

الشرط الثانى : الا يكون الشفيع محروما من الاخذ بالشفعة :

نصت القوانين المتفرقة على حرمان بعض الاشخاص من شراء العقارات او بعضها لانفسهم ، ومن هذه الحالات ما يلى

١ - زيادة الحد الاقصى لملكية الاراضى الزراعية والصحراوية :

وضع قانون اصلاح الزراعى وتعديلاته حدا اقصى للملكية الزراعية للفرد خمسون فدانا وللأسرة مائة فدان ، وكذلك وضع قانون الاراضى الصحراوية . حدا اقصى لملكية الفرد ٢٠٠ فدان وللأسرة ٣٠٠ فدان اذا كان الرى بالطرق الحديثه اعتمادا على المياه الجوفية ، فإن كان الرى بالطرق التقليدية الرى السطحى فالحد الاقصى لملكية الفرد مائة فدان ، وللأسرة ١٥٠ فدان ولا تحسب ملكية الاراضى الصحراوية ضمن الحد الاقصى من الاراضى الزراعية ، فإن كان يترتب على الاخذ بالشفعة زيادة الملكية عن الحد الاقصى للملكية فى الاراضى الزراعية او الصحراوية ، فلا يجوز الاخذ بالشفعة .

٢ - حالة النيابة عن الغير :

يحظر على النائب عن غيره بمقتضى اتفاق او نص او امر من السلطات المختصة ان يشتري بنفسه مباشرة او باسم مستعار ولو بطريق المزاد العلنى ، ما نيط ببيعه وكذلك يتمتع عليه الشفعة فيها .

٣ - السماسرة والخبراء :

ايضا لا يجوز للسماسرة او الخبراء ان يشفعوا فى العقارات المعهود اليهم ببيعها او تقدير ثمنها .

٤ - القضاة واعضاء النيابة والمحامون وكتبة المحاكم والمحضرون :

يحظر على كل هؤلاء ان يشتروا بأسمائهم ولا باسم مستعار الحقوق المتنازع فيها ، كلها او بعضها ، وايضا يتمتع عليهم الشفعة فى اى منها .

٥ - الوقف :

يحظر على جهات الوقف ان تأخذ بالشفعة بصفة عامة .

"عدم التنازل عن الشفعة"

- اجاز المشرع التنازل عن الحق فى الاخذ بالشفعة .
- تنازل الشفيع عن الحق فى الاخذ بالشفعة قد يكون صريحا وقد يكون ضمنيا :

١- التنازل الصريح :

- وفيه يصرح من توافر له شروط الاخذ بالشفعة عن تنازله عن هذا الحق ، بعد ابرام عقد البيع او قبل ذلك سواء للبائع او للمشتري او لهما معا .
- ولصحة التنازل** ← يجب ان يكون المتنازل اهلا له ، اى كامل الاهلية ، فإن كان ناقص الاهلية فالتنازل قابل للابطال لمصلحته وبالتالي فالاهلية المطلوبة اهلية التصرف وليس التبرع .
- ايضا يشترط لصحة التنازل** ← الا يكون المتنازل (الشفيع) مضللا فى اى من بيانات المبيع او البيع ، كأن يبلغ بالرغبة فى بيع جزء من العقار وليس جميع العقار فيرفض الاشتراك مع الملاك الاخرين ، او يعلموه بثمن اعلى بكثير من الثمن الحقيقي الذى تم به التعاقد ليعجزوه عن المطالبة بالشفعة .
- فإذا ثبت وقوع تمة غلط او تدليس فيكون التنازل قابلا للابطال لمصلحة الشفيع ويحق له المطالبة بالاخذ بالشفعة
- يضاف الى ما سبق ان تكون ارادة الشفيع حرة ، اى خالية من اى اكراه مادي او معنوي مارسه عليه المتعاقدان او ايهما او شخص من الغير تابع لهما او غير تابع .

٢- التنازل الضمنى :

- قد يصدر عن الشفيع بعض التصرفات او الافعال التى يستخلص منها تنازله الضمنى عن الاخذ بالشفعة ، قبل او بعد البيع .
- فقد يطلب من له حق الشفعة من المشتري ايجار العقار لفترة معينة او رهنه او تقرير حق ارتفاع له عليه او يتقدم شاهدا على عقد البيع للمشتري .
- فكل هذه التصرفات والمواقف يستخلص منها تنازلا ضمنيا من الشفيع عن حقه فى الاخذ بالشفعة ، ويحق لمحكمة الموضوع استخلاص التنازل الضمنى من وقائع الدعوى .

مركز

ولكن هل يمكن ان يحصل الشفيع على مقابل لتنازله عن الاخذ بالشفعة ، سواء طلب هو ذلك ام عرض عليه المقابل ، فإن تم ذلك فهل هذا جائز ، ام ان هذا المقابل يجوز اعادته مطالبته به بإعتباره امرا مخالفا مع صحة التنازل .

- يبدو انه لا مانع من طلب مقابل عن التنازل عن الحق فى الاخذ بالشفعة فهو من الحقوق المالية التى يمكن التصرف فيها ، بالتنازل عنه بمقابل او تبرعا .
- ولكن ذلك قد يفتح الباب على مصريه للاتجار بالعقارات لاشخاص ليس لديهم الرغبة الجدية فى الشفعة ، ونخرج عن الهدف من تقرير الشفعة وهو دفع الضرر المحتمل تطبيقا لمبدأ (لا ضرر ولا ضرار) .
- لذلك فالراى يميل لعدم اتخاذ الشفعة وسيلة للتجارة والاكراء على حساب الغير دون سبب ، وبالتالي يحق للمشتري او البائع طلب استرداد ما دفعه للشفيع ، بعد الاطمئنان على مركزهم القانونى مع صحة التنازل عن الشفعة

"اجراءات الشفعة"

- بعد توافر شروط الاخذ بالشفعة وانهقاد عزم الشفيع على المطالبة بها لابد من اتباع اجراءات محددة ودقيقة ، وتبدأ هذه الاجراءات بإبداء الشفيع رغبته فى الاخذ بالشفعة ، وتسجيل هذه الرغبة ثم رفع الدعوى خلال مدة معينة ، مع ايداع كامل الثمن خزينة المحكمة ، ثم متابعة الدعوى .

مبدأ عدم جواز تجزئة الشفعة :

- المبدأ المتفق عليه حين طلب الشفعة هو عدم جواز طلب الشفعة فى بعض العقار المبيع دون البعض الآخر ، فذلك من شأنه تجزئة الصفقة على المشتري واجباره على تبعض المبيع وربما تفويت الغرض منه ويبدو تطبيق هذا المبدأ سهلا فى الفرض البسيط ، وهو بيع العقار ارض او مبنى .
- اما ان كان المشتري قد اشترى فى صفقة واحدة او اكثر من عقار كمشخص باع منزلا وارض فضاء وارض زراعية ومصنعا مملوكا له ، وتم البيع للمشتري فى صفقة واحدة ، فهل يجوز للشفيع ان يطلب الارض الزراعية فقط بالشفعة ، حيث تتوافر له شروط الشفعة فيها ولا تتوافر فى غيرها من العقارات المباعة ام ان الامر يتعلق بعدم تجزئة الصفقة .

نفرق هنا بين فرضين : الاول : وحدة الغرض من الصفقة ، والثاني : تفرق الغرض :

اولا : الصفقة متفرقة مع وحدة الغرض :

إذا كان المشتري قد أبرم الصفقة المجزأة تحقيقا لغرض واحد يجمعها جميعا ، حيث سيجمع بينهما في مشروع يكمل العقارات بعضها وكان من شأن السماح بالشفعة في بعضها تفويت هذا الغرض فلا يجوز الاخذ بالشفعة في جميع هذه العقارات .

فإذا كان المشتري في المثال السابق سيقوم بتشغيل المصنع على انتاج المزرعة وسيجعلها تابعه له في انتاجه ، وسيخصص الارض الفضاء لخدمة اغراض المصنع من التوسعات والتخزين والصيانة ومنفذ التوزيع ، اما المنزل فسيقوم هو به لقربه من المصنع ، فذلك مشروع متكامل ، ولو كانت العقارات من طبيعة مختلفة ، والسماح بالشفعة في الارض الزراعية يضيع الغرض من الصفقة . وبالتالي لا يجوز الاخذ بالشفعة .

ثانيا : الصفقة متفرقة ولا غرض واحد يجمعها :

هنا انتفت وحدة الغرض في الصفقة المجزأة اصلا ، كمن يريد تصفية اعماله في بلد ما فباع كل ممتلكاته لشخص واحد ، الذي اشترى مزرعة وفيلا في منطقة بعيدة عن الاولى ، وشقة في مدينة ثالثة ، وشالية في مدينة ساحلية ، وقطعة ارض في احدى المدن الجديدة ، ولا يجمع بينهم جميعا اي غرض مشترك . فيحق للشفيع ان يطلب الشفعة في العقار المبيع الذي توافرت في شأنه شروط الاخذ بالشفعة له .

" اعلان الرغبة عن الشفعة وتسجيلها "

اولا : النصوص القانونية :

على من يريد الاخذ بالشفعة ان يعلن رغبته فيها الى كل من البائع والمشتري خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانذار الرسمي الذي يوجهه اليه البائع او المشتري والا سقط حقه ويزاد على تلك المدة ميعاد المسافة اذا اقتضى الامر ذلك .

يشتمل الانذار الرسمي على البيانات الآتية والا كان باطلا :

- بيان العقار الجائز اخذه بالشفعة بيانا كافيا .
- بيان الثمن والمصروفات الرسمية وشروط البيع واسم كل من البائع والمشتري ولقبه وصناعته وموطنه .

ثانيا : اعلان الرغبة قبل انذار الشفيع رسميا :

يحق للشفيع بعد بيع العقار ان يبدي رغبته في الاخذ بالشفعة للبائع وللمشتري او لأيهما ، وذلك في اي وقت مالم يسقط حقه في الاخذ بالشفعة باحدى مسقطات الشفعة . ولم تشترط المادة شكلا معيناً ولا صيغة محددة لاعلان الرغبة ، فبأي صيغة يفهم منها رغبه الشفيع الاكيدة في الاخذ بالشفعة لكن يشترط في الاعلان بالرغبة ان يكون رسميا والا كان باطلا ، اذا فيجب ان يكون الاعلان مكتوبا ورسميا .

ثالثا : وجوب اعلان الشفيع الرغبة خلال ١٥ يوما من تاريخ انذاره رسميا :

إذا كان اختيار وقت الاعلان حقا للشفيع فيحق له الاعلان عن الرغبة في اي وقت مادام حقه في الاخذ بالشفعة قائما لم يسقط ، فإن المشرع قد اعطى المتعاقدين الحق في اجبار الشفيع على اعلان رغبته في الاخذ بالشفعة خلال مدة قصيرة ١٥ يوما والا سقط حقه في الاخذ بالشفعة ويكون ذلك بإنذاره رسميا بضرورة ابدائه رغبته في الشفعة خلال تلك الفترة . وقد اشترط القانون ان يكون الانذار رسميا ، اي ورقة انذار على يد محضر يقوم بإبلاغ الشفيع رسميا بها كما اشترطت المادة ٩٤١ ان يتضمن الانذار بيانات اساسية والا كان باطلا ، هذه البيانات تتعلق بوصف العقار المبيع وصفا نافيا للجهالة . كما يتضمن الانذار بيان الثمن والمصروفات الرسمية ، وشروط البيع واسم البائع والمشتري ولقبه وصناعته او مهنته وموطنه .

رابعا : تسجيل الرغبة في الاخذ بالشفعة ، والاحتجاج به على الغير :

١ - رسمية اعلان الرغبة :

يجب تسجيل اعلان الرغبة في الاخذ بالشفعة ، ولا يكون هذا الاعلان حجة على الغير الا بالتسجيل . ولم يحدد المشرع هنا بيانات محددة يتضمنها الاعلان ، فيجوز ان يشتمل على بيانات عن الشفيع ورغبته في الشفعة في المبيع بأي صيغة .

٢- الاخذ بالشفعة عند تولي البيوع :

لا تغنى رسمية اعلان الرغبة عن ضرورة تسجيله طبقا لقواعد التسجيل بالشهر العقاري للاحتجاج به على الغير ، وبالتالي فإذا اكتسب الغير حقا على المبيع او قرر له المشتري هذا الحق او انتقلت اليه ملكية المبيع فتنجح هذه التصرفات القانونية وغيرها ، آثارها في مواجهة الشفيع اذا ما تمت قبل تسجيل اعلان الرغبة في الاخذ بالشفعة .

فإن سجل الشفيع رغبته هذه فلا يحتج عليه بأى من التصرفات او الوقائع التي تقع او تجرى بعد هذا التسجيل .
اما عن اعادة البيع مرة اخرى لمشتري ثانى او ثالث او رابع ، فقد نصت المادة ٩٣٨ مدنى على انه " اذا اشترى شخص عينا تجوز الشفعة فيها ثم باعها قبل ان تعلن ايه رغبة فى الاخذ بالشفعة او قبل ان يتم تسجيل هذه الرغبة ، فلا يجوز الاخذ بالشفعة الا من المشتري الثانى وبالشروط التي اشترى بها " .
وبالتالى فعند توالى البيوع ، فسيكون التصرف الجديد نافذا فى حق الشفيع اذا ما صدر قبل اعلان الرغبة فى الشفعة رسميا ، او صدر قبل تسجيل هذا الاعلان .

وهذا ما يحدث فى الكثير من البيوع ، حيث يتزقب المشتري موقف الشفيع فإن صرح الشفيع بالرغبة فى الشفعة ولم يعلن ذلك رسميا او لم يسجل الرغبة فيسارع المشتري بإعادة بيع العقار لاحد اصوله او فروع او زوجه او اقاربه نسباً للدرجة الرابعة او مصاهرة للدرجة الثانية ، فيقف حق الشفيع ويتعطل نهائيا ، فالبيع الجديد لا تجوز فيه الشفعة .

ولكن يشترط لتعطيل حق الشفيع ان يكون بيعا حقيقيا وليس صوريا تحايلا على حق الشفيع .

اياداع الثمن

١- ايداع كل الثمن الحقيقى :

يحرص المشرع على المعاملة الجدية للشفيع حين طلبه الشفعة فليست اقاويل مرسله ولا اوراق مقدمه للمحاكم ، فالشفيع لديه الحق فى الاخذ بالشفعة ولديه القدرة المادية على دفع الثمن ، لذا اوجب على الشفيع ايداع كل الثمن الحقيقى خزينة المحكمة ، حتى ولو كان بعض الثمن مؤجلا فى عقد البيع .
والثمن المقصود كما ذكر فى الفقرة هو الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع ، ولا مشكلة ان كان الثمن فى حدود ثمن مثل المبيع ، **ولكن ان كان الثمن مغلا فيه فالى ثمن يجب على الشفيع ان يودعه ؟**

يبدو ان المشرع نص على الثمن الحقيقى ، وليس الثمن المسجل فى العقد ، فيجوز للشفيع ايداع الثمن الحقيقى ، وهو ثمن المثل وعليه ان يثبت بعد ذلك صورية الثمن بكافة طرق الاثبات ، فإن اعيتته السبل وفشل فى اثبات صورية الثمن فلن يستطيع المطالبة بتكملة الثمن ، لأن المشرع اشترط ايداع الثمن كشرط اجرائى فى ميعاد محدد .

والا فضل له ايداع كل الثمن المكتوب وان كان صوريا والا يجازف على ان يقوم بعد ذلك بالتدليل على الصورية لاثبات الثمن الحقيقى ، فإن نجح فيها استرد الفرق ولم يفقد حقه فى الشفعة .

اما ان كان الثمن اقل من الثمن الحقيقى ، فيستطيع الشفيع ايداع هذا الثمن خزينة المحكمة والتمسك به مادام هو حسن النية ، او يعتقد انه الثمن الفعلى فإن نجح المشتري والبائع فى اثبات صورية الثمن فيجوز لهما المطالبة بتكملة الثمن ، ولن يفقد الشفيع حقه فى الاخذ بالشفعة فقد استوفى الشرط الاجرائى فى الميعاد .

فإن اخفى الطرفان حقيقة الثمن من الشفيع ولم تسعفه ايه وسيلة للعلم بالثمن فله ان يودع الثمن الذى يعتقده حقيقيا وهو ثمن المثل وقت البيع .

٢- الايداع خلال ثلاثين يوما :

وهى مدة رأى المشرع كافيا لتدبير الثمن وايداعه ، وتحسب مدة الثلاثين يوما من تاريخ اعلان الرغبة فى الاخذ بالشفعة ، وهى مدة سقوط وليس تقادم ، فلا تقبل الوقف او الانقطاع ، فإن فاتت فقد سقط حق الشفيع فى طلب الشفعة

٣- الايداع فى خزينة المحكمة التى يقع فى دائرتها العقار المطبوع :

والمحكمة التى يجب ايداع فى خزيتها لكامل الثمن الحقيقى هى التى يقع فى دائرة اختصاصها مكانيا العقار المشفوع فيه ، فإن تعددت العقارات التى يجوز فيها الاخذ بالشفعة فيكون الايداع فى خزينة المحكمة التى يقع فى دائرة اختصاصها اكثر العقارات قيمة ، على ان يراعى ان يكون الايداع قبل رفع الدعوى .

فإن تم الايداع فى خزينة محكمة غير مختصة بعد صدور الحكم بعدم الاختصاص والاحالة فإن الشفيع معرض لسقوط حقه .

"رفع الدعوى"

يجب رفع الدعوى خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلان الرغبة فى الاخذ بالشفعة .

١- اطراف الدعوى :

- توجه المطالبة القضائية الى كل من البائع والمشتري معا حيث يجب ان يرفعها الشفيع عليهما معا ، وتوجه اليهم على محال اقامتهم المذكور فى الانذار الرسمى الموجه للشفيع ، او فى عقد البيع .
- والدعوى المرفوعة هى دعوى المطالبة بالاخذ بالشفعة فى العقار المبيع .
- وان وجهت لاحدهما دون الآخر فلن تنتج آثارها .

٢- المحكمة المختصة :

- المحكمة المختصة هى الواقع فى دائرتها العقار المبيع ، او اكثر العقارات قيمة .
- وتختلف العقارات فى القيمة حيث تختص المحكمة الجزئية او الكلية بنظر النزاع بحسب قيمة الدعوى .

٣- امدة الواجب خلالها رفع الدعوى :

- يجب رفع الدعوى خلال الثلاثين يوما من تاريخ اعلان الرغبة فى الاخذ بالشفعة ، الا سترتب على ذلك سقوط الحق فى الاخذ بالشفعة وهى مدة سقوط .
- وقد يفضل الشفيع اتخاذ اجراءات رفع الدعوى مباشرة فى مواجهة المشتري والبائع ولا يلجأ لإعلان الرغبة فى الاخذ بالشفعة رسميا وتسجيله بل يودع الدعوى المحكمة المختصة وتعلن لهما ، وتكون بمثابة اعلان رغبة ورفع دعوى معا فى ذات الوقت ويسارع بتسجيل صحيفة الدعوى بالشهر العقارى حتى يحتج بها على الغير .

"انتقال الحق فى الشفعة ومسقطاتها"

١- انتقال الحق فى الاخذ بالشفعة للخلف العام :

- الشفعة رخصة منحها المشرع للشفيع لاعتبارات معينة يقدرها هو وليس حق مالى يورث وينتقل للخلف العام مطلقا لذلك فإن مات الشفيع بعد البيع وثبت حقه فى الاخذ بالشفعة ولم يعلن عن رغبته فى الاخذ بالشفعة فلا ينتقل هذا الحق للخلف العام .
- اما ان مات الشفيع بعد الأعلان عن رغبته فى الشفعة ، او بعد رفع الدعوى فينتقل الحق فى استكمال الاجراءات للورثة .
- فإن توفى بعد صدور الحكم فقد ثبت الحق لورثتهم ولهم من بعده كتركه وتنصرف اليهم اثار الحكم بالشفعة .

٢- مسقطان الشفعة :

أ- التنازل عن الحق فى الاخذ بالشفعة قبل او بعد البيع ← يجوز التنازل عن الحق فى الاخذ بالشفعة ،

قبل البيع توقيا من المشتري لطلب الشفيع او بعد البيع ويجوز التنازل الضمنى بجانب التنازل الصريح ، ويقع التنازل صحيحا دون مقابل لأن بيع حق الشفعة مقابل بدل لا يقع صحيحا .

ب- فوات مدة ١٥ يوما على انذار الشفيع رسميا ← إذا فوت الشفيع مدة ١٥ يوما على انذاره رسميا ولم

يعلن عن رغبته فى الاخذ بالشفعة بشكل رسمى فيسقط حقه فى الاخذ بالشفعة ، وهى مدة سقوط وليس تقادم فلا تقبل الوقف او الانقطاع .

ج- عدم اتخاذ الاجراءات فى مواعييدها ← يجب على الشفيع ايداع كامل الثمن الحقيقى خزينة المحكمة

الواقع فى دائرتها العقار المبيع خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلان رغبته فى الاخذ بالشفعة ، ورفع دعوى الشفعة على البائع والمشتري فى خلال ذات الفترة امام المحكمة المختصة الواقع فى دائرتها العقار المشفوع فيه ، فإن لم تتم الاجراءات على الوجه المنصوص عليه فيسقط حق الشفيع .

د- فوات مدة اربعة اشهر على تسجيل عقد البيع ← اذا ما سجل المشتري عقد بيعه ، تسجيلا رضائيا او

بعد صدور حكم قضائى لمصلحته بصحة ونفاذ عقد البيع وتسجيل الحكم فإن فوات مدة اربعة اشهر على هذا التسجيل يسقط حق الشفيع فى الاخذ بالشفعة .

- ويرجع ذلك الى ان التسجيل هو اعلان للجميع بملكية المشتري للمبيع وعلى من يرغب فى الشفعة اعلان رغبته فى ذلك حتى تستقر الاوضاع القانونية .

هـ- فوات مدة ١٥ عاما على عقد البيع ← اذا لم ينذر البائع والمشتري ، او ايهما ، الشفيع رسميا بالاخذ

بالشفعة ، ولم يسجل المشتري عقد البيع فيظل للشفيع الحق فى الاخذ بالشفعة حتى سقوط حقه بالتقادم الطويل ، أى مرور مدة ١٥ عاما تحسب من تاريخ انعقاد عقد البيع .

- و. **موت الشفيع** ← يسقط حق الشفعة أيضا اذا مات الشفيع بعد البيع وقبل اعلان الرغبة فى الاخذ بالشفعة ، حيث ان حق الشفعة لا يورث .
- ز. **زوال ملك الشفيع** ← اذا زال ملك الشفيع فى اى مرحله ، قبل تمام الاخذ بالشفعة فيسقط ، حقه فى الشفعة حيث يشترط ان يكون الشفيع مالكا وقت البيع ، وان يظل مالكا حتى تمام الاخذ بالشفعة ولكن زوال الملكية بعد الحكم له بالشفعة لا اثر له على حقه الذى ثبت بالحكم النهائى بالشفعة .

س ١٦ : وضع الآثار المترتبة على الحكم بثبوت الشفعة؟

" آثار الشفعة "

" الشفعة بالتراضى "

- ⦿ اذا تراضى الاطراف على الشفعة فيحل الشفيع محل المشتري ، وذلك بأن يبرم عقدا جديدا مع البائع ، بذات الشروط السابقة او بشروط جديدة ويصبح الشفيع فى هذا العقد الجديد مشتريا له حقوق المشتري وعليه الالتزامات المتفق عليها ويصبح مالكا للعقار المبيع من تاريخ تسجيل عقده .
- ⦿ ويسلم الثمن للبائع وليس للمشتري السابق مالم يتفق على غير ذلك مع حق الاخير فى مطالبة البائع برد الثمن السابق المدفوع له ، ولكن ليس للشفيع ان يلزم البائع بمنحه اجالا او تقسيطا للثمن كما فعل مع المشتري السابق مالم يوافق البائع على ذلك برضائه الحر .
- ⦿ فإن استحق العقار من تحت يده ، لأى سبب فليس له الا الرجوع على البائع له ، فالملتزم بضمان التعرض والاستحقاق هو البائع .

" الشفعة قضائية "

- ⦿ اذا طرح النزاع على المحكمة المختصة فنظرته حتى اصدرت حكما بثبوت الشفعة ، فقد نظم القانون آثار الشفعة فى هذه الحالة :

اولا : ملكية الشفيع نُسند لحكم الشفعة ، ومن دارجة :

- ⦿ نصت المادة ٩٤٤ مدنى على انه " الحكم الذى يصدر نهائيا بثبوت الشفعة يعتبر سندا لملكية الشفيع ، وذلك دون اخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل " .
- ⦿ ويعتبر الحكم الصادر بالشفعة حكما منشئا للملكية وليس مقرر لها فلا تنتقل الملكية للشفيع الا من تاريخ الحكم .

ثانيا : حلول الشفيع محل المشتري (العلاقة بين الشفيع والبائع) :

- ⦿ بصدور الحكم بثبوت الشفعة يحل الشفيع محل المشتري فى كل حقوقه والتزاماته ، فمن ناحية التزامات الشفيع والتي يحل فيها محل المشتري فقد سبق ودفع الثمن وادعه خزينة المحكمة قبل رفع الدعوى ، ويستطيع البائع تسلمه من الخزينة ويلتزم بتسليم العقار المبيع ، ويلتزم البائع برد الثمن للمشتري اذا كان قد قبضه سلفا ، ولا يحق للمشتري مطالبة البائع بأى تعويضات اضافية عن الاخذ بالشفعة فليس هناك خطأ من البائع .

- ⦿ كما ان للشفيع ذات حقوق المشتري من تسلم المبيع اما نقل الملكية فيستطيع تحقيق ذلك بتسجيل منطوق حكم الشفعة النهائى الصادر لصالحه .

- ⦿ ولكن ان استحق المبيع من تحت يده فليس امامه الا البائع وليس له علاقة بالمشتري فى هذا الشأن .
- ⦿ فإن كان الثمن مؤجلا كله او بعضه بالنسبة للمشتري فليس للشفيع ان يجبر البائع على التمتع بهذا الاجل له ايضا

ثالثا : العلاقة بين الشفيع والمشتري :

- ⦿ يحل الشفيع محل المشتري فى كل حقوقه والتزامات تجاه البائع ، هذا فى العلاقة مع البائع اما مع المشتري ذاته فقد يكون قد اقام منشآت او غراس فى العقار المبيع بعد شراؤه العقار مباشرة وقد يكون قد هدم بعض المنشآت المقامة اصلا فى العين او تلفت بإهماله .

- ⦿ هذا فى شأن الافعال المادية اما التصرفات القانونية فقد يباشرها المشتري على العقار المبيع قبل او بعد ابداء الرغبة فى الشفعة .

١- الاعمال العادية :

٢- حكم البناء او الغراس على العقار المبيع :

🌟 **البناء او الغراس قبل اعلان الرغبة** ← اذا بنى المشتري فى العقار المشفوع او غرس فيه اشجارا قبل اعلان الرغبة فى الشفعة كان الشفيع ملزما تبعا لما يختاره المشتري ان يدفع له اما المبلغ الذى انفقته او مقدار ما زاد فى قيمة العقار بسبب البناء او الغراس .

🌟 وعادة ما يختار المشتري القيمة الاعلى ويجبر الشفيع على الوفاء بالقيمة المختارة وذلك احتراماً لحسن نية المشتري .

🌟 **البناء او الغراس بعد اعلان الرغبة** ← المعاملة هنا مغايرة حيث علم المشتري برغبة الشفيع فى الاخذ بالشفعة ولكنها لم تنزل لمستوى البانى سبب النية فى احكام الالتصاق للشفيع ان يطلب الازالة فإذا اختار ان يستبقى البناء او الغراس فلا يلتزم الا بدفع قيمه ادوات البناء واجرة العمل او نفقات الغراس " .

أ- حكم الهدم والاتلاف فى العقار المبيع :

🌟 فإذا كان الهدم او التلف بفعل المشتري او خطأه للشفيع ان يطلب خصم ذلك من الثمن الذى سيتسلمه من خزانة المحكمة ، فإن تسلم الثمن فله الحق فى مطالبته بالتعويض عما اتلفه فإن كان بقوة قاهرة او بسبب اجنبى بصفة عامة فلا يحق للشفيع مطالبة المشتري بشئ .

ب- التصرفات القانونية :

🌟 اعتد المشرع هنا بتاريخ تسجيل اعلان الرغبة فى الاخذ بالشفعة ، حيث نصت المادة ٩٤٧ مدنى على انه " لا يسرى فى حق الشفيع اى رهن رسمى او اى حق اختصاص اخذ ضد المشتري ولا اى بيع صدر من المشتري ولا اى حق عينى رتبه ضده اذا كان كل ذلك قد تم بعد التاريخ الذى سجل فيه اعلان الرغبة فى الشفعة ، ويبقى مع ذلك للدائنين المقيدين ما كان لهم من حقوق الاولوية فيما آل للمشتري من ثمن العقار

🌟 حيث لا ينفذ فى حق الشفيع اى تصرف قانونى صادر من المشتري ومتعلق بالعقار المبيع بعد تسجيل اعلان الرغبة فى الاخذ بالشفعة ، ولا يمنع هذا من حق المتصرف اليه .في مطالبة المشتري برد حقوقه وتكون لهم اولوية فى إستيفاء حقوقهم من الثمن المودع خزانة المحكمة .

🌟 اما ما صدر من المشتري من رهن او بيع او تقرير حق ارتفاق او غيره من التصرفات قبل تسجيل الاعلان بالرغبة فى الاخذ بالشفعة فتنفذ مطلقا فى حق الشفيع ولا يملك الشفيع الا إقرارها .

🌟 وقد قضت محكمة النقض بأنه " العين المشفوعة لا تصير إلي ملك الشفيع في غير حالة التراضي إلا بالحكم النهائي القاضى له بالشفعة مما يستتبع ألا يكون للشفيع حق في ريع هذه العين إلا ابتداء من تاريخ هذا الحكم .

أولاً: اجب عن الاسئلة الآتية

س ١ :وضح لمن يثبت الحق في الشفعة ؟

س ٢ :ما هي شروط البيع المحقق للشفعة ؟

س ٣ : اكتب في مبدأ عدم جواز تجزئة الشفعة ؟

س ٤ :وضح الآثار القانونية المترتبة علي الحكم بثبوت الشفعة ؟

س ٥ :وضح حكم إقامة صاحب المواد منشآت علي أرض مملوكة لغيره ؟

س ٦ :اذكر حالات التحايل علي قواعد الميراث في شكل تصرفات قانونية فورية ؟

س ٧ : اكتب في التنازل عن الحق في الأخذ بالشفعة وهل يجوز التنازل قبل البيع ؟

س ٨ : وضع حكم إقامة مالك الأرض منشآت علي أرضه بمواد مملوكة للغير ؟

س ٩ : هل ينتقل الحق في الأخذ بالشفعة للخلف العام وما هي مسقطات الشفعة ؟

ثانياً: بين مدي صحة او خطأ العبارات الآتية:

العلامة	السؤال	م
	كل عمل قانوني يصدر من شخص في مرض الموت ويكون مقصوداً به التبرع تسري عليه احكام الوصية	-١
	للباني سن النية طلب نزع ما اقامة من منشآت علي ارض الغير حتي اذا طلب صاحب الارض استبقائها	-٢
	الشفعة ليست حق شخصي او حق عيني بل هي سبب لاكتساب ملكية العقار	-٣
	يجوز التنازل عن الحق في الشفعة قبل او بعد ثبوت الحق فيها	-٤
	تثبت الشفعة للشريك في الشيوع في الجزء المفروض المبيع	-٥
	اذا تزامن الشفعاء من طبقة واحدة يقسم العقار عليهم كل بقدر نصيبه	-٦
	تثبت الشفعة في جميع التصرفات القانونية الناقلة للملكية	-٧
	لا تثبت الشفعة في الوقائع المادية المرتبة لاثار قانوني كالوفاة المرتبة للميراث	-٨
	تثبت الشفعة في التصرفات في الشركة المضافة لما بعد الموت كالوصية او المنجزة كالوقف	-٩
	عقد البيع الصوري لا يفتح باب الاخذ بالشفعة	-١٠
	عقد البيع الباطل بطلان مطلق وبطلان نسبي لا يفتح باب الاخذ بالشفعة	-١١
	اذا تقرر ابطال العقد فان البيع يزول باثر رجعي ويعتبر كأن لم يكن ويزول معه حق الشفع	-١٢
	العقارات بالتخصيص يمكن ان يرد عليها الشفعة استقلالاً	-١٣
	يرد حق الشفعة علي الطائرة والسفينة والسيارة	-١٤

الاستيلاء والحيازة

يعتبر كل من الاستيلاء والحيازة مصدرا مستقلا للحق العيني بصفة عامة .
يتفق الاستيلاء مع الحيازة فى انهما وضع يد ، اى السيطرة الفعلية على شئى بنية اكتساب الحق العيني عليه .
ولكن هناك بعض الفروق الجوهرية بينهما والتي حددت بالمشرع للفرقة بين احكام كلا منهما ، حيث ان :

- ١- **الاستيلاء** يرد على المنقولات فقط ، اما **الحيازة** فتد على المنقولات والعقارات .
 - ٢- **الاستيلاء** يرد على المنقولات التى لا مالك لها ، اما **الحيازة** فتد على منقول او عقار مملوك للغير .
 - ٣- **الاستيلاء** يكسب حق الملكية على المنقول فقط ، اما **الحيازة** فتكسب كل الحقوق العينية على الشئى .
 - ٤- **الاستيلاء** يكسب الملكية فورا على المنقول المباح ولا يحتاج لمرور فترة من الزمن لكسب الملكية .
- الحيازة** فتحتاج الى ما يدعها من مرور فترة زمنية لتصلح سببا لاكتساب الحق العيني (التقادم المكسب) .

الاستيلاء تعريف الاستيلاء ونطاقه

اولا : تعريف الاستيلاء :

يعرف الاستيلاء بأنه "وضع اليد على منقول مادي لا مالك له بنية تملكه" فهو قائم على الحيازة اى وضع اليد (الركن المادي) وتتمثل فى السيطرة الفعلية على الشئى بحسب طبيعته ، بالاضافة للركن المعنوى وهو (النية) .

ثانيا : نطاق الاستيلاء :

اما عن مجال او نطاق الاستيلاء فيرد على المنقولات والعقارات وعلى المنقولات المادية بالذات .
فالعقارات بصفة عامة لا بد لها من مالك ، والا فالدولة مالكةا حيث تملك الدولة كل الاراضى الصحراوية او غير المزروعة بصفة عامة ولا يجوز وضع اليد (الحيازة) على اراضى الدولة مالم يحصل الامر بترخيص منها طبقا للشروط القانونية .
والمنقولات التى يرد عليها الاستيلاء هى المنقولات المادية وهى التى يمكن السيطرة عليها ، اما المنقولات المعنوية (كحق المؤلف وبراءات الاختراع والعلامات التجارية والاوراق التجارية) فلا يرد عليها الاستيلاء حيث لا تخضع للحيازة او السيطرة المادية عليها .
وكذلك الشأن فى المجموعات التى تجمع بين الجانب المادي والجانب الادبى من مجموعات الاموال كالتركات والمحال التجارية ، فلا تخضع هى الاخرى للاستيلاء .
والاستيلاء احد اسباب كسب الملكية على المنقولات التى لا مالك لها .

شروط الاستيلاء

الشرط الاول : الحيازة :

تعنى الحيازة السيطرة المادية على الشئى ، بنية التملك وهى تعتمد على وجود ركنين ،

الركن الاول : مادي وهو السيطرة المادية ،

الركن الثانى : معنوى وهو النية .

السيطرة فتكون فى المنقول بحيازته ووضعه فى حرز او مكان تابع للحائز .

فاذا وضع الصياد شبأكه فى الماء ودخلها بعض السمك فيصير السمك حكما فى حيازة مالك الشبكة ، وان لم يستخرجه بعد منها وكذلك من حفر حفرة لاحد الحيوانات البرية فوقع فيها و نصب له فخا فأتطبق عليه او صاد طائرا ببندقيته فوقع بعيدا عنه ، فيصبح فى حيازة الصياد .

فيشترط اذن ان تكون اداة الحائز جعلت الشئى غير ممتنع عنه بالفرار ، وان لم يقبضه فعلا .

الركن المعنوى فيتلخص فى نية التملك والتى تظهر من خلال افعال الحائز ذاته ، فقد يلقي الصياد بالشئى مرة اخرى فى الماء او يترك الحائز الشئى مكانه بعد ان امسك به وتفحصه .

هذه مظاهر تدل على انتفاء نيته فى حيازة الشيء وتملكه .
إن قبضه وعمل على تحسينه او تجميله او رعايته ، كفصل الملابس وكيها او تنظيف الحيوان واطعامه او الاعتناء والرعاية بالطائر الاسير ، فتدل هذه الافعال على توافر النية للملك .

الشرط الثانى : المنقول لا مالك له :

ويكون المنقول لا مالك له اما لأنه من الاشياء المشتركة والمباحة للكافة واما لأن مالكة تنازل عنه بإرادته :

١- المنقولات المشتركة (المباحة) :

غير المملوك لاحد بعينه بل مباحه للكافة ، يشترك كل الناس فى الانتفاع بها على السواء ، وذلك كالهواء ومصادر المياه العامة العذبة او المالحة واشعة الشمس والاسماك فى المياه العامة والطيور البرية
هذه الاشياء مملوكة للكافة على السواء ، يحق لكل فرد الانتفاع بها وتملكها فى اى وقت ودون اذن ، ما لم يعطل حق الآخرين او ينظم الاستخدام من السلطات العامة فقد تنظم الدولة الصيد الجائر للحيوانات البرية حتى لا تنقرض بعض الاصناف او للكائنات البحرية .

٢- حكم خاص بالحيوانات غير الليفة :

وضع المشرع حكما خاصا بالحيوانات كما يلى " وتعتبر الحيوانات غير الليفة لا مالك لها مادامت طليقة ، واذا اعتقل حيوان منها ثم اطلق عاد لا مالك له اذا لم يتبعه المالك فورا او اذا كف عن تتبعه ، وما روض من الحيوانات والف الرجوع الى المكان المخصص له ثم فقد هذه العادة يرجع لا مالك له " .

وواضح من تلك الصياغة ان المشرع يفرق بين الحيوانات الليفة وبين الحيوانات غير الليفة :

فالحوانات الليفة ← حيوانات المزرعة من البقر والجاموس والابل والغنم والخيول والحمام وغيرها ، دائما ما يكون لها صاحب ، واذا ضلت او فقدت من صاحبها فله حق تتبعها ، ومن يجده عليه اتباع احكام اللقطة ، حيث يجب ابلاغ الشرطة خلال ثلاثة ايام فى المدن وثمانية ايام فى القرى ، وعليه ان يعلن عنها ، اما ان احتفظ بها بنية تملكها فيأخذ حكم السارق .

الحيوانات غير الليفة ← فالاصل ان لا مالك لها ، بل هى من الاشياء المباحة مادامت طليقة فى بيئتها الطبيعية فإن استطاع شخص حيازتها فيصير مالكا لها كاصطياد غزال او ضب او اسد او نمر او صقر او احد طيور الزينة ، ويحق له التصرف فيها كيفما يشاء .
فإن استطاع الحيوان او الطائر او الكائن البحرى الافلات من حيازة الشخص فيعود طليقا ومباحا للكافة ، وذلك ما لم يكتشف صاحبة هروبه فيتعقبه فورا ويبحث عنه فإن وجدته استرده .

٣- المنقولات المتخلى عنها مالكة بإرادته :

وهى الاشياء التى سبق لاحد تملكها ثم بعد فترة طالت ام قصرت رغب مالكةا فى تركها والتخلى عنها بإرادته ، وحينئذ يمكن لاي شخص ان يملكها بالاستيلاء لأنها صارت لا مالك لها .
" يصبح المنقول لا مالك له اذا تخلى عنه مالكة بقصد النزول عن ملكيته " .

ويقصد بالتخلى عن الملكية ← تنازل الشخص نهائيا عن ملكيه الشيء اى انصراف نيته للترك ، وتظهر النية فى الظروف المحيطة بالمسألة كترك الشيء فى اماكن القاء القمامة او قريبا منها او فى الطريق .
ولكن اذا لم تنصرف النية للتخلى فلا يصبح الشيء بدون مالك فمن وقعت منه ساعة اليد او تليفونه المحمول او قطعة حلى ذهبية فى كيس قمامه او بجواره ، فيظل مالكة ، حيث لم يتخلى عنها بإرادته ، بل فقدت منه .

اثر توافر شروط الاستيلاء :

اذا توافرت شروط الاستيلاء من الحيازة على منقول لا مالك له بنيه تملكه صار الحائز مالكا لما استولى عليه ، ومن تاريخ وضع يده عليه ، وله التمتع بكل سلطات المالك فى الاستعمال والاستغلال والتصرف .

١- الكنز:

الكنز "هو الاشياء الثمينة التي خبأها يد الانسان في شيء آخر" فهو موضوع في حرزه بيد بشرية ، خبأته عن اعين الناس عامدة ذلك ، ويتكون من اشياء ثمينة القيمة ايا كان نوعها ، ويختلف في طبيعته عن الارض او البناء المخفي فيه .

حكمه

- ١- الكنز المدفون او المخبوء الذي لا يستطيع احد ان يثبت ملكيته له ، يكون لمالك العقار الذي وجد فيه الكنز او لمالك رقبته .
- ٢- والكنز الذي يعثر عليه في عين موقوفه يكون ملكا خالصا للواقف ولورثته .
- فالكنز ليس ملك لمن وجده او حازه باعتباره منقولا لا مالك له ، وبناء عليه فالاصل ان الكنز هو مالك من وضعه في مخبأه ، لا ينازعه احد في ذلك متى اقام الدليل القاطع على ملكيته له .
- فإن لم يستطع ان يدلل على ملكيته للكنز وهذا ما سيحدث في اغلب الاحوال لفوات مدة طويلة على وضعه او عدم وجود ادله قاطعة على الملكية ، فهو ملك لمالك العقار الذي وجد فيه الكنز .
- فاذا انفصلت ملكيته عن ملكية المنفعة في العقار الذي وجد فيه الكنز ، كانت ملكيته لمالك الرقبة .
- فإن كان العقار الذي وجد الكنز مخبأ فيه موقوفا ، اي ملكا لجهات الوقف فالكنز يكون ملكا لا لجهة الوقف بل للشخص الواقف ذاته .
- وفي الحقيقة فإن اهمال المشرع جانب مكتشف الكنز كليه ، واختصاص مالك العقار بالكنز كليه فيه اجحاف بحقوق مكتشف الكنز .

٢- حكم اللقطة:

- اللقطة هي "الاشياء الضائعة والتي خرجت من حيازة صاحبها دون ارادته" وذلك كالامتعة والحقائب وبعض الملابس التي ينساها اصحابها في وسائل النقل العام او تفقد منهم في اي مكان ، فهي منقولات ذات قيمة ، فقدت من صاحبها دون ارادته فإذا وجدها شخصا اخر فما حكمها .
- لا تسري قواعد الاستيلاء على الاشياء المفقودة او الضائعة بل تظل ملكا لصاحبها حيث لم يتخلى عنها بإرادته بل دون ارادته او رغما عنه ، فهي ليست ملكا لمن وجدها وحازها بل ان القانون اوجب على من وجدها ان يبلغ بأوصافها الشرطة خلال ثلاثة ايام في المدن وثمانية ايام في القرى (للعمد) وله الحق في الحصول على مكافأة ١٠% من قيمة الشيء .
- فإن احتفظ بها بنية تملكها عد في حكم السارق لها وتطبق عليه عقوبة السارق .

٣- الصيد:

- امتهن كثير من الناس اعمال الصيد البري والبحري لضآله التكلفة وكبر العائد وقد اثر ذلك بشكل كبير على الحيوانات والطيور والكائنات الحية البحرية ، فعرض بعضها للانقراض .
- لذلك عمدت الدولة بصفة عامة لوضع قوانين تنظيم الصيد بكافة انواعه بقوانين خاصة فقيدته في مناطق واباحته في الاخرى ، وخطرت في مناطق ومحرمات فطبق احكام الاستيلاء على الصيد ايا كان نوعه ، متى كان مرخصا به وفي اطار ما هو مسموحا به .

٤- الآثار:

- تحوز مصر ثلث آثار العالم او اكثر وهي عرضه لمطامع الكثيرين لذلك عمد المشرع لتنظيم وضع الآثار ، حيث يعتبر أثرا كل ما ابدعته الحضارات الانسانية السابقة من مباني ومسلات ومنقولات وتماثيل وحلى وتوابيت وغيرها "فكل عقار عقار او منقول اظهرته او احدثته الفنون والعلوم والاداب والاديان والاخلاق وغيرها في عصر ما قبل التاريخ وفي العصور التالية الى نهاية عصر اسماعيل" .
- ويعتبر المكان او المبنى أثرا اذا مر عليه مائة عام وتمتع بفن معماري وهندسي يدخله في عداد الآثار ، والاثار ايا كان نوعه او تاريخه يعتبر ملكا للدولة ملكية عامة ، ولا يجوز لأحد تملكه بالاستيلاء او الشراء او خلافه ومحظور التعامل عليه قانونا ، ويخضع المخالف للعقوبات الجنائية المغلظة .

٥- المعادن:

- المعادن هي "ما يوجد في باطن الارض من اصل الخلقة والطبيعة ، كالحديد والنحاس والذهب والفضة والبتترول والغاز" .
- وتشتهر مناطق معينة في العالم بالثروات المعدنية ، وتعتمد الدولة في ميزانيتها على بيع هذه الثروات وتوجيه العوائد النقدية للتنمية الداخلية .
- لذلك تعد المعادن من المصادر السيادية للدخل القومي ، وتعتبر ملكا للدولة في اغلب الدول (ملكية خاصة) .

اهمية دور الحياة فى الحياة القانونية :

تقوم الحياة بدور هام فى الحياة القانونية فالسيطرة على الشيء بما يتفق مع طبيعته ، والتي تتسم بالهدوء والاستقرار والعلائية والوضوح ، هو وضع ومركز قانونى للحائز يحميه القانون فى حد ذاته ، بصرف النظر عن سند الحائز فى حيازته اما من يدعى بعدم احقية الحائز فيما يحوز فعليه عبء الاثبات لما يدعيه .

ولكن لا يمكن غضب الحياة او الاستيلاء عليها كرها بالقوة من الحائز . وبجانب ذلك ، **تعطى الحياة مركز الافضية للحائز فى اثبات ملكيته لما يحوز** او لاكتسابه الحق العيني الاصلى عليه ، فالحياة قرينة قانونية على الملكية ، تصلح وحدها كسب قانونى لاكتساب الملكية ، ولهذه القرينة والوسيلة فائدة عظيمة عند المنازعة فى الملكية ، اذ قد يكون الحائز قد اشترى العقار بعقد عرفى (غير مسجل) معتمدا على ضمير البائع واحترامه لتعهداته ، او لعدم قدرته على دفع مصروفات التسجيل .

فى هذه الحالات تتدخل الحياة كسبب لاكتساب الحق العيني ، خاصة حق الملكية كطوق نجاه للمالك ، حيث يمكنه ان يستند اليها وحدها كسبب للملكية . وليست الحياة كسبب لاكتساب الملكية لا تصادف حقائق على الارض فالمالك الذى يسلم ملكه لشخص اخر فترة طويلة من الزمن تصل الى خمسة عشرة عاما دون ان يحرك ساكنا فى مواجهته ، ولم يطالبه قضائيا باسترداد ملكه ، ولم يحصل منه على اقرار ، قضائى او غير قضائى ، يؤكد حقه فى العقار **فذلك** يفسر على احد احتمالين

الاحتمال الاول : وهو الراجح ان المالك قد تنازل عن ملكيته للحائز بمقابل (باع بثمن) او بدون مقابل (هبه) وان ذمة الحائز قد برئت فى مواجهته منذ زمن طويل .

الاحتمال الثانى انه مهمل فى ملكه وهذا فرض نادر ولا يهتم بأمر عقاره ، فيستحق جزاء اهماله وقد يتصادم ذلك مع الشعور الاجتماعى ، حيث يسمح للغاصب بتملك شيئا ملكا لغيره دون وجه حق . ولكن الحقيقة ان هذا فرض نادر الوقوع فأغلب الحالات يستند فيها الحائز على سند مشروع لما يحوزه ، ولكن لم يفلح فى التدليل عليه لفقده او سرقة ، او لوفاة المتعاقدين الاصيلين على العقار وعدم وجود دليل كتابى على عقدهما ، فعدم الاعتداد بالحياة يؤدى لضياع هذه الحقوق . ولقد وصل فقهاء الشريعة الاسلامية لذات النتيجة فى حماية الحائز واعتبر الحياة قرينة على الملكية ودليلا للظاهر .

النظرة العامة للحياة

" اركان الحياة — اربعة وعيوبها "

الاشياء التى تصلح محلا للحياة :

ترد الحياة على الاشياء التى يمكن حيازتها والسيطرة عليها وهى الاشياء المادية من عقار او منقول ، اما الاشياء المعنوية من الحقوق الذهنية كحق المؤلف وبراءات الاختراع وغيرها فهى مبادئ وافكار قانونية يصعب القول بإمكانية سيطرته عليها ماديا .

كما ان الحق الشخصى اى علاقة المديونية القائمة بين الدائن والمدين لا تسرى عليها الحياة ، فلا يتصور ان يصبح الشخص مدينا لآخر بمجرد اعلان الدائن بذلك لفترات طويلة .

اما الاموال الخاصة المملوكة للدولة او لاحد الاشخاص المعنوية العامة الاخرى فهى وان كانت تقبل التعامل فيها بشأن كيفية تأجيرها والتصرف فيها الا انها لا يرد عليها الحياة ايضا .

اولا : الركن المادى (السيطرة على الشيء) :

١- تعريف السيطرة وممارستها :

يتمثل الركن المادى فى الحياة فى السيطرة على الشيء المحوز ، اى وضع اليد فعلا عليه ، والذي يختلف طريقته بحسب طبيعة الشيء المحوز ذاته .

فحياة المنزل تكون بسكنائه والمحل بممارسته النشاط المخصص له والارض بزراعتها والسيارة بركوبها ، والمواشى بإقتنائها ورعايتها والحصول على البانها واصوافها او ركوبها ان صلحت لذلك كالخيل والبغال والحمير .

ولا يشترط فى الحياة ان يظل الحائز واضعا يده طوال اليوم على الشيء وكل يوم فقد يغادر الشخص منزله طلبا للرزق او للسباحة او العلاج ، والارض يتركها صاحبها ليلا ويعود اليها نهارا .

الحيازة لا تقوم على الاعمال المتقطعة :

- ❖ قلنا أنه لا يعنى غياب الشخص فترة عن منزله او مزرعته انه غير مسيطر عليها .
- ❖ ولكن ليس معنى ذلك جواز قيام الحيازة على الاعمال المتقطعة ، اى التى تستمر فترة وتنقطع فترات او فترات اخرى ، فالانقطاع غير المعتاد فى اعمال الحيازة يفقدها ركنها المادى .
- ❖ وهذه مسألة تخضع لتقدير محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض متى بنيت قضائها على اسباب سائغة .

٢- لا يشترط فى الحائز التمييز :

- ❖ تقوم الحيازة فى ركنها المادى على مباشرة اعمال مادية وليس تصرفات قانونية وهذه الاعمال قد يباشرها الحائز بنفسه ، كما يمكن ان يباشرها الغير لحساب الحائز ، لظروف معينة من ضيق الوقت او عدم التخصص او انعدام او نقص الاهلية او دواعى السفر .
- ❖ وبالتالي فقد اجاز القانون ان يكون الحائز شخص عديم التمييز ، كالصغير الذى لم يبلغ السابعة والمجنون والمعتوه

٣- الحيازة بالواسطة :

- ❖ فدواعى السفر او عدم التخصص او ضيقا لوقت او غيرها قد تضطر الحائز للاتفاق مع الغير على ادارة شؤونه المالية ، ومنها القيام بأعمال الحيازة المادية لحساب الحائز ذاته .
- ❖ ويشترط لذلك ان يحوز الوسيط باسم ولحساب الحائز ، وان يكون تابعا للحائز فى هذا الشأن اى يتلقى اوامره ونواهيته من الحائز ذاته .
- ❖ وتصح الحيازة بالواسطة سواء كان مأجورة او غير مأجورة ، وسواء كان الوسيط يعمل بصفة دائمة عند الحائز (كبوب المنزل او العمارة او خفير المزرعة او المنزل او المخزن) او عند الحاجة اليه كالعامل الزراعى الموسمى المهم انها ترد على الاعمال المادية فقط اما العنصر المعنوى فيظل قائما لحساب الحائز نفسه .

س ١٨ : اكتب فى الركن المعنوي للحيازة مبينا عيوبها؟

ثانيا : الركن المعنوى (النية)

١- معنى النية فى الحيازة :

- ❖ يقوم العنصر المعنوى فى الحيازة على نية الحائز وقصده فى العمل لمصلحته اى فى حيازة الشيء لحسابه الخاص ، فإذا كان الحق المراد كسبه على الشيء هو حق ملكية او اى من الحقوق المتفرعة عنها فيجب ان يكون لدى الحائز نية تملك الشيء او اكتساب حق ارتفاق عليه مثلا ، وبصفة عامة نية الظهور بمظهر صاحب حق عيني يحوز لنفسه ولحسابه الخاص .
- ❖ **هذه النية هى الركن المعنوى** ← وهى التى تفرق بصفة عامة بين الحائز وبين ما قد يقوم بذات الاعمال المادية فقط ، كالمستعير والمستأجر والوكيل والنائب القانونى ، فهؤلاء حائزين عرضيين للشيء .
- ❖ والنية امر نفسى داخلى يقام الدليل عليه بكل وسائل الاثبات .
- ❖ والاصل ان تتوافر النية لدى الحائز ذاته ، وبالتالي يشترط ان يكون لديه الاهلية المدركة لما يحوز وما يترتب على حيازته ، الا ان ذلك لم يمنع المشرع من اجازة الحيازة لناقصى وعديمى الاهلية .
- ❖ ولمحكمة الموضوع سلطة استخلاص ثبوت النية من عدمه ، دون رقابة عليها من محكمة النقض .

٢- انتفاء النية فى الحيازة القائمة على الاعمال المباحة او التسامح :

- ❖ تقوم الحيازة كسبب لاكتساب الحق العيني الاصلى بصفة عامة ، والملكية بصفة خاصة ، على اعمال التعدى على حيازة وملك الغير ، بعلم الغير او بدون علمه فإذا انتفى معنى التعدى منها بأن كان ما يقوم به الحائز هو من الاعمال المباحة للكافة بنص القانون ، فلا تعدى ولا سيطرة فعلية على الشيء المحوز .
- ❖ وكذلك الشأن اذا كان المالك يعلم بما يقوم به الحائز من اعمال مادية فى ملكه ويوافق على ذلك من باب التسامح والود والتضامن الاجتماعى فلا تعدى ايضا .
- ❖ وعلى ذلك فإن قام شخص بفتح منور فى اعلى جدار منزله لدخول الهواء والضوء للمكان دون ان يكون قد ترك اى مسافة من ارضه بجوار ملك الجار ، فذلك من الاعمال المباحة .
- ❖ ولا يمنع ذلك الجار الآخر من حقه فى البناء على ملكه بما يلاصق الجدار المفتوح به المنور وما يترتب عليه من سد المنور ، ولو مضى على فتحه اكثر من خمسة عشرة عاما ، ولا يستطيع الحائز التمسك بالحيازة هنا لأن ما قام به من الاعمال فيما سبق لم يكن الا رخصة تشريعية مباحة للكافة ، وليس عمل متعدى .

٣- أعمال التسامح لا تصلح لوجود الحيابة :

أعمال التسامح توقف الحيابة عن انتاج آثارها حيث انتفى التعدى عليها ، فسماع المالك للحائز بما يقوم به من أعمال توطيدا للقرابة او للتضامن الاجتماعى هذا التفضل لن يقابل بالجور والتكران ، فلن تصلح الحيابة لانتاج آثارها .

٤- الحائز الحقيقى والحائز العرضى :

فالحائز الحقيقى ← هو من اجتمع له ركنى الحيابة المادى والمعنوى حيث يباشر السلطة والسيطرة المادية على الشئ لحسابه الخاص ، سواء كان بسند او بدون سند ، بنفسه مباشرة او بالواسطة .

الحائز العرضى ← هو ان كان يباشر كل الاعمال المادية التى يباشرها الحائز على الشئ عادة وبشكل مستمر دون انقطاع الا انه ينقصه العنصر المعنوى وهو نية العمل للحساب الخاص ، بل هو يعترف بأن حيازته ليست لمصلحته بل لحساب شخص آخر .

ويتجلى ذلك فى حالات عديدة منها المستأجر والمستعير والولى والوصى والقيم والوكيل والحارس القضائى والمرتهن حيازيا والتابع والناقل والمودع لديه .

فهؤلاء محرزون للشئ وليسوا حائزين حقيقيين ، حيث يقرون بملكية الغير للشئ محل الحيابة ، وانهم لا ينون تملكه بل ادارته او الانتفاع به لفترة مؤقتة ، يعود بعدها لملكه وحائزه الحقيقى .

٥- تحول الحائز العرضى لحائز حقيقى :

ولكن هل تصلح الحيابة العرضية لان تتحول لحيازته حقيقة اى يتحول الحائز العرضى لحائز حقيقى ؟

نعم يمكن ذلك بأن ينتقل الحائز العرضى من مركزه هذا القلق المؤقت لمركز قانونى افضل ودائم وهو الحائز الحقيقى ويكون ذلك بأحد طريقين :

الاول : فعل الحائز لنفسه . والثانى : فعل الغير .

أ- تغيير الحيابة العرضية الى حقيقة بفعل الغير :

يقصد بالغير ← هنا اى شخص غير المالك الحقيقى ، ويقوم الغير بعمل من شأنه تغيير صفة الحائز من عرضى الى حقيقى كإبرام عقد بيع منه للحائز او هبة او مقايضة او غيره من التصرفات .

فإذا ظهر شخص من الغير بمظهر المالك او الوارث الظاهر او الوكيل الظاهر ، وعرض الشئ محل الحيابة على الحائز العرضى كعرضه المزعة على المستأجر لبيعها له ، ووافق المستأجر على الشراء وقام بدفع الثمن وإبرام عقد البيع ، فهنا انقلبت حيازة المستأجر من حيازة عرضية الى حيازة حقيقة بفعل الغير .

ولكن ليس اى عمل من الغير من شأنه تحول الحيابة هكذا بل يشترط ان يكون الحائز العرضى حسن النية وقت تعامله مع الغير .

ب- تغيير صفة الحيابة بفعل الحائز نفسه :

ايضا قد تتغير صفة الحيابة بفعل الحائز نفسه ، بأن يتعرض المالك فى ملكه والمقصود بذلك الاعمال التى يأتيتها الحائز العرضى والتى تدل دلاله قاطعة على انه ينكر على المالك ملكيته ويرد الاستئثار بها لنفسه ، سواء كان حسن النية او سيئها ، كأن يمتنع عن دفع الاجرة او عن رد المأجور بإدعائه ملكيته او انكار حق المؤجر عليه .

ويجب ان تكون هذه المعارضة فى مواجهة المالك نفسه ، فلا يكفى مثلا ان يدعى المستأجر امام جمع من الناس ، فى غيبه المالك ، ملكية العين ، لأن ادعائه هذا لم يتم فى مواجهة المالك .

فلا تصلح الاعمال المادية التى يقوم بها الحائز العرضى على العين لتغيير صفته ولا تعسفه فى استعمال حقوق الحائز العرضى ، بل يجب ان يعارض الحائز العرضى حق المالك فىقوم بينهما مباشرة نزاع على ملكية العين ، يدعيها الحائز لنفسه وينكر المالك ذلك عليه .

ثالث : عيوب الحيابة

١- عيب الاكراه :

ويعنى وضع اليد بالقوة والغلبة ، اى بالغصب فالحائز قد لجأ لشرعية الغابة وليس للقانون فاستغل قوته الشخصية او العصبية القبلية او نفوذه فى السلطة لى يستولى عنوه على ملك الغير ، والاقرار له على ما فعل يعنى انهاء قوة القانون وعوده الفوضى والاضمحلال .

والاكراه المقصود هو المعاصر للحظة وضع اليد والسيطرة على الملك ، وهو الذى يعيب الحيابة ، ولكن ان زالت قوة الحائز الغاضب ونفوذه ومع ذلك ظل حائزا بشكل هادئ قد تنقلب حيازته الى حيازة قانونية وعلى من يريد استردادها منه ان يلجأ للقضاء ليحكم بأحقية فى ذلك .

وعكس الاكراه الهدوء ، وبالتالي فتنتج الحيابة آثارها متى بدأت فى هدوء ودون اكراه او غصب وقوه حتى استقر الوضع للحائز .

وتكون الحيازة مشوبة بعيب الخفاء اذا لم تكن ظاهرة او علنية فالحيازة هي الظهور بمظهر صاحب الحق ، ولهذا يجب ان يتصرف الحائز كما يفعل عادة من يمارس حقا من الحقوق فلا يخفى ما يقوم به ، فصاحب الحق لا يستعمله خفيه بل يستعمله علنا . والغالب الا يتحقق عيب الخفاء الا بالنسبة للمنقولات سهولة اخفائها ، اما بالنسبة للعقارات فمن النادر ان تكون الحيازة خفية .

وعكس الخفاء هو الوضوح والعلانية ، اي الظهور امام المالك والكافة بمظهر الحائز القانوني . ولا يشترط حتى تكون الحيازة علنية ان تكون ظاهرة للناس كافة ، بل يكفي لاعتبارها كذلك ان تكون ظاهرة للمالك او من يراد الاحتجاج عليه بها ولو كان امرها خفيا عن باقى الناس .

٣. الغموض او اللبس :

ويعنى ذلك غموض الامر والتباسه على الناس ، فلا نعرف ما اذا كان الحائز يحوز الشيء لحساب نفسه او لحساب الغير او لحسابه ولحساب الغير فى آن واحد ، فالامر غير واضح على الكافة ، حيث نية الحائز فى العمل للحساب الخاص لم تنجلي ولم تكن واضحة جلية .

ويحدث ذلك عادة حينما يكون الشيء شائعا وخاصة اذا نتج الشيوع عن الميراث ولم يقتسم الشركاء على الشيوع الشيء بعد ، بل تركوه فى يد احدهم .

فهنا الحائز للشيء الشائع لا يتضح نيته فى الحيازة لمصلحته فقط ، فالشيء جزء من تركه ، والشركاء الآخرون يروحون ويجيئون عليه دون ادنى اعتراض ، ولا تنتج الحيازة اى اثر فى كسب الحق العيني على الشيء .

وعكس الغموض هو الوضوح ، فإذا اعلنت نية الحائز فى انه يحوز لحساب ذاته فقط وليس لحساب الغير وصار الامر جليا فتننتج الحيازة آثارها من تاريخ الوضوح .

٤. عيوب الحيازة مؤقتة ونسبية :

تعد عيوب الحيازة الثلاثة عيوب مؤقتة لأنها تظل تمنع الحيازة عن انتاج آثارها طالما بقيت ، فإن زالت فى او وقت باتت الحيازة كاملة منتجة لآثارها ، فإن كانت الحيازة غامضة او خفية طوال خمس سنوات ، ثم باتت واضحة جلية علنية للناس كافة وللمالك الحقيقي ذاته ، فقد صارت منتجة لآثارها من تاريخ زوال العيب ، اما ما مضى من الزمن قبل زوال العيب فلا يحسب فى مدة التقادم .

ايضا الاكراه ، يظل مانعا للحيازة عن انتاج آثارها ، فإن زال النفوذ والقوة والسلطة وعاد الشخص الحائز لا يملك ولا يقوى على ايداء احد او التهديد بالايذاء ومع ذلك ظل حائزا للشيء بهدوء واستقرار فهنا تبدأ الحيازة فى انتاج آثارها ولا تحسب المدة السابقة .

وهى عيوب نسبية :

ويعنى ذلك انه لا يجوز الاحتجاج والتمسك بالعيب الا من الشخص الذى وقع عليه العيب ، اى الشخص المكروه او الذى التبس عليه الامر او اخفى عنه ، فلا يجوز للكافة التمسك بالعيب اذ ليس من النظام العام ، بل لمن وقع فى شأنه فقط .

فإذا كان الشريك الحائز للمزرعة قد اوضح نيته تجاه بعض الشركاء فى انه لن يعطيهم شيئا منها لأنه يحوزها لنفسه وهو مالکها وحده ، وانكر عليهم اى حق فيها وظل فى الوقت ذاته يعطى الآخرين نصيبهم من ثمراتها والريع ويستقبلهم كالعادة فيها فإن الفريق الاول ، والذى انكر حقهم عليهم صار الامر واضحا لهم فتسرى الحيازة فى حقهم اما الفريق الآخر فالامر غامض ملتبس بالنسبة لهم فلا يسرى فى شأنهم التقادم . فالامر نسبي وليس مطلق للكافة .

" انتقال الحيازة وزوالها وحمايتها "

اولا : انتقال الحيازة :

١ - كيفية انتقال الحيازة :

📌 عادة ما تنتقل حيازة الاشياء بالتسليم :

📌 **التسليم الحقيقى** ← يكون بوضع الشيء تحت تصرف المشتري مع اعلامه بذلك ويكون رمزيا بتسليمه مستندات ومفاتيح المبيع كتسليم المشتري رخصة السيارة واوراقها ومفاتيحها .

📌 **التسليم حكما** ← بتغيير نية الشخص ، فلو كان المشتري حائزا للمبيع قبل شراؤه بأيه صفة ، كما لو كان مستأجرا له او مستعيرا او مودعا لديه ، ثم اشتراه من مالكة مع استمرار حيازته له فإن التسليم يكون بتغيير نية المشتري ، فقبل البيع كان مستأجرا له ، وبعد البيع صار مالكا له .

📌 فطبقا للنصوص القانونية تنتقل الحيازة كما يلى :

أ **الانتقال الفعلى** ← تنقل الحيازة من الحائز الى غيره اذا اتفقا على ذلك وكان فى استطاعة من انتقلت اليه الحيازة ان يسيطر على الحق الوارد عليه بالحيازة .

ب **الانتقال الحكمى** ← يجوز ان يتم نقل الملكية دون تسليم مادي اذا استمر الحائز واضعا يده لحساب من يخلفه فى الحيازة .

ج **الانتقال الرمزى** ← تسليم السندات المعطاه عن البضائع المعهود بها الى امين النقل او المودعة فى المخازن يقوم مقام تسليم البضائع ذاتها .

📌 وهذه الحالات تتعلق بالخلف الخاص .

📌 **اما الخلف العام** ← هو الذى يتلقى عن السلف كل ذمته المالية او جزء غير معين منها وهو الوارث او الموصى له بحصة غير معينة من التركة كالربع او الثلث فتنتقل اليه كل الذمة المالية ، ويحوزها بمجرد وفاة المورث او الموصى .

٢ - صفات الحيازة عند انتقالها :

أ - احتفاظ الحيازة بصفاتها عند انتقالها للخلف العام :

📌 فتنتقل الحيازة للخلف العام بصفاتها على انه اذا كان السلف سيئ النية واثبت الخلف انه كان فى حيازته حسن النية جاز له ان يتمسك بحسن النية .

📌 فالقاعدة انه اذا كانت حيازة السلف عرضية او بها عيب الاكراه او الخفاء او الغموض فإنها تنتقل للخلف بذات الاوصاف والعيوب ، فتكون حيازة الخلف عرضية ايضا او معيبة بالاكراه .

📌 الاستثناء المنصوص عليه من تلك القاعدة يتعلق بحسن النية او سوءها ، فإذا كان السلف سيئ النية ، وتوفى وكان الخلف حسن النية لا يعلم بسوء نية مورثه فإن للخلف الحق فى التمسك بحسن نيته هو وترتيب الآثار القانونية على ذلك .

📌 فإذا وجد الخلف ضمن التركة منقولا او عقارا ، واعتقد ان مورثه كان قد اشتراه او انه تلقاه بشكل مشروع وظل حائزا له بحسن نية ، اى يجهل انه يعتدى على حق الغير ، ولم ينسب اليه اى خطأ جسيم ، فيمكن له ان يتمسك بحسن نيته هو ولا علاقته له بسلفه فى هذه الجزئية .

ب - استقلال حيازة السلف عن حيازة الخلف الخاص :

📌 فحيازة الخلف الخاص حيازة جديده مستقلة عن حيازة السلف ، وثبت لها صفاتها الخاصة التى قد تختلف او تتفق مع حيازة السلف ، فقد تكون حيازة السلف معيبة وتكون حيازة الخلف صحيحة خالية من العيوب .

📌 وان اراد الخلف الخاص ضم حيازة سلفه له ، وهذا من حقه فيجب ان تكون كلا الحيازتين صالحتين لانتاج آثارها اى كلاهما صحيحة وخالية من العيوب .

ثانياً : زوال الحيازة

❖ فإذا كانت الحيازة تجتمع للحائز بتوافر عنصريها المادي والمعنوي فهي تزول عنه ايضاً بتخلي الحائز عن حيازته ، اي بالنزول الارادي عنها كبيعها العقار وتسليمه للمشتري او هبته وتسليمه للموهوب له ، كما تكون بفقده الركن المادي او زوال السيطرة الفعلية على الشيء بأي طريقة كانت غير التخلي الارادي .

❖ ولكن اذا تم فقد السيطرة على الحيازة دون ارادة الحائز ولمانع وقتي فلا تزول حيازته وتظل ثابتة له حتى زوال المانع الوقتي وكان يحدث هذا في وقت فيضان النيل حيث تغطي المياه على بعض الاراضي المجاورة ، فلا تزول ملكيتها ولا حيازتها عن اصحابها وتعود الامور كما كانت بعد انحسار المياه .

❖ ولكن ان استمر المانع لمدة سنة كاملة ، فإن الحيازة تنقضي اذا وضع شخص آخر يده على الشيء غصباً عن الحائز او بدون علمه .

ثالثاً : حماية الحيازة :

١- دعاوى الحيازة الثلاثة :

❖ اثر المشرع حماية الحيازة القانونية من اي اعتداء قد يمسها صوناً للامن الاجتماعي وحماية للأوضاع الظاهرة فأنشأ للحائز القانوني الحق في اللجوء للقضاء طلباً للحماية بأي من الدعاوى الثلاث المرخص له باستعمالها ، وهي **دعوى استرداد الحيازة ودعوى منع التعرض ، ودعوى وقف الأعمال الجديدة** .

❖ وهذه الدعاوى تعتمد على اجتماع اركان وشروط الحيازة في يد الحائز ، اي هو حائز قانوني ، ولا علاقة لها بأصل او سند حيازته .

❖ هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فإنه اذا كان الاصل ان المستفيد من دعاوى الحيازة هو الحائز القانوني وليس الحائز العرضي ، الا ان القانون قد منح (استثناء) المستأجر الحق في اللجوء لهذه الدعاوى وهو حائز عرضي حفظاً وصوناً لحقوقه الشخصية الناتجة عن الايجار ، ومنها الحيازة .

❖ وهذه الدعاوى لا تحمي سوى حيازة العقارات ، اما بالنسبة للمنقولات فإن قاعدة (الحيازة في المنقول سند الملكية) تجعل دعوى الحيازة عديمة الجدوى .

❖ ودعاوى الحيازة تحمل طابع الاستعجال ، فتدخل في اختصاص القاضي الجزئي وتختص بنظرها المحكمة الواقع في دائرتها العقار .

٢- دعوى استرداد الحيازة :

❖ دعوى استرداد الحيازة تقوم على حق الحائز الذي فقدت حيازته ان يطلب استردادها خلال السنة التالية لتاريخ فقدها .

❖ وترفع دعوى الاسترداد من الحائز القانوني والحائز العرضي ، طبقاً للقانون "لحائز العقار اذا فقد الحيازة ان يطلب خلال السنة التالية لفقدانها ردها اليه فإن كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت ان ينكشف ذلك ويجوز ايضاً ان يسترد الحيازة من كان حائزاً بالنيابة عن غيره " .

❖ فإن لم يكن فاقد الحيازة قد مرت على حيازته سنة كاملة قبل ان يفقد حيازته فلا يجوز له رفع دعوى الاسترداد ، الا اذا كان الحائز الجديد هو الآخر ليست حيازته احق بالترتيب حيث لم تمر سنة على حيازته هو الآخر .

❖ يوازن القاضي بين الطرفين في الحيازة الاولى بالرعاية حيث يقضي لمصلحته من كان له منهما سند قانوني بحيازته فإن تساوى ، او لم يكن لديهما اي سند ، فيقضي لمصلحة السابق في التاريخ ، وذلك مالم تكن الحيازة قد نزلت قسراً اي بالقوة فيقضي لمصلحة الحائز الاول في جميع الاحوال .

٣- دعوى منع التعرض :

❖ تفترض هذه الدعوى ان شخص ما يتعرض للحائز مادياً او قانونياً في الانتفاع بحيازته الهادئة المستقرة ، حيث يقوم بمنعه من دخول العقار ، او يضع عراقيل في طريقه كقطع الطريق او حفره او قطع الكهرباء عنه ، او يدعى بأي عمل قانوني يتعارض مع حقوق الحائز ، يكون من شأنه ان يجعل الحيازة محل نزاع او خصومة اما القضاء كإذاره بعدم زراعة الارض او اتلاف الزراعة .

❖ ويشترط لرفع دعوى منع التعرض هذه ان يكون الحائز قد حاز عقاره لمدة سنة كاملة على الاقل قبل وقوع اعمال التعرض ، اي اجتمعت له الحيازة القانونية قبل سنة من تعرض آخر له ، فإن لم تضي هذه السنة الكاملة على حيازته الهادئة المستقرة الخالية من العيوب فلا حق له في اللجوء لها .

❖ فإن وقع تعرض له بعد انقضاء المدة ، فإن له الحق في خلال العام التالي في رفع دعوى منع التعرض "فمن حاز عقاراً واستمر حائزاً له سنة كاملة ثم وقع له تعرض في حيازته جاز ان يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض" فلا يتأخر عن العام من تاريخ وقوع اعمال التعرض حتى لا يكتسب المتعرض حيازة قانونية فيما تعرض له فيه ، فهذه مدة سقوط وليس مدة تقادم ، ومن ثم فهي تسري على غير كامل الاهلية والغائب ، ولا توقف ولا تنقطع

٤- دعوى وقف الاعمال الجديدة :

وهذه الدعوى تتعلق بالبداية في تنفيذ اعمال مادية جديدة ، كبناء حائط او سد طريق بسور مبنى او زراعة اشجار على غير المسافات القانونية ، مما يؤدي لسد مطل الحائز او فقده طريقه او اتلاف مزروعاته ، ويخشى الحائز لأسباب معقولة من تهديدها لحيازته الهادئة المستقرة لو اكتملت هذه الاعمال فيلجأ للقضاء بطلب وقفها .

ويشترط لرفع هذه الدعوى ما يلي :

- ان يكون حيازة العقار (القانونية) قد استمرت **سنة** على الاقل قبل البدء في هذه الاعمال .
- ان توجد **اسباب معقولة** للحائز في تهديد هذه الاعمال لحيازته وفي هذا تختلف دعوى منع التعرض عن دعوى وقف الاعمال الجديدة ، فالاولى لا ترفع الا اذا وقع التعرض فعلا ، اما الثانية فترفع لمجرد الخشية من تهديد هذه الاعمال للحيازة فيما لو تمت .
- الا تكون هذه الاعمال المادية الجديدة قد **اكتملت** ، لو اكتملت فلا فائدة من رفع دعوى وقف اعمال فقد تمت بل دعوى منع التعرض .
- الا تمضي مدة عام على بدء هذه الاعمال الجديدة** فمرور عام على بدأها يكون الباني او القائم بهذه الاعمال قد اكتسب حيازة يمكن له طلب حمايتها قانونا .

ويتضح مما سبق ان هناك فروقا ثلاثة بين دعوى وقف الاعمال الجديدة ودعوى منع التعرض :

- في دعوى وقف الاعمال الجديدة تبدأ الاعمال في عقار المدعى عليه ، اما في دعوى منع التعرض فقد تكون في عقار المدعى عليه او في عقار المدعى او في عقار الغير .
- في دعوى وقف الاعمال الجديدة تبدأ هذه الاعمال دون ان تتم ، ودون ان يقع تعرض فعلى اما في دعوى منع التعرض فتتم هذه الاعمال ويقع تعرض فعلى .
- وفي دعوى وقف الاعمال الجديدة يقضى بوقف الاعمال الجديدة ، دون ازالتها اما في دعوى منع التعرض فيجوز ان يقضى بإزاله هذه الاعمال .

" آثار الحيازة (دور الحيازة في كسب الحق العيني "حق الملكية")"

"التقادم المكسب (الطويل)"

الفرق بين التقادم المكسب والتقادم المسقط :

- يقوم التقادم المكسب على واقعة ايجابية هي **حيازة الشئ** ، اي وضع اليد والسيطرة عليه مدة معينة من الزمن بالشروط القانونية المحددة فيكتسب الحائز ملكية الشئ كحق الارتفاق والانتفاع . وعلى العكس من التقادم المكسب يوجد **التقادم المسقط** ، وهو الذي يعتمد على واقعة سلبية ، وهي سكوت صاحب الحق عن المطالبة بحقه ممن حازه او ممارسه اي سلطات عليه فترة محددة من الزمن ، دون مانع فيؤدى لسقوط الحق عن صاحبه .
- والتقادم المسقط** اوسع نطاقا من **التقادم المكسب** حيث يمتد ليشمل الحقوق الشخصية بجانب الحقوق العينية المتفرعة عن حق الملكية .
- اما حق الملكية ذاته فلا يسقط ابدا بالتقادم ، والتقادم المكسب ينحصر نطاقه في الحقوق العينية الاصلية اما الحقوق الشخصية فلا تكتسب بالتقادم .
- والتقادم المسقط** لا يتمسك به الا عن طريق الدفع ، فإذا رفع صاحبا لحق الذي سقط بالتقادم دعواه امكن للمدعى عليه ان يدفع على هذه الدعوى بالتقادم المسقط ، اما **التقادم المكسب** فيتمسك به عن طريق الدفع وعن طريق الدعوى على السواء ، فللحائز ان يدفع دعوى الاستحقاق المرفوعة عليه من المالك بالتقادم المكسب .
- واخيرا فإن **التقادم المكسب** يعتد فيه بحسن النية ، اذا الحائز حسن النية يتملك الحق في مدة اقصر من المدة التي يتملكه فيها الحائز سيئ النية ، اما في **التقادم المسقط** فلا اثر لحسن النية في انتاجه لآثاره .

هذا عن الفروق بينهما ، ولكن مع ذلك توجد قواعد مشتركة بينهما خاصة في حساب المدد ووقف التقادم وانقطاعه ، والتمسك به امام القضاء والتنازل عنه والتعديل في مدده .

التقادم فى الفقه الإسلامى :

- لا يقر الفقهاء المسلمون التقادم بنوعيه المكسب والمسقط ، تأسيسا على الحديث الشريف (لا يسقط حق امرئ مسلم وإن قدم) فيترتب على ذلك ان الاصل هو ان الحق لا يكتسب ولا يسقط بمرور الزمن ، فوضع اليد على غير المباح من الاشياء لا يكسب عليه حقا مهما طال الزمن .
- على ان المتأخرين من فقهاء المالكية والحنفية قد أخذوا بمبدأ مرور الزمن لا كمكسب للحق او مسقط له ، بل كمانع من سماع الدعوى يستفيد منه واضع اليد والمدين اما الحق فباق على حاله ، فما يسقط اذن هى الدعوى وليس الحق نفسه .

س ٢٠ : وضع شروط التقادم الطويل ؟

اولا : شروط التقادم الطويل :

١ - الشرط الاول : الحيازة :

- الشرط الاول البديهي فى التقادم المكسب ، وهى تقوم على استجماع عناصرها فى يد شخص الحائز ، وخلوها من العيوب .
- اما محل الحيازة فيسرى التقادم الطويل على العقار وعلى المنقول على السواء ، كما لا يشترط فيه حسن النية او وجود سند او سبب صحيح ، فلو كان بسوء نية ، او بسند باطل او بدون سند اساسا ، فهى تنتج اثارها فى حق الحائز اذا استمرت مدة خمسة عشر عاما دون وقف او انقطاع ولكن بشرط ان يكون محل الحيازة من الاشياء القابلة لاكتساب الحق عليها بالحيازة ، فالاشياء العامة والخاصة المملوكة للدولة او لاشخاص القانون العام والوقف لا يسرى عليها قواعد التقادم .
- ويوفر شرط الحيازة ميزة هامة للحائز عند المنازعة ، حيث يستطيع الحائز اللجوء لدعاوى الحياز الثلاث السابقة لحمايه حيازته ، كما ان القانون قد انشأ قرينة لصالحه باعتبار الحائز للحق هو صاحبه ، حتى يقوم الدليل على العكس .
- بل ان الحائز المادى هو الاول بالحماية القانونية عند تنازع اكثر من شخص على حيازة حق واحد .

٢ - الشرط الثانى : المدة :

- يتمثل الشرط الثانى لاكتساب الحق العيني بصفة عامة بالتقادم ، فى مرور فترة من الزمن كفيلة بكسب الحائز للحق واسقاطه عن صاحبه فى ذات الوقت ، وهى مدة **خمس عشرة سنة** ، وهى اطول مدة تقادم مكسب للحقوق فى القانون المصرى .
- وقد يتبادر الى الذهن ان هناك نوعا اخر من التقادم مدته ثلاث وثلاثون سنة يتعلق بحق الارث ، ولكن بالرجوع للمذكرة الايضاحية للمشروع القانون المدنى ذكرت انه " اما دعوى الارث فهى تسقط بثلاث وثلاثين سنة والتقادم هنا مسقط لا مكسب .
- فالنص يتعلق بالتقادم المسقط لا المكسب اى ان الوارث الذى يسكت عن المطالبة بحقه مدة ثلاث وثلاثين سنة يسقط حقه فى الارث ويؤول لباقي الورثة .
- وعلى ذلك فليس هناك ما يمنع ان يملك احد الورثة بعض اعيان التركة بالتقادم الطويل مدة خمس عشرة سنة ، شأنه فى ذلك شأن اى اجنبى عن التركة اذا استوفت حيازته الشروط القانونية .

قرينة استمرار الحيازة :

- يصعب على الحائز اثبات حيازته للعقار او المنقول واستمرارها فى كل يوم من ايام التقادم الطويل .
- لذلك رأى المشرع ايجاد قرينة قانونية مضمونها اثبات الحائز لتاريخ بدء حيازته واثبات انه يحوز الان او وقت المنازعة ، وافترض القانون استمرار الحيازة بصفاتها القانونية خلال تلك المدة الطويلة ، ومن يدعى عكس ذلك عليه الاثبات .
- حيث انه اذا ثبت قيام الحيازة فى وقت ثابت معين وكانت قائمة حالا ، فإن ذلك يكون قرينة على قيامها فى المدة ما بين الزمنين مالم يقيم الدليل على العكس .

ثانيا : وقف التقادم وانقطاعه

١ - وقف التقادم :

- يعنى وقف التقادم** ← انه طرأ مانع يؤدي مؤقتا لعدم سريان التقادم طوال وجود المانع على ان يعاود التقادم سريانه بعد زواله مع ضم المدة السابقة على الوقف مع المدة اللاحقة لاكتمال مدة التقادم فالتقادم لا يؤدي لزوال المدة السابقة على المانع بل يحتفظ بها الحائز حتى يكملها بالمدة المتبقية له بعد زوال المانع .

أ- المانع المادي او الادبي ← وهى اسباب ترجع لظروف مادية او اضطرارية :

🕒 **المانع المادي** ← ويقصد بالمانع المادي العقبة التي يتعذر معها ماديًا على من يسرى التقادم ضده ان يرفع على الحائز الدعوى التي تحمى حقه كقيام حرب او اندلاع ثورة او وقوعه في الاسر او الاعتقال او حدوث فيضان ادى لانقطاع طرق المواصلات .

🕒 **اما المانع الادبي** ← فيقصد به العلاقة التي تقوم بين الحائز ومن يسرى التقادم ضده ، سواء أكانت على اساس من المحبة والوثام او الخشية والاحترام بحيث يتعذر ادبيا على من يسرى التقادم ضده المطالبة بحقه كعلاقة الزوجية او القرابة ، فعلاقة الزوجية مثلا تعتبر مانعا ادبيا يوقف سريان التقادم لأن من شأن مطالبة احد الزوجين بحقه ان تؤدي الى حلول الشقاق بينهما وتعكير صفو الحياة الزوجية ، ويقف التقادم كذلك طالما قامت علاقة النيابة بين الحائز ومن يسرى التقادم ضده .

🕒 ويلاحظ على كل حال ان اعتبر العلاقة مانعا او غير مانع من الامور الموضوعية التي يقدرها قاضي الموضوع في كل دعوى بحسب ظروفها .

ب- اسباب ترجع للشخص ذاته : عدم وجود ممثل قانوني :

🕒 ايضا يقف التقادم اذا لم يوجد ممثل قانوني لكل من ناقصى وعديمى الاهلية والغائب والمحكوم عليه بعقوبة الجنائية .

٢- انقطاع التقادم :

🕒 **يعنى قطع التقادم** ← زوال مدة التقادم السابقة على حدوث سبب القطع ، فإن حدث واستمر التقادم بعد زوال سبب قطعه ، فتبدأ مدة تقادم جديدة لا علاقة لها بما سبق على القطع فقد زالت كل آثاره ، وينقطع التقادم بفقد الحيازة ، والمطالبة القضائية والاقرار .

أ- فقد الحيازة (الانقطاع الطبيعي) :

🕒 اذا كانت الحيازة هي الشرط الاول في التقادم المكسب ، فإن فقدها يعنى زوال سبب التقادم المكسب ويكون فقد الحيازة اراديا بالتخلي عنها نهائيا مع تسليمها لحائز جديد باتفاق كالباع والهبة او دون تسليمها لاحد كالكاء منقولات قديمة في اماكن ترك القمامة .

🕒 فإذا استطاع الحائز الذي فقد الحيازة استردادها خلال سنة من تاريخ فقدها او رفع دعوى باستردادها خلال هذه السنة ايضا ، وقضى لصالحه بالاسترداد ولو بعد فوات السنة ، فإن التقادم لا يعد منقطعاً بل موصولا ويكمل المدة الباقية للتقادم المكسب .

ب- المطالبة القضائية :

🕒 " ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ، ولو رفعت الدعوى لمحكمة غير مختصة ، وبالحجز وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تظليس او توزيع او بأى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه اثناء السير في احدى الدعوى " .

🕒 والمطالبة المقصودة هي رفع الامر للقضاء وليس للمطالبة الودية ، فلا تكفى المطالبة الودية ولو بكتاب مسجل او بإنذار رسمى على يد محضر .

🕒 ويجب ان تكون المطالبة القضائية صحيحة بأن توجه ضد الحائز وتتضمن المنازعة في حيازته موضوعيا ، وان تخلو من عيوب الشكل والاجراءات .

ج- الاقرار :

🕒 ايضا ينقطع التقادم اذا اقر الحائز بحق المالك في الشيء المحوز ، اقرارا صريحا او ضميا ، سواء أكان قضائيا ، اى صادرا في ساحة القضاء في دعوى متعلقة بالشيء المحوز ، او اقرارا غير قضائي صادر في خارج ساحة القضاء .

🕒 فأقرار الحائز بحق المالك يقطع بالتقادم والسبب في ذلك انه يعتبر منه نزولا عن التمسك بالمدة السابقة على الاقرار والاقرار الضمني يستفاد من اى عمل يصدر من الحائز فيه معنى الاقرار كما لو دفع الحائز اجرة العقار للمالك

" التقادم المكسب القصير "

🕒 اذا وردت الحيازة على ملكية عقار او على حق عيني اخر عليه واقتترنت بحسن نية ، وبسبب صحيح فإن المشرع رأى انقاص مدة التقادم من خمس عشرة سنة الى خمس سنوات ، تقديرا منه لحسن نية الحائز واستناده في حيازته (للحق العقاري) لسبب صحيح .

أولاً : شروط التقادم القصير :

الشرط الاول : الحيابة :

- ١ ذات الشرط فى التقادم الطويل حيث الحيابة قانونية خالية من عيوبها ومتصلة لم تنقطع او انقطعت واستطاع الحائز استردادها او رفع دعوى الاسترداد خلال عام من تاريخ العقد .
- ٢ الجديد هنا قصر الحيابة فى التقادم الخمسى على الحقوق العينية التى ترد على عقار معين بالذات ، اى ان يكون محل الحيابة عقارا ، ولا ينطبق التقادم الخمسى .

ضم الحيابة من السلف للخلف (حالة تعاقب الحائزين) :

- ٣ اذا لم تعسف الحائز المدة التى حازها للعقار فى كسبه للحق العينى الاصلى عليه ، مع توافر باقى الشروط .
- ٤ **فهل يجوز له ضم مدة سلفه الى مدته لاكتمال مدة التقادم ؟**

- ٥ المبدأ هو جواز ضم مدة السلف الى الخلف لاكتمال مدة التقادم ، **ولكن مع اختلاف الشروط فى حالة الخلف العام عنها فى الخلف الخاص :**

- ٦ **فيحيابة الخلف العام** ← هى امتدادا لحيابه سلفه فإذا كانت حيابة السلف صحيحة وقانونية فتظل كذلك بالنسبة لخلفه حتى اكتمال مدة التقادم الطويل ، وان كانت معينة فيظل العيب ملاصقا لها

- ٧ **الخلف الخاص** ← فيحيابه دائما حيابة مستقلة عن حيابه سلفه ، وذلك لانها تنتقل اليه بالاتفاق ويستطيع ان يتأكد من صحة حيابة ووضع يد السلف قبل التعاقد معه ، ولكى يستفيد من قواعد الضم هنا يجب ان تكون حيابه قانونية وغير معينة وايضا ان تكون حيابة سلفه هى الاخرى صحيحة وغير معينة.

- ٨ فإذا كانت حيابة سلفه معينة وكان هو حسن النية ولديه السبب الصحيح فعليه ان يكمل مدة الخمس سنوات كاملة على الاقل للاستفادة من التقادم الخمسى على العقارات وان يسجل سنده ، اما ان كانت حيابه هو معينة فلن يستطيع التمسك بها أصلا لأن حيابه غير قانونية او لسوء نيته .

الشرط الثانى : المدة (مرور خمس سنوات) :

- ٩ على عكس التقادم الطويل والذى يجب استمراره مدة خمس عشرة سنة ، فالتقادم القصير اختصره القانون لخمس سنوات فقط ، مراعاة لوجود حسن نية الحائز وسنده الصحيح .

الشرط الثالث : حسن النية :

أ. معنى حسن النية :

- ١٠ يشترط للتمسك بالتقادم القصير ان يكون الحائز حسن النية ومعنى حسن النية انه يجهل اعتدائه على حق الغير ، فهو يعتقد وله حق فى اعتقاده ، انه تعامل مع شخص ذو صفة قانونية فى نقل الحق العينى العقارى اليه ، بعوض او بدون عوض ، فاتفق معه على ذلك وايدت كل المظاهر والدلائل الخارجية انه يتعامل مع صاحب حق حقيقى فهو حسن النية وهو معيار شخصى مبنى على كل اسباب معقولة تؤيده وتجاوز حيابة الحق العينى العقارى من الشخص المعنوى او الطبيعى على السواء والعبرة بتوافر حسن النية لدى الحائز للحق وفى حالة الشخص المعنوى تكون العبرة بحسن نية من يمثله قانونا امام الغير وكذلك فى حالة انعدام الاهلية او انقاصها فالعبرة بحسن نية النائب القانونى له .
- ١١ ويستمر الحائز حسن النية حتى يعلم يقينا انه يعتدى على حق الغير .
- ١٢ ويعتبر كذلك الحائز سبئ النية من وقت اعلانه بعيوب حيابه ، على ان يكون الاعلان بذلك فى صحيفة دعوى ، وحسن النية او سوءها مسألة واقعية تقدرها محكمة الموضوع بناء على الثابت امامها .

ب. اهمية التمييز بين حسن النية او سوء النية فى الحيابة عموما :

- ١ **حق الحائز فى استرداد المصروفات** ← يحق للحائز استرداد المصروفات النافعة اذا كان حسن النية
- ٢ **مسئولية الحائز عن هلاك العين** ← اذا هلك الشئ المحوز فى يد الحائز فإن مسئوليته عن هذا الهلاك تختلف فى حالة حسن النية عن انتفاؤها .
- ٣ **يقتضى احكام التقادم القصير الخمسى على العقارات** ← واكتساب ملكية المنقول فورا بالحيابة ان يكون الحائز **حسن النية** فإن كان سبئ النية فلا يكتسب الملكية على العقار او المنقول الا بالتقادم الطويل .

الحالة الاولى : الخطأ الجسيم :

❖ " يعد حسن النية من يحوز الحق وهو يجهل انه يعتدى على حق الغير ، الا اذا كان هذا الحق ناشئاً عن خطأ جسيم " .

❖ **الخطأ الجسيم** ← خطأ لا يقع فيه ابسط الناس حرصاً وحذراً فهو خطأ واضح لا يقتضيه الا مهمل او مستهتر بالحقوق .

❖ فمن يتعامل على عقار مكتوب عليه لافته كبيره ، تقول انه ملك لشخص آخر غير المتصرف وانه غير مخصص للبيع او للتصرف فيه عموماً او يكون مسجلاً في الشهر العقاري حديثاً باسم شخص آخر مالكا ، غير المتصرف ، فهو مخطئ خطأ جسيماً ، ولا يستطيع الادعاء بأنه حسن النية .

الحالة الثانية : الاكراه :

❖ فالشخص الذى استعمل القوة او هدد بالجوع اليها او استغل نفوذه وسطوته وعصبيته لانتزاع حيازة الاخرين تحت تهديد البطش والقوة ، لا يستطيع الادعاء بأنه حسن النية فمن اين تأتى حسن النية فى هذه الحالات اذا كان مجرد وضع اليد كان بالقوة والغلبة وليس بالهدوء والقانون .

❖ والعبرة فى حسن النية (او سوءها) بوقت تلقى الحائز لحقه من المتصرف (البائع او الوصى او الواهب) فإذا كان حسن النية وقتها فقد توافر فى شأنه الشرط الثالث للتقادم القصير حتى لو علم بعد ذلك خاصة بعد فوات مدة الخمس سنوات بأنه قد تعامل مع غير ذى صفة فى نقل الحق اليه .

❖ فإذا كان الحائز وقت ابرام التصرف (عقد البيع مثلاً) حسن النية فتحسب المدة من تاريخ التصرف فإن اكتملت مدة الخمس سنوات على البيع فيمكن التمسك بالتقادم الخمسى .

الشرط الرابع : السبب الصحيح :

❖ **السبب الصحيح** ← " سند يصدر من شخص لا يكون مالكا للشيء او صاحباً للحق الذى يراد كسبه بالتقادم ويجب ان يكون مسجلاً طبقاً للقانون " .

❖ ويشترط لتوافر السبب لدى الحائز فى التقادم الخمسى شروطاً اربعة :

أ- ان يكون تصرفاً قانونياً :

❖ فالسبب الصحيح ينقل الحق من شخص لآخر ، أى ان الحيازة تنتقل بين الاحياء فالعقد او التصرف بإرادة منفردة (وصية- وعد بجائزة) هو الذى ينقل الحق العيني بين الاحياء ، اما الواقعة المادية التى ترتب آثاراً قانونية كالميراث فليست تصرفاً قانونياً ولا تعد سبباً صحيحاً .

❖ فمن وجد فى تركه مورثه أرضاً فظن انها لمورثته وظل حائزها مدة خمس سنوات ، ثم طلب مالكتها الاصلى استردادها ، فلن يستطيع الوارث ان يتمسك بالسبب الصحيح .

ب- ان يكون تصرفاً ناقلاً للملكية او للحق العيني المراد كسبه على العقار :

❖ فليست كل التصرفات القانونية هى ناقلة للحق العيني الاصلى بصفة عامة ، بل يقتصر الامر فى التقادم الخمسى على التصرفات الناقلة للملكية ، كالبيع والهبة والمقايضة والوصية بعقار معين بالذات اذا لم تتجاوز ثلث التركة .

❖ فإذا لم يكن التصرف ناقلاً للملكية او للحق العيني فلن يصلح سبباً صحيحاً ، وبالتالي فعقد الايجار وعارية الاستعمال على عقار معين بالذات وعقد الحراسة وعقد الوديعة والوكالة ليست بتصرفات تصلح كسبب صحيح ، فمن تعاقد على استعمال الشيء كعارية استعمال فترة معينة لا يستطيع التمسك بالتقادم القصير لاكتساب الملكية .

❖ وتعتبر فى حكم التصرفات القانونية وان لم تكن تصرفات بالمعنى الصحيح الاحكام الناقلة للملكية كالحكم بالشفعة والحكم برسو المزداد ، فهذه الاحكام تصلح اسباباً صحيحة يستند اليها الشفيع او الراسمى عليه المزداد للتمسك بالتقادم الخمسى اذا تبين ان الشركاء او المدين او من اخذ منه العقار لم يكونوا ملاكاً .

❖ التصرفات او الاحكام الكاشفة او المقررة للملكية او الحق العيني فلا تعتبر سبباً صحيحاً ، كالقسمة فى القوانين التى تأخذ بالاثار الكاشف لها .

ج- ان يكون التصرف صادرا من غير مالك الشيء او صاحب الحق :

اذا كان التصرف صادرا من مالك حقيقى او صاحب حق فعلى ، فلسنا بحاجة للتحدث عن التقادم .
ولكن المشكلة تظهر حينما يتضح بعد التعاقد ان البائع لم يكن مالكا للعقار بل انه باع ملك الغير ، واجتمعت الشروط الاخرى للمشتري من حسن نية وتسجيل عقد البيع ومرور خمس سنوات على ذلك فهنا يمكن اللجوء للتقادم القصير ليحمى الحائز من ان يستحق العقار من تحت يده .
اما المالك الحقيقى والذى لم يستطع استرداد ملكه لتمسك الحائز بالتقادم الخمسى الصحيح فيبقى له دعوى فى مواجهة البائع لملكه يطالبه فيها بكل التعويضات .
ويستوى ان يكون المتصرف (البائع مثلا) لم يكن مالكا للعقار فى اى وقت (بيع ملك الغير) او انه كان مالكا له لفترة معينة ثم زال سبب ملكيته له بأثر رجعى لبطلان عقد البيع او لفسخه .
ولكن يشترط فى التصرف ان يكون موجودا على الاقل ، فإذا كان معدوما فلن يمكن التمسك به ، فالتصرفات الباطلة بطلانا مطلقا والتصرفات المعلقة على شرط واقف قبل تحقق الشرط ، لن تعد سببا صحيحا لانعدام وجودها .

د- ان يكون السند مسجلا :

وهذا هو الشرط الذى يقلل من فاعلية التقادم الخمسى فى الحياة العملية ، اذ ان القاعدة فى التعامل على العقارات هى عدم انتقال ملكيتها او اى حق عيني آخر عليها من شخص لآخر ولا بالنسبة للغير الا بالتسجيل طبقا للقانون .
ويصعب على الحائز ان يسجل سند ملكيته (عقد البيع) على العقار اذا كان صادرا من غير المالك ، حيث يتطلب الامر لتسجيل عقد البيع ان يكون صادرا من المالك المقيّد باسمه فى السجلات .
ولكن ان حدث ان نجح المشتري فى تسجيل عقد بيعه فى الشهر العقارى ، فيمكن حينئذ له التمسك بالتقادم الخمسى .
ويقع عبء اثبات وجود السبب الصحيح على الحائز الذى يتمسك بالتقادم القصير ويخضع فى الاثبات للقواعد العامة حيث الامر يتعلق بتصرف قانونى صادر اليه ، فى نصاب الكتابة او ما يقوم مقامها ، وبما انه يجب ان يكون مسجلا فدائما ما سيكون مكتوبا .

س ٢٢: وضع الاثار المترتبة على التقادم المكسب؟

ثانيا . اثار التقادم المكسب (الطويل والقصير)

١- ضرورة التمسك بالتقادم :

اذا توافرت الشروط السابقة فى التقادم الطويل فإنه يلزم الحكم به ان يتمسك به الحائز امام المحكمة فالتقادم المكسب لا يرتب اثره القانونى من تلقاء ذاته او بقوة القانون بل يلزم تعبير الحائز عن رغبته فى التمتع بهذا المركز القانونى ، فالامر لا يتعلق بالنظام العام .
وان توافرت كل شروطه ولم يتمسك به الحائز فى دعوى الاستحقاق المرفوعة ضده وتكلم فى موضوع آخر كصحة سنده وعدم بطلانه فلن تستطيع المحكمة ان تحكم به من تلقاء نفسها ولو كان الحائز سيتعرض لخسران الدعوى فالمحكمة لا تقضى الا بما يطلب منها وفى حدوده والا كان حكمها معيبا مستوجبا نقضه ومرجع ذلك الى رغبة المشرع فى ارجاع الامر برمته للحائز ، الذى يكون غاصبا للشيء وتنتابه ضحوة ضمير او تأبى اخلاقه ان يأخذ مالىس من حقه وقد يرى ان الشيء من حقه فقد دفع ثمنه وان لم يسجل عقده ، فيلجأ للتقادم المكسب كطوق نجاة للذود عن حقوقه وفى جميع الاحوال يتعلق التقادم بمصالح خاصة وليس عامة .
ويستطيع الحائز التمسك بالتقادم المكسب فى اى مرحلة من مراحل التقاضى ولكن لا يجوز له التمسك به لأول مرة امام محكمة النقض .
على انه اذا نقضت محكمة النقض الحكم واعادته مرة ثانية لمحكمة الاستئناف التى اصدرته بدائرة اخرى ، فليس هناك ما يمنع من التمسك بالتقادم امام محكمة الاستئناف هنا .
ولا يقتصر حق التمسك بالتقادم المكسب على الحائز ذاته فقط ، بل يجوز ان يتمسك به كل ذى مصلحة فى اثبات الملكية او الحق العيني للحائز ، كالخلف الخاص او العام وكذلك دائى الحائز .

٢- جواز التنازل عنه :

إذا كان القانون قد اشترط ضرورة التمسك بالتقادم لتقضى به المحكمة فهل يمكن ان يتنازل الحائز عنه ؟
المفروض ان يكون التقادم المكسب قد اكتملت مدته لكى يمكن الكلام عن التمسك به او جواز التنازل عنه ، وهو ما سجلته المادة ٣٨٨ مدنى فى فقرتها الاولى انه "لا يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه " .

فإن اكتملت مدة التقادم فهل يجوز للحائز ان يتنازل صراحة او ضمنا عن التقادم المكسب ؟

الواضح من النصوص القانونية جواز التنازل الصادر من الحائز ، سواء أكان صراحة او ضمنا بشرط ان يكون بعد اكتمال المدة

التنازل الصريح ← لا مشكله فيه ، فبأى شكل يمكن التعبير عن الرغبة فى التنازل امام القضاء او خارج مجلس القضاء .

التنازل الضمنى ← فيستفاد من الدلائل والظروف المحيطة بالموضوع كتسليمه العقار للمالك الحقيقى ، او ابرامه عقد ايجار معه يكون هو مستأجرا للعين .

والتنازل هو تصرف قانونى من جانب واحد لا يحتاج لقبول الطرف الاخر لانتاج آثاره ، ولكن يجب ان يتوافر فيه شروط التصرفات القانونية بصفة عامة من رضا ومحل وسبب وكذلك شروط الصحة كالاهلية وخلو الارادة من العيوب ، الا فيسكون التنازل ذاته موضع طعن قانونى على صحته .

والاهلية المطلوبة لتنازل الحائز هنا هى اهلية التبرع ، حيث يتنازل عن حق مالى له دون مقابل سيتلقاه من التنازل لصالحه ، فيبطل التنازل اذا صدر من عديم الاهلية او ناقصها .

ولكن اذا كان التنازل من حق الحائز فهل يجوز لدائنيه الطعن على هذا التنازل باعتباره تصرفا سيضر بحقوقهم او بالذمة المالية الضامنة لحقوقهم ؟

اجازت المادة ٣٨ مدنى فى فقرتها الثانية لكل شخص يملك التصرف فى حقوقه ان ينزل ولو ضمنا عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه على ان هذا النزول لا ينفذ فى حق الدائنين اذا صدر اضرارا بهم ، فللدائنين الطعن بالدعوى البوليصة (عدم نفاذ التصرفات) على هذا التنازل اذا كان سيضر بحقوقه فالتنازل عن التقادم يعادل التنازل عن الحق ذاته .

٣- حظر الاتفاق على تعديل مدد التقادم وشروطه :

تعد احكام التقادم عموما (المكسب او المسقط) من النظام العام فى مددها وشروط سريانها لا فى ضرورة التمسك بها او جواز التنازل عنها ، فلا يجوز للأفراد الاتفاق على تطويل مدد التقادم او تقصيرها على خلاف القواعد القانونية ، كما لا يجوز الاتفاق على حذف او اضافة شرط لم يأت به النص القانونى . ويقع اى اتفاق على خلاف ذلك باطلا مطلقا وتطبق الاحكام القانونية .

٤- ما يكسبه الحائز :

يكسب الحائز باكتمال شروط التقادم وتمسكه به ملكيه العقار المحوز بما يتبع ملكيته من حقوق ارتفاق لعقاره على العقارات الاخرى ، كحق ارتفاق او انتفاع فيكسب الحائز هذا الحق وحده .

كما يكسب الحائز ملكيه الشيء (العقار) بما له من حقوق عينية اخرى قائمة .

فإذا كان العقار المحوز محمل بتكاليف عينية (حق مرور او حق ارتفاق) او حقوق عينية تبعية (مرهون رهنا رسميا- محمل بحق امتياز) فتظل هذه الحقوق محملة على العقار المحوز مالم تسقط او تنتهى بأسبابها الخاصة .

فإذا كان مالك الشيء قد رتب عليه ، قبل بدء سريان التقادم ، حقا عينيا اصليا كحق ارتفاق او انتفاع ، فإن مجرد التقادم الذى ترتب عليه كسب الحائز للملكية لا يؤدى الى سقوط حق الانتفاع او الارتفاق ، مالم يكن صاحب هذا الحق نفسه قد امتنع بسبب الحيابة عن استعماله مدة خمس عشرة سنة فإن هذا الحق يسقط لعدم الاستعمال .

٥- الأثر الرجعى للتقادم :

ايضا يترتب على اكتمال مدة وشروط التقادم المكسب ، اعتبار الحائز مالكا للشيء المحوز ، او صاحب الحق العيني الاصلى المقرر عليه منذ بدايه مدة التقادم وليس منذ اكتمال هذه المدة فالتقادم له اثر رجعى

فإذا حاز شخص ارضا زراعية منذ او يناير عام ١٩٩٥ وظل حائزا لها حيابة قانونية فيحق له ان يملكها بالتقادم الطويل ، اى نهاية ٢٠١٠/١٢/٣١ وعند اكتمال هذه المدة يعد الحائز مالكا للارض ليس من بداية ٢٠١٠/١/١ بل اعتبارا من تاريخ بدء الحيابة ووضع اليد فى ١٩٩٥/١/١ فالتقادم له اثر رجعى .

- ويترب على ذلك نتيجتان هامتان ← تتعلق الأولى بتملك الحائز للثمار ، والثانية بسقوط الحقوق التي رتبها المالك السابق على الارض بعد بدء التقادم وبقاء الحقوق التي رتبها الحائز بعد بدء التقادم .
- فالنسبة للثمار ← يعد الحائز مالكا للثمار التي سيقبضها المدنية او الطبيعية وتعد كل تصرفاته صحيحة في الشيء المحوز وذلك بإعتباره مالكا للشيء وليس حائزا له .
- وبالنسبة للحقوق العينية ← التي رتبها المالك السابق على الشيء بعد بدء التقادم فتعتبر هذه التصرفات تمت على ملك الغير ولا تنفذ في حق المالك الحقيقي الا بإقرارها منه ، اما التصرفات التي رتبها هو (الحائز) على الشيء بعد بدء الحيازة فتعد صحيحة مطلقا .

٦- بقاء الدعاوى الشخصية في مواجهة الحائز :

- واذا كان التقادم المكسب يجعل الحائز مالكا للشيء محل الحيازة فلا بد وان نلاحظ انه ليس من شأن ذلك ان يؤثر على الدعاوى الشخصية التي يمكن ان توجه الى الحائز بسبب التصرف الذي نقل اليه حيازة الشيء الذي تملكه بالتقادم كدعوى الفسخ والبطالان ، مالم تكن هذه الدعاوى قد سقطت بالتقادم فإذا كان التصرف الذي تلقى به الحائز الشيء الذي تملكه بالتقادم قابلا للفسخ ، او للابطال جاز للمتصرف رفع دعوى الفسخ او البطلان فإن افلح في كسب دعواه كان له استرداد الشيء من الحائز رغم انه كان قد تملكه بالتقادم .

٧- تخلف التزام طبيعي عن التقادم المكسب :

- كما يتخلف التزام طبيعي عن الالتزام الذي ينقضي بالتقادم المسقط ، فإنه يتخلف التزام طبيعي عن الحق الذي يكسب بالتقادم المكسب ، فإذا ملك الحائز العين بالتقادم المكسب ولم يكن قبل التقادم مالكا لها ، فإنه بالرغم من تملكه العين بالتقادم يبقى ملتزما بالتزاما طبيعيا نحو المالك الحقيقي برد العين اليه .

"ملك المنقول (فورا) بالحيازة (قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية)"

- نظمت المادة ٩٧٦ مدني كسب ملكية المنقول بالحيازة ، فورا بشروط معينة فنصت على انه :

 - ١- من حاز بسبب صحيح منقولا او حقا عينيا على منقول او سندا لحامله فإنه يصبح مالكا له اذا كان حسن النية وقت حيازته .
 - ٢- فإذا كان حسن النية والسبب الصحيح قد توافر لدى الحائز في اعتبار الشيء خاليا من التكاليف والقيود العينية فإنه يكسب الملكية خالصة منها .
 - ٣- والحيازة في ذاتها قرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية مالم يقيم الدليل على عكس ذلك .

اولا : اهمية اكتساب ملكية المنقول بالحيازة

- تولي القوانين بصفة عامة اهمية خاصة لاكتساب ملكية المنقول وأثبتت هذه الملكية حيث المنقولات عامة يسهل تداولها وانتقالها من يد لآخر ، ولكثرتها وتنوعها بين الحيوانات والجمادات ، فلم تشترط القوانين ضرورة تسجيل التصرف الناقل للملكية في الشهر العقاري كشرط لنقل الملكية بين الطرفين ، لصعوبة تطبيق ذلك عملا على كافة المنقولات .
- اذا فكيف يستطيع الحائز اثبات ملكيته لمنقولاته ، والفرض انه اشتراها او حازها دون ان يهتم بالاحتفاظ بسندات الملكية كالثياب والأثاث والأطعمة والحيوانات وأجهزة المحمول والكمبيوتر .
- اذا فلم يبق الا حماية حيازة المنقول في حد ذاتها ، لذا برزت قاعدة (الحيازة في المنقول سند الحائز او المالك)

ب- وباتت للحيازة في المنقول عامة دورين رئيسيين :

- الدور الاول : الاثبات ← فالمنقولات تنتقل ملكيتها بين الافراد بمجرد التعاقد ، شفويا او كتابة ، كالحيوانات والمأكولات والثياب .
- وعند المنازعة في ملكية شخص ما للمنقولات الحائز لها ، فلا يبقى في يده من دليل على ملكيته الا الحيازة ، فحيازته الصحيحة للمنقولات تعد وسيلة اثبات هامة يدفع بها الحائز دعوى اي شخص ينازعه في ملكيه المنقول ، ويبقى عبء اثبات الملكية على عاتق المدعى وليس للحائز .
- اما الدور الثاني : فهو اكتساب ملكية المنقول بالتقادم ← فمن حاز منقولا حيازة قانونية يستطيع ان يكسب ملكيته ، حتى وان كان غاصبا له وسيئ النية ، بمرور مدة التقادم الطويل اي خمس عشرة سنة من تاريخ الحيازة .

س ٢٣: وضع شروط كسب ملكية المنقول بالحيازة الفورية؟

ثانيا : شروط كسب ملكية المنقول بالحيازة الفورية

الشرط الاول : ان يتعلق الامر بالمنقول :

القاعدة :

تنطبق قاعدة الحيازة فى المنقول سند المالك على المنقولات بصفة عامة سواء أكانت منقولات بطبيعتها او عقارات بالتخصيص وهى المنقولات التى وضعها مالکها فى خدمة عقاره كحيوانات المزرعة واوداتها ومستلزماتها من اسمده وبذور والآت رى وادوات زراعة .

اما المنقولات بحسب المآل فلا تنطبق القاعدة عليها الا بعد هدمها او قطعها او قطفها حيث تسرى القاعدة على الثمار بعد قطفها ، والاشجار الخشبية بعد قطعها ومتخلفات الهدم كالابواب القديمة او الحديد او المواسير والطوب .

الاستثناءات :

يستثنى من تطبيق القاعدة السابقة المنقولات التى لا تخضع للحيازة (المنقولات المعنوية) والمنقولات التى يشترط القانون تسجيلها لنقل ملكيتها (شبه العقار) ، ومجموعات الاموال والمنقولات المملوكة للدولة .

١- المنقولات المعنوية :

لا تسرى القاعدة على المنقولات المعنوية ، كالديون وبراءات الاختراع وحق المؤلف والعلامات التجارية والاوراق التجارية التى تنتقل بالتحويل او التظهير .

اما السند لحامله فتد عليه القاعدة حيث يختلط الجانب المعنوى بالورقة ذاتها ويصبحان شيئا واحدا ، بحيث اذا وضع شخص يده عليه بحسن نية وبسبب صحيح تملكه لأنه حامله ، وجاز له صرف المبلغ المدون فيه ، فالسند لحامله ينتقل الحق فيه لحامله عن طريق المناولة من يد الى يد فأى شخص يحمل السند يكون هو الدائن .

٢- المنقولات التى يسرى عليها قواعد التسجيل (شبه العقار) :

وهى التى يشترط التسجيل طبقا للقانون لنقل ملكيتها بين اطرافها او بالنسبة للغير وهى الطائرة والسفينة والسيارة .

٣- المجموعات القانونية :

وهى المجموع من المال والتى تضم عقارات ومنقولات مادية ومعنوية مختلفة ومتنوعة .
فالتركة منظورا اليها بمجموعها ، عبارة عن الذمة المالية عند الوفاة ، فهى بهذا الاعتبار شئ غير مادي ، بل مجموع من المال يحوى عناصر مختلفة من الاموال العقارية والمنقولة ، والمحال التجارية تحوى بجانب المنقولات المادية من بضائع وارفف واجهزة حفظ او عرض او بيع ومبانى ومخازن ، تحوى ايضا عناصر معنوية ن السمعة والاتصال بالعملاء والاسم التجارى والعلامة التجارية ، وهى فى مجملها مجموعة متنوعة من المنقولات المادية والمعنوية يصعب القول بحيازتها .

٤- المنقولات المملوكة للأشخاص العامة :

تستثنى ايضا من الخضوع للقاعدة المنقولات المملوكة للدولة او لاحد الاشخاص المعنوية العامة كالتماثيل والمنقولات الاثرية والوثائق القومية المحفوظة لدى الجهات المعنية من وزارات ومكاتب ودار الكتب ومقتنيات المتاحف العامة ، والذخائر والاسلحة والمهمات الحربية ، والمنقولات المخصصة للمنفعة العامة .

حيث تستطيع الدولة تتبعها واستردادها من حائزها ولو كان حسن النية ، ولا يستطيع الحائز التمسك بتملكها بالتقادم الطويل ١٥ سنة على حيازتها .

الشرط الثاني : الحيابة القانونية :

التي يجتمع لحائزها العنصرين المادى والمعنوى ، وتكون خالية من عيوب الحيابة ، حيث يضع الحائز يده على منقول مادى تجوز حيازته بينه تملكه او اكتساب الحق العيى الذى يمكن ان يرد على المنقولات كحق الاستعمال وحق الرهن الحيازى والامتياز والانتفاع ، اما الحائز العرضى للمنقول فلا تصح حيازته لاكتساب الملكية مهما طال الزمن كالمستأجر للمنقول او المستعير له .
فإن شاب الحيابة احد عيوبها من اكراه او غموض او خفاء فلا تنتج آثارها حيث لم تعد قانونية .
ويجب فى حيازة المنقول ان تكون حيازة حقيقة ، فالحيابة الرمزية فى المنقول لا تكفى لتطبيق القاعدة ، كما اذا تسلم شخص البضائع المعهود بها الى امين النقل او المودعة فى المخازن عن طريق تسلمه سنداتھا .
اما الحيابة الحكمية والتي تتم بمجرد تغيير النية فلا تصلح ايضا لتطبيق القاعدة اذا لم يتسلم المشتري المنقول فعلا .
وتستقل محكمة الموضوع بتقدير مدى كون الحيابة حقيقة من عدمه .

الشرط الثالث : السبب الصحيح :

حيث يتلقى الحائز للمنقول الحيابة مستندا لسبب صحيح ، اى تصرف قانونى ناقل للملكية ، صادرا من غير صاحب الحق على المنقول .
ولكن شرط ان يكون السبب الصحيح مسجلا لا يسرى هنا ، حيث الامر يتعلق بمنقولات لا يشترط القانون تسجيلها لنقل الملكية بين الطرفين او بالنسبة للغير .
والسبب الصحيح هنا قد يكون عقد بيع صحيح ، ولكن البائع فسخ او ابطال عقده الاول ، وبما ان المشتري فى العقد الباطل او المقضى بفسخه كان قد اعاد بيع المنقول لمشتري جديد ، فيحق للمشتري الجديد التمسك بقاعدة الحيابة فى المنقول بحسن نية وبسبب صحيح سند الحائز ، ولا يرد المنقول وينحصر اثر البطلان او الفسخ فى التعويضات .

الشرط الرابع : حسن النية :

ويعنى ان الحائز يجهل انه يعتدى على حق الغير ، ان يعتقد وقت تلقيه الحق انه يتعامل مع شخص ذو صفة فى التصرف فى المنقول ، بعوض او بدون عوض ، على الا ينسب للحائز اى خطأ جسيم ، او يكون قد اكتسب حيازة المنقول بالاكره والغصب فالاكراه يتنافى بدهاة مع حسن النية .

افتراض المشرع وجود السبب الصحيح وحسن النية لدى حائز المنقول :

وتخفيفا على حائز المنقول فقد اقام المشرع قرينة لصالحه ونص على أن الحيابة فى ذاتها قرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية ، ما لم يقيم الدليل على عكس ذلك ، فإن احتج عليه شخص آخر فى ملكيته للمنقول فعلى المدعى اثبات انتفاء السبب الصحيح او النية الحسنة لدى الحائز .
وهو فرق جوهرى مع التقادم الخمسى على العقارات ، حيث الزم القانون الحائز والذي يرغب فى التمسك بالتقادم الخمسى ان يقيم الدليل على وجود السبب الصحيح لديه ، وان يكون السبب الصحيح مكتوبا .

ثالثا : آثار الحيابة فى المنقول (الآثار المكسبة ، والآثار المفقطة) :

١ - الآثار المكسبة :

بتوافر الشروط الاربعة يصبح الحائز مالكا للمنقول محل الحيابة ، وفورا اى لا يحتاج لمرور فترة زمنية لتملكه المنقول بل يملكه فور حيازته .
ويكتسب الحائز الحق العيى الذى يقصد حيازته ، وليس الملكية فقط ، بل قد يكون حق عيى اصلى او تبعى اخر ، كحق الانتفاع او الاستعمال او الرهن الحيازى او حق الامتياز ، وفى خصوص امتياز صاحب الفندق على امتعة النزىل عن اجرة الاقامة وما صرف لحسابه "ويقع الامتياز على الامتعة ولو كانت غير مملوكة للنزىل اذا لم يثبت ان صاحب الفندق كان يعلم وقت ادخالها عنده بحق الغير عليها ، بشرط الا تكون تلك الامتعة مسروقة او ضائعة " وكذلك الشأن بالنسبة لإمتياز المؤجر على منقولات المستأجر الموجودة بالعين ، ولو كانت مملوكة لزوج المستأجر او للغير ولم يعلم المؤجر وقت وضعها بالعين بحق الغير عليها .
ويستطيع الحائز بمقتضى الآثار المكسبة للقاعدة دفع دعوى الاستحقاق التى يرفعها المالك عليه لاسترداد المنقول وايضا يستطيع دفع دعوى الابطال او الفسخ التى يرفعها عليه شخص اخر .
ومع ذلك تبقى الدعاوى الشخصية الناشئة عن عيوب السبب الصحيح ، كما اذا كان التصرف ذاته الذى تلقى به الحائز المنقول من غير المالك قابلا للابطال او كان الحائز يستحق جزاء الفسخ لخلاله بالتزاماته (لم يدفع باقى الثمن للمتصرف غير المالك) .

٢- الاثر المسقط :

- الاثـر الثـانى للقاعدة هو سقوط جميع الحقوق والتكاليف المقررة على المنقول محل الحيازة فيتملك الحائز المنقول خالصا مطهرا منها ، وذلك بشرط ان يكون حسن النية والسبب الصحيح قد توافر لدى الحائز فى خلو المنقول من هذه الحقوق والتكاليف اى انه لحظه انتقال الحق للحائز كان يعتقد بعدم وجود اى حق للغير على المنقول .
- فإذا استطاع النزىل فى الفندق اخراج الامتعة المحملة بحق الامتياز لصاحب الفندق وباعها فى السوق لمشتري حسن النية او استطاع المستأجر اخراج منقولاته من العين المؤجرة وباعها لمشتري حسن النية فإن المشتري فى الحالتين يـتملك المنقول خاليا من اى حقوق امتياز كانت ملحقه به ، حيث لديه حسن نية وسبب صحيح فى اعتبار المنقول خاليا من اى قيود للغير عليه .
- والاثر المسقط للحيازة لا يزيل التكاليف التى كانت على المنقول فقط ، بل يؤدى ايضا الى سقوط القيود العينية كشرط المنع من التصرف ، فإذا وجد هذا الشرط وتصرف المالك فى المنقول رغم ذلك وتسلمه المتصرف اليه وهو حسن النية غير عالم بوجود هذا الشرط فإنه لا يجوز لمن تقرر المنع لمصلحته ان يحتج به على الحائز .

س ٢٤ : وضع حكم المنقولات المسروقة او الضائعة ؟

رابعا : حكم خاص بالمنقولات المسروقة او الضائعة :

- رأى المشرع ان تطبيق احكام قاعدة الحيازة فى المنقول سند الملكية ما قد يؤدى لانتشار السرقات والتصرف فى الاشياء المفقودة والضائعة .
- فالسارق يبغى دائما التصرف فى المسروقات ، وبأى سعر ، حتى لا تضبط لديه وينتهز بعض الاشخاص هذه الفرصة ويشتررون هذه المنقولات بأبخس الاسعار اعتمادا على ان الحيازة فى المنقول سند الملكية .

مركز

لذا اراد المشرع التوفيق بين حق مالك الشئ المسروق او الضائع فى استرداده ، وبين حق الحائز حسن النية ، ولديه سبب صحيح ، فى التمسك بالقاعدة

- يجوز لمالك المنقول او السند لحامله اذا فقده او سرق منه ، ان يسترده ممن يكون حائزا له بحسن نية وذلك خلال ثلاث سنوات من وقت الضياع او السرقة .
 - فإذا كان من يوجد الشئ المسروق او الضائع فى حيازته قد اشتراه بحسن نية فى سوق او مزاد علنى او اشتراه من يتجر فى مثله ، فإن له ان يطلب ممن يسترد هذا الشئ ان يعجل له الثمن الذى دفعه .
- وبناء عليه فقد غلب القانون حق مالك المنقول المسروق او المفقود فى استرداده على حق الحائز حسن النية** وبذلك تعطل القاعدة ، حيث سمح القانون للمالك برفع دعوى الاسترداد من الحائز ولو كان حسن النية ، اما ان كان الحائز سيئ النية ويعلم ان المال مسروق فقد يعد مشتركا فى جريمة السرقة بإخفاء اشياء مسروقة .
- الشرط الاساسى هنا ان يرفع المالك دعوى الاسترداد خلال ثلاث سنوات من وقت الضياع او السرقة ، وهذه مدة سقوط لا مده تقادم فلا تقبل الوقف او الانقطاع ، وذلك ان كان الحائز حسن النية ، اما الحائز سيئ النية فيحق للمالك استرداد المنقول من تحت يده ، مالم يملكه الحائز بالتقادم الطويل (١٥ سنة) .
- قيـد على حق الاسترداد هنا :**
- اراد المشرع التوفيق بين حق المالك وحق الحائز حسن النية ، فحق المالك فى الاسترداد قائم لا محالة ، ولكن الحائز حسن النية قد يكون دفع ثمن المنقول المسروق او الضائع .
 - فهل يجوز له مطالبة المالك برد ما دفع من ثمن قبل تسليمه المنقول ؟**
 - اجاب المشرع بالإيجاب هنا** ← ولكنه قيد المطالبة بكون الحائز حسن النية كان قد اشترى المنقول من سوق او من مزاد علنى او من شخص يتاجر فى مثل هذا المنقول ، فليس حسن النية هنا فقط هو السبب فى التمسك برد ما دفعه من ثمن بل ان كل الظروف الخارجية تؤيد حق الحائز .
 - والقول بغير ذلك يؤدى لقلق واضطراب المعاملات وتعطيل حركة تداول المنقولات فالاسواق مليئة بالمنتجات والبضائع والحيوانات ، وكلها تباع وتشترى بالتراضى .

- ❖ فالمالك ان اراد استرداد منقولاته عليه بتعجيل الثمن اولا لحائزها حسن النية اذا كان اشتراها من الاماكن السابقة ، ويحق للحائز حبس المنقول تحت يده لحين استلام الثمن وهو ما يحجم عملا حق الاسترداد للاشياء المسروقة او الضائعة .
- ❖ ولا يمنع هذا مالك المنقول من مطالبة السارق او المتصرف فى المنقول الضائع بالتعويضات ان امكن التعرف عليه .

" كسب ملكية الثمار "

- ❖ الحائز للشيء يملك الثمار التى ينتجها الشيء فورا ودون حاجة لمرور فترة من الزمن بل يملكها فور قبضها اولا بأول اذا كانت الثمار مدنية .
- ❖ وثمار الشيء هى ما يتجدد دوريا دون ان ينتقص من اصل الشيء وهو اما ثمار طبيعية كالكلا ، واما مستحدثة بفعل الانسان كالفاوة بأنواعها ، واما ثمار مدنية كأجرة الاماكن المؤجرة ، والثمار غير المنتجات والتى تتجدد مع الانتقاص من اصل الشيء كالمناجم والمحاجر والنفط والغاز ولا تنطبق هذه القاعدة على المنتجات .
- ❖ والاصل ان الحائز يملك الشيء ذاته منتج الثمار ولكن ان تخلفت شروط تملكه للشيء كأن يكون عقده قابلا للابطال ، او وقع فسخه ، او لم تكتمل للحائز حسن النية مدة التقادم ، او كان قد اشترى المنقول المسروق من شخص لا يتأجر فى مثله واستطاع المالك الحقيقى فى الحالات السابقة استرداد الشيء من الحائز فإن القاعدة كانت توجب على الحائز اعادة ما قبضه من ثمار الشيء لذلك قرر المشرع حق الحائز فى تملك الثمار فورا .
- ❖ واساس قاعدة تملك الثمار بالحيازة ، هو ان الحائز الذى يضع يده على الشيء معتقدا بحسن نية بأنه هو مالكة غالبا ما يكون قد بذل جهدا وانفق فى سبيل العناية به والمحافظة عليه ما انفق فيكون من الجور ان نتعمد الاضرار به فنستعيد منه ثمار الشيء التى قبضها .

س ٢٥: وضع شروط كسب الحائز ملكية الثمار؟

شروط كسب الحائز ملكية الثمار :

١- قبض الثمار :

- ❖ يلزم لكسب الحائز للثمار ان يكون قد قبضها اما تلك التى لم يقبضها فلا سلطان له عليها ، ذلك ان الثمار التى قبضها غالبا ما يكون قد استهلكها فيكون الزامه بردها اقرار له ، اما الثمار التى لم يقبضها بعد فقد تبين انها مملوكة لغيره فلا يصح ان يملكها الحائز .
- ❖ **القبض** ← يعنى الاستيلاء الحقيقى عليها ، بفصلها وحيازتها فى الثمار الطبيعية والمستحدثة واولا بأول فى الثمار المدينة فالثمار الطبيعية والمستحدثة كالكلا والمحاصيل الزراعية يكون الحائز قد قبضها بانفصالها عن الارض بغض النظر عما اذا كان قد استهلكها اما الثمار المدنية كالاجرة التى يلتزم بها المستأجر فتعتبر مقبوضة يوما بيوما .
- ❖ يترتب على ذلك انه اذا رفعت يد الحائز قبل ان يقبض الاجرة التى استحققت عن مدة وضع يده بحسن نية فإن المالك يلزم بأن يؤدى للحائز الاجرة التى تأخر دفعها ، اما ان كان الحائز قد قبض جزءا منها معجلا قبل انقطاع حيازته او سوء نيته ، فإنه يلزم بأن يرد للمالك ما قبضه معجلا من الثمار الحديثة .

٢- حسن النية :

- ❖ يشترط ثانيا لكسب ملكية الثمار ان يكون الحائز حسن النية ، اى يجهل انه يعتدى على حق الغير بغير خطأ غير مغتفر او خطأ جسيم او غصب للحيازة فيحق له ان يكتسب الثمار التى قبضها طالما كان حسن النية ولم تنقطع حيازته للشيء وحسن النية مفترض وعلى من يدعى العكس عبء الاثبات .
- ❖ العبرة فى توافر حسن النية هو لحظة قبض الثمار .
- ❖ ان كان الحائز سيئ النية فلا يملك الثمار التى قبضها ويعنى سوء النية انه يعلم انه ليس له الحق فى قبض الثمار وانه يعتدى على حق الغير ، وتسوء نية الحائز اذا ما رفع المالك دعوى استرداد ملكية عليه (دعوى الاستحقاق) وفى هذه الحالة لا يجوز للحائز ان يثبت حسن نيته من يوم رفع الدعوى .
- ❖ فإن ثبت سوء النية فإن القانون يعامل الحائز سيئ النية معاملة يستحقها ، حيث يحاسبه على الثمار التى قبضها فعلا والتى قصر فى قبضها ، حيث يستطيع المالك مطالبة بكل الثمار التى قبضها والتى اهمل وتركها تتلف على الشجر او فى الارض وضاعت فرص جمعها على المالك بخطأ الحائز .

ان اجازت هذه المادة للحائز سيئ النية المطالبة بالنفقات التي انفقها فعلا فى انتاج هذه الثمار .
مما سبق يتبين انه يشترط وجود السبب الصحيح لاكتساب ملكية الثمار بالقبض كما هو الحال بالنسبة
لتملك المنقول بحسن نية وبسبب صحيح ، ولكن من الناحية العملية لا يتصور ان يتمسك الشخص
بحسن نيته اذا لم يكن يستند لوجود سند او سبب لانتقال الحق والحيازة اليه وبالتالي لكسبه ثمار الشيء
فوجود السبب الصحيح يؤكد حسن نية الشخص .

س ٢٦: وضع حق الحائز فى استرداد المصروفات ومسئوليته عن هلاك الشئ ؟

" حق الحائز فى استرداد المصروفات ومسئوليته عن هلاك الشئ "

اولا : حق الحائز فى استرداد المصروفات :

- قسم المشرع المصروفات لثلاثة طوائف الاولى مصروفات ضرورية ، والثانية نافعة ، والثالثة كمالية ، ووضع حكما لكل منها :
- المصروفات ضرورية :** وهى اللازمة لحفظ الشئ من الهلاك فيجوز للحائز استردادها مطلقا
وكاملا ، فعلى المالك الذى يرد اليه ملكه ان يؤدى للحائز جميع ما انفق من المصروفات
الضرورية منعا للاثراء على حساب الحائز دون سبب .
 - المصروفات النافعة :** وهى التى تزيد من قيمة الشئ ولكن ليست لازمة لحفظه من الهلاك ،
كغرس الارض بالاشجار المثمرة ، او اضافة بعض الاجزاء للمبنى او انشاء قنوات الري ،
فيعامل البانى او الغارس سيئ النية معاملة قاسية حيث يجوز لمالك الارض طلب ازالة
المنشآت ، واعادة الارض لسابق عهدها او طلب استبقائها مع دفع قيمتها مستحقة الازالة .
 - البانى حسن النية** ← وهو من يعتقد انه يبني فى ملكه ، او ان مالك الارض يوافق على ما يقوم به من
منشآت فلا يحق لمالك الارض طلب نزعها ولكن يملكها على ان يرد اما ما انفق البانى او ما زاد على ثمن
الارض بسبب هذه المنشآت .
 - المصروفات الكمالية :** وهى ما يصرف على الشئ لتحسينه او تجميله كإعادة طلاء الجدران
والاسقف ، وزرع الورود واشجار الزينة وتغيير الاضاءة وعمل رسومات ومناظر على الجدران والسقف
فقد نص القانون بعدم احقية الحائز فى استرداد هذه المصروفات وان اجازت له نزعها بشرط ان يعيد
الشئ لحالته الاولى ، الا اذا اختار المالك استبقائها فإختيار المالك مقدم على الحائز ، وعلى المالك حينئذ
ان يدفع قيمتها على انها مستحقة الازالة .

ثانيا : مسؤولية الحائز عن الهلاك :

اذا ما هلك الشئ تحت يد الحائز ، فهل يلزم تعويض المالك عن الهلاك ؟
الحقيقة ان الامر يختلف بحسب حسن او سوء نية الحائز .

١ - الحائز حسن النية :

- اذا كان الحائز حسن النية وانتفع بالشئ وفقا لما يحسبه من حقه فلا يكون مسئولا قبل من هو ملزم برد
الشئ اليه عن اى تعويض بسبب هذا الانتفاع .
- ولا يكون الحائز مسئولا عما يصيب الشئ من هلاك او تلف الا بقدر ما عدا عليه من فائدة ترتبت على
هذا الهلاك او التلف .
- فإذا كان الحائز حسن النية ، اى يجهل انه يعتدى على حق الغير ، وكان ينتفع بالشئ طبقا لما يفعله اى
شخص فيما يملك ، فلا يسأل عن هلاك الشئ قبل المسترد او المالك له ، ولا عن اى تعويض له ، مالم
يدخل فى ذمته اى مبلغ من الهلاك او التلف كتعويضات قضى بها من التأمين عليه او تعويضات تسلمها
من الدولة او الجهات المختصة .

٢ - الحائز سيئ النية :

" اذا كان الحائز سيئ النية فإنه يكون مسئولا عن هلاك الشئ او تلفه ولو كان ذلك ناشئا عن حادث
مفاجئ ، الا اذا ثبت ان الشئ كان يهلك او يتلف ولو كان باقيا فى يد من يستحقه " .

🕒 الحائز سبي النية يكون مسئولاً عن هلاك الشيء أو تلفه ولو كان الهلاك أو التلف ناشئاً عن حادث مفاجئ ولا يستطيع الحائز أن يتخلص من المسؤولية إلا في حالة ما إذا أثبت " أن الشيء كان سيهلك أو يتلف ولو كان باقياً في يد من يستحقه " كهلاك الشيء بعيب فيه لا يد للحائز في حدوثه ولا سبيل إلى دفعه ، وإذا كان الشيء منقولاً سرقة الحائز فإنه يكون مسئولاً عنه وإن أثبت أنه كان سيهلك ولو في يد من يطلب استرداده .



أولاً: اجب عن الأسئلة الآتية

س ١ : **وضح الفرق بين الإستيلاء والحيازة ؟**

س ٢ : **عرف الإستيلاء على المنقول مبيناً شروطه ؟**

س ٣ : **وضح أهمية دور الحيازة في الحيازة القانونية ؟**

س ٤ : **اشرح شروط التقادم المكسب الطويل ؟**

س ٥ : **ما هي شروط التقادم الخمسي (القصير) ؟**

س ٦ : **وضح الآثار القانونية المترتبة علي التقادم المكسب ؟**

س ٧ : **اكتب في قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية ؟**

س ٨ : **وضح أسباب وقف التقادم وانقطاع التقادم المكسب الطويل ؟**

س ٩ : **اشرح بالتفصيل الركن المادي للحيازة (السيطرة علي الشيء) ؟**

س ١٠ : **اشرح بالتفصيل الركن المعنوي للحيازة (النية) ؟**

ثانياً: بين مدي صحة او خطأ العبارات الآتية:

العلامة	السؤال	م
	يتفق الاستيلاء مع الحيابة في انهما وضع يد	-١
	الاستيلاء والحيابة ترد علي المنقول والعقار	-٢
	ترد الحيابة علي الاشياء المادية والاشياء المعنوية	-٣
	الاموال الخاصة المملوكة للدولة لا يرد عليها الحيابة	-٤
	لا يجوز ان يكون الحائز شخص عديم التمييز	-٥
	يجوز ان يكون الحائز ناقص الاهلية	-٦
	تصلح الحيابة العرضية لان تتحول لحيابة حقيقية	-٧
	عيوب الحيابة مؤقتة ونسبية	-٨
	يقوم التقادم المكسب علي واقعة ايجابية بينما يقوم التقادم المقسط علي واقعة سلبية	-٩
	الانقطاع المدني والانقطاع الطبيعي للحيابة امر نسبي يستند الي عمل قانوني	-١٠
	يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه	-١١
	افترض المشرع وجود السبب الصحيح وحسن النية لدي حائز المنقول	-١٢
	للحائز حسن النية مطالبة المالك بدفع ثمن المنقول المسروق او الضائع	-١٣
	يلزم لكسب الحائز للثمار ان يكون قد قبضها بحسن النية	-١٤



القسم الثاني : التأمينات الشخصية والعينية



الصفحة	السؤال
ص: ٤	س ١: عرف الرهن الرسمي مبيناً خصائصه؟
ص: ٦	س ٢: وضح الشروط الواجب توافرها في المال المرهون رهناً رسمياً؟
ص: ٧	س ٣: وضح حكم رهن ملك الغير؟
ص: ٨	س ٤: تكلم عن التزامات الراهن في عقد الرهن الرسمي؟
ص: ٩	س ٥: وضح حقوق الراهن علي العقار المرهون؟
ص: ١٠	س ٦: وضح حقوق الدائن المرتهن في مواجهة الراهن؟
ص: ١١	س ٧: وضح آثار الرهن الرسمي بالنسبة للغير؟
ص: ١٥	س ٨: اكتب في سلطة التتبع مبيناً خيارات الحائز؟
ص: ٢١	س ٩: عرف حق الاختصاص مبيناً شروطه وآثاره؟
ص: ٢٥	س ١٠: عرف الرهن الحيازي مبيناً آثاره؟
ص: ٢٧	س ١١ : تكلم عن آثار الرهن الحيازي بالنسبة للدائن المرتهن ؟
ص: ٢٨	س ١٢ : تكلم عن آثار الرهن الحيازي بالنسبة للراهن ؟
ص: ٢٩	س ١٣ : تكلم عن آثار الرهن الحيازي بالنسبة للغير ؟
ص: ٣٠	س ١٤ : تكلم عن سلطات الدائن المرتهن في مواجهة الغير ؟
ص: ٣٥	س ١٥ : عرف عقد الكفالة مبيناً خصائصه ؟
ص: ٣٧	س ١٦ : وضح شروط واركان عقد الكفالة ؟
ص: ٤٠	س ١٧ : وضح آثار الكفالة مبيناً العلاقة بين الدائن والكفيل ؟
ص: ٤١	س ١٨ : اكتب في الدفوع الناشئة عن عقد الكفالة ؟
ص: ٤٥	س ١٩ : اكتب في دعوي الكفالة ودعوي الحلول ؟

الوجيز في التأمينات العينية والشخصية

١- ماهية الضمان العام:

☞ "أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان إلا من كان له منهم حق التقدم طبقاً للقانون".

٢- مخاطر الضمان العام:

☞ **أولاً** ← أن الضمان لا ينصب على مال معين بالذات من أموال المدين بل يقع على جميع الأموال، بحيث يضار الدائن إذا هلك هذا المال أو نقصت قيمته.

☞ **ثانياً** ← عدم كفاية أموال المدين المكونة للضمان العام، للوفاء بجميع ديونه، والدائن هنا دائن عادي ليس له سوى حق الضمان العام، فيهدده خطر الاشتراك مع غير من الدائنين من خلال الخضوع لقسمة الغرماء.

٣- وسائل حماية الضمان العام:

☞ **الدعوى غير المباشرة** ← وهي الدعوى التي يقوم برفعها الدائن على مدين مدينه للمطالبة بحقوق هذا الأخير إن هو تقاعس عن المطالبة بها.

☞ **دعوى عدم نفاذ التصرف (الدعوى البولصية)** ← وهي الدعوى التي يرمي من خلالها الدائن إلى عدم نفاذ التصرفات المدين في حقه، إذا كان من شأن هذه الأعمال أن تنقص من الضمان العام للدائنين.

☞ **دعوى الصورية** ← وهي الدعوى التي يقيمها الدائن للطعن في تصرفات مدينه التي قد تنطوي على خطر تهريب أمواله وذلك بإبرام عقود صورية.

٤- عدم كفاية وسائل المحافظة على الضمان العام:

☞ لا مناص من القول، بأن الوسائل التي تقدم ذكرها-على الرغم من أهميتها- فإنها تبدو غير كافية لحماية الدائن من مخاطر الضمان العام .

☞ استناداً على ما سبق، فإنه يتبين لنا **عدم فاعلية وسائل المحافظة على الضمان العام بالنظر لما قد يتهدهه الدائن من خطر إعسار مدينه، حيث ظهرت الحاجة إلى ضرورة وجود تأمينات أكثر فاعلية مثل التأمينات الخاصة التي تهدف إلى توفير حماية للدائن من خطر إعسار المدين أو غشيه أو إهماله.**

٥- ظهور التأمينات الخاصة:

☞ تهدف هذه التأمينات إلى توفير الطمأنينة للدائن إلى أنه سيكون في مركز قانوني ممتاز يجعله في مأمن من إعسار المدين أو مزاحمة الدائنين له عند استحقاق الوفاء بحلول أجله.

تنقسم التأمينات الخاصة إلى نوعين هما: تأمينات شخصية، وتأمينات عينية.

☞ **المقصود بالتأمينات العينية** ← هي تخصيص مال معين من جانب المدين للوفاء بحق الدائن عند حلول أجله

☞ **بينما يقصد بالتأمينات الشخصية** ← التي تعتبر الكفالة هي الصورة المثلى لها هي ضم ذمة شخص يسمى الكفيل إلى ذمة المدين في المطالبة بتنفيذ الالتزام أو هي إيجاد شخص آخر غير المدين يستطيع الدائن أن يطالبه بذات الدين، بحيث إذا لم يستطيع الدائن أن يحصل على حقه كاملاً من المدين كان له أن يرجع على الكفيل لكي يطالبه بالوفاء بالدين.

انتبه

☞ التأمينات العينية أفضل من الشخصية لأن في الأولى يكون حق الدائن مضموناً بالأموال التي خصصت للوفاء بدينه .

سوف نقسم دراسة التأمينات العينية إلى جزئين على النحو التالي:

☞ **الأول: التأمينات العينية** ← نتناول فيه الرهن الرسمي والرهن الحيازي وحق الاختصاص وحقوق الامتياز.

☞ **الثاني: التأمينات الشخصية** ← نتناول فيه عقد الكفالة.

القسم الأول : التأمينات العينية

الرهن الرسمي

س ١: عرف الرهن الرسمي مبيناً خصائصه؟

أولاً: تعريف الرهن الرسمي:

"عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقاً عينياً .

- **يتضح أن** الرهن الرسمي هو ضمان عيني يقدم بناء على عقد رسمي لصالح الدائن، وضماناً للوفاء بدينه، حقاً عينياً على عقار، دون حاجة لتخلي الراهن عن حيازة العقار المثل بالضمان.
- هو يمنح الدائن **سلطة التتبع** أي أن يقوم باستيفاء حقه في مواجهة من انتقلت إليه ملكية العقار المرهون.
- كذلك **سلطة التقديم** بمقتضاه يتقدم الدائن على الدائنين العاديين، والدائنين المرتهنين التاليين له في المرتبة في استيفاء حقه من ثمن ذلك العقار.
- الرهن الرسمي لا يترتب عليه انتقال حيازة العقار المرهون إلى الدائن فالراهن يظل محتفظاً بحيازة العقار المرهون رهناً رسمياً والانتفاع به كما يشاء.

ثانياً: خصائص الرهن الرسمي:

١- الرهن الرسمي حق عيني:

- إذ هو يمنح الدائن سلطة مباشرة على الشيء "العقار المرهون"، تمكنه من استيفاء حقه من المقابل النقدي لهذا الشيء؛ وهذه السلطة تتمثل في حق التقديم كما تتمثل أيضاً في حق التتبع، حيث يستطيع الدائن المرتهن أن ينفذ على العقار المرهون تحت أي يد ينتقل إليها هذا العقار.
- الحق العيني التبعية لا يخول للدائن بناء على الرهن الرسمي الاستئثار بشيء من منافع العقار المرهون، كما أن الحق العيني لا يحتاج به في مواجهة الغير إلا إذا تم شهره بطريق القيد الخاص بتنظيم الشهر العقاري.
- **الرهن الرسمي يختلف بمضمونه كحق عيني تبعية عن حق الملكية كحق عيني أصلي** ← وما يتفرع عنه من حقوق مثل الانتفاع والارتفاق؛ حيث أن الرهن يخول صاحبه السلطات ما يمكنه من استيفاء حقه بالأولوية من المقابل النقدي للعقار، وتختلف عما يخوله حق الملكية وما يتفرع عنه من سلطات تتضمن التصرف والاستعمال والاستغلال وهي لا تثبت للدائن المرتهن.

٢- الرهن الرسمي حق تبعية:

- يعتبر حق الرهن الرسمي من الحقوق العينية التبعية، لأنه لا يوجد مستقلاً بذاته، وإنما يكون تابعاً لالتزام أصلي يضمن الوفاء به، مما يترتب عليه وجود رابطة تبعية بين الرهن والحق الذي أنشئ هذا الرهن لضمان الوفاء به.

فالرهن يدور وجوداً وعدمياً مع الالتزام المضمون .

٣- الرهن الرسمي حق عقاري:

- فهو لا يرد إلا على العقارات، أما المنقولات فلا يجوز بحسب الأصل أن تكون محلاً للرهن الرسمي، لأن نظام الشهر الواجب اتباعه حتى ينفذ الرهن الرسمي في حق الغير يصعب تطبيقه بالنسبة للمنقولات .
- **الأصل** ← قصر الرهن الرسمي على العقارات دون المنقولات،
- **استثناء** ← جواز رهن بعض المنقولات رهناً رسمياً، مثل المحل التجاري والسفينة.

٤- الرهن الرسمي حق غير قابل للتجزئة:

- بمعنى أن العقار المرهون ضامناً في جملته وفي كل جزء منه لوفاء الدين كله وكل جزء منه.

🔴 يتبين أن عدم قابلية الرهن للتجزئة تنصرف إلى العقار المرهون وكذلك إلى الدين المضمون.

(أ) عدم التجزئة بالنسبة للعقار المرهون:

🔴 فهي تعني أن كل جزء من العقار المرهون يضمن الوفاء بالدين بأكمله. فتجزئة العقار المرهون لا تؤدي إلى تجزئة الرهن.

🔴 **تطبيقاً لذلك** ← فإنه إذا باع الراهن جزء من العقار المرهون، أو أحد العقارات المرهونة عند تعددها، فإن للدائن المرتهن أن ينفذ بكل حقه على الجزء من العقار الذي ظل على ملك الراهن، كما أن له أن ينفذ به على الجزء الذي انتقلت ملكيته إلى المشتري.

(ب) عدم تجزئة الرهن بالنسبة للدين المضمون:

🔴 فهي تعني أن كل جزء من الدين يكون مضموناً بكل العقار المرهون، فإذا وفى المدين أكثر الدين، بقيت مع ذلك كل العقارات المرهونة ضامنة ما بقى منه.

🔴 وإذا توفى الدائن تاركاً أكثر من وارث استطاع كل واحد من هؤلاء الورثة أن ينفذ بحقه على كل العقار المرهون؛ لأن كل جزء من الدين يضمنه العقار المرهون بأكمله.

إنشاء الرهن الرسمي

🔴 **إن الرهن التأميني ينشأ بمقتضى عقد هو عقد الرهن التأميني** ← وهذا العقد يلزم أن يكون صحيحاً؛ وهو في ذلك يخضع للقواعد العامة في إبرام العقود من حيث ضرورة توافر الأركان العامة للعقد وهي الرضا والمحل والسبب مع ضرورة توافر شروط الصحة، وهي الأهلية، وخلو الإرادة من العيوب وهذه هي الشروط الموضوعية لعقد الرهن.

🔴 **الأصل في العقود هو الرضائية** إلا أن المشرع قد يتدخل في بعض الأحيان ليشترط **شكل معين** لإنعقاد بعض العقود - كما هو عليه الحال بالنسبة للرهن الرسمي - فهو يعتبر من **العقود الشكلية**.

🔴 نستخلص مما سبق، أن **عقد الرهن الرسمي هو عقد شكلي**، والشكلية فيه هي الرسمية، والرسمية ركن فيه لا يقوم بدونها، فإذا ما تخلفت كان العقد باطلاً بطلائعاً مطلقاً.

الشروط الموضوعية لعقد الرهن الرسمي — الشروط الموضوعية العامة لعقد الرهن الرسمي

التراضي في عقد الرهن الرسمي

🔴 يشترط في التراضي أن يكون موجوداً وصحيحاً.

أولاً: وجود التراضي:

🔴 يجب أن يصدر الرضا من أطراف عقد الرهن الرسمي وهما المدين الراهن والدائن المرتهن.

🔴 ويلزم أن تتطابق الإرادتين بين طرفي العقد .

🔴 مع الوضع في الاعتبار، أنه الغالب أن يكون الراهن هو المدين نفسه، ولكن ليس ثمة ما يمنع أن يكون الراهن شخصاً آخر غير المدين يقوم برهن ماله ضماناً للوفاء بدين غيره ويسمى اصطلاحاً بالكفيل العيني .

🔴 تجدر الإشارة، إلى أن الكفيل العيني يخضع لأحكام الكفالة والرهن معاً.

ثانياً: صحة التراضي:

🔴 لا يكفي التحقق من وجود التراضي ، بل يجب أن يكون هذا التراضي صحيحاً وهو لا يكون كذلك إلا إذا

كان خالياً من أي عيب من عيوب الرضا، كما أنه يلزم أن يكون صادراً من شخص ذي أهلية.

الأهلية في عقد الرهن الرسمي

أولاً: أهلية المدين الراهن:

- يعتبر الرهن الرسمي بالنسبة إلى المدين الراهن عملاً من أعمال التصرف الدائرة بين النفع والضرر < تتحقق أهلية التصرف ببلوغ الشخص سن الرشد وأن يكون متمتعاً بكامل قواه العقلية وغير محجور عليه .
- إذا كان الراهن شخصاً آخر غير المدين يرهن العقار الذي يملكه ضماناً للوفاء بدين على غيره < فإن الرهن الصادر منه يعتبر من الأعمال الضارة ضرراً محضاً، ولذلك يعد رهنه من قبيل التبرع، ويلزم حتى يكون تصرفه صحيحاً أن يكون بالغاً سن الرشد وإلا وقع رهنه باطلاً بطلاناً مطلقاً.

ثانياً: أهلية الدائن المرتهن:

- يعتبر الرهن الرسمي بالنسبة للدائن المرتهن من التصرفات النافعة نفعاً محضاً < فلا يلزم أن يتوافر لديه أهلية التصرف بل يكفي توافر أهلية الاغتناء، طالما أنه بلغ سن الرشد غير محجور عليه أو حتى كان صغيراً مميزاً، حيث تكون التصرفات الصادرة منهما صحيحة وغير قابلة للإبطال.

الشروط الموضوعية الخاصة لعقد الرهن الرسمي

الدين المضمون بالرهن

- يمكن تخصيص الدين بتحديد من حيث المقدار ومن حيث المصدر، ولتحديد مصدر الدين أهمية في معرفة ما إذا كان الدين قد نشأ صحيحاً أم لا.
- يجب أن يرد تخصيص الدين في عقد الرهن، وقد يكون الدين المضمون معلقاً على شرط مستقبلي أو احتمالي .
- إذا كان الدين يحتمل الزيادة كما هو عليه الحال في حالة فتح حساب جاري، فيجب تحديد الحد الأقصى الذي ينتهي إليه.

س ٢: وضع الشروط الواجب توافرها في المال المرهون رهناً رسمياً؟

العقار المرهون "أموال المرهون"

- يشترط في المال المرهون أن يكون عقاراً وأن يكون موجوداً وقت الرهن وأن يكون معيناً تعييناً دقيقاً ومما يصح التعامل فيه وأن يكون العقار مملوكاً للراهن. وسوف نتناول هذه الشروط على النحو التالي:

الشرط الأول: الرهن الرسمي لا ينشأ حسب الأصل إلا على عقار:

- الرهن الرسمي < لا يرد إلا على عقار، المقصود بالعقار: هو كل شيء مستقر بحيزه ثابت لا يمكن نقله دون تلف، أما المنقولات بصفة عامة فلا يجوز رهنها رهناً رسمياً، بينما العقار بالتخصيص لا يرد عليه الرهن الرسمي منفصلاً عن العقار المخصص له.

- مع ذلك، فقد قرر المشرع الرهن الرسمي في بعض المنقولات التي تخضع للتصرفات الخاصة للشهر عن طريق القيد مثل المحل التجاري والسفن.

الشرط الثاني: أن يكون العقار موجوداً وقت الرهن:

- حيث يقع رهن الأموال المستقبلية باطلاً بطلاناً مطلقاً
- المقصود بالمال المستقبل < هو المال غير الموجود في ذاته وقت إبرام العقد وإن كان يحتمل وجوده في المستقبل كبناء شخص يزمع إقامته .

- بينما يرى البعض الآخر بأنه بعد صدور القانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠١ بشأن التمويل العقاري، فقد أباح المشرع رهن المال المستقبل

- ترجع العلة < في بطلان رهن المال المستقبل إلى أنه يتعارض مع مبدأ تخصيص الرهن بالنظر إلى صعوبة تعيينه تعييناً دقيقاً، هذا القول غير صحيح؛ لأنه بإمكان الشخص الذي يشتري شقة على الخريطة أن يقوم بتعيينها تعييناً دقيقاً من خلال بيان موقع وحدود الأرض المقام عليها البناء.

الشرط الثالث: أن يكون العقار أو ائمال المرهون مما يصح التعامل فيه وبيعه بالمزاد العلني:

يلزم أن يكون المال المرهون داخلاً في دائرة التعامل، فلا يجوز رهن المخدرات كونها خارجة عن دائرة التعامل، أو بصفة عامة لا يجوز رهن كل ما هو مخالف للنظام العام أو الآداب العامة، فلا يجوز رهن الأموال العامة أو الموقوفة.

ترجع العلة التي قررها المشرع من ضرورة أن يكون المال المرهون مما يصح التعامل فيه وبيعه بالمزاد العلني من أجل تحقيق النتيجة المباشرة للرهن ألا وهي تمكين الدائن المرتهن في حالة عدم استيفاء حقه من التنفيذ على العقار المرهون وبيعه بالمزاد العلني.

الشرط الرابع: أن يكون العقار المرهون معيناً نوعياً دقيقاً:

يلزم أن يكون العقار المرهون معيناً نوعياً دقيقاً وهو ما يطلق عليه اصطلاحاً بمبدأ تخصيص الرهن الذي يعتبر من أهم المبادئ في نظام الرهن الرسمي.

يلزم تعيين العقار سواء في عقد الرهن ذاته أو في اتفاق لاحق عليه حتى يكون الرهن صحيحاً بأن يحدد طبيعته أي نوعه كأن يذكر إن كان أرضاً زراعية أو بناء أو منزلاً أو حديقته، كما يجب تعيين العقار المرهون من حيث موقعه كأن يذكر المحافظة أو الشارع والرقم، أما إذا لم يعين العقار تعييناً دقيقاً يمنع الجهالة، فإن الرهن يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً.

س ٣: وضع حكم رهن ملك الغير؟

ملكية الراهن للعقار المرهون

حكم رهن ملك الغير:

يجب أن يكون الراهن سواء كان مديناً أو كفيلاً عينياً مالاً للعقار المرهون، فإذا لم يكن الراهن مالاً له، فلا يتصور أنه يستطيع إعطاء الدائن المرتهن أي حق عليه لأن فاقده الشيء لا يعطيه.

المقصود بالبرهن ملك الغير ← هو الرهن الذي يعقده الراهن باسمه وحسابه على عقار مملوك لغيره. مع الوضع في الاعتبار، أنه لا يعتبر رهنًا لملك الغير الرهن الذي يصدر من النائب عن مالك العقار حتى ولو كان قد تجاوز حدود نيابته.

يثور تساؤلاً في هذا الصدد مفاده هل يقع باطلاً الرهن الصادر من غير مالك العقار المرهون؟ وهل يكون الرهن باطلاً

بطلاناً نسبياً في حالة رهن ملك الغير كما هو عليه الحال في حالة بيع ملك الغير؟

المشرع لم يرتب البطلان في حالة عدم ملكية العقار المرهون للمدين الراهن بل يكون عقد الرهن صحيحاً، إذا أقره المالك الحقيقي بورقة رسمية

أولاً: حكم رهن ملك الغير فيما بين المتعاقدين:

يرتب عقد الرهن آثاره الشخصية فقط دون آثاره العينية بين الراهن والدائن المرتهن على أساس أن العقد نشأ صحيحاً بين طرفيه، إلا أن الرهن يقع قابلاً للإبطال لمصلحة الدائن المرتهن على الرغم من صحة العقد. كما يكون للدائن المرتهن وحده الحق في طلب إبطاله، فلا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. كما يزول حق الدائن المرتهن في طلب الإبطال إذا أجازه صراحة أو ضمناً. أو إذا آلت ملكية العقار المرهون إلى الراهن، كما أنه إذا أقر المالك الحقيقي الرهن، فإن العقد يصبح نافذاً في حقه، ويزول حق الدائن المرتهن في طلب إبطاله.

ثانياً: حكم رهن ملك الغير بالنسبة للمالك الحقيقي:

لا ينفذ رهن ملك الغير في مواجهة المالك الحقيقي إلا إذا أقره، فالعقد شريعة المتعاقدين ولا يمكن أن ينفذ أو يضر غير عاقيه أو خلفائهم، فالمالك الحقيقي يعتبر من الغير بالنسبة إلى عقد الرهن.

الشروط الشكلية لانعقاد الرهن الرسمي —

لا يكفي لإبرام عقد الرهن الرسمي توافر الشروط الموضوعية فقط بل يلزم توافر شروط شكلية .

أولاً: الرسمية كشرط لانعقاد الرهن وحكمة اشتراطه:

الرهن الرسمي عقد شكلي، فلا يكفي لانعقاده تراخي الطرفان عليه بل يلزم إفراغ عقد الرهن في ورقة رسمية .
حيث يستلزم إبرام عقد الرهن تحريره من قبل موظف خاص هو الموظف المختص بتحرير العقود أي موظفي مكاتب التوثيق التابعة للشهر العقاري.

أما بالنسبة إلى الحكمة من اشتراط الرسمية

فبالنسبة للمدين الراهن ← تعتبر الرسمية تذكيراً له بخطورة ما هو مقدم عليه من تصرف قد ينتهي بفقدان العقار المرهون .

بالنسبة للدائن المرتهن ← فالرسمية تجعله في مأمن من خطر عدم ملكية الراهن للعقار المرهون أو عدم أهليته للتصرف فيه، وبالإضافة إلى ذلك تزود الرسمية الدائن بسند قابلاً للتنفيذ يغنيه عن إجراءات التقاضي في حالة عدم وفاء المدين بالدين عند حلول أجله.

تظهر أهمية الرسمية بالنسبة إلى الائتمان العقاري ← فيما يتطلبه من تخصيص الدين المضمون بالرهن وتخصيص العقار المرهون في البيانات المتعلقة بالورقة الرسمية.

ثانياً: الجهة المخصصة بإجراء الرسمية:

تعتبر مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري هي الجهة المختصة بتوثيق عقد الرهن الرسمي، بينما إذا كان العقد أبرم في الخارج، فيمكن إجراء الرسمية في إحدى قنصلياتنا في الدولة التي أبرم فيها العقد.

ثالثاً: الجزاء المترتب على تخلف الرسمية:

إذا كانت الرسمية ضرورية لانعقاد الراهن فإن تخلفها يترتب عليه بطلان العقد بطلاناً مطلقاً ذلك أن الرسمية ركن فيه لا يقوم العقد بدونها.

آثار الرهن الرسمي

— آثار الرهن الرسمي بالنسبة إلى المتعاقدين —

س ٤: تكلم عن التزامات الراهن في عقد الرهن الرسمي؟

التزامات الراهن

أولاً: التزام الراهن بإنشاء حق الرهن:

أن الالتزام الرئيسي في ذمة الراهن هو إنشاء حق الرهن لصالح الدائن المرتهن على العقار المرهون، وهذا الالتزام يماثل التزام البائع بنقل الملكية إلى المشتري والتزام المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة.

فإذا كان العقار المرهون مملوكاً للراهن نشأ حق الرهن لمصلحة الدائن المرتهن بمجرد انعقاد العقد، بينما يشترط القانون لنفاذ الرهن في حق الغير قيد الرهن

القيد

هو الإجراء الذي يسمح بنفاذ حق الرهن تجاه الغير، فلا يستطيع الدائن المرتهن بدون قيد الراهن أن يتتبع العقار المرهون في يد الغير .

ثانياً: التزام الراهن بضمان سلامة الرهن:

الحكمة من وجود هذا الالتزام ← هو بقاء العقار المرهون محتفظاً بقيمته التي كانت عليها وقت إبرام عقد الرهن .

مع الوضع في الاعتبار، أن مضمون الالتزام بضمان السلامة هو التزام الراهن بضمان التعرض الشخصي وضمان التعرض الصادر عن الغير.

١- ضمان التعرض الشخصي:

يلتزم الراهن بأن يضمن تعرضه الشخصي القانوني والمادي، بحيث يمتنع على الراهن على أساس ضمان التعرض الشخصي القانوني بعدم الإسراع إلى شهر الحقوق التي رتبها على العقار المرهون قبل أن يقيد الدائن المرتهن حقه، لأن التصرفات التي قيدت أو التي تم شهرها قبل قيد الرهن سوف تكون نافذة في حق الدائن المرتهن .

ضمان التعرض الشخصي المادي فيلتزم الراهن بمقتضاه بالامتناع عن القيام بأي من التصرفات المادية التي يكون من شأنها الانتقاص من قيمة الضمان، حيث يجب على الراهن أن يمتنع عن هدم العقار المرهون أو نزع بعض ملحقاته.

مع الوضع في الاعتبار، أنه لا يتوقف التزام البائع عن القيام بالتصرفات الإيجابية فقط بل يمتنع عليه القيام بالتصرفات السلبية كأن يترك العقار بدون صيانة فيتهدم .

٢- ضمان التعرض الصادر عن الغير:

يلتزم الراهن بضمان التعرض الصادر عن الغير غير أنه في هذه الحالة لا يضمن سوى التعرض القانوني دون المادي.

إذا كان التعرض الصادر من الغير ليس قانونياً وإنما مادياً أي لا يستند فيه الغير إلى إدعاء حق من الحقوق، فإنه يجب على الدائن المرتهن أن يدفعه بنفسه على أساس أن الراهن لا يضمن تعرض الغير المادي.

كما لو شرع الجار في إقامة بناء يترتب عليه الإعتداء على حقوق الارتفاق للعقار المرهون أو على العقار المرهون ذاته، كان للدائن المرتهن أن يطلب من القاضي وقف هذه الأعمال من خلال إتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر.

ثالثاً: التزام الراهن بضمان هلاك أو تلف العقار المرهون:

المشرع المصري يفرق بين هلاك العقار المرهون الذي يرجع إلى خطأ الراهن وبين هلاك العقار المرهون الذي يرجع إلى سبب أجنبي.

١- هلاك العقار المرهون بفعل المدين الراهن:

فإذا حدث وتسبب الراهن بخطئه في هلاك المال المرهون كان الخيار حينئذ للدائن المرتهن بين أن يطالب بتأمين آخر أو أن يسقط أجل الدين ويستوفي حقه حالاً .

٢- هلاك العقار المرهون بسبب أجنبي:

الفرض هنا أن المدين بذل العناية المطلوبة من أجل تفادي هلاك العقار لكن رغم ذلك وقع الهلاك، ففي هذه الحالة، فإن الخيار سيكون للمدين الراهن بين أن يقدم للدائن تأميناً وافياً أو أن يوفي الدائن حقه فوراً.

بحيث إذا اختار المدين الراهن أن يقدم تأميناً كافياً عوض التأمين الذي هلك فليس على الدائن رفضه ومطالبته باستيفاء دينه؛ لأن رفضه يكون تعسفياً .

٣- انتقال حق الرهن إلى المقابل الذي سيحل محل هلاك العقار المرهون أو تلفه:

ينتقل حق الرهن إلى المقابل الذي يحل محل هلاك العقار ويكون الانتقال على أساس فكرة الحلول العيني، ومن أمثلة الحقوق التي تحل محل هلاك العقار المرهون وهي:

أ- مبلغ التعويض:

طبقاً لقواعد المسؤولية التقصيرية، فإذا تسبب شخص بخطئه في وقوع ضرر ما، فإنه يقع على عاتقه التزام بتعويض هذا الضرر، وعليه فإذا تسبب الغير في هلاك العقار المرهون، فإنه يلتزم بأن يدفع تعويضاً لمالك العقار المرهون الذي ينتقل إليه حق الرهن ليمارس عليه الدائن المرتهن حقه في التقدم والتتبع.

ب- مبلغ التأمين:

في هذه الحالة تلتزم شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين إلى المؤمن له "الراهن" بحيث ينتقل حق الرهن إليه، ليحل بذلك محل العقار الهالك أو التالف ويكون الانتقال هنا أيضاً وفقاً لفكرة الحلول العيني.

ج- مقابل نزع الملكية للمنفعة العامة:

فإذا قامت الدولة بنزع ملكية عقار مرهون من يد الراهن من أجل المنفعة العامة، فإنها تعطي لهذا الأخير تعويضاً عادلاً نتيجة ما لحقه من ضرر بسبب نزع ملكيته.

في هذه الحالة ينتقل حق الرهن إلى هذا التعويض الذي تدفعه الجهة القائمة بنزع الملكية.

رابعاً: التزام الراهن بنفقات الرهن:

نفقات عقد الرهن تكون على المدين الراهن باعتباره صاحب المصلحة في إبرام العقد فهو يوافق على الرهن مقابل حصوله على القرض من جانب الدائن.

ومع ذلك، فإن هذه القاعدة ليست من النظام العام، أي أنه يمكن الاتفاق على أن تكون نفقات عقد الرهن على الدائن المرتهن أو أن توزع هذه النفقات على طرفي العقد.

س هـ: وضع حقوق الراهن على العقار المرهون؟

حقوق الراهن على العقار المرهون

لا يترتب على الرهن الرسمي انتقال حيازة العقار المرهون من الراهن إلى الدائن المرتهن، كما هو الحال في الرهن الحيازي. إذ أن الرهن الرسمي لا ينزع العقار المرهون من يد الراهن.

أولاً: حق الراهن في التصرف في العقار المرهون:

فيحق للراهن باعتباره مالكا أن يتصرف في العقار المرهون كلياً أو جزئياً في ذات العقار أو في بعض ملحقاته.

حرية الراهن في التصرف في العقار المرهون لا يجوز أن يقيد بها اتفاقاً بينه وبين الدائن المرتهن. مع ذلك، فالتصرف الذي يقوم به الراهن إما أن يكون تصرفاً قانونياً كالبيع أو الهبة أو الرهن وإما أن يكون تصرفاً مادياً كإدخال بعض التغييرات المادية في العقار المرهون.

إذا يجب التفرقة بين التصرفات القانونية والتصرفات المادية التي يمكن أن يقوم بها الراهن على النحو التالي:

١- بالنسبة للتصرفات القانونية:

أ) التصرفات القانونية الصادرة من الراهن قبل قيد الرهن:

وبالنظر إلى أنها تؤدي إلى الإضرار بالدائن المرتهن، فلا يجوز للراهن القيام بها، لأن ذلك يعتبر بمثابة إخلالاً بالتزامه بضمان سلامة الرهن.

ب) التصرفات القانونية الصادرة من الراهن بعد قيد الرهن:

أما التصرفات القانونية الصادرة من الراهن بعد أن قيد الدائن المرتهن حقه، فلا تنفذ في مواجهته ولا يلحقه منها ضرر، وعلى ذلك يستطيع الراهن أن يتصرف بالبيع أو الهبة للعقار، ولكن الملكية تنتقل مثقلة بالرهن.

٢- بالنسبة للتصرفات المادية:

للراهن أن يقوم بالتصرفات المادية في العقار المرهون، طالما أنها لا تنتقص من الضمان إنقاصاً كبيراً. ولا يجوز للمدين الراهن القيام بالأعمال المادية التي يكون من شأنها المساس بسلامة الرهن أو الإنقاص من قيمة الضمان إنقاصاً كبيراً مثل هدم العقار.

ثانياً: حق الراهن في إدارة العقار المرهون واستغلاله:

إذا كان الرهن لا يجرد الراهن من ملكية العقار المرهون ولا من حيازته، فيبقى العقار المرهون في يده يستعمله كما كان قبل الرهن، فإذا كان العقار منزلاً وكان يسكنه استمر في سكنه وإن كان أرضاً زراعية استمر بزراعتها.

مع ذلك، تنقيد سلطة الراهن في استعمال العقار المرهون بمبدأ هام هو عدم الإضرار بحقوق الدائن المرتهن.

س ٦: وضع حقوق الدائن المرتهن في مواجهة الراهن؟

حقوق الدائن المرتهن في مواجهة الراهن

يجوز للدائن المرتهن التنفيذ على العقار المرهون، كما أنه لا يجوز أن يتفق الدائن المرتهن والمدين على أنه إذا حل أجل الوفاء بالدين ولم يتم الوفاء به أن يملك الدائن العقار المرهون مقابل الدين أو نظير ثمن معين يتفق عليه فيما بينهما.

أولاً: حق الدائن المرتهن في التنفيذ على العقار المرهون:

١- تنفيذ الدائن المرتهن على العقار في مواجهة الراهن:

فالدائن يكون له صفتان في مواجهة المدين الراهن، فله صفة الدائن العادي أي صاحب حق شخصي، وهو بهذه الصفة يكون له ضمان عام على أموال مدينه، فيكون له أن ينفذ على أي مال من الأموال المملوكة لمدينه، كما أنه له صفة الدائن الممتاز أي صاحب حق عيني تبعي، وهو بهذه الصفة يكون له ضمان خاص على العقار المرهون.

أ- حقوق الدائن المرتهن بوصفه دائن عادي:

يكون للدائن المرتهن بصفته دائناً عادياً جميع الحقوق التي تثبت للدائن العادي، فله حق شخصي على الضمان العام أي على جميع أموال مدينه الحاضرة منها والمستقبلية.

ب- حقوق الدائن المرتهن بوصفه دائناً مرتهناً:

أن حقوق الدائن المرتهن باعتباره دائناً مرتهناً تنحصر على العقار المرهون، فلا يكون للدائن المرتهن حق على أي مال آخر غير العقار المرهون. ويجب على الدائن المرتهن عند التنفيذ على العقار المرهون اتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات.

٢- تنفيذ الدائن المرتهن على العقار في مواجهة الكفيل العيني:

الكفيل العيني ← هو الشخص الذي رهن عقاره ضماناً لدين على غيره. حيث أن مسؤولية الكفيل العيني تنحصر على العقار الذي رهنه، فلا يجوز للدائن المرتهن أن ينفذ على أمواله الأخرى غير العقار المرهون.

ثانياً: بطلان شرط ملك العقار المرهون عند عدم الوفاء:

فلا يجوز للدائن المرتهن أن يتفق مع الراهن على أنه إذا لم يستوفي الدين عند حلول أجله أن يملك العقار المرهون نظير الدين أو نظير ثمن يتفق عليه فيما بينهما.

والأمر كذلك بالنسبة لشرط الطريق المهد ← حيث أنه لا يجوز للدائن المرتهن أن يتفق مع المدين الراهن على أنه إذا حل أجل الدين ولم يقوم الراهن بالوفاء به أن يبيع العقار المرهون دون اتباع الإجراءات المقررة قانوناً، كالاتفاق على البيع بالطرق الودية أو عن طريق المزاد لكن بدون تدخل من جانب القضاء.

س٧: وضع اثار الرهن الرسمي بالنسبة للغير؟

— اثار الرهن الرسمي بالنسبة إلى الغير —

❊ إذا أبرم عقد الرهن الرسمي صحيحاً بأن توافرت شروط انعقاده الموضوعية وكذلك الشكلية، فإنه يرتب آثاره بين المتعاقدين، بينما لا يرتب هذا العقد آثاره ولا ينفذ في مواجهة الغير إلا من تاريخ قيده، فلا يكون هذا العقد نافذاً في حق الغير قبل قيد العقد.

وجوب قيد الرهن للاحتجاج به في مواجهة الغير

أولاً: المقصود بالغير:

❊ هو كل شخص يمكن أن يضار من وجود الرهن أو عدمه. **منهم:** الدائنون العاديون للراهن - الدائنون أصحاب التأمينات العينية المتأخرة في المرتبة عن مرتبة الدائن المرتهن - الشخص الذي يكتسب على العقار المرهون حقوقاً عينية أصلية بعد ترتيب حق الرهن،... إلخ.

ثانياً: ماهية القيد:

❊ هو الوسيلة التي نظمها المشرع لشهر أو إعلان التصرفات المتعلقة بالحقوق العينية التبعية، والتي بدونها لا تنتج هذه التصرفات آثارها في حق الغير.
❊ ويتم القيد بإثبات البيانات الجوهرية المستخرجة من المحرر المتضمن سند إنشاء الحق في سجل خاص بمصلحة الشهر العقاري.

ثالثاً: أوجه الاختلاف بين التسجيل والقيد:

- ١- يعد التسجيل هو الطريق المقرر لشهر الحقوق العينية الأصلية، بينما يعد القيد هو الإجراء اللازم لشهر الحقوق العينية التبعية العقارية.
- ٢- أن التسجيل يؤدي إلى حفظ الحق الأصلي دون تحديد مدة معينة، بينما القيد يؤدي إلى حفظ الحق التبعية لمدة معينة يجب بعدها تجديد القيد ولا اعتبر كأن لم يكن.
- ٣- يكون التسجيل بحفظ أصل المحرر الواجب تسجيله وإثبات كافة محتوياته في دفتر الشهر، أما القيد فيتم عن طريق عمل ملخص للمحرر، وإثبات البيانات الجوهرية فقط في دفتر الشهر.

رابعاً: وقت إجراء القيد:

❊ لم يحدد القانون وقتاً معيناً لإجراء القيد في عقد الرهن، ولذلك يجوز إجراء قيد الرهن في أي وقت بعد انعقاده ولكن مصلحة الدائن المرتهن توجب الإسراع في إتمام القيد وعدم التأخر في قيد رهنه.

خامساً: الجهة المختصة بإجراء القيد:

❊ "يختص كل مكتب من مكاتب الشهر دون غيره بشهر المحررات المتعلقة بالعقارات التي تقع في دائرة اختصاصه.
❊ إذا كانت العقارات واقعة في دائرة اختصاص مكاتب متعددة، وجب إجراء الشهر في كل مكتب منها، ولا يكون للشهر الذي يتم في أحد هذه المكاتب أثره إلا بالنسبة إلى العقارات أو أجزاء العقارات التي تقع في دائرة اختصاصه...".

سادساً: تجديد القيد:

❊ يلزم حتى يظل القيد مفعوله سارياً أن يقوم ذو الشأن بتجديده قبل مضي عشر سنوات من حصوله.
❊ ترتيباً على ذلك، **يجب تجديد القيد، قبل مضي عشر سنوات على تاريخ إجرائه**، وتحسب تلك المدة بالتقويم الميلادي الذي تقوم على أساسه دفاتر الشهر، وبالطبع لا يحسب اليوم الأول أي يوم القيد ذاته ولكن يحسب اليوم الأخير.

❊ **الحكمة** ← من اشتراط تجديد القيد هي تسهيل الكشف في دفاتر الشهر العقاري.

❊ يتم تجديد القيد بطلب من الدائن المرتهن "صاحب المصلحة الأول في طلب القيد" أو خلفه.

سابعاً: محو القيد أو شطبته:

- هو إزالته إذا ما طرأ أمر يدعو إلى ذلك حتى يعلم الغير بتحرير العقار من الرهن .
- ولا يقصد بمحو القيد شطبته مادياً من السجلات بل المقصود هو التأشير على هامشه بما يفيد اعتباره غير موجود

ركز

- ومحو القيد إما أن يتم بالتراضي، أي بموافقة الدائن المرتهن، وإما بحكم نهائي .

المحو الرضائي:

- يكون محو القيد رضائياً إذا حصل برضاء الدائن المرتهن، ولا يلزم لقيامه قبول المدين الراهن .
- يجب أن يفرغ رضاء الدائن بمحو القيد في ورقة رسمية وإلا وقع باطلاً، كما يشترط أن يكون الدائن المرتهن أهلاً للنزول عن الرهن .

المحو القضائي:

- يتحقق ذلك في حالة إمتناع الدائن المرتهن أو من حل محله في الرهن عن إجراء المحو الاختياري.
- فيلجأ صاحب المصلحة في المحو إلى المحكمة "الراهن أو الحائز"، فإذا صدر حكم من المحكمة بإلغاء القيد، وكان هذا الحكم نهائياً أي غير قابل للطعن فيه بالطرق العادية، مما يسمح من التأشير بالمحو بناء على هذا الحكم، فلا يجوز التأشير بالمحو قبل أن يصبح الحكم الصادر به نهائياً .

إلغاء المحو:

- قد يطرأ من الأسباب ما يدعو بعد محو القيد إلى ضرورة إلغاء هذا المحو، كما لو تبين أن رضاء الدائن المرتهن قد شابه غلط أو تدليس أو إكراه، أو كنتيجة لإلغاء الحكم الصادر به بعد الطعن عليه بطريقة غير عادية من طرق الطعن "النقض، إلتماس إعادة النظر".
- الأصل أنه يترتب على إلغاء المحو أن تعود للقيد مرتبته الأصلية قبل المحو، ولكن المشرع - استثناء - لم يجعل لهذا الإلغاء أثر رجعي بالنسبة للقيود والتسجيلات التي أجريت ما بين المحو والإلغاء، قاصداً من ذلك حماية الغير الذي يكسب حقاً على العقار خلال هذه الفترة .

أثر قيد الرهن في حق الغير

سلطة التقدم

- المقصود بسلطة التقدم أن يتقدم الدائن المرتهن في استيفاء حقه على الدائنين العاديين والتاليين له في المرتبة، سواء بقى العقار المرهون في يد الراهن أو انتقلت ملكيته إلى الحائز، ويكون ذلك حسب مرتبته في القيد والتي تتحدد كقاعدة عامة من وقت القيد لا من وقت نشوء الحق .

أولاً: وعاء التقدم:

- يقصد بوعاء التقدم هو المال الذي يستوفي منه الدائن المرتهن حقه بالتقدم على غيره من الدائنين .
- لما كان المقابل النقدي الذي يمارس عليه الدائن المرتهن حق التقدم يتحدد بصور أصلية في ثمن العقار المرهون، كما أنه يتحدد أيضاً بصورة تبعية في كل مال يحل محل العقار المرهون.

١- ثمن العقار المرهون:

- فهذه الحالة تفترض تحويل العقار المرهون إلى مبلغ نقدي عن طريق البيع الجبري بالمزاد العلني، ومن ثم يمارس الدائن المرتهن حقه في التقدم على هذا المبلغ النقدي.

٢- المال الذي يحل محل العقار المرهون:

- يمكن للدائن المرتهن أن يمارس حق التقدم في استيفاء حقه من ثمن الأنقاض، ومبلغ التعويض ومبلغ التأمين، ومقابل نزع الملكية للمنفعة العامة.

ثانياً: تحديد مرتبة الدائن المرتهن عند النزاح:

- تحدد مرتبة الدائن كقاعدة حسب الأسبقية في القيد، فيتقدم الأسبق قيداً على من يليه في ترتيب القيد، بحيث يتقدم الدائن الأعلى مرتبة على من يليه في المرتبة .
- مع الوضع في الاعتبار، أنه تحتسب مرتبة التقدم من تاريخ القيد ولو أجرى في يوم واحد.
- فلا أسبقية** ← تعني الأسبق في التقدم، فمن كان أسبق في القيد تقدم على المتأخر، حتى ولو تقدم إثنان في ساعة واحدة، ولو كان أحدهما متأخراً بدقائق عن الآخر.
- مع الوضع في الاعتبار، أن الدائن المرتهن يتقدم على جميع الدائنين العاديين مهما كان تاريخ نشوء حقوقهم في ذمة المدين، أي حتى لو كانت حقوقهم ناشئة قبل الرهن.

ثالثاً: الحقوق التي يستوفيه الدائن بالتقدم:

١- أصل الدين:

- يجب أن يذكر المبلغ المضمون بالرهن أو أصل الدين في عقد الرهن، كما يجب ذكره كذلك في قائمة القيد، أما في حالة اختلافهما بأن ذكر في عقد الرهن قيمة أقل أو أكبر من القيمة المذكورة بالقيد فالعبرة تكون بأقل القيمتين المذكورة في عقد الرهن أو القيد.

٢- المصاريف:

- حيث تقع هذه المصروفات - بحسب الأصل - على عاتق المدين الراهن، فإذا أنفقها الدائن دون اتفاق خاص على أنه هو الذي يتحملها، كان له أن يستوفيه من المدين بضمان الرهن ذاته وفي نفس مرتبته دون حاجة إلى نص خاص.

- تتمثل في** ← نفقات العقد والقيد وتجديد القيد، فلا يدخل فيها أي مصروفات أخرى كمصاريف الدعوى التي يرفعها الدائن للمطالبة بالدين مثلاً أو مصاريف محو القيد أو إلغاء المحو.

٣- الفوائد:

- الفوائد تكون مستحقة وقت قيد الرهن، إذا كانت ذكرت في قائمة القيد، فإنها تكون مضمونة بالرهن بنفس مرتبته، بينما تكون الفوائد مستحقة بعد ذلك، إذا لم تذكر الفوائد في قائمة القيد، بحيث يمكن إجراء قيد تكميلي فتكون لها مرتبة هذا الأخير.
- فضلاً عن ذلك، فهناك فوائد يضمنها القيد بقوة القانون دون حاجة لنص خاص عليها في القائمة وتكون لها مرتبة الالتزام الأصلي ذاته وهي فوائد السنتين السابقتين على تسجيل تنبيه نزع الملكية والفوائد التي تستحق من هذا التاريخ إلى يوم رسو المزاد.

رابعاً: نزول الدائن المرتهن عن مرتبة الرهن لدائن مرتهن آخر:

- إذا كان من المتفق عليه أن الأسبقية في قيد الرهن من شأنها أن تجعل الدائن المرتهن يتمتع بمركز ممتاز على غيره من الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة في إستيفاء دينه، إلا أن هذا لا يمنع من تنازل الدائن المرتهن المتقدم في المرتبة إلى دائن آخر متأخر عنه في المرتبة، فالمسألة تتعلق بمصلحة خاصة للدائن المرتهن، لذا أجاز المشرع التنازل عن المرتبة في قيد الرهن.

١- المقصود بالتنازل عن مرتبة الرهن:

- يفترض النزول عن مرتبة الرهن وجود عدة دائنين مرتهنين لنفس العقار، فيمكن الإتفاق بين الدائن المرتهن المتقدم في المرتبة والدائن المتأخر في المرتبة على أن يتنازل الأول عن مرتبته للثاني فيصبح كل منهما في مرتبة الآخر.

٢-أسباب نزول الدائن المرتهن عن مرتبة رهنه لدائن مرتهن آخر:

❖ قد يكون التنازل عن المرتبة على أساس أن الأسبق في المرتبة أكثر ملاءمة مالية من المتأخر، وتكون بينهما روابط أو مصالح معينة، تدفع بهما إلى الاتفاق على أن التنازل يكون إما معاوضة أو على سبيل التبرع.

أ-النزول عن مرتبة الرهن تبرعاً:

❖ **الحالة الأولى** ← إذا كان للدائن المرتهن تأمين آخر غير العقار المرهون فإنه يعتمد على التأمين الآخر الذي يفي بحقه كاملاً.

❖ **الحالة الثانية** ← إذا كان الدائن المرتهن المتنازل واثقاً أن قيمة العقار المرهون، تكفي لسداد كل الديون المقيدة .

ب-النزول عن مرتبة الرهن معاوضة:

❖ قد يعتمد الدائن المرتهن إلى التنازل عن مرتبة رهنه مقابل عوض مالي يحصل عليه من الدائن المرتهن المتنازل له.

٣-شروط النزول عن مرتبة الرهن:

الشرط الأول: يجب أن يكون النزول لصالح دائن آخر له رهن مقيد على نفس العقار:

الشرط الثاني: يجب أن يكون النزول في حدود دين الدائن المتنازل وليس في حدود دين الدائن المتنازل له:

❖ **حكمه هذا الشرط** ← هي عدم المساس بحقوق الدائنين الذين يحتلون مرتبة وسطى بين المتنازل والمتنازل له.

❖ **مثال ذلك** ← إذا كان دين زيد ١٠٠٠ جنيه في المرتبة الأولى ودين عبيد ٢٠٠٠ جنيه في المرتبة الثانية ودين بكر ٣٠٠٠ جنيه في المرتبة الثالثة فإذا نزل زيد عن مرتبة رهنه إلى بكر، فإن هذا الأخير لا يستفيد من المرتبة الأولى التي حل فيها محل زيد إلا لضمان ١٠٠٠ جنيه فقط، وإلا ترتب على النزول الإضرار بالدائن عبيد.

الشرط الثالث: يجب السماح للدائنين أصحاب المرتبة الوسطى بالتمسك ضد المتنازل له بكافة الدفوع التي كان

من الجائز التمسك بها ضد المتنازل:

❖ لما كان التنازل عن القيد لا يجب أن يضر بحقوق الدائنين المرتهنين أصحاب المراتب الوسطى، أعطى القانون هؤلاء الدائنين إمكانية استعمال الدفوع التي كان من الجائز التمسك بها ضد المتنازل ومن هذه الدفوع نجد الدفع ببطالان دين المتنازل، الدفع بانقضاء الدين، الدفع بعدم تجديد القيد.

❖ تأسيساً على ذلك، يحق لعبيد في المثال السابق أن يتمسك في مواجهة بكر بكافة الدفوع التي كانت له في مواجهة زيد

❖ مع الوضع في الاعتبار، أنه يجب التأشير بالتنازل عن المرتبة في هامش القيد الأصلي حتى يكون نافذاً في مواجهة الغير.

س٨: اكتب في سلطة التتبع مبيناً خيارات الحائز؟

سلطة التتبع

المقصود بالتتبع:

❖ يقصد بسلطة التتبع أو حق التتبع هي مكنة يخولها حق الرهن للدائن المرتهن يكون له بمقتضاه أن يقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ على العقار المرهون .

شروط مباشرة سلطة التتبع:

أولاً: الشروط الخاصة بالدائن المرتهن:

❖ أن يحل أجل دينه من جهة وأن يكون حقه (حق الرهن) نافذاً في مواجهة من انتقلت إليه ملكية العقار المرهون من جهة أخرى.

(أ) حلول أجل الدين:

إن الدائن المرتهن لا يستطيع مباشرة حق تتبع العقار المرهون للتنفيذ عليه في يد الحائز إلا إذا حل أجل دينه .

(ب) نفاذ الرهن في مواجهة الغير (الحائز):

يجب أن يكون الدائن المرتهن قد قيد حقه قبل أن يسجل الشخص الحائز السند الذي انتقلت بموجبه ملكية العقار المرهون إليه، وأن يظل القيد قائماً إلى حين ممارسة حق التتبع، فإذا سقط القيد بعدم تجديده مثلاً، سقط حق الدائن المرتهن في التتبع .

فلكي يستطيع الدائن المرتهن تتبع العقار يجب أن يكون حقه على هذا العقار نافذاً في مواجهة الحائز، وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان مقيداً قبل اكتساب هذا الأخير حقه على ذات العقار، ذلك أن حق التتبع ما هو في حقيقة الأمر إلا تزام بين صاحب حق عيني تبغي هو الدائن المرتهن، وصاحب حق عيني أصلي هو المتصرف إليه، ومن المعلوم أن كلاهما لن يكون حقه نافذاً في مواجهة الغير إلا بعد شهره، ومن ثم يكون تاريخ الشهر الأمر الحاسم للتزام بينهما، وليس تاريخ إنشاء السند المنشئ للحق.

ثانياً: الشروط الخاصة بالحائز:

يقصد بالحائز ← هو من تنتقل إليه ملكية العقار المرهون بتصرف قانوني أو واقعة قانونية، أو أي حق عيني آخر قابل للرهن، دون أن يكون مسؤولاً مسؤولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن.

الشروط الواجب توافرها في الحائز

(أ) أن يكون الحائز مالكا للعقار المرهون:

لا يُعتبر الشخص حائزاً إلا إذا انتقلت إليه ملكية العقار المرهون كلها أو بعضها بغض النظر عن السبب الذي بمقتضاه تلقى الحائز هذا الحق سواء كان تصرفاً قانونياً كالبيع أو الهبة أو الوصية، أو بناء على واقعة قانونية كالتقادم المكسب.

أما من انتقل إليه حق عيني تبغي كالرهن الرسمي أو الحيازي، فإنه لا يعتبر حائزاً ولا يستعمل ضده حق التتبع .

مع الوضع في الاعتبار، أن يكون الحائز قد تملك العقار المرهون أو الحق العيني بعد قيد الرهن وليس قبل قيد الرهن .

(ب) أن لا يكون الحائز مسؤولاً مسؤولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن:

هذا الشرط يعني ألا تتوافر في الحائز صفة المديونية، كالكفيل الشخصي، فإن هذا الشخص لا يعد حائزاً للعقار المرهون على أساس أن هذا الشخص يلتزم بضمان الدين في جميع أمواله تجاه الدائن المرتهن.

ترتيباً على ما سبق، فإذا كان الحائز مسؤولاً شخصياً عن الدين، جاز للدائن المرتهن أن يُنفذ على جميع أموال الحائز بمقتضى حقه في الضمان العام بما في ذلك العقار المرهون، فلا يكون في حاجة إلى استعمال سلطة التتبع ضد الحائز.

بناءً على ذلك، لا يعتبر حائزاً من اشترى العقار المرهون من الراهن، إذا كان شريكاً في الدين سواء كان متضامناً أو غير متضامن .

أما بالنسبة إلى الوارث، فإنه لا يعتبر حائزاً، لأنه يسأل عن ديون التركة مسؤولية شخصية بحيث تكون مسؤوليته محددة بمقدار هذه التركة.

خيارات الحائز:

أولاً:- قضاء الدين:

يمكن للحائز قضاء الدين بصورة اختيارية وهو الأصل، أو قضاء الدين بصورة إجبارية وهو الاستثناء في بعض الحالات.

أ- الوفاء الاختياري للدين:

❁ إذا كان الحائز مشترياً للعقار المرهون بضمن مؤجل، فيحق للحائز أن يوفى بالضمن إلى الدائن المرتهن بدلاً من الوفاء بالضمن للبائع.

❁ يجب على الحائز أن يقضي الدين وملحقاته إلى آخر جنبيه، بحيث إذا أوفى الحائز بجزء من الدين فقط وليس بالدين كله، فإنه يجوز للدائن متابعة إجراءات التنفيذ ضده، وذلك إعمالاً لمبدأ عدم تجزئة الرهن . يستفاد من هذا النص، أنه ثبت للحائز الذي أوفى الدين مجموعة من الدعاوى يمكن أن نذكرها على النحو التالي:

١) رجوع الحائز على المدين الراهن بالدعوى الشخصية:

❁ حيث يحق للحائز أن يرجع على المدين الراهن على أساس دعوى الإثراء بلا سبب وفقاً للقواعد العامة .
❁ في هذه الحالة، يجوز للحائز أن ينفذ على جميع أموال المدين بمقتضى ماله من حق في الضمان العام.

٢) رجوع الحائز على المالك السابق للعقار المرهون بدعوى الضمان:

❁ يحق للحائز أن يرجع على سلفه الذي تلقى منه ملكية العقار المرهون بدعوى الضمان إذا كان سنده موجباً للضمان .

❁ أما إذا تلقى الحائز ملكية العقار تبرعاً من المدين الراهن عن طريق الهبة أو الوصية مثلاً، فلا يمكن له الرجوع بدعوى الضمان في هذه الحالة، حيث لا يوجد ضمان في التبرعات كقاعدة ومن ثم لا يستطيع الحائز أن يرجع على الواهب أو الموصي بشيء.

٣) حلول الحائز محل الدائن في حقوقه وتأميناته على أساس دعوى الحلول:

❁ فإذا أوفى الحائز لدائن المدين حقه، حل الحائز محل الدائن في حقوقه قبل المدين وفي كل ما يكفل هذه الحقوق من تأمينات.

❁ **قد وضع المشرع استثناء للقاعدة في مجال الرهن الرسمي تقضي بأن** "الحائز الذي حل محل الدائن الذي أوفى له حقه لا يستفيد سوى من التأمينات التي قدمها المدين، أما التأمينات التي قدمها غير المدين (الكفيل العيني والشخصي)، فإن الحائز لا يستفيد من وجود هذه التأمينات حتى لا يضر الكفيل الشخصي والعيني من تصرف المدين في العقار المرهون.

❁ **يترتب على ذلك:** أنه لا يجوز للحائز أن يحل محل الدائن في الرجوع على الكفيل الشخصي للمدين ولا على الكفيل العيني الذي قدم عيناً لضمان الدين.

ب- الوفاء الإجباري للدين:

❁ **الحالة الأولى** ← إذا كان في ذمة الحائز بسبب إمتلاك العقار المرهون مبلغ مستحق الأداء حالاً، يكفي لوفاء جميع الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار.

❁ **الحالة الثانية** ← إذا كان الدين الذي في ذمة الحائز غير مستحق الأداء حالاً، أو كان أقل من الديون المستحقة للدائنين، أو مغايراً لها، جاز للدائنين إذا اتفقوا جميعاً أن يطالبوا الحائز بدفع ما في ذمته بقدر ما هو مستحق لهم، ويكون الدفع طبقاً للشروط التي التزم الحائز بالوفاء بمقتضاها وفي الميعاد المحدد أصلاً للوفاء.

ثانياً: تطهير العقار:

هو وسيلة قانونية ينتقي بها حائز العقار إجراءات التنفيذ ضده وذلك عن طريق عرض قيمة العقار على الدائنين أصحاب هذه الحقوق، فإذا قبلوها ودفعها لهم الحائز حسب ترتيب استحقاقهم، فإن العقار يكون خالياً مما يثقله من حقوق مقيدة، بينما إذا اعترض أحد الدائنين، فإن العقار يباع بالمزاد العلني.

أ- مزايا التطهير:

١. يفيد الحائز في الاحتفاظ بملكية العقار المرهون دون أن يدفع أكثر من قيمته.
٢. يفيد الراهن لأن إجازة القانون للتطهير يكون من شأنه أن يشجع الغير على شراء العقار من الراهن من أجل تطهيره دون اتباع إجراءات نزع الملكية.
٣. يفيد الدائن المرتهن لأنه سوف يحصل على قيمة العقار دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية.
٤. يشجع حركة الإئتمان لأنه يسهل التعامل في العقارات المرهونة.

ب- عيوب التطهير:

١. أنه يجبر الدائنين على قبول الوفاء بديونهم قبل ميعاد حلولها.
٢. أنه يجبر الدائنين على قبول الوفاء الجزئي وتجزئة الرهن خلافاً للأصل، كما تحسب قيمة العقار وقت التطهير، وقد ترتفع قيمته إذا اتخذت إجراءات نزع الملكية.

ج- الأشخاص الذين يحق لهم التطهير:

- حائز العقار هو الذي أجاز له القانون استعمال وسيلة التطهير دون غيره.
- يشترط ألا يكون الحائز مسؤولاً عن الدين بصفة شخصية كالكفيل الشخصي .

د- آثار تطهير العقار:

- يترتب على تطهير العقار استقرار ملكية العقار بصفة نهائية للحائز خالصة من كل قيد.
- بينما إذا رفض الدائنون العرض الموجه إليهم من الحائز بشأن تطهير العقار المرهون، فإنه يلزم على هؤلاء في خلال مدة ثلاثون يوماً من آخر إعلان أن يطالبوا ببيع العقار المطلوب تطهيره، فإذا انقضى هذا الميعاد دون أن يطلب أحد الدائنين بيع العقار فإنه يعتبر مكوّتهم بمثابة قبولاً ضمناً لعرض الحائز الذي تستقر له ملكية العقار خالصة من كل قيد.

ثالثاً: تخلية العقار:

- يمكن للحائز أن يتخلى عن العقار المرهون بأن يترك العقار في يد حارس أو أمين تعينه المحكمة لتباشر إجراءات نزع الملكية .

أ- فائدة التخلية:

١. تفادي المساس بالسمعة المالية للحائز من خلال عدم توجيه إجراءات التنفيذ إليه، بحيث تتخذ الإجراءات في مواجهة الحارس نفسه دون الحائز.
٢. توفر التخلية للحائز ما قد ينفقه من مال وجهه في متابعة إجراءات التنفيذ.
٣. تمتد فائدة التخلية للدائن المرتهن أيضاً، حيث أنها تمثل اعترافاً من الحائز بحق الدائن المرتهن.

ب-الأشخاص الذين يحق لهم التخلية:

- يجوز لحائز العقار دون غيره إجراء التخلية .
- بينما لا تجوز التخلية من المدين الراهن أو الكفيل الشخصي على أساس أن هؤلاء مسئولون مسئولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن .

ج-آثار التخلية:

- إذا كانت التخلية لا يترتب عليها تخلي الحائز عن ملكية العقار المرهون، ولا عن حيازته القانونية وإنما عن حيازته المادية "العرضية" فقط فهي تؤدي إلى النتائج التالية:
- ١- للحائز حق التصرف في العقار المرهون إلى وقت تسجيل تنبيه نزع الملكية، لكن لا تنفذ هذه التصرفات في مواجهة الدائنين إذا تم شهرها بعد تسجيل التنبيه بنزع الملكية.
- ٢- إذا رسا المزاد بثمن يزيد عن ديون الدائنين، فإن الباقي بعد وفاء هذه الديون يكون من حق الحائز.
- ٣- للحائز قبل رسو المزاد، الرجوع عن التخلية بدفع ديون الدائنين، ولا يكون ذلك إلا إذا قضى الحائز جميع الديون ومحقاتها.
- ٤- إذا رسا المزاد على الحائز استقرت الملكية له، وإذا رسا المزاد على غير الحائز تلقى الراشي عليه المزاد الملكية من الحائز.

انقضاء الرهن الرسمي

انقضاء الرهن بصفة تبعية

- أن الرهن ينقضي بصفة تبعية، إذا انقضى الدين المضمون بأي سبب من أسباب انقضاء الالتزامات مثل الوفاء والتجديد والمقاصة واتحاد الذمة والإبراء والتقادم، ويلزم أن يكون الانقضاء كلياً وليس جزئياً، فإذا بقى جزء من الدين، فلا ينقضي الرهن بل يظل كله ضامناً له تأسيساً على قاعدة عدم تجزئة الرهن.
- ومع ذلك، لا يجوز أن يترتب على عودة الرهن مع الدين الأصلي أي ضرر يلحق الغير حسن النية الذي لا يعلم بالعيب الذي يشوب سبب انقضاء الرهن، إذا كان قد كسب حقاً على العقار، كما لو اشتراه أو ارتهنه في الفترة ما بين انقضاء الرهن وعودته، فإن الرهن لا يكون نافذاً في مواجهته ولا يكون من شأنه الإضرار به.

انقضاء الرهن بصفة أصلية

- ينقضي الرهن بصفة أصلية بنزول الدائن المرتهن عنه أو بتطهير العقار المرهون أو ببيعه بالمزاد العلني أو بهالك العقار المرهون.

أولاً: النزول عن الرهن:

- قد يتنازل الدائن المرتهن عن الرهن فقط دون الدين، ويكون ذلك إما صراحة أو ضمناً .
- يلزم أن تتوافر لدى الدائن المرتهن وقت النزول عن الرهن أهلية الإبراء من الدين .

ثانياً: هلاك العقار المرهون:

- ينقضي الرهن بهلاك العقار المرهون، على أنه يلزم أن يهلك هلاكاً كلياً، فإذا كان الهلاك جزئياً، فإن الجزء الآخر يبقى ضامناً للدين كله عملاً بقاعدة عدم تجزئة الرهن.
- الرهن ينقضي أياً كان سبب الهلاك، فقد يكون الهلاك بسبب خطأ الراهن مما يعطي الدائن الحق في الاختيار بين أن يستوفي الدين فوراً أو أن يقتضي تأميناً كافياً.
- فإن كان الهلاك لا يد للراهن فيه كان المدين مخيراً بين أن يقدم تأميناً كافياً أو أن يوفي الدين فوراً قبل حلول الأجل.

ركز

- حيث ينقضي الرهن الرسمي لانعدام المحل سواء كان الهلاك مادياً أو قانونياً، **مثال على الهلاك المادي** كما لو نزعت ملكية العقار للمنفعة العامة، **مثال على الهلاك القانوني**، كما إذا رهن المنتفع حقه ثم انقضى هذا الحق بموت المنتفع أو بحلول الأجل.

ثالثاً: تطهير العقار المرهون:

- إذا تمت اجراءات التطهير انقضي حق الرهن الرسمي نهائياً ويظل أثر التطهير قائماً حتى ولو زالت فيما بعد ملكية الحائز الذي طهر العقار لأي سبب من الأسباب حتى ولو كان زوالها بأثر رجعي كفسخ وبطلان سند ملكيته، فالملكية تعود عندئذ إلى المالك السابق خالصة من الرهون التي سبق تطهيرها.

رابعاً: بيع العقار بيعاً جبرياً بالمزاد العلني:

- الرهن ينقضي عند بيع العقار المرهون بالمزاد العلني متى تم إيداع الثمن الذي رسا به المزاد لدى خزانة المحكمة، أو يسلم إلى أحد الدائنين المقيدة حقوقه منه.

س ٩: عرف حق الاختصاص مبيناً شروطه واثاره؟

حق الاختصاص

أولاً: تعريف حق الاختصاص:

- هو حق عيني تبقي يثبت للدائن **بأمر من القضاء** على عقار معين أو أكثر من عقارات مدينه، بناء على حكم واجب التنفيذ بإلزام المدين بالدين، ويكون للدائن بموجب هذا الحكم أن يستوفي دينه من المقابل النقدي لهذا العقار، أو العقارات، في أي يد يكون.
- حق الاختصاص يتفق مع الرهن الرسمي في أثره، ولكنه يختلف عنه من حيث نشوءه** في أنه لا يتقرر باتفاق بين الطرفين، بل يتقرر بناء على حكم واجب التنفيذ بإلزام المدين بالدين.

ثانياً: تقرير نظام الاختصاص:

- تقرير حق الاختصاص يحقق مصلحة للمدين في الاحتفاظ بأمواله حتى يتمكن من الوفاء لا سيما وأن الدائن قد لا يتعجل التنفيذ.
- يعاب على حق الاختصاص** بأنه يؤدي إلى تفضيل أحد الدائنين على غيره من الدائنين بمجرد السبق في الحصول على الحكم، بينما يكون سبب تأخير الدائنين الآخرين في الحصول على الحكم راجعاً إلى سبب خارج عن إرادتهم، كما أنه يترتب عليه إثقال كاهل القضاء بقضايا لا مبرر لها بالإضافة إلى زيادة المصروفات.

انشاء حق الاختصاص

— شروط الحصول على حق الاختصاص —

الشرط الأول: وجوب أن يكون بيد الدائن حكم قضائي نفاذ فيه شروط معينة:

وجود حكم قضائي، وأن يكون واجب التنفيذ، وأن يكون صادراً في موضوع الدعوى، وملزماً للمدين بشيء معين.

(١) وجود حكم قضائي:

لا يشترط أن يكون الحكم صادراً عن المحاكم المصرية، إذ يجوز أخذ حق اختصاص بموجب حكم صادر من محكمة أجنبية، متى أصبح هذا الحكم واجب التنفيذ في مصر، أي بعد الحصول على الصيغة التنفيذية، وفقاً لأحكام قانون المرافعات.

(٢) أن يكون الحكم واجب التنفيذ:

يكون الحكم واجب التنفيذ، إذا كان نهائياً، أي غير قابل للطعن فيه بطرق الطعن العادية مثل الاستئناف أو المعارضة أو إذا كان مشمولاً بالنفاذ المعجل.

(٣) أن يكون الحكم صادراً في موضوع الدعوى:

ذلك سواء فصل هذا الحكم في موضوع الدعوى كله أو في جزء منه، أما الأحكام الصادرة قبل الفصل

في الموضوع، فلا يجوز تقرير حق اختصاص بناء عليها؛ وهذا هو شأن الأحكام التمهيدية.

(٤) أن يكون الحكم ملزماً للمدين بشيء معين:

يجب أن يلزم الحكم المدين بشيء، كدفع مبلغ من النقود أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل.

الشرط الثاني: المحل الذي يرد عليه حق الاختصاص:

"لا يجوز أخذ حق اختصاص إلا على عقار أو عقارات معينة مملوكة للمدين وقت قيد هذا الحق وجائز بيعها بالمزاد العلني".

١- أن يكون العقار معيناً تعييناً دقيقاً:

بذلك لا يكفي أن يكون محل الاختصاص قابلاً للتعيين، بل يجب أن يتضمن أمر القاضي به تعيينه بالذات تعييناً دقيقاً وكافياً وبيان موقعها.

٢- أن يكون العقار مملوكاً للمدين:

يلزم أن يكون العقار محل الاختصاص مملوكاً للمدين؛ هذا وقد تطلب المشرع أن تكون الملكية قائمة وقت قيد حق الاختصاص.

٣- أن يكون العقار مما يجوز بيعه بالمزاد العلني:

يقصد بذلك، أن يكون العقار مما يجوز الحجز عليه، حتى يتمكن الدائن من استيفاء حقه في الدين جبراً عن المدين، في حالة عدم وفائه بالدين اختياراً، وذلك عن طريق التنفيذ على العقار محل حق الاختصاص.

الشرط الثالث: يلزم أن يكون الدائن حسن النية:

يجب للحصول على حق الاختصاص أن يكون الدائن حسن النية، فلو باع المدين عقاراً له، ثم أخذ الدائن حق اختصاص على هذا العقار وهو عالم ببيعه، وقيد حق الاختصاص قبل تسجيل البيع، فإن هذا الحق لا ينفذ في حق المشتري.

— إجراءات الحصول على حق الاختصاص —

لا يتقرر حق الاختصاص بقوة القانون بمجرد توافر شروطه، وإنما يجب أن يطلبه الدائن من رئيس المحكمة المختصة وهي المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها العقار محل الاختصاص .

١- تقديم طلب الحصول على الاختصاص:

طلب الاختصاص يقدم من الدائن إلى رئيس المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرتها العقار المراد الاختصاص عليه، وإذا كانت العقارات تقع في دوائر اختصاص محاكم مختلفة وجب تقديم طلب إلى رئيس كل محكمة عن العقارات التي تقع في دائرتها.

يجب أن ترفق بالعريضة صورة رسمية من الحكم أو شهادة من قلم الكتاب مدون فيها منطوقه، كذلك يلزم أن ترفق بالعريضة الأوراق الدالة على قيمة العقارات المطلوب الاختصاص بها .

٢- سلطة رئيس المحكمة في إصدار الأمر بالاختصاص:

(أ) قبول طلب الاختصاص:

يدون رئيس المحكمة في ذيل العريضة أمره بالاختصاص، وكذلك يجب عليه عند الترخيص به أن يراعى مقدار الدين وقيمة العقارات

وحتى يمتنع على الدائن الحصول على اختصاص آخر أو اختصاصات بعقارات تزيد قيمتها كثيراً على دينه، ألزم المشرع قلم الكتاب بالتأشير بالاختصاص على صورة الحكم أو الشهادة التي تقوم مقامها وعلى كل صورة أو شهادة أخرى تسلم للدائن. وبذلك يتعذر على الدائن أن يحصل على اختصاصات متعددة من محاكم مختلفة على عقارات تقع في دوائر هذه المحاكم دون أن تعلم كل محكمة تعطي اختصاصات بما أعطته المحاكم الأخرى من ذلك.

(ب) رفض طلب الاختصاص:

يجوز لرئيس المحكمة أن يرفض طلب الاختصاص كلياً أو جزئياً إذ قد يرى عدم توافر الشروط اللازمة لأخذ حق اختصاص، أو قد يرى الاختصاص على بعض العقارات التي طلب الدائن أخذ اختصاص عليها. وفي هذه الحالة، يجوز للدائن التظلم من قرار الرفض، ويرفع هذا التظلم إلى المحكمة الابتدائية.

٣- التظلم من قرار رئيس المحكمة:

يجوز للدائن أن يتظلم من الرفض، ويرفع تظلمه في جميع الأحوال إلى المحكمة الابتدائية .

آثار حق الاختصاص وانقاصه وانقضاؤه

— آثار حق الاختصاص —

- ❖ فلا يجوز للمدين بعد تقرير حق الاختصاص على عقاره، أن يرتب على هذا العقار أي حق يشهر قبل قيد حق الاختصاص.
- ❖ أما بالنسبة لهلاك العقار وتلفه، فإذا كان الهلاك أو التلف بخطأ المدين كان الدائن مخيراً بين أن يقتضي تأميناً كافياً أو أن يستوفي حقه فوراً، وإذا كان الهلاك أو التلف قد نشأ عن سبب أجنبي كان المدين مخيراً بين أن يقدم تأميناً كافياً أو أن يوفي بالدين فوراً.
- ❖ إذا هلك العقار أو تلف لأي سبب من الأسباب انتقل الاختصاص بمرتبته إلى الحق الذي يحل محل العقار حلاً عينياً، كالتعويض أو مبلغ التأمين أو الثمن الذي يقرر مقابل نزع الملكية للمنفعة العامة.

— إنقاص حق الاختصاص وانقضاؤه —

- ❖ أجاز المشرع إنقاص حق الاختصاص إلى القدر المناسب وذلك إذا كانت قيمة العقار الواقع عليه لا تتناسب مع الدين المضمون إما بسبب أن رئيس المحكمة أخطأ في تقدير قيمة العقار أو لأن الأوراق الدالة على هذه القيمة لم تكن تتضمن تحديداً دقيقاً لها أو لأن الدين قد انقضى جزء منه.
- ❖ **المقصود بالإنقاص** ← هو رفع الضرر الذي يقع على المدين من إثقال عقاراته بحق اختصاص يتجاوز ما يلزم لضمان الدين، كما أنه يتفق مع رغبة المشرع في المحافظة على التناسب بين مقدار الدين وقيمة العقارات الضامنة.

❖ **يلاحظ أنه**

- 1- يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب إنقاص الاختصاص إلى الحد المناسب إذا كانت الأعيان التي رتب عليها هذا الحق تزيد قيمتها على ما يكفي لضمان الدين .
 - 2- ويكون إنقاص الاختصاص إما بقصره على جزء من العقار أو العقارات التي رتب عليها أو بنقله إلى عقار آخر تكون قيمته كافية لضمان الدين .
 - 3- المصروفات اللازمة لإجراء الإنقاص ولو تم بموافقة الدائن على من طلب الإنقاص .
- ❖ مع الوضع في الاعتبار، أن المدين هو الذي يتقدم بطلب الإنقاص، كما أجاز المشرع لكل ذي مصلحة أن يطلب إنقاص حق الاختصاص مثل حائز العقار أو الدائن التالي في المرتبة للدائن صاحب حق الاختصاص.

- ❖ يقع على عاتق طالب الإنقاص كافة المصروفات اللازمة لإجراء الإنقاص .

الرهن الحيازي

أولاً: تعريف الرهن الحيازي:

📌 **الرهن الحيازي** ← عقد به يلتزم شخص، ضماناً لدين عليه أو على غيره، أن يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبي يعينه المتعاقدان، شيئاً يترتب عليه للدائن حقاً عينياً يخوله حبس الشيء لحين استيفاء الدين، وأن يتقدم الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة في اقتضاء حقه من ثمن هذا الشيء في أي يد يكون".

📌 **يختلف الرهن الحيازي عن الرهن الرسمي** ← في أنه لا يقتصر على العقار بل يجوز أن يكون محله منقولاً أو عقاراً، كما أن الرهن الحيازي مقارنة بالرهن الرسمي، يخول الدائن المرتهن سلطة حيازة الشيء المرهون وحبسه أي الامتناع عن رده إلى حين استيفاء الدين، وعليه واجب إدارته واستغلاله والمحافظة عليه ورده عند انتهاء الرهن، وفيما عدا هذه الاختلافات يشترط في محل الرهن الحيازي ما يشترط في محل الرهن الرسمي، أي أن يكون مما يصح التعامل فيه وبيعه بالمزاد العلني، وأن يكون معيناً ومملوكاً للراهن.

ثانياً: أهمية الرهن الحيازي:

📌 **الناحية النظرية** ← يعتبر الرهن الحيازي صورة من التأمين العيني، فهو يوفر للدائن ضماناً قوياً؛ حيث يخوله حق حبس الشيء المرهون حتى استيفاء حقه، فضلاً عن حقه في الأولوية على ثمنه في أي يد يكون.

📌 **الناحية العملية** ← يعتبر الرهن الحيازي من العقود شائعة الاستعمال، فقد جرى العمل على كثرة رهن المنقولات من بضائع وغيرها في المعاملات التجارية، وبذلك أصبح من السهل على التاجر والصانع الحصول على الائتمان اللازم عن طريق رهن منقولاته من آلات وبضائع.

ثالثاً: خصائص الرهن الحيازي:

١- **أنه تأمين اتفاقي** ← لأن مصدره هو العقد الذي يبرم بين الدائن ومالك الشيء المرهون وقد يكون المدين نفسه هو مالك الشيء المرهون وهذا هو الوضع الغالب أو قد يكون شخص آخر غير المدين "الكفيل العيني".

٢- **أنه حق عيني يرد على منقول وعقار** ← يعتبر الرهن الحيازي بمثابة حق عيني يرد على منقول وعقار.

٣- **أنه حق تباعي** ← إن الرهن الحيازي هو حق تباعي يستلزم وجود التزام أصلي يلحق به ويكون ضامناً له.

٤- **عقد رضائي وملزم لجانبين** ← الأصل أن الرضائية ركن أساسي في إبرام عقد الرهن الحيازي الذي ينعقد بمجرد تطابق إرادتي طرفي العقد المدين الراهن والدائن المرتهن.

انشاء الرهن الحيازي

ينشأ الرهن الحيازي نتيجة عقد يبرم بين الراهن والدائن المرتهن، ويلزم أن يستوفي هذا العقد أركانه من رضا ومحل وسبب.

الشروط العامة

أولاً: التراضي:

بارتباط الإيجاب الصادر عن أحد العاقدین سواء كان المدين الراهن أو الدائن المرتهن وقبوله من الطرف الآخر.

ثانياً: الأهلية المطلوبة لأطراف العقد:

١- أهلية الراهن:

فبالنسبة إلى الراهن ← فإذا كان هو المدين كان التصرف بالنسبة له من التصرفات الدائرة بين النفع والضرر، فيلزم أن تتوافر فيه أهلية التصرف أي أن يكون بالغاً سن الرشد.

أما بالنسبة إلى الرهن الصادر من شخص غير المدين أي الكفيل العيني ← فإن الرهن يكون بالنسبة له من التصرفات الضارة ضرراً محضاً، ولهذا لابد من توافر الأهلية الكاملة.

٢- أهلية الدائن المرتهن:

أما بالنسبة لأهلية الدائن المرتهن، فإن الرهن بالنسبة له من التصرفات الدائرة بين النفع والضرر. ومن هذا المنطلق، فإذا كان الدائن المرتهن ناقص الأهلية كالصبي المميز أو من في حكمه، فإن الرهن يكون قابل للإبطال، بينما إذا كان الدائن المرتهن عديم الأهلية كالمجنون أو المعتوه، فإن الرهن في هذه الحال يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً.

الشروط الخاصة

أولاً: ائمال المرهون:

الشرط الأول: الرهن الحيازي يرد على عاقل كما يرد على مشغول:

حيث يجوز رهن جميع الأشياء رهناً حيازياً سواء كانت أراضي أو مباني وإن كان الوضع الغالب في مصر أن يرد الرهن الحيازي على الأراضي الزراعية بينما يرد الرهن الرسمي على المباني. كذلك جميع المنقولات يجوز رهنها رهن حيازياً كان نوعيتها وطبيعتها، طالما أنها قابلة للحجز عليها أو البيع بالمزاد العلني، سواء كانت منقولات مادية أو معنوية، كما يجوز رهن المنقولات المعنوية باختلاف أنواعها مثل الديون وبراءة الاختراع وحقوق المؤلف والأسهم والسندات.

الشرط الثاني: يجب أن يكون المال المرهون موجوداً وقت الرهن:

يجب أن يكون المال المرهون موجوداً وقت الرهن، فلا يجوز رهن الأموال المستقبلية رهناً حيازياً.

الشرط الثالث: يجب أن يكون المال المرهون مما يطع التعامل فيه ويبيعه بالمزاد العلني:

حيث أنه يشترط قابلية بيع الشيء المرهون بالمزاد العلني، فلا يجوز رهن الأموال العامة أو الموقوفة رهناً حيازياً، وكذلك لا يجوز رهن العقارات بالتخصيص وحق الارتفاق رهناً حيازياً بالنظر إلى أن مثل هذه الحقوق غير قابلة للبيع بالمزاد العلني بصفة مستقلة.

الشرط الرابع: يجب أن يكون المال المرهون معيناً:

يجب أن يكون المال المرهون معيناً، حيث أن تراخي المتعاقدين على الشيء المرهون لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كان هذا الشيء معيناً أو قابلاً للتعيين.

الشرط الخامس: يجب أن يكون المال المرهون مملوكاً للراهن:

يشترط أن يكون الراهن مالكا للمال المرهون سواء كان الرهن الحيازي صادراً من المدين نفسه أو من شخص آخر يقدم الرهن لمصلحة المدين "الكفيل العيني" وتطبق على الرهن الحيازي سائر الأحكام التي تطبق على رهن ملك الغير رهناً رسمياً، بحيث يقع الرهن قابلاً للإبطال لمصلحة الدائن المرتهن، فيكون غير نافذ في مواجهة المالك الحقيقي إلا إذا أقره، كما أن الدائن وحده الذي يستطيع المطالبة بإبطاله، ويسقط حق الأخير في هذه المطالبة، إذا أقر المالك الحقيقي الرهن الصادر من غيره.

تجدر الإشارة إلى أنه لا يلزم في إقرار المالك الحقيقي للرهن الحيازي أن يكون حاصلاً بورقة رسمية، لأن الرهن الحيازي على خلاف الرهن الرسمي هو عقد رضائي ينعقد صحيحاً بدون حاجة إلى رسمية.

ثانياً: الدين المضمون:

الرهن الحيازي هو حق تبعي للدين المضمون، كغيره من الرهون الأخرى، فلا يتصور وجود الرهن الحيازي إلا إذا كان هناك التزام في ذمة المدين يضمن الوفاء به.

آثار الرهن الحيازي

— آثار الرهن الحيازي بالنسبة للمتعاقدین —

س ١١: تكلم عن آثار الرهن الحيازي بالنسبة للراهن؟

آثار الرهن الحيازي بالنسبة للراهن

أولاً: التزامات الراهن:

١- التزام الراهن بتسليم الشيء المرهون:

المقصود بالتسليم ← وضع المال المرهون تحت تصرف الدائن المرتهن أو العدل بحيث يتيسر له حيازته . حيث يهدف التسليم إلى حماية الدائن المرتهن من مخاطر تهريب المرهون لا سيما إذا كان منقولاً . كما يهدف التسليم أيضاً إلى إعلام الغير بوجود الرهن ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا بوضع الشيء المرهون تحت تصرف الدائن المرتهن بحيث يتمكن من حيازته دون عائق حتى ولو لم يستولي عليه استيلاء مادياً ما دام أن الراهن قد أعلمه بذلك.

فالراهن يعتبر مخلاً بالتزامه بالتسليم، إذا قام بتسليم الدائن مفاتيح مخازن المدين التي يوجد بها البضاعة المرهونة، بينما يكون الراهن قد وفى بالتزامه، إذا ترك البضاعة في أحد مخازنه مع تأجير المخزن للدائن، حيث تكون البضاعة في حيازة الدائن المرتهن بصفته مستأجراً، كما أن هذه الحيازة تكون ظاهرة وجدية متى وضع يده على البضاعة المرهون منها وبالتالي يحتج بها في مواجهة الغير.

٢- الالتزام بضمان سلامة الرهن ونفاذه:

فقد أوجب المشرع على الراهن الالتزام بضمان سلامة الرهن ونفاذه، فليس له أن يقوم بأي أعمال يكون من شأنها الانتقاص من قيمة الشيء المرهون أو الإخلال بأي حق من حقوق الدائن المرتهن.

٣- الالتزام بضمان هلاك الشيء أو تلفه:

يقع على عاتق الراهن تبعه هلاك الشيء المرهون أو تلفه سواء كان ناشئاً عن خطأ الراهن ذاته أو ترتب على قوة قاهرة، بينما يتحمل الدائن تبعه الهلاك، إذا كان ناشئاً عن خطأ هذا الأخير، بحيث يكون مسؤولاً في مواجهة الراهن مع تعويضه عن الضرر الذي لحق به.

ثانياً: حقوق الراهن:

لا يترتب على الرهن انتقال ملكية المرهون من الراهن للدائن المرتهن بل تظل له الملكية، فيجوز له أن يباشر من سلطات المالك ما لا يتعارض مع حقوق الدائن المرتهن .

بينما يمتنع على الراهن القيام بالتصرفات المادية إذا كان من شأنها أن تؤدي إلى المساس بسلامة الشيء المرهون

آثار الرهن الحيازي بالنسبة للدائن المرتهن

أولاً: التزامات الدائن المرتهن:

يقتضي الرهن الحيازي تخلي الراهن عن حيازة المال المرهون وتسليمه للدائن المرتهن ليحبسه ، ولا يصح أن يضر الراهن ببقاء المرهون تحت يد الدائن خلال مدة الرهن، ولذلك يفرض المشرع على هذا الأخير من الالتزامات ما يحقق هذه الغاية، فيلزمه بحفظ المرهون وصيانته وكذلك بإدارته واستغلاله وأخيراً برده في نهاية الرهن بعد أن يستوفي كامل حقه .

١- الالتزام بحفظ الشيء المرهون وصيانته:

الدائن المرتهن يلتزم بحفظ الشيء المرهون وصيانته، وهذا الالتزام ينشأ من وقت انتقال حيازة الشيء إليه، فهو التزام تعاقدى ناشئ عن عقد الرهن ذاته .

مع الوضع في الاعتبار، أنه يختلف مضمون هذا الالتزام وفقاً لطبيعة الشيء المرهون، فإذا كان الشيء المرهون منقولاً مثل آلة كهربائية أو ميكانيكية، فإنه يلزم على الدائن المرتهن أن يقوم بأعمال النظافة والعناية اللازمة من أجل المحافظة عليها

إذا كان الشيء المرهون عقاراً، فإنه يجب على الدائن المرتهن أن يقوم بأعمال الصيانة ودفع كافة النفقات اللازمة لحفظه على أن يرجع بها بعد ذلك على الراهن .

٢- الالتزام بإدارة الشيء المرهون واستثماره:

أ- التزام الدائن المرتهن بإدارة الشيء المرهون :

الدائن المرتهن يلتزم بإدارة الشيء المرهون بما يتلائم مع طبيعته، فإذا كان المرهون أرضاً زراعية فتكون الإدارة بزراعتها، وإذا كان المرهون مبنى معد للسكنى، فتكون الإدارة بسكناه.

ولا يجوز للدائن المرتهن بدون موافقة الراهن أن يعدل من الطريقة المألوفة لإدارة الشيء المرهون واستغلاله .

مع الوضع في الاعتبار، أن الدائن لا يحصل على مقابل نظير إدارته للشيء المرهون .

ب- التزام الدائن المرتهن باستثمار الشيء المرهون :

يجب على الدائن المرتهن أن يستغل المرهون استغلالاً كاملاً، فلا يصح أن يتركه دون استغلال حتى لا يترتب على ذلك خسارة تلحق بالراهن، بمعنى أنه يجب على الدائن المرتهن أن يجعل الشيء المرهون ينتج كل ما هو قابل لإنتاجه من إيرادات أو غلة.

كما أنه لا يصح أن يعدل في الطريقة المألوفة لاستثماره إلا إذا رضي الراهن بذلك، فمثلاً إذا كان المرهون محلاً تجارياً، فإنه يجب استغلاله وفقاً لما أعد له، فلا يجوز استغلاله كمخزن أو مصنع، وإذا كان المرهون حصاناً من خيول السباق، فإنه لا يصح استخدامه في النقل.

مع الوضع في الاعتبار، أن الدائن المرتهن يملك الاختيار بين أن يستغل المرهون إما بنفسه وإما عن طريق الغير، فلو كان الشيء المرهون أرضاً زراعية، فله أن يؤجرها أو يزرعها بنفسه .

ولا يجوز للدائن المرتهن الذي يقع الإيجار الصادر منه صحيحاً في مواجهة الراهن نفسه، أن يؤجر الشيء المرهون لمدة تزيد عن ثلاث سنوات .

٣- الالتزام برد الشيء المرهون:

الدائن المرتهن ملزم برد الشيء المرهون بمجرد انقضاء الدين المضمون بالرهن، كما أنه يجب أن يكون الشيء المرهون بالحالة التي كان عليها وقت التسليم، فإذا هلك أو تلف وقت رده فتقوم مسؤولية الدائن، إلا إذا أثبت أن الهلاك يرجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه ويكون رد الشيء المرهون بعد استيفاء المرتهن حقه كاملاً وانقضاء الرهن.

يمكن للمدين الراهن إجبار الدائن على الرد من خلال إحدى دعويين:

- أ- **دعوى عينية** ← هي دعوى الاستحقاق بصفته مالكا للشيء المرهون .
- ب- **دعوى شخصية** ← وهي دعوى ناشئة عن عقد الرهن ذاته، وتسقط هذه الدعوى بانقضاء خمسة عشرة سنة من تاريخ إنقضاء الرهن .

ثانياً: حقوق الدائن المرتهن:

- من المتفق عليه، أنه يمكن للدائن المرتهن أن يطالب بالبيع الجبري وفقاً للقواعد المقررة في الرهن الرسمي وقانون المرافعات إذا لم يستوفي حقه.
- كما يجوز له أن يطلب من القاضي بتمليكه للشيء وفاء الدين على أن يحسب عليه بقيمته حسب تقدير الخبراء.

س ١٣: تكلم عن اثار الرهن الحيازي بالنسبة للغير؟

— اثار الرهن الحيازي بالنسبة للغير —

شروط نفاذ الرهن الحيازي في حق الغير

[١] الشرط العام لنفاذ الرهن الحيازي في حق الغير:

أ) انتقال الحيازة:

- يجب لنفاذ الرهن الحيازي أن تنقل حيازة الشيء المرهون من الراهن، فإذا بقي الراهن حائزاً لهذا الشيء، فلا يمكن الاحتجاج بالرهن في مواجهة الغير .
- والحكمة من اشتراط انتقال الحيازة من الراهن، هي إعلام الغير بوجود الرهن، إذ لو بقي الشيء المرهون في حيازة الراهن، لما علم الكثيرون بكون هذا الشيء مرهوناً .

ب) نقل الحيازة للدائن المرتهن أو من ينوب عنه:

- لابد أن يتنازل الراهن عن حيازة المال المرهون، والطبيعي أن يكون هذا التنازل للدائن المرتهن لأنه هو صاحب المصلحة في الحفاظ على الشيء، حتى يستوفي دينه، فالحيازة تحمي الدائن المرتهن من مخاطر إخفاء أو تهريب المنقول، على أنه ليس هناك ما يمنع أن تنتقل الحيازة إلى شخص آخر أجنبي "العدل" يتفق عليه المتعاقدان، كما يمكن أن تنتقل الحيازة إلى الخارس إذا ما سلبت الحيازة من الدائن لإساءة استعمال حقه في الإدارة.

ج) الشروط الواجب توافرها في الحيازة:

- الغرض المقصود من نقل الحيازة** ← هو إعلام الغير بأن المال المرهون لم يعد خالصاً للراهن بل تقرر عليه حق للغير، وعلى هذا النحو يبدو أنه يلزم في الحيازة أن تكون ظاهرة لا يكتنفها غموض، وأن تكون مستمرة لا يتخللها انقطاع حتى لا ينخدع الغير بعودة المرهون إلى يد الراهن.

يجب أن تكون الحيازة ظاهرة:

- لابد أن تكون حيازة الدائن المرتهن للمرهون ظاهرة واضحة لا لبس فيها ولا غموض، فيوضع الشيء تحت يده بطريقة يستدل منها بوضوح على أنه قد ترتب عليه حق للغير. ولا يعتبر التسليم الرمزي كافياً بدوره لانتقال الحيازة ما لم يكن ذلك التسليم ظاهراً بعلامات مادية .

يجب أن تكون الحيازة مستمرة:

- يلزم أن تستمر الحيازة للدائن المرتهن، أي أن يظل الشيء المرهون تحت يد الدائن المرتهن ولا يعود إلى الراهن، فإذا رجع المرهون إلى حيازة الراهن بإرادة الدائن المرتهن وعلمه، انقضى الرهن؛ لأن ذلك يعتبر نزولاً عن الرهن. وتعتبر الحيازة مستمرة حتى لو تخلى الدائن المرتهن للغير عن الشيء المرهون على سبيل الحيازة العرضية كما لو كان مستأجراً.

[٢] الشرط الخاص لنفاذ الرهن الجازي في حق الغير:

(أ) وجوب قيد الرهن العقاري:

- يشترط لنفاذ الرهن العقاري في حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة أن يقيد عقد الرهن، وتسري على هذا القيد الأحكام الخاصة بقيد الرهن الرسمي
- فلا يكفي قيد الرهن وحده، بل يلزم أيضاً انتقال الحيازة، ولا يكتسب الدائن المرتهن مرتبة إلا منذ اجتماع الأمرين، فلو تعددت الرهون، فإن أسبقية القيد وحدها لا تكفي، بل لابد أن تقترن بوضع اليد.

(ب) نفاذ رهن المنقول المادي:

- يشترط لنفاذ رهن المنقول في حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة أن يدون العقد في ورقة ثابتة التاريخ يبين فيها المبلغ المضمون بالرهن والعين المرهونة بياناً كافياً. وهذا التاريخ الثابت يحدد مرتبة الدائن المرتهن
- فإذا كان المرهون منقولاً مادياً، فيشترط لنفاذ رهنه في حق الغير، أن يكون مكتوباً أياً كانت قيمته، فالكتابة هنا شرط لنفاذ الرهن لا لإثباته .

س ١٤ : تكلم عن سلطات الدائن المرتهن في مواجهة الغير؟

سلطات الدائن المرتهن في مواجهة الغير

أولاً: الحق في حبس الشيء المرهون:

- حيث أنه بمقتضى الحق في الحبس يمكن للدائن المرتهن الإمتناع عن التخلي عن الشيء المرهون، طالما أنه لم يستوفي حقه كاملاً سواء كان الشيء المرهون منقول أو عقار.
- إذا كان الشيء المرهون في حيازة أجنبي اتفق عليه طرفا العقد، فإن هذا الشخص المعين هو بمثابة حائزاً لحساب الدائن المرتهن وعليه حبس الشيء المرهون وإذا أخل بذلك فيعتبر مسؤولاً عما يلحق الدائن من ضرر.
- كما يخول الحق في الحبس للدائن المرتهن إذا خرج الشيء من يده دون إرادته أو دون علمه استرداد حيازته من الغير وفقاً لأحكام الحيازة.

ثانياً: سلطة التنبؤ:

- إذا كان الشيء المرهون عقاراً وانتقلت ملكيته إلى شخص آخر كان للدائن المرتهن أن ينفذ عليه في مواجهة المالك الجديد.
- إذا كان منقولاً، فيكون للدائن أيضاً الحق في تتبعه، إذا انتقلت ملكيته إلى الغير، إلا أنه قد يصطدم من الناحية العملية بقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية.

ثالثاً: سلطة التقدم:

١- حق الدائن المرتهن في التقدم بحسب مرتبة رهنه:

- يمكن للدائن المرتهن أن يتقدم على كل الدائنين العاديين بشرط أن يكون رهنه نافذاً في مواجهتهم، كذلك يتقدم الدائن المرتهن على الدائنين المرتهنيين الآخرين، متى كانوا في مرتبة تالية له، أي أنه يلزم أن يكون سابقاً عليهم في المرتبة، والعبرة بتاريخ قيد الرهن عند ترتيب هؤلاء الدائنين.
- فإذا كان الشيء المرهون عقاراً، فإن مرتبة الدائن المرتهن تتحدد بانتقال الحيازة وقيد الرهن
- أما إذا كان الشيء المرهون منقولاً، فإن الأسبقية تكون بانتقال الحيازة وتدوين الرهن في ورقة ثابتة التاريخ.

٢- حق الدائن المرتهن في التقدم على ثمن المال المرهون أو المال الذي حل محله:

- يمكن للدائن المرتهن أن يباشر حقه في الأولوية على المال الذي يحل محل الشيء المرهون في حالة هلاكه أو تلفه من تعويض أو مبلغ تأمين أو مقابل نزع الملكية للمنفعة العامة.

٣- حق الدائن المرتهن في التقدم على الدين المضمون وملحقاته:

- 🔹 تكفل الأولوية للدائن المرتهن استيفاء الدين المضمون وملحقاته الواردة بنص المادة ١١١١ من القانون المدني والتي تنص على أن الرهن يضمن:
- أ- المصروفات الضرورية التي أنفقت على الشيء مثل نفقات حفظ المرهون وإصلاحه.
- ب- التعويضات عن الأضرار الناشئة عن عيوب الشيء .
- ج- مصروفات العقد الذي أنشأ الدين ومصروفات عقد الرهن الحيازي وقيده عند الانقضاء.
- د- المصروفات التي يقتضيها تنفيذ الرهن، كالنفقات التي يتكبدها الدائن المرتهن عند تسلم الشيء المرهون من المدين الراهن عند قيام الرهن ثم كذلك نفقات رده عند انقضاء الرهن.
- هـ- جميع الفوائد المستحقة حتى رسو المزايد .

انقضاء الرهن الحيازي

— إنقضاء الرهن الحيازي بصفة تبعية —

- 🔹 إذا انقضى الدين المضمون، فإن الرهن ينقضي بصفة تبعية، وهناك أسباب عديدة لإنقضاء الدين مثل الوفاء والمقاصة أو الإبراء أو اتحاد الذمة.
- 🔹 يلزم أن يكون الوفاء بالدين كلياً حتى ينقضي الرهن فإذا بقي منه جزء بقي المرهون بأكمله ضامناً للوفاء به .
- 🔹 مع الوضع في الاعتبار، أنه إذا كان حق الرهن ينقضي بإنقضاء الدين، فإن الرهن يعود من جديد إذا زال سبب إنقضاء الدين، فإذا كان الوفاء هو سبب إنقضاء الدين مثلاً ثم تبين أن الوفاء باطل لصدوره من غير ذي أهلية، يعود الدين المضمون ويعود معه الرهن تباعاً. بحيث لا يضر الغير حسن النية .

— إنقضاء الرهن الحيازي بصفة أهلية —

١- تنازل الدائن المرتهن عن الرهن:

- 🔹 قد يتنازل الدائن المرتهن عن الرهن دون الدين أي يظل الدائن محتفظاً بحقه الشخصي قبل المدين، بحيث يصبح مجرد دائن عادي بعد أن كان دائناً مرتتهناً.
- 🔹 يلزم لصحة تنازل الدائن عن الرهن ضرورة توافر الأهلية اللازمة وهي بنص المادة ١١١٣ هي أهلية الإبراء من الدين الذي يعتبر من التصرفات الضارة ضرراً محضاً، فتكون الأهلية المطلوبة هي أهلية التبرع.
- 🔹 قد يكون النزول عن مرتبة الرهن صريحاً، كما يجوز أن يستفاد ضمناً عن طريق تخلي الدائن المرتهن باختياره عن الشيء المرهون وموافقته على التصرف فيه دون تحفظ.

٢- زوال الرهن بسبب اتحاد الذمة:

- 🔹 ذلك عندما يصبح الدائن المرتهن مالكاً للشيء المرهون كما هو الحال إذا ورثه أو اشتراه، فلا يجوز للشخص أن يباشر الرهن على ملكه .

٣- زوال الرهن بسبب هلاك الشيء المرهون:

- 🔹 في كل الحالات التي ينقضي فيها الرهن بهلاك الشيء المرهون، فإنه ينتقل حق الدائن المرتهن بمرتبته إلى المال الذي يحل محله في ذمة الراهن مثل مبلغ التعويض أو التأمين أو مقابل نزع الملكية للمنفعة العامة.



أولاً: اجب عن الاسئلة الآتية

س ١ : اكتب في حق الاختصاص ؟

س ٢ : تكلم عن الرهن الحيازي موضحاً آثاره وشروط نفاذه ؟

س ٣ : اكتب في الشروط الموضوعية الخاصة لعقد الرهن الرسمي ؟

س ٤ : وضح الفرق بين الرهن الرسمي والرهن الحيازي مبيناً حكم رهن ملك الغير

س ٥ : اكتب في التزام الراهن بضمان سلامة الرهن وضمان هلاك او تلف العقار المرهون ؟

س ٦ : اكتب في وجوب قيد الرهن للاحتجاج به في مواجهة الغير موضحاً بإيجاز اثر قيد الرهن ؟



2026

ثانياً: بين مدي صحة او خطأ العبارات الآتية:

العلامة	السؤال	م
	الرسمية أهم أركان الرهن الحيازي؟	-١
	الرهن الرسمي حق غير قابل للتجزئة مطلقاً؟	-٢
	يترتب علي عدم ملكية الراهن للعقار المرهون بطلان الرهن بطلاناً مطلقاً؟	-٣
	رهن ملك الغير يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً فيما بين المتعاقدين؟	-٤
	لا يستفيد الكفيل العيني في الرهن بأوجه الدفع التي يجوز للمدين الراهن التمسك بها؟	-٥
	الدين المضمون بالرهن الرسمي يجب أن يكون دفع مبلغ من النقود؟	-٦
	لا يشترط تعيين محل ومصدر الدين المضمون في عقد الرهن؟	-٧
	ينشئ حق الرهن الرسمي عن طريق التوثيق أو الأحكام القضائية أو محاضر الصلح	-٨
	الرسمية إجراء قصد منه حماية الدائن المرتهن فقط؟	-٩
	الرهن الرسمي من العقود الملزمة للجانبين بخلاف الرهن الحيازي فهو من العقود الملزمة لجانب واحد؟	-١٠
	الرهن الرسمي والرهن الحيازي من العقود الرضائية؟	-١١
	الرهن الرسمي من العقود الشكلية حيث لا يكفي لإنعقاده أن يتراضي الطرفان عليه	-١٢
	يضمن الراهن هلاك أو تلف الشئ المرهون سواء كان ذلك راجعاً إلي خطأ الراهن أم إلي القوة القاهرة؟	-١٣
	للاهن سلطة التصرف في العقار المرهون رهناً رسمياً بدون أي قيد؟	-١٤
	يجوز تعهد الراهن للدائن المرتهن بالآلا يتصرف في العقار المرهون بعد قيد الرهن الرسمي؟	-١٥

١٦-	يكون باطلاً تعهد الراهن للدائن المرتهن بالآ يتصرف في العقار المرهون بعد قيد الرهن
١٧-	للاهن سلطة إيجار العقار المرهون رهنًا رسمياً بشرط ألا تزيد مدة الإيجار عن ثلاثة سنوات ؟
١٨-	ينقضي حق الإختصاص كما ينقضي الرهن الرسمي ؟
١٩-	حق الإختصاص تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ؟
٢٠-	يشترط أن يطلب الدائن من المحكمة إصدار أمر بتقرير حق الإختصاص لأنه لا يتقرر بقوة القانون
٢١-	حق الإختصاص يرد علي العقارات والمنقولات ؟
٢٢-	حق الإختصاص لا يرد إلا علي العقار ولا يرد علي المنقولات
٢٣-	ينشأ حق الرهن وحق الإختصاص بمقتضي عقد بين الدائن والمدين ؟
٢٤-	يجوز للدائن الحصول علي حق إختصاص علي عقار في التركة بعد وفاة المدين ؟
٢٥-	لا يجوز للدائن بعد موت المدين أخذ إختصاص علي عقار في التركة (صح)
٢٦-	لا يجوز للدائن طلب حق الإختصاص علي عقار المدين إذا كان الحكم وقتي ؟
٢٧-	يلتزم الراهن رهنًا حيازياً بإدارة الشئ المرهون واستثماره ؟
٢٨-	الشرط الخاص لنفاذ الرهن الحيازي للعقار في مواجهة الغير هو وجوب الكتابة ؟
٢٩-	يشترط لنفاذ الرهن العقاري في حق الغير إلي جانب انتقال الحيازة ان يقيد عقد الرهن
٣٠-	يجوز أخذ حق الإختصاص بناء علي الأحكام التحضيرية أو التمهيدية

القسم الثاني – التأمينات الشخصية (عقد الكفالة)

التعريف بالكفالة

س ٥١: عرف عقد الكفالة مبيناً خصائصه؟

ماهية الكفالة

أولاً: عقد الكفالة لغة:

وردت كلمة (كَفَلَ) بالقرآن الكريم في قوله تعالى: (وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا)، أي ضمها إلى نفسه، وفي حديث السنة النبوية الشريفة قوله عليه الصلاة والسلام "أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين..."، أي الذي يضمه إليه.

كما جاءت كلمة الكفالة في كتب اللغة بعدة معانٍ ← فالكفالة في اللغة تعني: "كفل الرجل، وبالرجل كفلاً، وكفالة: ضممه".

ثانياً: عقد الكفالة اصطلاحاً:

"ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة مُطلقاً".

ثالثاً: عقد الكفالة قانوناً:

حيث أوردت المادة ٧٧٢ من القانون المدني المصري تعريفاً للكفالة بقولها الكفالة هي "عقد يكفل بمقتضاه شخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بأن يفي بهذا الالتزام إذا لم يَفِ به المدين نفسه".

وعلى هذا الأساس، يمكن كفالة أي التزام أياً كان مصدره وأياً كان وصفه، كما أن الكفيل يتعهد للدائن "المكفول له" حتى يكون مفهوماً أن الكفيل يلتزم مباشرة قبل الدائن.

وهو ما يعني جواز كفالة المدين بغير علمه أو رغم معارضته ورضاه بحيث أن مصدر التزام المدين بتقديم الكفيل قد يكون قانونياً.

أطراف عقد الكفالة وإثباته

أولاً: أطراف عقد الكفالة:

أ- **الكفيل** ← يلزم أن يتوافر لدى الكفيل أهلية التبرع، ويحق للدائن أن يطالب الكفيل بوفاء الدين إن لم يوفي به المدين، فهو ضامن للدين في حالة عدم سداد المدين له فهو ملزم بسداده بدلاً من المدين للدائن الذي له الحق في مطالبة الكفيل بالسداد.

ب- **المكفول له** ← والمكفول له هو الدائن الأصلي الذي يكون له دين لدى المدين الذي يدخل طرف آخر لزيادة الثقة في السداد وفي حالة التأخر أو التخلف عن السداد يقوم هذا الكفيل بالسداد بدلاً عنه في حالة رغبة الدائن في مطالبة الكفيل في السداد ولا يمنع ذلك الكفيل من الرجوع على المدين للمطالبة بما سدده عنه.

ثانياً: إثبات عقد الكفالة:

"لا تثبت الكفالة إلا بالكتابة، ولو كان من الجائز إثبات الالتزام الأصلي بالبيينة".

خصائص الكفالة

أولاً: الكفالة عقد رضائي:

الكفالة عقد رضائي ينعقد بمجرد التراضي ما بين الكفيل والدائن، فلا حاجة في انعقاده إلى شكل خاص، فالكفالة تخضع للقاعد العامة في إبرام العقود وهي الرضائية.

مع الوضع في الاعتبار، ان المدين ليس طرفاً في عقد الكفالة، حيث أن رضاء أو عدم رضاء هذا الأخير لا أثر له على انعقاد عقد الكفالة.

ثانياً: الكفالة عقد ضمان شخصي:

الكفالة التزام شخصي للكفيل يضاف إلى التزام المدين أي أنها تمنح الدائن ضماناً شخصياً بالتزام الكفيل بالوفاء بما التزم به المدين عند عدم وفاء هذا الأخير بالتزامه وبذلك يكون كل من (المدين والكفيل) مسؤولاً مسؤولية شخصية في جميع أمواله عن الوفاء بالتزام المدين".

ويترتب على اعتبار الكفالة عقد من عقود الضمان الشخصي، أنها لا تجنب الدائن تماماً مخاطر الإعسار .

ثالثاً: الكفالة عقد ملزم لجانب واحد:

لما كان أطراف عقد الكفالة هما الدائن والكفيل بمقتضاها يتعهد الأخير للدائن بضمان حقه لدى المدين، فالكفالة تعتبر **عقد ملزم لجانب واحد هو الكفيل**، فهي لا ينشأ عنها سوى التزام الكفيل، قبل الدائن، بالوفاء بالتزام إذا لم يف به المدين نفسه .

مع الوضع في الاعتبار، أنه ليس معنى أن الكفالة عقد ملزم لجانب واحد أنها تنعقد بالإرادة المنفردة للكفيل وحده بل هي عقد لا ينعقد إلا بتبادل وتطابق إرادتي كل من الكفيل والدائن.

رابعاً: الكفالة عقد نابع:

تهدف الكفالة إلى ضمان الوفاء بدين من الديون، **فالالتزام الكفيل يتبع التزام المدين في وجوده وصحته**، فلا تنشأ الكفالة إلا إذا وجد التزام أصلي، ولا يكون التزام الكفيل صحيحاً إلا إذا كان الالتزام المكفول صحيحاً وفكرة التبعية هي التي تحكم آثار الكفالة .

نتيجة لذلك فإن التزام الكفيل، كالتزام تابع يتبع الالتزام الأصلي من حيث الوجود، الصحة الوصف، النطاق، الآثار والانقضاء.

فأما من حيث الوجود ← فإنه لا تطبق أحكام الكفالة على التزام الكفيل قبل البت في التحقق من وجود التزام المدين الأصلي .

أما من حيث الصحة ← فتظهر التبعية حيث لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الالتزام المكفول صحيحاً.

أما من حيث الوصف ← فيتبع التزام الكفيل الالتزام الأصلي المكفول من حيث الوصف سواء كان معلقاً على شرط أو مقترناً بأجل ومن ثم تجوز الكفالة في الدين الشرطي .

أما من حيث النطاق ← لا تجوز الكفالة في مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين للدائن .

ذلك أن من مقتضى تبعية التزام الكفيل للالتزام الأصلي المكفول من ناحية وأن المدين هو صاحب المصلحة في الدين من ناحية أخرى، أن التزام الكفيل لا يجوز أن يزيد عن التزام المدين الأصلي أو أن يكون أشد عبثاً منه .

وإذا خالف التزام الكفيل هذه القواعد، فكان أشد وأكثراً عبثاً من التزام المدين الأصلي، **فإن الجزء لا يكون البطلان وإنما إنقاصه إلى ما يعادل الالتزام المكفول.**

أما من حيث الآثار ← فإنه يمكن للكفيل أن يحتج بجميع الدفوع التي يحتج بها المدين .

خامساً: الكفالة عقد تبرع بحسب الأصل:

تعتبر الكفالة من العقود التي يلتزم فيها الكفيل بالضمان دون أي مقابل كونها تبرع من جانبه لكفالة المدين. ولكن بالإمكان أن تكون الكفالة ليست تبرعاً وتكون من عقود المعاوضة بحيث يأخذ الكفيل مبلغ مقابل كفالته سواء كان من الدائن أو المدين فيصبح حينها العقد عقد معاوضة.

أنواع الكفالة —

أولاً: أنواع الكفالة من حيث مصدر الالتزام بها:

١- **الكفالة الاتفاقية** ← وهي التي تنشأ نتيجة اتفاق المدين مع الدائن، بحيث يلتزم الأول بتقديم كفيل للثاني لكي يضمن دينه في حالة تخلفه عن الوفاء به، وهذا الاتفاق هو مصدر التزام المدين بتقديم الكفالة.

٢- **الكفالة القانونية** ← تكون الكفالة قانونية عندما يلتزم المدين بأن يُقدم كفيل في الأحوال التي يوجب القانون فيها على المدين تقديم كفيل للدائن.

من أمثلة الكفالة القانونية في القانون المدني المصري ← مسؤولية المتبوع عن أفعال التابع .

٣- **الكفالة القضائية** ← تكون الكفالة قضائية في الحالات التي يكون مصدر التزام المدين بتقديم كفيل للدائن هو حكم القضاء تطبيقاً لنصوص قانونية معينة.

ثانياً: أنواع الكفالة حسب محل الالتزام:

- ١- **الكفالة الشخصية** ← هي الكفالة العادية التي ترتب التزاماً في ذمة الكفيل بضمان الوفاء إذا لم يفي به المدين .
- ٢- **الكفالة العينية** ← تعرف الكفالة العينية بأنها اتفاق بأن يقدم الكفيل مالاً مملوكاً له أو عقاراً أو منقولاً من أجل ضمان دين على غيره. حيث يسمى هذا الكفيل بالكفيل العيني إذا رهن عقاراً أو منقول رهناً رسمياً أو حيازياً، فهو لا يضمن الوفاء إلا في الحدود المال الذي قدمه، فالضمان لا يرد على كل ذمته المالية كما هو عليه الحال في الكفالة الشخصية.

انعقاد الكفالة

س ١٦: وضع شروط و اركان عقد الكفالة؟

— الرضا بالكفالة —

- ☞ فهي لا تنعقد إلا بتراضي فلا يلزم حصول الرضا من جانب المدين، فهو لا يعد طرفاً في العقد، فالكفالة تنعقد بغير علمه ورغم معارضته .
- ☞ كما يجب أن يتوافر لدى طرفي العقد إرادة معتبرة قانوناً، حيث يشترط أن يكونا مميزين على الأقل حتى تنعقد الكفالة صحيحة، فإذا كان أحد طرفي العقد سواء الكفيل أو الدائن غير مميز، فإن الكفالة تقع باطلة بطلاناً مطلقاً.

الراضي بين الكفيل والدائن

- ☞ تنعقد الكفالة بمجرد أن تتطابق إرادتي كل من الكفيل والدائن .
- ☞ لا يكفي وجود الرضا في الكفالة لكي ترتب آثارها القانونية، وإنما يلزم أن يكون هذا الرضا صحيحاً، وهو لا يكون كذلك إلا بتوافر شرطين هما: التمتع بالأهلية، وأن تكون الإرادة خالية من عيوب الرضا

أولاً: التمتع بالأهلية:

أ- أهلية الكفيل:

- ☞ بالنسبة للكفيل عقد الكفالة هو من عقود التبرع، فإن الكفالة تعتبر بالنسبة للكفيل من الأعمال الضارة ضرراً محضاً، فإنه يجب أن تتوافر في الكفيل أهلية المتبرع، أهلية الأداء الكاملة .
- ☞ وعلى هذا الأساس، تقع كفالة القاصر بالنسبة إلى دين على شخص آخر باطلة، إذا كانت الكفالة تبرعاً بدون مقابل.

ب- أهلية الدائن:

- ☞ تعتبر الكفالة بالنسبة للدائن عملاً نافعاً نفعاً محضاً، فلا تشترط فيه سوى التمييز حتى تكون كفالة صحيحة .

ثانياً: يجب أن تكون الإرادة خالية من عيوب الرضا:

- ☞ حتى ينعقد عقد الكفالة صحيحاً - وفقاً للقواعد العامة - فإنه يلزم ألا يكون إرادة الكفيل معيبة بأي عيب من عيوب الإرادة

١. **الإكراه** ← هو رهبة تنبعث في نفس الشخص فتدفعه إلى التعاقد. **مثال:** حمل الزوج زوجته بما له من سلطة عليها أن تكفله في دين كبير عليه، وهي تعلم أن زوجها لا يستطيع الوفاء بهذا الدين .
٢. **الغلط** ← هو عبارة عن وهم يقوم في ذهن أحد المتعاقدين فيصور له الشيء على خلاف حقيقته. ويجب أن يكون الغلط جوهرياً ويبلغ حداً من الجسامه .

٣. **التدليس** ← هو إيقاع المتعاقد في غلط أي إيهامه بغير الحقيقة لدفعه إلى التعاقد. **مثال ذلك**: كأن يوهم الدائن الكفيل بأن المدين موسر أو أن هناك ضمانات أخرى تضمن الوفاء بالمدين.
٤. **الاستغلال** ← هو استغلال أحد المتعاقدين ما لدى المتعاقد الآخر من طيش أو هوى جامع عند إبرام العقد وذلك للحصول منه على مزايا دون مقابل .

— محل الكفالة —

١. إن محل الالتزام في عقد الكفالة هو ضمان الوفاء بالالتزام الأصلي إذا لم يف به المدين نفسه، وذلك مهما كان مصدره وأياً كان محله، كأن يكون مصدره العقد أو العمل غير المشروع أو القانون، وسواء كان محله إعطاء شيء أو التزام بعمل أو الالتزام بامتناع عن عمل، كما يجوز أن يكون التزام الكفيل محلاً لكفالة أخرى، وهذا ما يسمى بكفيل الكفيل، أو ما يطلق عليه بـ: "المصدق".
٢. والشروط الواجب توافرها في محل الكفالة هي ذات الشروط المطلوبة في محل أي عقد طبقاً للقواعد العامة، وهي أن يكون محل العقد (الالتزام المكفول) موجوداً، وصحيحاً، ومعيناً أو قابلاً للتعيين.

وجود الالتزام المكفول

٣. الكفالة تفترض وجود التزام أصلي، وإذا لم يوجد هذا الأخير كان محل الكفالة مستحيلاً في ذاته، وبالتالي يعتبر عقد الكفالة باطلاً.

رکز

٤. إذا كان يمكن أن يكون محل عقد الكفالة قابلاً للوجود، لذلك لا يوجد ما يمنع من كفالة الالتزام المستقبلي، أو الالتزام الشرطي، أو حتى الالتزام الطبيعي الذي يفترض لعنصر المسؤولية.

أولاً: كفالة الالتزام المستقبلي:

٥. أن متطلبات التعامل في الوقت الحاضر أصبحت تقتضي ذلك، لأن أصحاب الأموال لا يقبلون على منح الائتمان إلا إذا حصلوا مقدماً على ضمان يكفل لهم استيفاء حقوقهم، لكن في كل الأحوال لا تنتج كفالة الالتزام المستقبلي أثرها ولا تكون لازمة إلا إذا وجد هذا الالتزام فعلاً.
٦. **ويمكننا أن نذكر مثال على كفالة الدين المستقبلي** ← كأن يقدم المشتري كفيلاً يضمنه في البضائع التي يشتريها من متجر معين.
٧. ويعتبر ذلك تطبيقاً للقواعد العامة التي تنص على أنه "يجوز أن يكون محل الالتزام شيئاً مستقبلاً".

أن المشرع قيد كفالة المستقبلي بشرطين هما:

١. **يجب أن يكون الدين المستقبلي المكفول محدداً مسبقاً في عقد الكفالة** ← فإذا كفّل شخص ثمن بضائع لم تشتتر بعد، وجب تحديد المقدار الذي كفله الكفيل .
٢. **جواز رجوع الكفيل في الدين المستقبلي قبل نشوء الدين المكفول** ← إذا لم يكن قد حدد مدة معينة لكفالاته أما إذا حدد الكفيل كفالاته بمدة معينة فلا يجوز له أن يرجع فيها طوال هذه المدة، بل يجب عليه الوفاء بالدين الأصلي متى وُجد الدين وحل أجله إذا لم يف به المدين خلال تلك المدة .

ثانياً: كفالة الالتزام الطبيعي:

٨. **الالتزام الطبيعي** ← هو التزام ناقص، لأنه ينقصه عنصر المسؤولية ويتضمن فقط عنصر المديونية، بخلاف الالتزام المدني الذي يتوافر على عنصري المديونية والمسؤولية ويترتب هذا الالتزام في جميع الأحوال التي ينقضي فيها الالتزام المدني بالتقادم، وهو ما نص عليه القانون المدني "يترتب على التقادم انقضاء الالتزام، ولكن يتخلف في ذمة المدين التزام طبيعي".

معنى ذلك أنه لا يُتصور كفالة الدين المتقادم، لأن الكفالة في هذه الحالة يترتب عليها التزام مدني واجب الوفاء من الناحية القانونية في مواجهة الكفيل، مع أن الدين المكفول ليس كذلك، معنى ذلك أن الكفيل يصبح ملتزماً أصلياً لا تبعياً، وهو ما يتناقض مع خاصية تبعية الكفالة للدين الأصلي، التي من مقتضياتها ألا يكون التزام الكفيل في كل الأحوال أشد من التزام المدين الأصلي .

أن يكون الالتزام المكفول صحيحاً

فكرة تبعية التزام الكفيل للالتزام الأصلي تهيمن على كل أحكام الكفالة، وعليه حتى يكون التزام الكفيل قائماً وصحيحاً يجب أن يكون التزام المدين الأصلي صحيحاً . فالتزام الكفيل يدور مع الالتزام الأصلي صحة وبطلاناً ووجوداً وعدماً.

أن يكون الالتزام المكفول معيناً أو قابلاً للتعين

وهو الشرط الثالث الذي يجب أن يتوافر في محل أي عقد، ولكون محل الكفالة تابعاً للالتزام الأصلي المكفول، فإن هذا الأخير يجب أن يكون معيناً أو قابلاً للتعين حتى يتحدد على ضوءه التزام الكفيل الذي يمثل محل عقد الكفالة، ويتحدد الإلتزام المكفول بتعيين طرفيه ومحلّه ومصدره.

فبالنسبة لتعيين طرفي الالتزام المكفول ← يتحقق بتعيين كل من المدين والدائن بذكر كل ما يدل عليهما من اسم ولقب وعمر ومهنة ومكان إقامة .

أما فيما يتعلق بتعيين محل الالتزام المكفول ← فيجب ذكر نوعه من حيث كونه مبلغاً من النقود أو القيام بعمل معين أو الامتناع عن القيام بعمل معين مثلاً.

وليس هذا فحسب، بل يتطلب الأمر كذلك **تعيين الالتزام المكفول من حيث مصدره**، ويتحقق ذلك بذكر الواقعة القانونية التي أنشأت هذا الالتزام، فيذكر مثلاً أن مصدر الدين المكفول عقد قرض، أو أنه تعويض عن فعل ضار .

والحكمة من اشتراط تعيين مصدر الالتزام المكفول ظاهرة ← وهي أنه قد يكون للدائن تجاه مدينه دينين متساويين في القيمة لكن أحدهما مصدره عقد بيع والثاني عقد قرض فيكون من الضروري تحديد أي من الدينين يضمنه الكفيل

أولاً: قصر التزام الكفيل على جزء من الالتزام الأصلي:

التزام الكفيل يجب ألا يتجاوز حدود الالتزام الأصلي، لكن يجوز أن يكون أقل منه في مقداره أو في شروطه أو في أوصافه .

طبقاً لهذا النص لا يجوز للدائن والكفيل أن يتفقا على التزام هذا الأخير بمبلغ أكبر من مبلغ الدين الكفول وإذا كان الدين الأصلي مستحق الأداء في أجل معين في أول مارس ٢٠١٠، فلا يجوز الاتفاق على جواز الرجوع على الكفيل قبل ذلك، ولكن إذا مد الدائن أجل الدين الأصلي لفائدة المدين تأجل في حق الكفيل بنفس المدة، وإذا تحوّل الدين الأصلي إلى التزام طبيعي فلا يبقى مدنياً في حق الكيل، بل يتحول أيضاً في حقه إلى التزام طبيعي.

ركز

وقد تساءل الفقه عن حكم الكفالة التي تنعقد بشروط أشد من شروط الالتزام الأصلي المكفول.

استقر رأي المراجع ← على أنه تعتبر صحيحة في حدود الالتزام الأصلي، بمعنى يجب إنقاص التزام الكفيل إلى حدود التزام المدين.

وإذا كان لا يجوز الاتفاق على أن يكون التزام الكفيل أشد من التزام المدين، فإنه على العكس تماماً يجوز أن يكون بمبلغ أقل وبشروط أخف.

ثانياً: كفالة الكفيل:

وفي هذه الحالة لا يجوز للدائن أن يرجع على كفيل الكفيل قبل رجوعه على الكفيل إلا إذا كان كفيل الكفيل متضامناً مع الكفيل".

بحيث يخضع كفيل الكفيل في علاقته بالكفيل إلى نفس القواعد التي يخضع لها الكفيل في علاقته بالمدين، وبالتالي تكون كفالة الكفيل تابعة للكفالة الأصلية ومرتبطة بها وجوداً وعدماً، بحيث يجوز لكفيل الكفيل أن يتمسك في مواجهة الدائن بكافة الدفوع المتعلقة ببطلان وإنقضاء الكفالة الأصلية.

سبب الكفالة

"إذا لم يكن للالتزام سبب، أو كان سببه مخالفاً للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلاً". حيث أن سبب العقد هو الباعث الدافع إلى التعاقد الذي حمل الشخص على قبول التعاقد والذي لولاه لما أبرم هذا العقد. وإذا كانت الكفالة من عقود التبرع بحسب الأصل، فإنها تكون صحيحة إذا بنيت على سبب مشروع، بينما تكون الكفالة باطلة إذا كان الباعث غير مشروع.

مثال ذلك ← في حالة التبرع من الكفيل إلى الدائن - إذا كفّل شخص دين على شخص آخر لدى دائن مقابل انتقام الأخير له من شخص ثالث.

بينما في حالة التبرع من الكفيل إلى المدين، كما لو كفّل شخص دين على امرأة بقصد حملها على إقامة علاقة غير مشروعة معه.

س ١٧: وضع اثار الكفالة مبيناً العلاقة بين الدائن والكفيل؟

اثار الكفالة

العلاقة بين الدائن والكفيل ميعاد مطالبة الدائن للكفيل

١. لا يجوز للدائن أن يطالب الكفيل إلا عند حلول أجل الكفالة، والغالب أن يكون أجل التزام الكفيل هو نفسه أجل الالتزام المكفول لا يجوز للدائن أن يطالب الكفيل بالوفاء بالدين قبل حلول أجل هذا الأخير،

٢. لا يجوز للدائن أن يقوم بالتنفيذ على أموال الكفيل قبل التنفيذ على أموال المدين.

٣. لا يجوز للدائن أن ينفذ على أموال الكفيل قبل التنفيذ على التأمين العيني.

وهذا هو ما سوف نتناوله على النحو التالي:

أولاً: وجوب حلول أجل الدين بالنسبة للكفيل:

إلا أنه قد يحدث أن يختلف الأجلان زيادة أو نقصاناً عن الأجل الأصلي، فيتغير تبعاً لذلك ميعاد مطالبة الدائن للكفيل للوفاء بالدين، ونميز هنا بين حالتين، هما:

• الحالة الأولى ← عند الاتفاق بين الدائن والكفيل على تحديد أجل التزام الكفيل .

مثال ذلك ← إذا كان أجل الدين الأصلي هو: ٢٠١٢/١٢/٣١، واتفق الدائن مع الكفيل على أن يكون أجل الدين بالنسبة لهذا الأخير هو: ٢٠١٣/١/١٨، فهنا لا يستطيع الدائن مطالبة الكفيل بالوفاء بالدين الذي لم يف به المدين في الأجل المحدد له، إلا بعد حلول الأجل الخاص به.

- **الحالة الثانية** ← عند عدم الاتفاق على تحديد أجل لالتزام الكفيل، فهنا يحل الأجل بالنسبة إليه بحلول أجل الدين الأصلي، لكن قد يحدث أن يتغير أجل الدين الأصلي باتفاق طرفيه (الدائن والمدين) أو بحكم قضائي، فهل يتأثر بذلك الأجل الممنوح للكفيل؟! **إن الإجابة على هذا التساؤل تختلف حسب الفرضين التاليين:**
 - **الفرض الأول** ← إذا اتفق الدائن والمدين أو صدر حكم قضائي بمد أجل الالتزام الأصلي، فإن الكفيل يستفيد من مد الأجل، ولا يجوز مطالبته قبل حلول الأجل الجديد.
 - **الفرض الثاني** ← إذا حدث العكس وتم الاتفاق بين الدائن والمدين على تعجيل أجل الالتزام الأصلي فإن الكفيل يجب ألا يضار من هذا الاتفاق، وبالتالي لا يجوز مطالبته إلا عند حلول الأجل الأصلي.
- ثانياً: وجوب رجوع الدائن على المدين أولاً قبل رجوعه على الكفيل:**
- لا يجوز للدائن مطالبة الكفيل وحده بالوفاء بالدين إلا بعد رجوعه على المدين، والمقصود بالرجوع هو المطالبة القضائية.
 - ويترتب على ذلك أن المطالبة الودية لا تعد رجوعاً بالمعنى الوارد في النص، ومع ذلك **توجد حالتين يعفى فيهما الدائن من شرط رفع الدعوى على المدين أولاً حتى يستطيع الرجوع على الكفيل، وهما:**
 - **حالة ما إذا أفلس المدين وتعذر على دائنيه اتخاذ إجراءات فردية ضده** ← فإنه يكفي هنا تقدم الدائن بحقه في تفليسه المدين، لكي يستطيع أن يستعمل حقه في الرجوع على الكفيل، وإذا لم يفعل يسقط حقه في الرجوع على الكفيل.
 - **حالة ما إذا كان لدى الدائن سنداً رسمياً صالحاً في ذاته للتنفيذ على المدين** ← وهنا يكون الدائن في غنى عن رفع دعوى قضائية على مدينه، إذ يكفي أن يكلف المدين بالوفاء بالدين، حتى يتمكن من الرجوع على الكفيل.

الدفع الممنوح للكفيل لرد مطالبة الدائن

- **المقصود بدفع الكفيل** ← الأوجه التي يستطيع من خلالها هذا الأخير أن يتمسك بها في مواجهة الدائن إذا طالبه بدفع الدين، وهدف الكفيل من إبداء هذه الدفع هو إما تأجيل المطالبة أو تقرير براءة ذمته.

س ١٨: اكتب في الدفع الناشئة عن عقد الكفالة؟

الدفع الناشئة عن الدين المكفول

- يحق للكفيل أن يتمسك بجميع الدفع التي يستطيع المدين التمسك بها في مواجهة الدائن، لأن تبعية التزام الكفيل تجعله يتأثر بكل ما يؤثر في الالتزام المكفول.
- نستخلص مما سبق، أنه **يستطيع الكفيل أن يتمسك في مواجهة الدائن بكل ما يستطيع المدين الأصلي أن يدفع به مطالبته**، ومن هذه الدفع ما يؤدي إلى بطلان الالتزام المكفول، كالدفع بالبطلان لانعدام الرضا أو المحل أو السبب.
- كما له أن يتمسك بالدفع المؤدية إلى انقضاء الالتزام المكفول كالوفاء، التجديد، والتقادم.

الدفع الناشئة عن عقد الكفالة

- إذا كان التزام الكفيل تابعاً للالتزام الأصلي فإنه يتأثر بكل ما يؤثر فيه، إلا أن التزام الكفيل له استقلالية خاصة به، بحيث يحق للكفيل - وفقاً للقواعد العامة - أن يتمسك في مواجهة الدائن بكل ما يتعلق بصحة أو نفاذ أو انقضاء التزامه بصرف النظر عن الالتزام الأصلي.
- وعلى هذا الأساس، فإنه يمكن للكفيل أن يدفع مطالبة الدائن ببطلان عقد الكفالة في حالة تخلف أي ركن من أركان انعقاده أو إذا شاب إرادته أي عيب من عيوب الإرادة مثل الغلط أو التدليس أو الإكراه.

كما منح المشرع المصري الكفيل دفوعاً خاصة به مراعاة لمصلحته على أساس أن عقد الكفالة بالنسبة له هو عقد تبرع مما يسمح للكفيل بالتمسك بالدفع بعدم جواز مطالبة الكفيل وحده إلا بعد الرجوع على المدين

أولاً: الدفع بعدم جواز مطالبة الكفيل وحده إلا بعد الرجوع على المدين:

هذا الدفع لا يتعلق بالنظام العام، وإنما هو مقرر لمصلحة الكفيل، وبالتالي يجوز له التمسك به أمام القاضي في أي مرحلة تكون عليها الدعوى ولو في مرحلة الاستئناف، ولا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.

ولكي يُسمح للكفيل بالتمسك بهذا الدفع يجب توافر الشروط التالية:

١. ألا يكون الكفيل قد تنازل عن حقه في هذا الدفع صراحة أو ضمناً.
 ٢. يجب ألا يكون الكفيل متضامناً مع المدين.
 ٣. أن يكون للكفيل مصلحة في التمسك بهذا الدفع، فلو كان المدين معسراً، فلا فائدة من تمسك الكفيل بوجوب الرجوع على المدين أولاً.
- مما سبق نخلص إلى القول، أنه إذا توافرت الشروط الثلاثة السابقة في الدفع الذي تمسك به الكفيل، فإنه يجب على القاضي أن يحكم بعدم قبول دعوى الدائن ضده، وذلك لعدم ثبوت الحق في رفعها بعد، وهذا الحكم لا يمس بأصل حق الدائن في مواجهة الكفيل.

ثانياً: عدم جواز التنفيذ على أموال الكفيل قبل التنفيذ على أموال المدين "الدفع بالتجريد":

تعريفه ← هو حق بمقتضاه يستطيع الكفيل منع الدائن من التنفيذ على أمواله قبل أن ينفذ على أموال المدين الذي قام بكفالته.

وسوف نتناول شروطه والآثار القانونية المترتبة عليه وكذلك بعض الصور الخاصة بالدفع بالتجريد على النحو التالي:

١- شروط الدفع بالتجريد:

الشرط الأول: يجب على الكفيل أن يتمسك بهذا الدفع:

وهذا ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة ٧٨٨ بقولها: "ولا يجوز له أن ينفذ على أموال الكفيل إلا بعد أن يجرد المدين من أمواله، ويجب على الكفيل في هذه الحالة أن يتمسك بهذا الحق". حيث أن هذا الدفع لا يتعلق بالنظام العام، لذا يجب على الكفيل التمسك به ولا يجوز للمحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها على أساس أن هذا الدفع مقرر لمصلحة الكفيل.

الشرط الثاني: يجب أن يرشد الكفيل الدائن إلى أموال المدين التي تفي بالدين كله:

إذا طلب الكفيل التجريد، وجب عليه أن يقوم على نفقته بإرشاد الدائن إلى أموال المدين التي تفي بالدين كله. ولا عبرة بالأموال التي يدل عليها الكفيل إذ كانت هذه الأموال تقع خارج الأراضي المصرية أو كانت أموالاً متنازعة فيها".

فلكي يكون الدفع بالتجريد مقبولاً وقائماً على أساس يجب أن تكون للمدين أموال يمكن للدائن التنفيذ عليها، ويقع على الكفيل عبء إثبات وجود أموال للمدين صالحة وكافية للوفاء بكل الدين، حيث يقوم الكفيل بإرشاد الدائن إلى هذه الأموال على نفقته.

مثال ذلك ← مصروفات استخراج صور مستندات ملكية المدين للأموال التي أرشد عنها.

ويتضح أنه يشترط في أموال المدين التي يرشد عنها الكفيل الشروط الآتية:

🔴 **أن تكون هذه الأموال مملوكة للمدين** ← ولا عبرة في هذه الأموال، إذا كانت منقولاً أو عقاراً، فالأموال الغير مملوكة له لا يعتد بها حتى ولو كانت في حيازته.

🔴 **أن تكون هذه الأموال قابلة للحجز عليها** ← وهو شرط يتفق مع الغاية من الإرشاد وهو التنفيذ.

🔴 **أن تكون هذه الأموال كافية للوفاء بكل الدين** ← فلا يكفي أن تفي إلا بجزء من الدين، فإن كانت الأموال التي يرشد عنها الكفيل لا تكفي لسداد الدين كله، فإنه لا يجوز التمسك بالدفع بالتجريد، لأن الدائن سيضطر للتنفيذ مرتين وفي ذلك إجبار للدائن على القبول بالوفاء الجزئي وهو ما لا يجوز، فضلاً على أنه فيه إرهاب للمحكمة.

🔴 **أن تكون هذه الأموال موجودة في مصر** ← وذلك لتجنب إرهاب الدائن من خلال مباشرة إجراءات معقدة عند وجود الأموال في خارج الأراضي المصرية.

🔴 **وجوب ألا تكون هذه الأموال متنازع فيها** ← لأن الأموال المتنازع عليها غير مأمونة العاقبة، فقد يسفر فض النزاع عن أنها غير مملوكة للمدين، وبالتالي لا يمكن التنفيذ عليها من قبل الدائن.

🔴 ويكون المال متنازعاً فيه، إذا كانت هناك دعوى مرفوعة في شأنه أو كان محلاً لنزاع جدي

🔴 **مثال ذلك** ← المال الشائع حيث لا يمكن التنفيذ عليه إلا بعد الفصل في دعوى القسمة.

الشرط الثالث: ألا يكون الكفيل متضامناً مع المدين:

🔴 "لا يجوز للكفيل المتضامن مع المدين أن يطلب التجريد".

🔴 يستفاد من هذا النص، بأن الكفيل المتضامن قد تخلى عن الحقوق التي منحها إياه المشرع في التمسك بالدفع بالتجريد، وهذا بخلاف الكفيل العادي الذي يبقى يستفيد من الدفع بالتجريد.

٢- آثار الدفع بالتجريد:

🔴 إذا ما توافرت شروط الدفع بالتجريد وتمسك به الكفيل، تعين على المحكمة قبوله والحكم به، ويترتب على ذلك الآثار القانونية التالية:

أ- وجوب البدء في التنفيذ على أموال المدين قبل أموال الكفيل

🔴 إذا ما توافرت شروط الدفع بالتجريد، فإن أول أثر يترتب على قبوله من قبل المحكمة هو وقف إجراءات التنفيذ على أموال الكفيل ويتحقق ذلك بمجرد إبداء الكفيل للدفع حتى تفصل المحكمة فيه، فإذا رُفض استمر الدائن في مباشرة إجراءات التنفيذ على أموال الكفيل، أما إذا قُبِل من جانب المحكمة، فإنه يُمنع على الدائن الاستمرار فيها.

ب- تحمل الدائن نتيجة عدم اتخاذ إجراءات التنفيذ في الوقت المناسب

🔴 إذا ما أرشد الكفيل الدائن إلى أموال المدين، وكانت هذه الأخيرة قابلة للتنفيذ عليها، وقبلت المحكمة الدفع بالتجريد، فإن على الدائن أن يبادر إلى اتخاذ إجراءات التنفيذ على هذه الأموال، وإلا تحمل نتيجة إعسار المدين الناجم على عدم اتخاذ إجراءات التنفيذ في الوقت المناسب.

🔴 **مثال ذلك** ← إذا أرشد الكفيل الدائن على منقولات المدين، وتراخى الدائن في اتخاذ إجراءات التنفيذ عليها، مما ترتب عليه تمكّن المدين من إخفائها أو تهريبها أو تبديدها، ففي هذه الحالة يكون الدائن مسؤولاً قبل الكفيل عما كان سيحصل عليه من ثمن هذه المنقولات لو أنه اتخذ إجراءات التنفيذ بمجرد أن أرشد عنها الكفيل، لأن سهولة إخفاء المنقولات أو تهريبها تقتضي السرعة في اتخاذ إجراءات التنفيذ.

ج- براءة ذمة الكفيل في حدود ما حصل عليه الدائن من حقه نتيجة التنفيذ على أموال المدين:

🔴 إذا ما باشر الدائن إجراءات التنفيذ على أموال المدين التي أرشد عليها الكفيل في الوقت المناسب، واستوفى حقه كاملاً من ثمنها، برئت ذمة المدين، وبرئت معها ذمة الكفيل بالتبعية.

🔴 أما إذا لم يحصل الدائن على حقه كاملاً من تلك الأموال بسبب عدم كفايتها نتيجة انخفاض قيمتها عند التنفيذ عليها بسبب تقلبات السوق، أو ظهور دائنون آخرون يزاحمون الدائن، ففي جميع تلك الفروض لا

تبرأ ذمة الكفيل إلا بمقدار ما استوفى الدائن حقه من أموال المدين بعد التنفيذ عليها، وهنا يستطيع الدائن الرجوع على الكفيل بالباقي من حقه.

٣- صورة خاصة للدفع التجريدي: "عدم جواز التنفيذ على أموال الكفيل قبل التنفيذ على التأمين العيني":

❗ "إذا كان هناك تأمين عيني خصص قانوناً أو اتفاقاً لضمان الدين وقدمت كفالة بعد هذا التأمين أو معه ولم يكن الكفيل متضامناً مع المدين، فلا يجوز التنفيذ على أموال الكفيل إلا بعد التنفيذ على الأموال التي خصصت لهذا التأمين".

❗ ويتضح من النص السابق، بأنه يستلزم توافر شروط معينة حتى يستطيع الكفيل أن يتمسك بهذا الدفع، هذه الشروط وهي:

- ١- أن يكون هناك تأمين عيني تقرر لضمان الدين المكفول ← وهذا التأمين قد يكون رهناً رسمياً أو حيازياً، ولا يشترط أن يكون هذا التأمين العيني كاف للوفاء بالدين أم غير كاف للوفاء بالدين كله.
- ٢- أن يكون التأمين العيني سابقاً أو معاصراً للكفالة ← وبمفهوم المخالفة إذا تقرر التأمين العيني بعد انعقاد الكفالة، فإن الكفيل لا يستطيع الدفع بالتنفيذ على هذا التأمين.
- ٣- أن لا يكون الكفيل متضامناً مع المدين ← وإلا جاز للدائن أن ينفذ على أمواله قبل التنفيذ على التأمين العيني.
- ٤- يشترط أن يتمسك الكفيل بالدفع بالتجريد ← ولا يجوز أن تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها؛ لأنه ليس من النظام العام، فهذا الدفع مقرر لمصلحته.

ثالثاً: الدفع بالتقسيم:

❗ يثبت هذا الدفع لأحد الكفلاء الذي رجع عليه الدائن في مواجهة البقية في حالة تعددهم.

❗ فإذا تعدد الكفلاء لدين واحد وفي عقد واحد ولم يكونوا متضامنين فيما بينهم، فإن الدين ينقسم عليهم، ولا يجوز للدائن أن يرجع على أي منهم بأكثر من قدر نصيبه في الدين.

أ- شروط الدفع بالتقسيم:

يشترط في الدفع بالتقسيم مايلي:

١. تعدد الكفلاء ← وهذا الشرط هو الفرض الأساسي الذي يقوم فيه الدفع بالتقسيم، فإذا كان هناك كفيل واحد فإن الدين لا ينقسم بينه وبين المدين، وبالتالي لا مجال للكلام عن التقسيم، لأن الكفيل يكون وحده مسؤول عن الدين كله.
٢. تعدد الكفلاء لدين واحد ← لا يجوز للكفيل أن يطلب تقسيم الدين بينه وبين كفيله (أي كفيل الكفيل)، لأن التزاميهما مختلفان فالكفيل يضمن الالتزام الأصلي أما كفيل الكفيل فيضمن التزام الكفيل.
٣. أن يكفل الكفلاء المتعددون نفس الدين ← فإذا تعدد المدينون المتضامنون، وقدم كل منهم كفيلاً، أي لكل مدين كفيل، فلا يجوز لهؤلاء الكفلاء المتعددين أن يطلبوا التقسيم، بل يبقى كل منهم مسؤولاً عن كل الدين لأنه في التضامن يجوز للدائن مسألة أي مدين بكل الدين لذا فإن كل كفيل لأي من المدينين مسؤول عن مجموع الدين.
٤. ألا يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ← لأنهم إذا كانوا متضامنين فيما بينهم، يجوز للدائن الرجوع على أي منهم، ويطالبه بالوفاء بكل الدين عملاً بأحكام التضامن، وبالتالي يحرم أي منهم من التمسك بحق الدفع بالتقسيم في مواجهة الدائن.
٥. تعدد الكفلاء بعقد واحد ← لأنه في هذه الحالة يكون كل واحد منهم اعتمد على غيره من الكفلاء، وبالتالي انصرفت نيته إلى أنه لا يلتزم إلا بقدر نصيبه لذلك قرر المشرع تقسيم الدين فيما بينهم بقوة القانون، أما إذا كان كل كفيل قد التزم بكفالة الدين بعقد مستقل، فإنه لا يكون قد اعتمد على بقية الكفلاء، وبالتالي لا ينقسم الدين بينه وبين غيره من الكفلاء، إلا إذا كان قد احتفظ لنفسه بحقه في التقسيم، وأنقسام الدين في هذه الحالة يقع بمقتضى الشرط وليس بقوة القانون.

ب- آثار الدفع بالتقسيم:

- إذا توفرت الشروط السابقة الذكر، فإنه لا يحق للدائن أن يطالب أي من الكفلاء إلا بقدر حصته من الدين، وإذا لم يتم الاتفاق على تحديد حصة كل كفيل في الدين، قسم الدين بينهم بالتساوي، ويقع التقسيم فيما بين الكفلاء المتعديين وغير المتضامنين بقوة القانون لو لم يطلبه الكفلاء.
- نتيجة لذلك، يجوز للكفيل التمسك بهذا الدفع في أي مرحلة كانت عليها الدعوى. مع الوضع في الاعتبار، أنه إذا أعسر أحد الكفلاء، فإن الدائن هو الذي يتحمل حصة المعسر منهم، ولا يمكن مطالبتهم بحصة المعسر.

التزامات الدائن عند استيفاء الدين من الكفيل

أولاً: الالتزام بنسليم المستندات:

- "يلتزم الدائن بأن يسلم الكفيل وقت وفائه الدين المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع"، والمقصود بالمستندات هنا سند الدين المكفول، وكذلك مخالصة من الدائن تفيد استيفائه للدين من الكفيل.

- وحتى يستطيع الكفيل الحلول محل الدائن، ومن ثم الرجوع بما وفى على المدين، فإنه يجب على الدائن أن يزوده بكل ما يفيد في الرجوع على المدين. فإذا لم يلتزم الدائن بذلك، فإنه يحق للكفيل الامتناع عن الوفاء وأن يقوم بالإيداع القضائي لمبلغ الدين المكفول

ثانياً: الالتزام بنقل التأمينات:

- "إذا كان الدين مضموناً بمنقول مرهون أو محبوس، وجب على الدائن أن يتخلى عنه للكفيل.
- وإذا كان الدين مضموناً بتأمين عقاري، فإن الدائن يلتزم أن يقوم بالإجراءات اللازمة لنقل هذا التأمين، ويتحمل الكفيل مصروفات النقل على أن يرجع بها على المدين". وإذا لم يقم الدائن بنقل التأمين، فإنه يحق للكفيل أن يمتنع عن الوفاء وإيداع المبلغ قضائياً.

العلاقة بين الكفيل والمدين

- لذلك يجوز للكفيل أن يرجع على المدين طبقاً للقواعد العامة للإثراء بلا سبب، ويكون رجوع الكفيل بأقل القيمتين، قيمة الإفتقار وكذلك قيمة الإثراء، ولكن المشرع لم يكتف بإعطاء الكفيل الحق في الرجوع على المدين وذلك طبقاً للقواعد العامة في الإثراء بلا سبب لكن نظم رجوع الكفيل بشيء من التفصيل وأعطى له دعويين وهما دعوى شخصية تستند إلى عقد الكفالة وكذلك دعوى الحلول.

س ١٩: اكتب فى دعوى الكفالة ودعوى الحلول؟

دعوى الكفالة

- "للكفيل الذي وفى الدين أن يرجع على المدين سواء كانت الكفالة قد عقدت بعلمه أو بغير علمه".
- المشرع المصري منح الكفيل الذي وفى بالدين أو جزء منه دعوى شخصية تستند على عقد الكفالة بأن يرجع على المدين بما وفاه للدائن.
- وإذا كان من المتفق عليه، أن الكفيل الذي وفى بالدين لمصلحة الدائن يمكنه الرجوع على المدين بالدعوى الشخصية سواء كانت الكفالة بعلمه أو بغير علمه إلا أنه يستثنى من ذلك الكفيل الذي يوفى بالدين للدائن رغم معارضة المدين أو أن تكون الكفالة قد عقدت لمصلحة الدائن دون مصلحة المدين.

أولاً: شروط دعوى الكفالة:

١- أن تكون الكفالة قد عقدت لمصلحة المدين ودون معارضته:

- من المسلم به، أن دعوى الكفالة تقتصر على الحالات التي تنعقد فيها، الكفالة دون معارضة المدين، فهذه المعارضة تنفي كل مصلحة له، فالغالب أن الكفالة تحقق مصلحة المدين أو مصلحة الدائن والمدين معاً.

بحيث يمكن للكفيل أن يرجع على المدين بدعوى الكفالة، إذا انتفت المعارضة سواء أبرمت هذه الكفالة بعلمه أو بغير علمه.

وتجدر الإشارة إلى أن الكفالة تحقق في الغالب مصلحة المدين أو مصلحة الدائن والمدين معاً، أما حيث يثبت أن الكفالة قد عقدت من أجل تحقيق مصلحة الدائن وحده، فلا يمكن للكفيل أن يرجع على المدين على أساس دعوى الكفالة.

٢- قيام الكفيل بوفاء الدين الدائن:

يجب أن يوفى الكفيل بالدين لمصلحة الدائن، والوفاء يكون بتقديم الشيء المستحق أصلاً أو القيام بما يقوم مقامه مما يترتب عليه براءة ذمة المدين من الدين.

ويحق للكفيل أن يرجع على المدين على أساس دعوى الكفالة حتى ولو وفى بجزء من الدين إلى الدائن الذي قبل منه الوفاء الجزئي. حيث تختلف دعوى الكفالة عن دعوى الحلول التي يشترط للرجوع بها أن يكون الوفاء كلياً، وللدائن أن يرجع في الوقت نفسه على المدين بما تبقى من حقه.

٣- وفاء الكفيل بالدين الدائن عند حلول أجله:

يجب أن يقوم الكفيل بالوفاء بالدين المكفول عند حلول أجله، فإن قام بالوفاء قبل الميعاد لم يكن له الرجوع على المدين إلا عند حلول الأجل، إذ ليس للكفيل أن يجبر المدين على الوفاء قبل حلول الأجل.

٤- ألا يكون الوفاء قد حصل خطأ من الكفيل:

يحق للكفيل الرجوع على المدين بالدعوى الشخصية بما وفاه من دين للدائن، بشرط أن يترتب على هذا الوفاء براءة ذمة المدين، أما إذا كان الوفاء خطأ من جانب الكفيل بسبب بطلان مصدر الدين أو انقضائه كلياً أو جزئياً، فإنه لا يمكن للكفيل أن يرجع على المدين بما وفاه.

حيث أوجب القانون على الكفيل أن يخطر المدين قبل الوفاء بالدين، بعزمه على الوفاء فقد يكون لدى المدين أسباب تمنع الوفاء. فإن قام الكفيل بالوفاء دون إخطار المدين، فإنه يتحمل مسؤولية ذلك الوفاء بحيث لو أثبت المدين بأنه لم يستفاد من هذا الوفاء، فإنه لا يمكن للكفيل أن يرجع على المدين بشيء مما وفاه ويتحمل مسؤولية وفائه الخاطيء.

ثانياً: ما يرجع به الكفيل على المدين:

يرجع الكفيل بأصل الدين والمصروفات ويكون للكفيل الحق في الفوائد القانونية عن كل ما قام بدفعه ابتداء من يوم الدفع.

أ- أصل الدين ← وهو كل ما دفعه الكفيل إلى الدائن لإبراء ذمة المدين، ويشمل ذلك مقدار الدين الأصلي، وكذا فوائد هذا الدين لو كان ينتج فوائد اتفاقية أو قانونية ما دامت تدخل ضمن الدين المكفول.

ب- المصروفات ← وهي كل المبالغ التي أنفقها الكفيل في تنفيذ عقد الكفالة، وتلك التي أنفقها الدائن في رجوعه على الكفيل واضطر الكفيل إلى ردها له، بالإضافة إلى ما يكون قد أنفق الكفيل في الإرشاد على أموال المدين لتجريده ومصروفات الدعوى التي رفعها الدائن على الكفيل، لكن لا يرجع بهذه المصروفات على المدين إلا بالذي دفعه من وقت إخبار المدين الأصلي بالإجراءات التي اتخذها ضده.

دعوى الحلول

"إذا وفى الكفيل الدين كان له أن يحل محل الدائن في جميع ماله من حقوق قبل المدين. ولكن إذا لم يوف إلا بعض الدين، فلا يرجع بما وفاه إلا بعد أن يستوفي الدائن كل حقه من المدين".

أولاً: شروط دعوى الحلول:

هناك شرطان أساسيان للرجوع بهذه الدعوى:

- أن يكون الكفيل قد وفى بالدين عند حلول الأجل.

- أن يكون الدائن قد استوفى حقه كاملاً من الكفيل.

ومن هذا المنطلق، فإن هناك اختلافاً بين دعوى الحلول والدعوى الشخصية، حيث تستلزم الدعوى الأولى أن يوفى الكفيل بالدين كاملاً لمصلحة الدائن حتى يمكنه الرجوع على المدين بالمقارنة بالدعوى الثانية التي يكفي فيها أن يوفى الكفيل بجزء من الدين لمصلحة الدائن حتى يستطيع أن يرجع بالدعوى على المدين.

ثانياً: ما يرجع به الكفيل على المدين:

يترتب على حلول الكفيل محل الدائن مايلي:

- 🕒 **يرجع الكفيل - وفقاً للقواعد العامة - بحق الدائن ذاته قبل المدين** ← وبما يلحق هذا الحق من خصائص، وما يلحقه من توابع، وما يضمنه هذا الحق من تأمينات، وما يرد عليه من دفعات.
- 🕒 **يحل الكفيل محل الدائن في حقه قبل المدين** ← فيجب أن يكون حق الدائن لا زال قائماً وقت الوفاء ليستطيع الكفيل الموفى أن يرجع به.
- 🕒 فإذا كان حق الدائن قد انقضى بأي سبب أو تقرر بطلانه قبل الوفاء، فإن الكفيل لا يستطيع أن يرجع بدعوى الحلول.
- 🕒 **يرجع الكفيل بحق الدائن بما له من خصائص** ← فإذا كان حق الدائن تجارياً، فإن الحق الذي يرجع به الكفيل على المدين يكون تجارياً، بحيث يسري عليه وسائل الإثبات وسعر الفائدة.
- 🕒 **يرجع الكفيل بحق الدائن بما يلحق هذا الحق من توابع** ← فلو كان حق الدائن منتجاً لفوائد بسعر معين انتقل إلى الكفيل منتجاً للفوائد بهذا السعر.
- 🕒 **يحل الكفيل محل الدائن في حقه بما يضمنه من تأمينات** ← سواء كانت تأمينات شخصية أو عينية .
- 🕒 **يحل الكفيل محل الدائن في مواجهة الكفيل بما يرد على هذا الحق من دفعات** ← حيث يتمسك المدين في مواجهة الكفيل بما كان يستطيع التمسك به في مواجهة الدائن كالدفع ببطلان الالتزام المكفول.

العلاقة بين الكفلاء فيما بينهم —

أولاً: انقسام الدين في حالة تعدد الكفلاء غير المتضامنين:

- 🕒 إذا تعدد الكفلاء لدين واحد وبعقد واحد وكانوا غير متضامنين فيما بينهم، قسم الدين عليهم، ولا يجوز للدائن أن يطالب كفيل إلا بقدر نصيبه في الكفالة. أما إذا كان الكفلاء قد التزموا بعقود متوالية، فإن كل واحد منهم يكون مسؤولاً عن الدين كله، إلا إذا كان قد احتفظ لنفسه بحق التقسيم.
- 🕒 نستخلص مما سبق، أن المشرع يتخذ من وحدة العقد دليلاً على أن كل كفيل قد اعتمد على الكفلاء الآخرين، فينقسم الدين فيما بين الكفلاء المتعديدين بقوة القالون، فلا يلتزم كل كفيل ابتداءً إلا بجزء من الدين فقط، أو بمعنى آخر لا يلتزم الكفيل إلا الوفاء بنصيبه من الدين.

ثانياً: عدم انقسام الدين في حالة تعدد الكفلاء المتضامنين:

- 🕒 "إذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم ووفى أحدهم الدين عند حلول أجله له أن يرجع على كل من الباقيين بحصته في الدين ونصيبه في حصة المعسر منهم".
- 🕒 **تضامن الكفلاء فيما بينهم** ← يعني التزام كل منهم بكل الدين، ويجب على من توجه إليه المطالبة من الدائن أن يقوم بوفاء الدين كله دون أن يتمسك بتقسيم المطالبة بينه وبين بقية الكفلاء، لأن حكم الكفلاء المتضامنين هو حكم المدينين المتضامنين.
- 🕒 ويرجع الكفيل الذي وفى بالدين على الكفلاء الآخرين بدعوى الإثراء بلا سبب أو بدعوى الحلول محل الدائن.

انقضاء الكفالة

انقضاء الكفالة بصفة أصلية —

أولاً: الأسباب العامة لانقضاء التزام الكفيل:

- ١- **انقضاء التزام الكفيل باتحاد الذمة** ← أن انقضاء الالتزام الأصلي يستتبع انقضاء التزام الكفيل بصفة أصلية أو تبعية، لأنه لا بقاء للتابع بعد زوال الأصيل .
- 🕒 وقد ينقضي التزام الكفيل باتحاد الذمة دون أن ينقضي التزام المدين المكفول .
- 🕒 **مثال ذلك** ← إذا مات الدائن وورثه الكفيل فاتحدت الذمة وانقضت الكفالة، فإن التزام الكفيل ينقضي بصفة أصلية؛ لأنه ورث الدائن فأصبح دائناً لنفسه، ولكن الدين المكفول لا ينقضي فيستطيع الكفيل الذي أصبح دائناً باتحاد الذمة أن يرجع على المدين بالدين ذاته كما كان يرجع الدائن قبل موته.

٢- **انقضاء التزام الكفيل بالإبراء** ← إذا أبرأ الدائن الكفيل من الكفالة، برئت ذمة الكفيل دون أن ينقضي الالتزام المكفول، فيكون الدائن قد أبرأ الكفيل، واستبقى المدين الأصلي، أما الفرض العكسي فلا يصح، فلا يجوز للدائن أن يبرئ ذمة المدين الأصلي دون أن يبرئ ذمة الكفيل، وذلك لأن التزام الكفيل تابع لالتزام المدين وزوال الأصل يستتبع زوال التابع.

🔸 وإذا أبرأ الدائن أحد الكفلاء، فلا يستتبع ذلك إبراء باقي الكفلاء، وتجوز مطالبتهم كل بقدر الحصة التي كفّلها إذا كانوا غير متضامنين، وتجوز مطالبة أيهم بكل الدين بعد استئصال حصة الكفيل المبرأ إذا كانوا متضامنين.

ثانياً: الأسباب الخاصة لانقضاء التزام الكفيل:

أ- انقضاء التزام الكفيل بقدر ما أضعه الدائن بخطئه من الضمانات:

حيث تنص المادة ٧٨٤ مدني مصري على أنه:

- ١- تُبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضعه الدائن بخطئه من الضمانات.
- ٢- ويقصد بالضمانات في هذه المادة كل تأمين يخصص لضمان الدين ولو تقرر بعد الكفالة، وكل تأمين مقرر بحكم القانون.

ويستفاد من نص المادة سالف الذكر، أنه يشترط لانقضاء الكفالة توافر شروط وهي:

- ١- أن يكون التأمين الذي أضعه الدائن تأميناً خاصاً.
- ٢- أن يكون إضاعة التأمين نتيجة خطأ من جانب الدائن.
- ٣- وجوب ترتب ضرر يلحق بالكفيل، وإلا فلا محل للتمسك ببراءة الذمة.

ب- انقضاء التزام الكفيل بسبب تأخر الدائن في اتخاذ الإجراءات ضد المدين رغم إنذاره:

🔸 لا تُبرأ ذمة الكفيل لمجرد أن الدائن تأخر في اتخاذ الإجراءات، أو لمجرد أنه لم يتخذها. على أن ذمة الكفيل تُبرأ إذا لم يقيم الدائن باتخاذ الإجراءات ضد المدين خلال ستة أشهر من إنذار الكفيل للدائن، ما لم يقدم المدين للكفيل ضماناً كافياً.

ج- انقضاء التزام الكفيل لعدم تقدم الدائن في نفليسة المدين:

🔸 إذا أفلس المدين وجب على الدائن أن يتقدم في النفليسة بالدين، وإلا سقط حقه في الرجوع على الكفيل بقدر ما أصاب هذا الأخير من ضرر بسبب إهمال الدائن.

انقضاء الكفالة بصفة تبعية

١- انقضاء التزام المدين بالوفاء:

🔸 إذا وفى المدين بالتزامه برئت ذمته، وبرئت ذمة الكفيل بطريق التبعية، وهذا في حالة الوفاء الكلي للدين، أما إذا وفى المدين ببعض الدين، فلا تُبرأ ذمته أو ذمة الكفيل إلا بقدر ما وفاه ويكون للدائن أن يرجع بالباقي على المدين وعلى الكفيل.

🔸 أما إذا قام بوفاء الدين للدائن شخص من الغير، فإن ذمة المدين، وكذلك ذمة الكفيل لا تُبرأ من الدين، فالدين لا زال قائماً بكل دفعه وتأميناته، وحل الغير فيه محل الدائن.

🔸 ويشترط لبراءة ذمة الكفيل بالوفاء الصادر من المدين أن يكون هذا الوفاء صحيحاً، وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان الموفى أهلاً للوفاء، ومالكاً للشيء الذي وفى به.

٢- انقضاء التزام المدين بالوفاء بمقابل:

🔸 إذا قبل الدائن أن يستوفي في مقابل الدين شيئاً آخر برئت ذمة الكفيل فالمقصود هنا هو الاستعاضة عن الدين الأصلي بنقل ملكية شيء آخر من المدين إلى الدائن، فهنا تُبرأ ذمة المدين من الدين عن طريق الوفاء بمقابل وتُبرأ ذمة الكفيل أيضاً تبعاً لذلك، ولما كان الوفاء بمقابل هو عبارة عن تجديد ووفاء في نفس الوقت، فهو تجديد بتغيير محل الدين وبهذا التغيير أصبح ديناً جديداً يحل محل الدين القديم ويترتب على ذلك أن الدين الأصلي ينقضي وتنقضي معه تأميناته ومنها الكفالة.

٣- انقضاء التزام المدين بالتجديد:

المستشار

❖ إذا انقضى التزام المدين بالتجديد بأن جدد المدين الأصلي دينه بتغير الدائن، أو تغيير المدين، أو تغيير الدين في محله أو في مصدره، فإن الدين المكفول ينقضي، وتنقضي معه تأميناته ومنها الكفالة أ- يترتب على التجديد أن ينقضي الالتزام الأصلي بتوابعه، وينشأ مكانه التزام جديد.
ب- ولا ينتقل إلى الالتزام الجديد التأمينات التي كانت تكفل تنفيذ الالتزام الأصلي إلا بنص القانون أو إلا إذا تبين من الاتفاق، أو من الظروف أن نية المتعاقدين قد انصرفت إلى ذلك، فإذا كان الالتزام الأصلي مضموناً بكفالة فانقضائه بطريق التجديد يؤدي إلى انقضاء الكفالة، ولا تنتقل الكفالة إلى الالتزام الجديد إلا بنص في القانون أو في الاتفاق.

٤- انقضاء التزام المدين بالاستحالة نفيده:

❖ إذا انقضى الدين المكفول باستحالة التنفيذ بسبب أجنبي، انقضت بانقضائه الكفالة، فإذا كان للدين كفيل ثم استحال تنفيذ الدين بسبب أجنبي لا يد للمدين فيه كقوة قاهرة أو خطأ للغير، أو خطأ للدائن ذاته فإن محل الالتزام يتحول إلى تعويض، ولا تبرأ ذمة المدين من الالتزام في هذه الحالة، إلا بأداء التعويض كذلك لا تبرأ ذمة الكفيل بل يبقى كفيلاً للتعويض، أما إذ هلك الشيء بخطأ الكفيل، فإن ذمة الكفيل تبرأ من الدين، إذا يعتبر خطأ الكفيل سبباً أجنبياً بالنسبة إلى المدين وتبرأ ذمة الكفيل، ولكن يبقى هذا الأخير مسؤولاً عن خطئه كمدين أصلي بالتعويض نحو المدين.

٥- انقضاء التزام المدين بالتقادم:

❖ إذا انقضى الدين المكفول بالتقادم انقضت بانقضائه الكفالة، فإذا تقادم الدين الأصلي برئت ذمة الكفيل، تبعاً لذلك، حتى لو لم يتمسك المدين الأصلي بالتقادم أو تنازل عنه، فلو كان المدين الأصلي لم يتمسك بالتقادم، جاز للكفيل أن يتمسك به.

٦- انقضاء التزام المدين بالفسخ:

❖ قد يزول التزام المدين بفسخ العقد الذي أنشأه فيصبح الدين كأن لم يكن وتصبح الكفالة أيضاً كأن لم تكن تبعاً للدين.

❖ **مثال ذلك** ← أن يضمن كفيل التزام المشتري بدفع الثمن ثم يفسخ البيع فيزول بأثر رجعي، ويعتبر دين الثمن كأن لم يكن، وكذلك يزول التزام الكفيل تبعاً لزوال التزام المشتري بدفع الثمن.

٧- انقضاء التزام المدين بالإبطال:

❖ إذا كان مصدر التزام المدين عقداً باطلاً بسبب تخلف التراضي وتخلف شروط المحل، أو عدم مشروعية السبب، أو مخالفة الشكل الذي تطلبه القانون للتصرف، أو كان قابلاً للإبطال لنقص الأهلية، أو لعيب من عيوب الإرادة كالغلط، والتدليس، والإكراه، والاستغلال، وقضى بإبطاله فإن الدين ينقضي لإبطال مصدره وينقضي معه التزام الكفيل باعتباره تابعاً له. عداً إذا كان المقصود من الكفالة هو ضمان نقص الأهلية ففي هذه الحالة إذا أبطل ناقص الأهلية العقد لنقص أهليته، فإن التزام الكفيل لا ينقضي بل يلتزم بصفته مدين أصلي.



أولاً: اجب عن الاسئلة الآتية

س ١ : عرف الدفع بالتجريد مبيناً شروطه واثاره ؟

س ٢ : وضع الشروط الواجب توافرها في محل الكفالة ؟

س ٣ : عرف عقد الكفالة قانوناً مبيناً خصائص الكفالة وانواعها ؟

س ٤ : اكتب في العلاقة بين الكفيل والمدين مبيناً ما يرجع به الكفيل علي المدين طبقاً للقواعد العامة والقواعد الخاصة بالكفالة ؟

ثانياً: بين مدي صحة او خطأ العبارات الآتية:

العلامة	السؤال	م
	لا يثور الدفع بالتجريد إلا بعد إنتهاء الدائن من إجراءات التنفيذ علي أموال الكفيل	١-
	يجوز الإتفاق بين المدين والكفيل علي ان يكون اجل التزام الكفيل قبل اجل الالتزام الأصلي	٢-
	إذا وافق الدائن علي مد اجل الإلتزام الأصلي فإن أجل مطالبة الكفيل لا تمتد للأجل الجديد	٣-
	تسجيل اجل الوفاء بالإلتزام الأصلي يجعل اجل مطالبة الكفيل يمتد تبعاً للأجل الجديد	٤-
	إذا كان الدائن بيده سند تنفيذي فلا حاجة إلي رفع دعوي علي المدين للرجوع علي الكفيل	٥-
	لا يجوز للكفيل ان يتنازل عن حقه في ان يرجع الدائن علي المدين قبل رجوعه عليه	٦-
	تجوز كفالة الكفيل	٧-
	يجوز أن يتنازل الكفيل عن حقه في التمسك بالدفع بتجريد المدين	٨-
	الدفع بالتجريد من الدفع المتعلقة بالنظام العام	٩-
	يلتزم الكفيل بدفع فوائد الإلتزام الأصلي	١٠-
	إذا تعدد الكفلاء يجوز للدائن مطالبة احدهم بالوفاء بالدين كله	١١-
	يستطيع الكفيل ان يدفع مطالبة الدائن له بدفع مستمدة من عقد الكفالة	١٢-
	التزام الكفيل بالضمان هو التزام تابع للإلتزام الأصلي	١٣-
	من كفل إلتزام عديم الأهلية كان ملزماً بتنفيذ الإلتزام إذا لم ينفذه المدين المكفول	١٤-
	من كفل التزام ناقص الأهلية بسبب نقص الأهلية لا يلتزم بتنفيذ الإلتزام المكفول إذا بطل الإلتزام الأصلي	١٥-
	لا يجوز للكفيل الرجوع علي المدين وفقاً للقواعد العامة	١٦-
	للكفيل الرجوع علي المدين بدعوي الكفالة بالرغم من ابرام عقد الكفالة لمصلحة الدائن ومعارضة المدين	١٧-
	للكفيل الرجوع علي المدين بدعوي الكفالة بالرغم من ابرام عقد الكفالة دون علمه	١٨-
	يجوز للكفيل الرجوع علي المدين بدعوي الكفالة إذا قام بالوفاء قبل حلول أجل الدين	١٩-
	عدم اخطار الكفيل للمدين قبل الوفاء بالدين لا يسقط حقه في الرجوع علي المدين بدعوي الكفالة	٢٠-

٢١-	الشرط الأساسي لرجوع الكفيل بدعوي الحلول هو ان يكون الكفيل قد اخطر المدين قبل الوفاء
٢٢-	الشرط الأساسي لرجوع الكفيل بدعوي الحلول هو ان يكون الكفيل قد وفى الدين كله للدائن
٢٣-	يجوز أن يكون إلتزام الكفيل أشد من الإلتزام الأصلي

ثانياً: حدد الاجابة الصحيحة:

السؤال	م
١- يقع علي جميع اموال المدين الحاضرة او المستقبلية A) التامينات الاجتماعية B) الضمان العام C) الضمان الخاص D) عقد التامين	-١
٢- هو شخص غير المدين يقوم برهن ماله ضمانا للوفاء بدين غيره. A) الكفيل العيني B) الحائز C) الراهن D) الدائن المرتهن	-٢
٣- يمنح القانون للدائنين وسائل متعددة للمحافظة علي الضمان العام هي: A) الدعوي غير المباشرة B) الدعوي البوليصة C) دعوي الصورية D) جميع ماسبق	-٣
٤- هو الذي يحصل برضاء الدائن المرتهن وحده ولا يحتاج الي قبول المدين الراهن A) المحو الرضائي B) المحو القضائي C) حق الامتياز D) جميع ماسبق	-٤
٥- الرهن الرسمي حق A) قابل للتجزئة B) غير قابل للتجزئة C) حق عيني اصلي D) جميع ماسبق	-٥
٦- هو حق للكفيل بان يتمسك بعدم جواز التنفيذ علي امواله قبل التنفيذ علي اموال المدين الذي كفله A) الدفع بالتقسيم B) حق الرهن C) الدفع بالتجريد D) حق الامتياز	-٦
٧- من الحقوق العينية التبعية التي يكون مصدرها القضاء A) الرهن الرسمي B) الرهن الحيازي C) حق الامتياز D) حق الاختصاص	-٧
٨- يتضمن انتقال الرهن الي الحق الذي يترتب علي هلاك العقار المرهون او تلفه مايلي A) مبلغ التعويض B) مبلغ التأمين C) مقابل نزع الملكية للمنفعة العامة D) جميع ماسبق	-٨
٩- تقوم علي اساس فكرة تخصيص مال معين من اموال المدين لضمان حق الدائن عند حلول اجله A) التامينات الاجتماعية B) الكفالة C) التامينات العينية D) عقد التامين	-٩
١٠- هي ايجاد شخص غير المدين يستطيع الدائن ان يطالبه بذات الدين A) التامينات الشخصية B) الحقوق العينية التبعية C) التامينات الخاصة D) الحقوق العينية الاصلية	-١٠
١١- هو الرهن الذي يصدر من شخص باسمه وحسابه علي عقار مملوك لغيره A) بيع ملك الغير B) رهن ملك الغير C) الرهن الرسمي D) الرهن الحيازي	-١١
١٢- هو المال الذي يستوفي منه الدائن المرتهن حقه بالتقدم علي غيره من الدائنين A) وعاء التقدم B) سلطة التتبع C) سلطة الاولوية D) مرتبة الرهن	-١٢
١٣- هي الدعوي التي يرفعها الدائن علي مدين مدينة للمطالبة بحقوق هذا الاخير في حالة تقاعسه عن المطالبة بها A) الدعوي البوليصة B) الدعوي غير المباشرة C) الدعوي الصورية D) جميع ماسبق	-١٣
١٤- هو حق للكفيل بان يتمسك بعدم جواز التنفيذ علي امواله قبل التنفيذ علي اموال المدين الذي كفله A) الدفع بالتقسيم B) حق الرهن C) حق الامتياز D) الدفع بالتجريد	-١٤

-١٥	 هو الاجراء الذي يسمح بنفاذ الرهن في حق الغير (A) التسجيل (B) القيد (C) محو القيد (D) الغاء المحو
-١٦	هي قدرة الدائن المرتهن علي اتخاذ الاجراءات اللازمة علي العقار المرهون اذا انتقلت ملكيته الي الغير (A) سلطة التقدم (B) التنازل عن مرتبة الرهن (C) سلطة التتبع (D) المحو القضائي

المستشار



2026